



Réviser le cadre juridique pour des Achats Publics Responsables et Durables au Sénégal



Avec l'appui de



AFRICAN DEVELOPMENT BANK GROUP
GROUPE DE LA BANQUE AFRICAINE
DE DÉVELOPPEMENT

et de



Avertissement

Ce rapport est issu d'un rapport de 304 pages qui a été remis à l'ARMP par les Consultantes Carol Cravero et Laurence Folliot Lalliot en mai 2021.

La présente version, rédigée par Laurence Folliot Lalliot, reprend la partie dédiée à la réforme du cadre juridique sénégalais et insère des avancées intervenues courant 2021, notamment la transformation annoncée de l'ARMP en Autorité de Régulation de la Commande publique (ARCOP) dotée de compétences en matière de promotion des APD. Elle tient compte des nouvelles lois relatives aux Partenariats Publics Privés (PPP) et à l'économie sociale et solidaire.

Dakar, Mars 2022

TABLE DES MATIÈRES

TABLE DES MATIÈRES	3
LISTE des TABLEAUX	5
SIGLES ET ABRÉVIATIONS	6
RÉSUMÉ EXÉCUTIF	7
INTRODUCTION	9
Le contexte de la politique de développement durable au Sénégal :	9
L'impact de la pandémie Covid-19 :	9
Le levier de la commande publique au Sénégal :	9
Les potentialités des Achats Publics Durables (APD) au Sénégal :	10
Réformer le droit des marchés publics pour introduire les options des APD :	13
Structures du Rapport :	15
PARTIE I LE CADRE JURIDIQUE ACTUEL DES APD AU SENEGAL	16
CHAPITRE 1 : DES DISPOSITIONS EXISTANTES PROPICES AUX APD MAIS PARCELLAIRES	16
Section 1 Les possibilités offertes par les Directives marchés publics de l'UEMOA	16
Section 2 Le cadre juridique inachevé du droit des marchés publics	17
Section 3 Les avancées du nouveau cadre juridique des PPP en faveur du développement durable et du « contenu local »	28
CHAPITRE 2 UN « ECOSYSTEME JURIDIQUE » MOBILISABLE POUR LES APD MAIS SOUVENT IGNORE	35
Section 1 Un « écosystème juridique » favorable aux APD	35
Section 2 Un éco-système juridique qui complète le droit des APD	36
Section 3 L'absence de lien entre le droit de l'environnement et le pilier environnemental de la commande publique	46
PARTIE II PROPOSITIONS de REVISION du CADRE JURIDIQUE des MARCHES PUBLICS	57
CHAPITRE 3 : IMPOSER UNE COMMANDE PUBLIQUE RESPONSABLE	58
Section 1 Compléter les principes de la commande publique	58
Section 2 Prévoir une Charte de l'Ethique et de la commande publique responsable obligatoire dans tous les contrats de la commande publique	59
Section 3 Toiletter les Visas du décret portant Code des marchés publics	61
Section 4 Compléter les définitions incluses dans le CMP	61
CHAPITRE 4 : INTRODUIRE DES OPTIONS APD A TOUS LES STADES DE LA COMMANDE PUBLIQUE	63
Section 1 Introduire les APD dans la phase de préparation en amont du contrat	64
Section 2 Choisir le type de contrat qui encourage les APD	69
Section 3 Choisir la procédure qui encourage les APD	72
Section 4 Rédiger l'avis d'appel à concurrence en intégrant les buts des APD	76
Section 5 Rédiger les documents du marché en intégrant les buts des APD	77

Section 6 Qualifier les entreprises au regard des exigences APD	85
Section 7 La phase d'attribution	89
Section 8 Organiser le contrôle des obligations de durabilité pendant l'exécution du marché	99
Tableau de synthèse des propositions de révision du CMP en faveur des APD.....	106
Chapitre 5 : REVISER LES DTAO POUR REFLETER L'HARMONISATION ET LA MODERNISATION NECESSAIRES AUX APD...	113
Section 1 Les dispositions en faveur de la commande responsable à insérer dans tous les DTAO	114
Section 2 Préparer des DTAO spécifiques « APD » afin de promouvoir leur impact positif	115
Section 3 Introduire dans les DTAO des mesures ajustées aux piliers des APD	118
Section 4 Développer des DTAO par produit ou par secteur	124
Partie III ACCOMPAGNER L'ESSOR DES APD PAR DES APPUIS INSTITUTIONNELS DEDIES	125
CHAPITRE 6 CONCEVOIR UNE MISE EN ŒUVRE TRANSVERSALE DE LA POLITIQUE DES APD	125
Section 1 Plan de formation et de sensibilisation à la réforme APD	125
Section 2 Conception de la politique des achats publics durables : des synergies à mettre en place	127
CHAPITRE 7 ATTIRER LES PME ET LES STARTUPS VERS LA COMMANDE PUBLIQUE.....	128
Section 1 L'appui institutionnel public aux PME	128
Section 2 L'appui du Secteur privé aux PME	129
CHAPITRE 8 ACCOMPAGNER LES AC DANS LE DEPLOIEMENT DES POLITIQUES APD	129
Section 1 Améliorer l'information des Autorités contractantes sur les APD	129
Section 2 Inciter et aider les AC à utiliser les dispositifs APD	132
Tableau récapitulatif des actions incitatives	133
CONCLUSION ET PLAN D'ACTIONS	137
LISTE des ANNEXES	139
Annexe 1 : Extraits du Plan National des Achats Publics durables (PNAPD) : Axe stratégique 4. Cadre juridique et institutionnel	139
Annexe 2 : Modèle d'engagement à respecter la Charte de l'Ethique et de la commande publique responsable	140
Annexe 3 Nouveau Modèle de PGES (adapté des Documents types de l'Agence Française de Développement 2019)	141
Textes consultés	143

LISTE des TABLEAUX

- Tableau récapitulatif : Dispositions existantes du CMP 2014 relatives à la dimension sociale des APD p. 20
- Tableau récapitulatif : Dispositions existantes du CMP relatives à la dimension économique (PME) des APD, p. 21
- Tableau récapitulatif : Dispositions existantes du CMP relatives à la dimension locale des APD, p. 23
- Tableau récapitulatif : Dispositions existantes du CMP relatives à la dimension environnementale des APD, p. 24
- Tableau récapitulatif : Dispositions existantes du cadre PPP relatives à la dimension sociale des APD p. 29
- Tableau récapitulatif : Dispositions existantes du cadre PPP relatives à la dimension locale des APD, p. 33
- Tableau récapitulatif : Dispositions existantes du cadre PPP relatives à la dimension environnementale des APD, p. 34
- Tableau récapitulatif : Dispositions de la loi sur les Startups du 6 janvier 2020 relatives à la dimension économique (PME) des APD, p. 44
- Tableau récapitulatif des principales sources d'obligations légales à considérer dans la commande publique responsable, p. 54
- Tableau de synthèse des propositions de révision du CMP en faveur des APD, p. 107
- Tableau récapitulatif des actions incitatives à la diffusion des APD, p. 132

SIGLES ET ABRÉVIATIONS

AC Autorité contractante
ACV Analyse du Cycle de Vie
ADEPME Agence de développement des Petites et Moyennes Entreprises
AME Agence de Maîtrise de l'Energie
ANEJ Agence nationale pour l'emploi des Jeunes
APD Achats Publics Durables
APIX
ARMP Autorité de Régulation des Marchés Publics
ASRGMV Agence Sénégalaise de la Reforestation et de la Grande Muraille Verte
BAD Banque Africaine de Développement
CGES Cadre de Gestion Environnementale et Sociale
CRD Comité de Règlement des Différends
CEDEAO Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest
CMP Code des Marchés Publics
CPD Commande Publique Durable
DAO Dossier d'Appel d'Offres
DTAO Dossier Type d'Appel d'Offres
DD Développement Durable
DCMP Direction Centrale des Marchés Publics
DEEC Direction de l'Environnement et des Établissements Classés
DER Délégation à l'Entrepreneuriat Rapide
DP Demande de Propositions
DRP Demande de Renseignements et de Prix
DSP Délégation de service public
EIES Études d'Impact Environnemental et Social
EIESS Etude d'Impact Environnemental, Santé, et Social
EEG Etude d'Evaluation du Genre
GES Gaz à Effet de serre
LPS/EDD Lettre de Politique du Secteur de l'Environnement et du Développement Durable
ODD Objectifs de Développement Durable
ONG Organisation Non Gouvernementale
PGES Plan de Gestion Environnementale et Sociale
PME Petites et Moyennes Entreprises
PNAPD Plan National d'Achats Publics Durables
PSE Programme Sénégal Émergent
SNDD Stratégie Nationale du Développement Durable
SNPEV Stratégie Nationale pour la Promotion des Emplois Verts au Sénégal
TPE Très Petite Entreprise
UEMOA Union Économique et Monétaire Ouest Africaine

3FPT : Fonds de Financement de la Formation Professionnelle et Technique

RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Ce Rapport intitulé « Promouvoir les Achats Publics Responsables et Durables au Sénégal » participe à la mise en œuvre du Plan National des Achats Publics Durables (PNAPD) dont il constitue l'étape juridique. Après la récente réforme de l'ARMP transformée en ARCOP dotée de nouvelles compétences en matière de commande publique durable, ce Rapport a pour objet de proposer des aménagements du droit de la commande publique sénégalaise afin d'y faciliter le recours aux Achats publics durables (APD) dans leurs trois dimensions : sociale, économique et environnementale, qui contribuent, ensemble ou séparément, au développement local, inclusif et responsable.

Dans sa finalité, ce Rapport ambitionne de marquer un tournant de la politique sénégalaise d'achats publics grâce à :

- **L'affirmation d'une commande publique « responsable »** afin d'inscrire tous les contrats de la commande publics dans la conformité au droit existant : droit du travail, respect du genre, droits des personnes victimes de handicap, droit de l'environnement et de l'urbanisme, respect des règles sur l'efficacité énergétique, conformité aux normes d'hygiène, santé et sécurité, afin d'aboutir à des achats publics pleinement « responsables » et exemplaires qui engagent les Acheteurs publics et les entreprises. A cet effet, le rapport propose une mesure symbolique : **l'adoption d'une nouvelle Charte de l'Ethique et de la commande publique responsable**, obligatoire dans tous les documents de marchés publics et qui a vocation à régir également les PPP, sous peine de sanctions.
- **L'harmonisation du cadre normatif de la commande publique avec son écosystème juridique pour répondre aux orientations du PSE2.** Dans un objectif de rationalisation et de cohérence du droit applicable, il convient de prendre en compte les dispositions propices aux piliers des APD issues d'autres pans du droit sénégalais et porteuses de solutions : par ex. les dispositions existantes en faveur des PME, des startups, des Artisans et des acteurs de l'économie sociale et solidaire au profit de l'emploi des groupes vulnérables, de la réduction de l'économie informelle, des mesures de protection de l'environnement ou encore de maîtrise de l'énergie. Car une commande publique en phase avec son écosystème juridique permet d'opérationnaliser et d'amplifier les effets des politiques sociales et économiques du pays.
- **La modernisation du cadre juridique vers une commande publique « durable » en introduisant des options d'APD à toutes les étapes de l'opération d'achat.** Dans ce but, ce rapport propose des dispositifs adaptés aux caractéristiques sénégalaises afin d'accentuer l'impact positif des APD en permettant aux Autorités contractantes, si elles le souhaitent, d'imposer des exigences sociales et/ou environnementales dans leurs marchés de fournitures, services et constructions, favorisant les PME locales (c'est-à-dire sénégalaises ou des pays UEMOA), l'emploi local et/ou les produits locaux, en mobilisant au besoin la RSE, pour un véritable impact positif et durable.

Ainsi ce Rapport débouche-t-il sur une sorte de *SBA (Small Business Act)* en faveur des PME avec une dimension sociale et environnementale marquée tout en restant compatible avec le cadre communautaire de l'UEMOA. Pour les appels d'offres nationaux, il propose de diversifier les outils juridiques à destination des Acheteurs publics afin d'accompagner l'essor des PME locales et de l'entrepreneuriat social et solidaire, sans oublier la protection de l'environnement. Cela passe par la structuration de l'offre afin d'identifier et d'accompagner les différentes catégories de participants à la commande publique, des mesures préférentielles d'accès telles que des marchés réservés aux acteurs de l'économie sociale et solidaire et aux Artisans, des marges de préférences pour les PME, y compris la PME « à direction féminine », des facilités pour recourir à la sous-traitance notamment lorsqu'elle emploie au moins 30 % de personnes victimes de handicap, ou 50 % de Jeunes sans qualification ou 50 % de femmes, des facilitations telles que la priorisation de l'allotissement ou la valorisation de l'innovation sociale et environnementale.

Dans une perspective de rationalisation de la commande publique, ces propositions juridiques s'efforcent également d'harmoniser le droit des marchés publics avec le nouveau cadre des PPP issu de la loi du 2 mars 2021. Elles réunissent des dispositions juridiques prescriptives mais également incitatives, et elles sont complétées de suggestions d'aménagements institutionnels pour refléter la dimension intersectorielle des APD. Elles poussent à la dématérialisation des procédures et à la montée en puissance des soutiens structurels, administratifs et financiers dédiés à

l'accompagnement des entreprises vers la commande publique. Elles sollicitent aussi les grandes entreprises publiques et privées qui devront, dans le cadre de leurs obligations RSE, s'impliquer davantage dans le mentorat des jeunes entreprises et la montée en capacité de leurs sous-traitants à travers leurs chaînes de valeur.

Ces outils d'aide à l'implantation de la réforme concernent aussi les Acheteurs publics. Afin de tenir compte des capacités des acteurs locaux, des dispositifs d'accompagnement sont prévus pour les Autorités contractantes (plateforme APD, conseils en amont des appels d'offres, *sourcing* et démarches pré-commerciales pour une meilleure connaissance de l'offre), avec des récompenses incitatives mais aussi des sanctions financières à l'encontre des Autorités contractantes récalcitrantes à s'engager dans les APD. Toutefois, pour une mise en oeuvre progressive, les obligations les plus contraignantes sont concentrées dans les DTAO des marchés aux montants les plus élevés tandis que seules les Autorités contractantes les plus importantes seraient, dès 2022, tenues de consacrer au moins 20 % de leurs achats annuels aux APD.

Première étape du nouveau cadre juridique en faveur des APD, la nouvelle ARCOP, qui remplace l'ARMP, est désormais chargée de surveiller la mise en oeuvre de la commande publique responsable et durable. Ce nouveau rôle doit s'appuyer sur un cadre juridique renouvelé et sécurisé qui doit répondre aux initiatives déjà lancées par certains acteurs. Ainsi structurée, cette réforme graduelle et pragmatique du cadre juridique des marchés publics devrait contribuer à amplifier l'effet levier des APD au service d'un développement durable, inclusif et local, en phase avec le plan Sénégal Emergent et les attentes de la population sénégalaise après les difficultés causées par la crise COVID.

INTRODUCTION

Le contexte de la politique de développement durable au Sénégal :

Le Sénégal s'est engagé dans une politique active de promotion du développement durable¹ comme axe de sa croissance économique. Comme énoncé par le Plan Sénégal Emergent (PSE), l'ambition de l'Etat du Sénégal est de favoriser une croissance économique à fort impact sur le développement humain. Cette aspiration s'est traduite par une vision d'« *Un Sénégal émergent en 2035 avec une société solidaire dans un État de droit* ». Dans ces conditions, l'objectif stratégique 2 de la Lettre de Politique Sectorielle de l'Environnement et du Développement Durable (LPSEDD, 2016-2020) portait sur l'intégration des principes du développement durable dans les politiques publiques, la gestion du cadre de vie, la promotion de moyens d'existence, la résilience des groupes vulnérables et les modes de production et de consommation. Les politiques publiques sénégalaises s'appuient ainsi sur la feuille de route des Objectifs de développement durable (ODD) adoptés en 2015 par les Nations Unies et l'ensemble de la communauté internationale. Révélateur de cette volonté de mieux appréhender les potentialités environnementales et sociales, les Nations Unies ont d'ailleurs adopté, en Mars 2021, un nouveau système de comptabilité qui intègre la valeur sociale et environnementale². Dans cette optique, le Sénégal s'est engagé dans la mise en œuvre de l'Objectif de Développement Durable n°12 qui encourage en particulier les modes de production et de consommation durables. En mettant l'accent sur la promotion des pratiques durables dans le cadre de la commande publique (cible n° 12.7 des ODD), le Plan National des Achats Publics Durables (PNAPD) élaboré en 2019 s'inscrit dans cette démarche dans le but d'accompagner, par étapes, le recours aux Achats publics durables (APD) dans leurs trois dimensions : sociale, économique et environnementale. Après la publication en 2020 du Guide des Achats Publics Durables, qui a mis l'accent sur le volet des marchés verts, le présent Rapport, préparé à la demande de l'ARMP, doit proposer une réforme globale du cadre juridique de la commande publique afin de permettre un véritable essor des APD au Sénégal.

L'impact de la pandémie Covid-19 :

En 2020, la crise du Covid-19 a eu un effet dévastateur sur plusieurs ODD. Toutefois, malgré les inflexions de croissance liées à la crise engendrée par la pandémie du COVID, les projections réajustées pour le Sénégal prévoient 38 % de réalisation globale des ODD en 2023³, dont 77,6 % de l'Objectif 12 relatif à l'adoption de modes de production et de consommation durables. Cette perspective illustre les attentes à l'égard du développement durable, vecteur à la fois de politique environnementale, de politique économique, et de politique sociale de relance, comme l'atteste le Pap2a PSE (Plan d'actions prioritaires ajusté et accéléré) adopté le 5 septembre 2020 pour ajuster le PSE face à la crise COVID. En particulier le Pap2a vise à promouvoir l'essor du secteur privé avec l'adoption de la loi sur les PPP, et à renforcer la résilience de l'économie et l'inclusivité de la croissance. L'axe 2 : « *capital humain, protection sociale et développement durable* » bénéficie de 29,5% du montant du PAP 2A, afin de satisfaire les besoins sociaux des populations⁴. **Dans ce contexte de contraction de l'économie, de perturbations profondes des circuits de production et des filets sociaux, l'outil de la commande publique durable peut permettre d'optimiser l'impact des financements mobilisés et de favoriser un développement inclusif et local en ouvrant la voie à la résilience sociale et économique.**

Le levier de la commande publique au Sénégal :

La transversalité de la commande publique en fait un outil privilégié pour la mise en oeuvre des politiques publiques, en particulier en phase de relance. L'effet de levier de la commande publique est désormais activé par la grande majorité des Etats, conscients des potentialités que recèle un instrument clé qui actionne des volumes majeurs de

¹ Suivant la définition adoptée depuis le rapport Brundtland de 1987, « Notre avenir commun » : « Le développement Durable est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs ».

² Il va permettre, au-delà du PIB qui ne reflète que les échanges de produits et services, de comptabiliser le capital naturel (zones humides et côtières, forêts, et autres écosystèmes) et de formaliser ainsi les pertes économiques induites par les destructions de l'environnement naturel. The 52nd United Nations Statistical Commission, on March 2021, has adopted the System of Environmental-Economic Accounting—Ecosystem Accounting (SEEA EA), <https://seea.un.org/ecosystem-accounting>

³ Source Pap2a 2020, p. 34 : niveau de réalisation des ODD projeté en 2023, d'après l'étude de la DGPPE 2020.

⁴ Le PAP2A porte essentiellement sur « (i) l'accès aux soins de santé, à l'eau potable et à l'assainissement ainsi qu'au renforcement de la nutrition ; (ii) l'amélioration des conditions d'habitat et du cadre de vie ; (iii) l'éducation de qualité et le développement des compétences et des qualifications ; (iv) la protection sociale et la solidarité avec les groupes vulnérables ; (v) la prévention et la gestion des risques et catastrophes ; (vi) la promotion de l'équité et de l'égalité de genre ; et (vii) la lutte contre la dégradation de l'environnement, des ressources naturelles et les changements climatiques ».

la dépense publique. De fait, les secteurs envisagés par le PAP2A vont ainsi fortement mobiliser la commande publique dans les prochaines années ⁵. Sur la période 2021-2023, les infrastructures représenteront en effet 32,3% des coûts programmés (soit 3910 Mds FCFA), mais on doit également citer l'hydraulique (5,7%) l'agriculture (8,4%), l'Administration publique (8,4%), ou encore le développement communautaire - équité sociale et territoriale (4,6%) soit (560 Mds FCFA). Or, à part les revenus de transferts et les subventions directes, la mobilisation de ces montants passe essentiellement par le vecteur de la commande publique, qu'il s'agisse de marchés publics ou de montages de Partenariats publics privés (PPP) à paiements publics. Ces budgets sectoriels conséquents envisagés pour la période 2021-2023 démontrent l'ampleur de l'effet de levier qui peut être attendu en cas de mise en œuvre d'une politique de commande publique durable. Ce constat permet de tempérer la part très modeste qui est affichée dans les mêmes prévisions du PAP2A pour le seul secteur de « l'environnement et du développement durable » : 0,7 % ou 75 Mdf FCFA.

De fait, les montants consacrés aux marchés publics sont considérables, en croissance constante, et ils représentent ainsi une part conséquente de la richesse nationale. En 2017, les marchés publics représentaient l'équivalent de 17% du PIB, avec une majorité des contrats attribués à des entreprises de taille moyenne⁶. Pour le 1^{er} trimestre 2021, le total des marchés a grimpé à plus de 662 milliards de F CFA (dont 72 % attribués par entente directe) pour 725 marchés immatriculés⁷. Pour cette même période, la part des marchés de travaux publiés est particulièrement élevée et témoigne de l'accroissement des investissements en infrastructures. Moins nombreux en volume, ils mobilisent toutefois près de 91 % des montants. Mais **l'impact réel des contrats de la commande publique engagés annuellement est encore plus élevé.** En effet, les statistiques ci-dessus mentionnées ne reflètent que les marchés publiés, c'est-à-dire les marchés qui dépassent certains seuils et pour lesquels les Autorités contractante se sont pliées à l'obligation de publication. Si on prend en compte les crédits de paiement inscrits au projet de budget pour 2021⁸, entre les « acquisitions de biens et services » (347 723 490 419 FCFA en CP) au titre des dépenses ordinaires et les dépenses en capital « investissements exécutés par l'Etat » (357 640 076 969 FCFA), les dépenses sur fonds propres totalisent 705 363 567 388 FCFA, auxquelles s'ajoutent les dépenses d'investissement en capital sur ressources extérieures (respectivement : 265 481 986 108 sur dons et 576 000 000 000 sur emprunt), soit un total pour l'année 2021 des dépenses ordinaires et en capital inscrites au budget général qui devraient passer en grande partie par la voie des contrats de commande publique (marchés publics et PPP) de 1 466 921 367 388 FCFA. On peut y ajouter le total des dépenses inscrites au titre des Comptes spéciaux du Trésor : dépenses ordinaires en acquisition de biens et services : 950 200 000 et investissement de l'Etat au titre des dépenses en capital : 22 242 000 000 soit 23 192 200 000, et un total général qui atteint : 1 490 113 567 388 donc pratiquement 1 500 Milliards de FCFA au titre de la commande publique, au niveau étatique. Il faudrait ajouter les mêmes catégories de dépenses au niveau des collectivités locales (sachant que nombre d'entre elles sont financées sur revenus de transfert), pour avoir une photographie réelle du poids de la commande publique directe au Sénégal. **Surtout, lorsqu'on évoque la part de la commande publique dans l'économie on ne mesure que la part des contrats de 1^{er} rang, sans mesurer le poids « indirect » dans l'économie que représentent la sous-traitance et les chaînes d'approvisionnement des acquisitions publiques.** Si cette commande publique de « second rang » pouvait être quantifiée, les chiffres souligneraient encore davantage l'effet d'entraînement économique et social de l'achat public.

Les potentialités des Achats Publics Durables (APD) au Sénégal :

Engager les Autorités contractantes sénégalaises dans une politique d'APD c'est simultanément leur permettre de contribuer à la politique de sortie de crise tout en se conformant aux ODD auxquels le Sénégal a consenti. Cette optimisation de la dépense publique doit répondre à une double visée : satisfaire les besoins des Administrations à travers leurs achats qui assurent leur fonctionnement quotidien, mais aussi permettre de concourir à la satisfaction d'objectifs nationaux en matière de retour à l'emploi des jeunes ou de lutte contre la pollution par exemple. Construire des écoles avec des matériaux locaux, réparer des routes en faisant appel à des groupements de villageois, équiper un hôpital en prévoyant une gestion durable des déchets constituent des exemples d'actions menées par des acteurs publics nationaux ou locaux, qui, chacune, peut permettre de fournir le service attendu à un coût raisonnable tout en poursuivant un objectif de croissance durable. Aussi pour le PNAPD, l'Etat veut faire des APD « *un important levier pour booster le développement économique*

⁵ PAP2A PSE du 5 septembre 2020, tableau p. 39

⁶ Chiffres rapport Carapaces, fév 2021, p. 10.

⁷ D'après les chiffres publiés sur le portail national www.marchespublics.sn. A ces données devraient s'ajouter les « petits marchés » qui ne sont pas publiés ou les PPP qui ne sont pas compatibles dans les marchés publics

⁸ Projet de loi de finances pour l'année 2021 - Annexe II: Tableau récapitulatif global en AE/CP par catégories de dépenses

et social, à travers la prise en compte de facteurs tels que l'emploi, l'équité sociale, la promotion de groupes vulnérables, etc. ».

Polyvalents, les APD offrent des marges de progression importantes dans l'impact des politiques publiques spécifiques puisqu'ils s'organisent autour des 3 piliers du développement durable : le pilier social, le pilier économique et le pilier environnemental : 3 piliers des APD, auxquels s'ajoute désormais le contenu local, qui peuvent être mobilisés individuellement ou simultanément.

Le pilier économique des APD vise à promouvoir l'accès des PME et TPE à la commande publique. Cette dimension des APD s'inscrit parfaitement dans les nombreuses initiatives déjà lancées par le Sénégal en faveur de la structuration du secteur privé puisque d'après les statistiques de l'Agence nationale de la statistique et la démographie, 95 % de l'économie est composée de PME/PMI et d'économie informelle⁹. Sur le plan des politiques publiques, cela s'est traduit par l'adoption de la loi d'orientation n° 2020-02 du 7 janvier 2020, relative aux Petites et Moyennes entreprises¹⁰ ainsi que de la loi sur les Startups du 6 janvier 2020. Les APD peuvent en effet contribuer à l'innovation en facilitant la proposition de nouveaux produits et services par des entreprises et startups locales grâce à des procédures d'achats publics adaptées, afin de développer des savoirs faire locaux innovants et porteurs de résultats et d'emplois. Cependant, si la loi sur les Startups du 6 janvier 2020 a prévu un accès préférentiel des Startups labellisées dans toutes les procédures d'attribution de contrats de la commande publique, comme ce Rapport va le démontrer, cette disposition n'a pas été opérationnalisée par des textes d'application dans le champ de la commande publique.

La commande publique durable face à l'enjeu de l'économie informelle. En l'état des règles d'accès aux marchés publics, la très grande majorité des unités économiques sénégalaises demeurent exclues des opportunités économiques offertes par les achats publics, ce qui représentent 97 % des structures économiques en-dehors de l'agriculture – 60 % des emplois – 48,8% de la population active¹¹. *A contrario* la commande publique ne concernerait que 3 % des entreprises sénégalaises (hors agriculture). Alors qu'il existe désormais un Ministère de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire ainsi qu'un Ministère en charge de l'Artisanat et de la transformation du secteur informel, tous deux en charge de s'attaquer à la difficile question de la résorption du secteur informel, la distinction entre les deux secteurs reste déterminante. Dans le domaine de la commande publique, elle est même fondamentale puisque seules les entreprises formalisées disposent de la capacité juridique pour pouvoir participer à une procédure d'attribution ou devenir sous-traitantes. En revanche, les structures qui relèvent de l'informel ne remplissant pas cette exigence de capacité, dépourvues de statut juridique, ni déclarées, ni à jour des cotisations et contributions requises, se retrouvent automatiquement exclues de l'accès à la commande publique. Ici réside un des enjeux de la régularisation des structures informelles ou, déjà, de la reconnaissance d'un statut intermédiaire avec des catégories de transition relevant des « *acteurs de l'économie sociale et solidaire* ». Ce Rapport doit, par conséquent, s'intéresser à cette problématique si l'on veut que la commande publique puisse pleinement jouer son effet de levier économique et social en contribuant à la résorption de l'informel.

Le Pilier social des APD offre une réponse aux difficultés des groupes vulnérables, en particulier dans l'accès à l'emploi. Le pilier social des APD est une réponse crédible à plusieurs initiatives qui ont cherché ces dernières années à favoriser l'activité de certains groupes vulnérables dont ceux des femmes, des jeunes, et des personnes victimes de handicap. Pour s'attaquer au chômage des plus défavorisés, les marchés à Haute Intensité de Main-d'œuvre (HIMO) peuvent être déployés rapidement pour réaliser des travaux simples (aménagements urbains, construction de pistes, de réservoirs et bassins pour l'hivernage, création de fosses à déchets, reforestation, etc...) ou des services simples à fort besoin de main d'œuvre (collecte et tris des déchets dans les communes). Ces marchés HIMO peuvent ainsi constituer une réponse intéressante au **chômage des jeunes sans qualifications** dans un bassin d'emplois déterminé, tout en garantissant des conditions de travail décentes, une activité d'accompagnement ou de formation, et en promouvant l'égalité hommes-femmes, sans oublier la prise en compte des paramètres environnementaux. Du côté des réponses que peut apporter la commande publique à **la situation des femmes**, 3 aspects du genre méritent d'être identifiés : la question de l'accès à l'emploi, la question du respect des droits des femmes salariées (égalité salariale par ex.) et enfin la question de l'accès des entreprises dirigées par des femmes (notamment des PME) à la commande publique. Or la question de l'entrepreneuriat des femmes est aujourd'hui posée avec acuité au regard des chiffres disponibles. D'après l'ONU, seulement

⁹ Données : <http://www.ansd.sn/>

¹⁰ Publiée au JO du 20 janvier 2020, p. 78.

¹¹ Chiffres indiqués par le Ministre Papa Amadou Ndiaye, Le Soleil 11 mars 2021, p. 9.

1% du marché des marchés publics dans le monde est attribué à des entreprises gérées par des femmes. Ceci se confirme au Sénégal où moins de 5% des femmes entrepreneures ont déclaré avoir une connaissance complète des processus et méthodes de passation des marchés publics¹². A ces difficultés genrées, le volet social des APD peut apporter des réponses ciblées. Tout comme il peut permettre d'appuyer la **politique publique du handicap**, notamment pour traduire concrètement les engagements de la Loi d'orientation sociale n° 2010-15 du 6 juillet 2010 relative à la promotion et la protection des droits des personnes handicapées¹³. Ces différentes considérations illustrent l'hétérogénéité des problèmes pour lesquels le pilier social des APD peut offrir des solutions adaptées.

Le pilier environnemental est l'élément historique le plus connu des APD. Aussi a-t-il été particulièrement exploré par le Guide des Achats publics durables qui a été préparé par l'ARMP en 2020. Pour le Sénégal, les APD peuvent permettre de réduire l'empreinte écologique des achats publics, soit en achetant des produits verts ou écologiques (par ex l'encouragement du recours aux énergies vertes) soit en achetant des produits « classiques » mais assortis de conditions de livraison, de maintenance ou de recyclage qui permettront d'en réduire les impacts négatifs sur l'environnement. Plus spécifique aux achats, le concept de l'économie circulaire, souvent associé à la notion de circuit court, mérite d'être considéré et expliqué dans la commande publique, puisqu'il s'agit de réemployer en tant qu'intrants dans un nouveau marché des produits qui ont déjà été utilisés précédemment. Au-delà de leur impact bénéfique sur l'environnement, ces deux mesures liées aux APD sont porteuses de dynamiques locales en incitant des PME ou des entreprises à vocation sociale locales à s'impliquer dans ces formes nouvelles de production de valeur¹⁴ à forte intensité de main d'œuvre.

Préoccupation plus récente, l'impact local va également bénéficier des options offertes par les APD. Au Sénégal, la notion de « contenu local » s'est récemment répandue dans le vocabulaire politique sénégalais pour refléter la préoccupation d'un développement inclusif et solidaire au profit de l'ensemble de la population et des territoires. Si la loi du 09 janvier 2019 relative au contenu local dans le secteur des hydrocarbures¹⁵ ne concernait pas les contrats de la commande publique, c'est surtout la récente loi 2021-23 du 2 mars 2021 relative aux contrats de partenariat public-privé qui a défini le contenu local comme étant un « *ensemble d'exigences pour les projets liées à des aspects de développement local englobant notamment des considérations relatives à l'emploi, l'éducation, ou d'ordre social ou environnemental* », et elle a repris l'élément « local » parmi les critères d'attribution du contrat de partenariats public-privé (art. 31 et 32). Cette volonté doit être prise en compte dans la révision du cadre juridique des marchés publics, tout en préservant les obligations internationales du Sénégal au regard de l'ouverture à la concurrence de ses marchés.

« D'une pierre, 3 coups » telle pourrait être la devise des APD car les combinaisons des objectifs et des solutions offertes permettent d'atteindre simultanément plusieurs résultats positifs. En offrant des outils ciblés, cette plasticité des mesures APD peut s'observer dans de nombreux secteurs. A propos des marchés de denrées alimentaires, la FAO a ainsi souligné¹⁶: « *Une caractéristique clé de l'achat public de denrées alimentaires est qu'il a la possibilité - en fonction de sa politique et de son cadre réglementaire - de déterminer non seulement la façon dont les aliments sont achetés, mais, en particulier (i) quels aliments seront achetés (locaux, diversifiés, nutritifs, sains, culturellement adaptés), (ii) auprès de qui (par ex. des agriculteurs locaux et / ou des petits exploitants, des petites et moyennes entreprises alimentaires, des femmes, des jeunes et / ou d'autres groupes vulnérables) et (iii) à partir de quel type de production (par exemple, une production agricole qui allie durabilité environnementale ainsi que biodiversité). Il déterminera également comment la nourriture sera reçue, stockée, préparée et ses déchets gérés.* » Cet exemple illustre les potentialités systémiques des APD pour répondre aux enjeux du pays tout en dégagant des résultats économiques et sociaux performants. Bien que les études soient longtemps restées empiriques et les données chiffrées rares pour étayer la vérification de l'impact positif des APD, des analyses récentes tendent à prouver l'efficacité des APD comme moteur d'un développement économique véritablement plus durable, au sens de pérenne. On peut citer l'exemple du Programme de gestion du littoral ouest-africain (WACA en anglais) qui est financé par la Banque Mondiale¹⁷, qui annonce des prévisions éloquentes. Si la dégradation environnementale du littoral du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal et du Togo a coûté en 2017 3,8 milliards de dollars,

¹² Réf. Rapport Carapaces, Fév. 2021, p. 9.

¹³ « *L'Etat apporte son appui aux personnes handicapées pour la création d'entreprises individuelles, de coopératives de production ou de petites et moyennes entreprises (PME).* » <http://www.handicap.sn/loi-orientation-sociale-au-senegal/>

¹⁴ En France, depuis le 1er janvier 2021, les acheteurs publics doivent acheter des biens issus du réemploi, de la réutilisation ou qui intègrent des matières recyclées dans des proportions de 20% à 100%, selon le type de produit. Toutefois, ces dispositions sont encore très expérimentales et méritent d'être testées dans des secteurs ou des produits déterminés

¹⁵ Mathieu NDIAYE et Bacary SEYDI, « Loi sur le contenu local au Sénégal : Les PME sénégalaises entre craintes et espoirs », Pmeinfo Juil 08, 2019, <https://www.pmeafricaines.com/2019/07/loi-sur-le-contenu-local-au-senegal-les-pme-senegalaises-entre-craintes-et-espoirs/>

¹⁶ Luana F. J. Swensson, Danny Hunter, Sergio Schneider, Florence Tartanac, Public food procurement for sustainable food systems and healthy diets, co-publié par la FAO et University of Rio Grande do Sul 2021 (à paraître).

¹⁷ Travaux du littoral à St Louis. Voir aussi les solutions prônées par le Programme de gestion du littoral ouest-africain (WACA).

soit 5,3 % du PIB des quatre pays, « des programmes de restauration de la nature, de gestion des inondations et de modernisation des logements peuvent créer des PME et des emplois verts pour la résilience. L'analyse coût-bénéfice des investissements d'adaptation côtière à court et à moyen-terme suggère un retour sur investissement de 13 % et un ratio coûts-avantages de 1,9 »¹⁸. Enfin, grâce à leur visibilité, les APD sont également des outils de bonne gouvernance puisqu'ils permettent de renforcer la légitimité de l'action publique. Par la transparence qu'impose leur préparation et la communication qui les entoure (les objectifs de durabilité doivent être mentionnés dès l'Avis d'appel d'Offres), par le suivi et les contrôles qui accompagnent leur exécution, ces marchés contribuent à souligner l'exemplarité de l'action publique et la démarche inclusive qui doit la caractériser.

Réformer le droit des marchés publics pour introduire les options des APD :

Même si le Sénégal a réalisé plusieurs avancées dans son système de passation de marchés publics ces dernières années, force est de constater que des efforts restent à fournir dans certains domaines dont celui des APD. L'évaluation de la MAPS (Méthodologie d'évaluation des systèmes nationaux de marchés publics), effectuée en 2017 au Sénégal à titre pilote, a conclu à la nécessité de développer une stratégie des achats publics durables. Cette stratégie a été adoptée par l'ARMP en 2019, sous la forme du PNAPD, ainsi qu'un Guide des APD, également recommandé par la MAPS 2017. La stratégie a prévu un plan d'actions sur 5 ans, notamment pour étayer le cadre juridique des APD au Sénégal, objet de ce Rapport.

Dans son périmètre, le présent Rapport vise à promouvoir les APD dans le droit de la commande publique sénégalaise, c'est-à-dire dans les catégories de contrats soumises au Code des Marchés Publics du Sénégal adopté en 2014 : les marchés publics¹⁹ et les délégations de service public (DSP²⁰) dont les concessions²¹ et affermages qui concernent principalement les acheteurs publics²². Dans la mesure où le concept de Commande publique couvre également les contrats de Partenariat Public Privé, le présent Rapport prend également en compte la loi n° 2120 du 2 mars 2021 relative aux PPP.

Les propositions formulées s'inscrivent dans le respect des principes fondamentaux de la commande publique : le libre accès, l'égalité de traitement des candidats et la transparence des procédures. La prise en compte du développement durable dans la commande publique ne signifie pas l'abandon de ces principes de base qui demeurent au cœur des politiques saines et redevables d'achats publics. A cet égard, le PNAPD affirme que : « Le respect de ces principes exige, d'une part, la définition préalable, la plus précise possible, des besoins des Autorités contractantes, en tenant compte d'objectifs de développement durable, et, d'autre part, la fixation d'exigences en lien exclusif avec l'objet du marché, de façon non-discriminatoire, proportionnées à l'objet du marché et évaluées sur des bases objectives ». Mais des évolutions récentes ont montré que ces principes fondamentaux peuvent aussi être appliqués au service d'une politique nationale de développement durable clairement identifiée. Cette prise en compte traduit une évolution : si les APD, ou les objectifs socio-environnementaux qu'ils poursuivent, ont longtemps été considérés comme des politiques secondaires dans le droit des achats publics alors que la primauté devait être réservée aux achats économiquement les plus avantageux déterminés suivant un processus compétitif basé essentiellement sur leurs coûts immédiats, cette hiérarchie cède le pas à

¹⁸ EDE IJJASZ-VASQUEZMARIA SARRAFSIMEON EHU, Comment soutenir une reprise verte, résiliente et inclusive sur le littoral ouest-africain ? <https://blogs.worldbank.org/fr/nasikiliza/comment-soutenir-une-reprise-verte-resiliente-et-inclusive-sur-le-littoral-ouest> 27 janvier 2021

¹⁹ Art. 4 § 23 du CMP 2014 : *Marché public* : « contrat écrit conclu à titre onéreux par une Autorité contractante pour répondre à ses besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services ou à des besoins combinant ces différentes catégories. Les marchés publics sont des contrats administratifs, à l'exception de ceux passés par les sociétés nationales et les sociétés anonymes à participation publique majoritaire, qui demeurent des contrats de droit privé ».

²⁰ D'après l'article 4 § 13 du CMP 2014 : « Délégation de service public : contrat administratif par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire, public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l'exploitation du service ».

²¹ D'après l'article 4 § 8 du CMP 2014 : la concession est un « contrat par lequel une personne publique charge un opérateur privé ou public, le concessionnaire, d'exécuter un ouvrage public ou de réaliser des investissements relatifs à tel ouvrage et de l'exploiter en vue d'assurer un service public, soit uniquement d'exploiter un ouvrage ou des équipements publics en vue d'assurer un service public. Le concessionnaire exploite le service en son nom et à ses risques et périls, en percevant des rémunérations des usagers de l'ouvrage ou des bénéficiaires du service concédé ». Dans le vocabulaire international, les contrats de concession de service (public) ou de travaux sont des PPP à financement privé.

²² Selon l'article 2 du CMP de 2014, il s'agit de l'Etat et ses services déconcentrés et les organismes non dotés de la personnalité morale placés sous son autorité ; les collectivités territoriales en y incluant ses services déconcentrés et les organismes non dotés de la personnalité morale placés sous leur autorité et les groupements mixtes et les établissements publics locaux ; les établissements publics ; les agences ou organismes de droit public ou privé, autres que les sociétés anonymes à participation publique majoritaire, dont l'activité est financée majoritairement par l'Etat ou une collectivité territoriale et s'exerce dans le cadre d'activités d'intérêt général ; les sociétés nationales et les sociétés anonymes à participation publique majoritaire, ainsi que les associations formées par l'Etat et ces dernières.

une approche plus nuancée. Dans de nombreux pays, les objectifs sociaux économiques et environnementaux sont devenus des politiques horizontales ou transversales, ils ont gagné en considération en raison de leur finalité sur le long terme (assurer la croissance durable) et doivent être mis en balance avec les exigences d'une concurrence stricte trop souvent réduite au prix le plus bas. Ainsi l'efficacité économique, l'équité sociale, et la croissance écologiquement soutenable deviennent-ils des objectifs non plus secondaires mais des paramètres à intégrer dans la conception du processus d'achat. Par ailleurs, à la différence des principes fondamentaux traditionnels qui portent essentiellement sur l'étape de la passation des marchés, l'objectif environnemental complété désormais par l'objectif social et l'objectif économique s'intéressent aussi beaucoup à la phase d'exécution des marchés qui contribue plus directement à rendre la durabilité effective. Les modalités d'exécution des contrats, telles que la présence de sous-traitants venus des PME locales, l'obligation d'offrir un certain nombre d'emplois aux groupes vulnérables, la préservation de l'environnement dans les techniques utilisées peuvent ainsi présenter des externalités positives sur le long terme qui viennent contrebalancer leurs coûts immédiats.

Les propositions formulées tiennent également compte des obligations internationales et régionales du Sénégal.

Le cadre UEMOA pour la commande publique est basée sur les 4 Directives qui ont été adoptées entre 2005 et 2012. Jusqu'à présent, le Sénégal s'est conformé à cette obligation de transposition et a respecté les règles de la sous-région. Cependant, depuis quelques années, un certain immobilisme a marqué la réflexion autour de l'évolution de ces directives qui, par certains aspects, ne sont plus toujours en phase avec les standards internationaux de la commande publique. Un travail de révision des Directives de l'UEMOA a d'ailleurs été lancé, notamment pour prendre en compte la dimension APD. L'adoption de la loi sur les PPP du 2 mars 2021 vient de démontrer que le Sénégal entendait faire évoluer ses règles rapidement. En adoptant la réforme en faveur des APD dans les marchés publics, le Sénégal pourrait ainsi jouer le rôle de précurseur dans la sous-région, capitalisant sur les initiatives déjà lancées par des pays non seulement du Nord mais également Africains.

Les mesures proposées permettent d'éclairer la notion d'APD dans le contexte sénégalais. Au-delà de l'énumération d'obligations sociales et environnementales qu'il conviendrait de déployer suivant la politique des APD, le Rapport propose une démarche à deux crans. Dans un 1^{er} temps, en obligeant tous les candidats et cocontractants à se conformer aux exigences éthiques, sociales et environnementales issues des lois applicables telles que les règles d'intégrité, des droits humains, d'égalité de genre, du droit du travail, du droit de l'environnement, de la maîtrise de l'énergie. Etablir les bases d'une commande publique responsable qui respecte les prescriptions du droit en vigueur est un préliminaire impératif. Dans un 2nd temps, le Rapport identifie les dispositions les plus à même de renforcer l'impact durable des APD avec des innovations adaptées au contexte sénégalais qui pourront être utilisées à différents stades de l'opération contractuelle, lorsque l'AC souhaite inclure des obligations environnementales ou sociales additionnelles dans ses marchés publics.

Les propositions formulées ont été adaptées à la situation particulière du Sénégal. Tout en s'inspirant de dispositifs APD étrangers performants qui ont démontré leur efficacité ou d'initiatives les plus récentes accompagnées par les PTF, les recommandations finales sont adaptées à la situation présente du développement sénégalais, doublée d'une situation économique spécifique dans le contexte de la crise COVID. A cet effet, **il a été estimé plus réaliste d'adopter une démarche progressive dans la mise en œuvre des APD au Sénégal afin de faciliter l'acceptation de cette réforme par les différents acteurs, publics et privés, de la commande publique.** Dans la mesure du possible, le Rapport distingue les mesures prescriptives, à caractère obligatoire, des mesures incitatives. Il adopte aussi une approche graduelle en ce qui concerne les exigences transcrites dans les DTAO : plus le montant des marchés est élevé, plus les exigences sociales et environnementales seront précises. Mais, *a minima*, tous devront s'engager dans la voie de la commande publique responsable.

Structures du Rapport :

PARTIE I : LE SYSTÈME ACTUEL DES APD AU SÉNÉGAL

Chapitre 1 : Des dispositions existantes propices aux APD, mais parcellaires. La préoccupation du développement durable a conduit à adopter quelques dispositions qui figurent déjà dans le Code des marchés publics de 2014 et ses textes d'application, ainsi que dans les Dossiers type d'appel d'offres (DTAO). Elles demeurent toutefois trop éparpillées et incomplètes pour être effectivement opérationnelles.

Chapitre 2 : Un « écosystème juridique » mobilisable pour les APD mais souvent ignoré. Ce chapitre permet de découvrir que le droit sénégalais est doté de dispositions favorables aux APD qui figurent dans des droits connexes, tels que le droit de l'environnement, le droit de l'énergie, le droit du travail, les droits des femmes, les règles d'hygiène santé et sécurité, etc... Sans textes d'application, inconnues des acteurs de la commande publique, ces dispositions n'ont pu développer tout leur potentiel jusqu'à présent.

PARTIE II : PROPOSITIONS de REVISION du CADRE JURIDIQUE

CHAPITRE 3 : IMPOSER LES PRINCIPES D'UNE COMMANDE PUBLIQUE RESPONSABLE DANS TOUS LES ACHATS PUBLICS, SANS EXCEPTION. Il s'agit de rappeler, au besoin par la mise en œuvre de nouvelles sanctions, que tout achat public doit se plier aux exigences légales déjà en vigueur en matière de respect du droit du travail, respect du genre, respect des droits des personnes victimes de handicap, respect de l'environnement, respect des règles sur l'efficacité énergétique, respect ou conformité aux normes en vigueur notamment en matière d'hygiène, santé et sécurité. Ce rapport propose une mesure symbolique : **l'adoption d'une nouvelle Charte de l'Ethique et de la commande publique responsable**, afin d'aboutir à des achats publics pleinement « responsables » et exemplaires où les Acheteurs publics et les entreprises s'efforcent de se conformer aux obligations sociales et environnementales existantes.

CHAPITRE 4 : INTRODUIRE DES OPTIONS APD A TOUTES LES ETAPES DE LA COMMANDE PUBLIQUE

Afin d'offrir aux Autorités Contractantes la possibilité de recourir volontairement aux APD, et dans un objectif de rationalisation et de cohérence du droit applicable, le rapport suggère déjà de consolider dans le droit de la commande publique les dispositions propices aux APD issues d'autres pans du droit sénégalais (par ex. les mesures de protection de l'environnement, les dispositions en faveur des PME, de l'artisanat, ou des startups). **Il propose également, en phase avec la réforme récente des PPP et de l'économie sociale et solidaire, d'introduire des dispositions de modernisation du cadre juridique de la commande publique qui répondent aux enjeux du développement local.**

CHAPITRE 5 : REVISER LES DTAO POUR REFLECTER L'HARMONISATION ET LA MODERNISATION NECESSAIRES AUX APD

Pour assurer la mise en œuvre effective des APD au Sénégal, il faut accompagner les AC et les entreprises en révisant les DTAO, d'abord en actualisant les DTAO existants afin de généraliser les obligations de la commande publique responsable puis en proposant une nouvelle série de « DTAO APD » contenant des mesures APD au service des AC qui recherchent un impact réel de leurs marchés publics.

PARTIE III : ACCOMPAGNER L'ESSOR DES APD PAR DES APPUIS INSTITUTIONNELS DEDIES

CHAPITRE 6 : CONCEVOIR UNE MISE EN ŒUVRE TRANSVERSALE DE LA POLITIQUE DES APD

Les mesures d'accompagnement de la réforme débutent par la mise en œuvre d'un plan de formation à destination de tous les acteurs de la commande publique. Mais ces mesures doivent aussi être conçues de manière concertée afin d'éviter les déboires passés avec l'élaboration d'un droit de la commande publique en silo, aussi des synergies ministérielles et administratives doivent-elles être mises en place.

CHAPITRE 7 : ATTIRER LES PME ET LES STARTUPS VERS LA COMMANDE PUBLIQUE

Le développement économique durable passe par la participation accrue des PME à la commande publique aussi faut-il mobiliser des appuis institutionnels ministériels et locaux adaptés. Mais l'attrait des PME pour la commande publique doit également être stimulé par le secteur privé lui-même, à commencer par les Grandes entreprises, titulaires des marchés publics.

CHAPITRE 8 : SOUTENIR LES ACTEURS DU SECTEUR PUBLIC

Le succès des APD passe aussi par des instruments de soutien et de responsabilisation des Autorités contractantes. Cette perspective permet d'insister sur le caractère intersectoriel et interinstitutionnel de la commande publique qui doit s'appuyer sur une collaboration organisée entre acteurs publics et avec le secteur privé.

Avertissement méthodologique :

Afin de faciliter la lecture du Rapport, des pictogrammes ont été utilisés et un code couleur permet d'identifier le pilier

environnemental  , le pilier économique  et le pilier social  ;

Des résumés figurent en tête de chaque chapitre et des tableaux synthétisent les propositions ;

La rédaction d'une phrase en caractère gras en tête de chaque paragraphe permet une lecture rapide ;

Un index est disponible à la toute fin du Rapport pour des recherches par mots-clés.

PARTIE I LE CADRE JURIDIQUE ACTUEL DES APD AU SENEGAL

Cette partie va permettre d'évaluer l'effectivité et l'efficacité du cadre juridique des APD au Sénégal, à travers l'examen de la réglementation applicable (chapitre 1). Puis, dépassant le strict cadre normatif de la commande publique, le chapitre 2 s'intéresse à « l'écosystème juridique » des APD au Sénégal à travers une exploration novatrice des domaines juridiques complémentaires et parallèles qui contribuent à la réalisation des APD.

CHAPITRE 1 : DES DISPOSITIONS EXISTANTES PROPICES AUX APD MAIS PARCELLAIRES

Ce chapitre présente une analyse critique des dispositions relatives aux APD qui figurent d'ores et déjà dans le droit de la commande publique sénégalais à partir d'une lecture partiellement appuyée sur le module APD de la MAPS (en anglais *Sustainable Public Procurement*) publié en janvier 2021²³. Aux piliers social, économique et environnemental, on doit ajouter un volet local qui focalise aujourd'hui l'attention du législateur sénégalais. Il permettra de montrer les liens consubstantiels qui existent entre les objectifs du développement durable, et donc des APD, avec la dimension locale.

La présentation du cadre juridique²⁴ débute par les Directives UEMOA dont le respect s'impose au Sénégal, puis une analyse du droit des marchés publics (Section 2) avant d'examiner les changements intervenus en matière de PPP (Section 3). Toutefois ces dispositions restent partielles, surtout tournées vers le volet économique des APD avec les marges de préférence en faveur de certains opérateurs. Peu ou pas accompagnées de mesures d'application, leur effectivité demeure encore limitée.

Section 1 Les possibilités offertes par les Directives marchés publics de l'UEMOA

Les Directives de l'UEMOA relatives aux marchés publics et DSP encadrent le régime des contrats de la commande publique en accordant une place limitée aux préoccupations sociales et environnementales. Ces Directives organisent les procédures de passation des contrats de la commande publique dans tous les pays qui relèvent de l'UEMOA

²³ Ce module (dont un résumé en anglais est présenté à l'annexe ) s'appuie sur 29 sous-indicateurs regroupés en 4 piliers : le cadre juridique existant ; le cadre institutionnel et les capacités ; les procédures et pratiques de marchés, puis enfin les questions de redevabilité, intégrité et transparence du système d'achats publics. Cependant, ce module s'est révélé insuffisant pour saisir pleinement la transversalité des APD et les champs juridiques connexes. Par conséquent, l'analyse a été étendue aux textes de lois sénégalais qui mentionnaient explicitement ou implicitement des dispositions à intégrer dans la commande publique. Le résultat aboutit à un tableau qui, sans être exhaustif, recense les principaux domaines collatéraux dont le respect doit être assuré, lors de la passation et de l'exécution des contrats de la commande publique sénégalaise.

²⁴ Inspiré par le sous-indicateur (1) a. du Module Sustainable Public Procurement de la MAPS 2021.

mais avec les premières, élaborées en 2005 et 2006²⁵ à une époque où la préoccupation environnementale, et encore moins celle du développement durable, ne rayonnait pas dans les textes internationaux²⁶, les APD ont été tout au plus effleurés. Curieusement la première Directive ne les envisage qu'à propos des critères d'évaluation des DSP, puisque son article 76 énonce : « *L'attribution de la convention s'effectue sur la base de la combinaison optimale de différents critères d'évaluation prévus dans le dossier d'appel d'offres, tels que (...) le potentiel de développement socioéconomique offert, le respect des normes environnementales* ». Les Directives de la 2^{de} vague, à partir de 2012²⁷, ne détaillent pas davantage ce domaine mais elles posent un cadre large qui permet d'envisager des déclinaisons nationales. La Directive relative à la maîtrise d'ouvrage déléguée dans son article 7 à propos de l'objet de la mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage liste « *l'aide au M.O. à la détermination de ses besoins, ses objectifs, ses besoins sociaux, fonctionnels, qualitatifs, techniques, environnementaux, de coût et de délai* » tandis que son article 13 dispose que la mission de maîtrise d'œuvre : « *a pour objet d'apporter une réponse architecturale, environnementale, technique et économique au programme de l'opération* ». De son côté, la Directive relative à l'éthique n'aborde pas les questions environnementales et sociales mais elle se préoccupe de la situation particulière des PME à prendre en considération (Article 17) à travers la définition des besoins fonctionnels et la rédaction des spécifications techniques et administratives intelligibles et objectives afin de ne pas « *introduire le moindre facteur discriminant vis-à-vis des candidats et soumissionnaires, et notamment, selon la nature et l'importance du marché, des petites et moyennes entreprises* ».

Les rédactions adoptées par les Directives UEMOA n'abordent pas précisément les APD, mais elles ne les interdisent pas. Tant leur esprit que leur rédaction permettent d'accueillir favorablement les initiatives APD qui pourraient être lancées par les Etats membres de l'UEMOA. L'analyse révèle que les possibilités d'insérer ces préoccupations dans les législations nationales paraissent en effet ouvertes à travers la définition des besoins, les conditions de qualification des entreprises, la certification de leurs compétences, ou encore les critères d'attribution, puisque ces derniers ne sont pas limitativement énoncés dans les Directives pour les marchés publics et, à propos des DSP en particulier, qu'ils font référence au développement socio-économique en général et au respect des normes environnementales. En revanche, une limite apparaît en matière de procédures d'attribution : toutes peuvent permettre les APD, sauf l'entente directe pour les marchés au-dessus des seuils UEMOA. En effet, les cas de recours à la procédure de l'entente directe sont limitativement énoncés sans avoir envisagé le cas d'un APD (Directive n° 04/2005, art 38²⁸). Aussi l'objet directement social et/ou environnemental ne pourra pas constituer un nouveau cas d'attribution par gré à gré, mais la portée de cette exclusion doit être relativisée : (i) rien n'interdit aux Acheteurs publics, une fois entrés dans une négociation de gré à gré, d'exiger la prise en compte de considérations contractuelles sociales et/ou environnementales, (ii) aucune restriction ne s'impose aux ententes directes sous les seuils. Par conséquent, cette limitation ne constitue pas une interdiction rédhibitoire pour les Etats membres.

On doit enfin mentionner qu'une révision de ces Directives UEMOA a été enclenchée depuis au moins 4 ans sans avoir encore abouti. Elle vise, notamment, à inclure et à approfondir les dimensions développement durable des achats publics. Mais il n'a pas été possible aux auteurs de ce Rapport d'avoir communication d'une version récente de ces projets.

Section 2 Le cadre juridique inachevé du droit des marchés publics

²⁵ La Directive n°04/2005/CM/UEMOA portant procédure de passation, d'exécution, et de règlement des marchés publics et des délégations de services publics dans l'UEMOA ; la Directive n°05/2005/CM/UEMOA portant contrôle et régulation des marchés publics et des délégations de services publics dans l'UEMOA.

²⁶ « *Le Traité de l'UEMOA renvoie, dans son article 3, aux droits fondamentaux énoncés par la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (CADHP) de 1981. (...) Elle a consacré une part importante à la préservation de l'environnement. En effet, en son article 24, la Charte consacre l'appartenance du droit à l'environnement aux droits humains fondamentaux. (Ainsi elle) a consacré formellement le droit à un environnement sain, qui à l'époque était un droit naissant* » repris ensuite dans les réformes nationales des pays de l'UEMOA », Yacouba SAVADOGO, L'environnement dans le traité de l'UEMOA : une prise en compte implicite, in Revue Africaine de Droit de l'environnement, (RADE) 2014 – 1, Actes du 1^{er} colloque sur le droit de l'environnement en Afrique p. 91, https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/rade_ndegl1.pdf

²⁷ Puis les Directives n°02/2012/CM/UEMOA du 28 septembre 2012, relative à l'éthique et à la déontologie dans les marchés publics et les DSP au sein de l'UEMOA et la Directive n° 02/2014/CM/UEMOA relative à la réglementation de la maîtrise d'ouvrage public déléguée au sein de l'UEMOA.

²⁸ « *Le marché est passé par entente directe dans les cas suivants : - lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation nécessitant l'emploi d'un brevet d'invention, d'une licence ou de droits exclusifs détenus par un seul entrepreneur, un seul fournisseur ou un seul prestataire ; - lorsque les marchés ne peuvent être confiés qu'à un prestataire déterminé pour des raisons techniques, artistiques ; - dans le cas d'extrême urgence, pour les travaux, fournitures ou services que l'autorité contractante doit faire exécuter en lieu et place de l'entrepreneur, du fournisseur ou du prestataire défaillant ; - dans le cas d'urgence impérieuse motivée par des circonstances imprévisibles ou de force majeure ne permettant pas de respecter les délais prévus dans les procédures d'appel d'offres, nécessitant une intervention immédiate, et lorsque l'autorité contractante n'a pas pu prévoir les circonstances qui sont à l'origine de l'urgence* ».

§ 1 Le cadre législatif des marchés publics ignore la commande publique durable

Le cadre législatif contemporain des marchés publics s'appuie sur la loi n° 65-51 du 19 juillet 1965 portant Code des Obligations de l'Administration modifiée par la loi n° 06-16 du 30 juin 2006. Cette structure hiérarchique permet d'inscrire les principes fondamentaux dans la loi et de prévoir les règles d'application dans le décret. Cependant, les principes fondamentaux de la commande publique méritent d'être réaffirmés et complétés. D'une part ces principes ne figurent pas expressément dans le texte à valeur réglementaire du CMP de 2014, d'autre part leur énoncé dans la loi n° 65-51 du 19 juillet 1965 portant Code des Obligations de l'Administration (COA) modifiée par la loi n° 06-16 du 30 juin 2006 reste incomplet. En effet le champ d'application du COA ne porte pas spécifiquement sur les contrats de la commande publique mais sur l'ensemble des contrats administratifs. Cette révision de 2006, qui avait pour objet d'aligner les textes sénégalais existants sur les nouvelles Directives de l'UEMOA qu'il convenait de transposer, a surtout insisté sur la distinction entre les marchés publics, les DSP et les contrats de partenariat, une distinction qui a perdu de sa pertinence avec la loi sur les PPP promulguée le 2 mars 2021.

L'article 24 du COA liste ainsi les « principes fondamentaux applicables aux achats : *En vue d'assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics, la conclusion des contrats d'achat passés à titre onéreux par les Acheteurs publics :*

- exige une définition préalable de leurs besoins par ces Acheteurs publics ;
- suppose l'existence de crédits suffisants selon le principe stipulé à l'article 17 du présent code ; et,
- doit respecter les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures ».

Outre que cette rédaction vise seulement les « contrats d'achats » paraissant exclure les contrats globaux de longue durée du type PPP, elle ne retient qu'une conception *a minima* des principes de la commande publique par rapport aux standards contemporains. Il n'est ainsi question ni de l'intégrité (alors que l'article 29 du COA proclame les règles d'éthique), ni de l'efficacité ou de l'efficacité des achats qui structurent aujourd'hui les systèmes modernes de commande publiques. **L'identification des besoins n'est pas expliquée et la prise en compte éventuelle de la finalité du développement durable est également ignorée.**

En revanche, le cadre juridique des PPP vient d'accueillir largement les préoccupations du développement durable, comme on le verra dans la Section 2.

§ 2 Un cadre réglementaire partiellement adapté à la commande publique durable

Le décret n° 2014-1212 du 22 septembre 2014 portant Code des Marchés publics (CMP) contient quelques dispositions éparpillées qui mentionnent certains aspects des APD qui seront repris dans les analyses propres à chaque pilier des APD. Le CMP est par ailleurs complété par les décrets n° 2007-546 et n° 2007-547 qui définissent l'organisation, la composition, le fonctionnement, les rôles, les responsabilités et les mandats de l'Autorité de régulation des marchés publics (ARMP) et de la Direction centrale des marchés publics (DCMP) et plusieurs arrêtés qui prévoient une réglementation spécifique pour l'application du Code des marchés publics. Toutefois l'adoption très récente de la réforme de l'ARMP qui devient l'ARCOP, par le décret du 21 octobre 2021, a permis de la doter de nouvelles compétences qui la place à la tête de la nouvelle stratégie des APD au Sénégal.

Concernant les procédures de passation, la réglementation sénégalaise actuelle prévoit des procédures simplifiées pour l'attribution des petits marchés, plus souples dans leurs exigences, qui peuvent être utilisées pour favoriser les APD. Comme ces procédures dites de Demandes de Renseignement de Prix (DRP) sont largement utilisées au niveau local, les collectivités territoriales disposent ainsi d'instruments qui peuvent être mobilisés en faveur des APD, à condition que ces collectivités soient formées et accompagnées en ce sens.

Il existe ainsi trois différents types de procédures DRP, régies par l'Arrêté n° 00107 du 7 janvier 2015, qui peuvent être utilisées pour les marchés sous certains seuils. De son côté, la procédure de la DRP ouverte a été justement créée pour simplifier la procédure classique d'Appel d'offres jugée trop lourde et contraignante. **Les procédures DRP existantes présentent des atouts qui les rendent attrayantes dans la perspective de la multiplication des APD.** On doit noter que les seuils des 3 DRP sont élevés, les règles de publicité et la possibilité de cibler certaines catégories de fournisseurs (telles que les organisations locales de petits exploitants agricoles ou les GIE de femmes) sont particulièrement bien

adaptées aux petits APD. Au-delà du critère du prix, la possibilité de faire appel à des critères d'attribution permettrait d'élargir la voie à des considérations de développement durable.

De surcroît, il existe des procédures allégées réservée par l'Article 79 du CMP 2014 aux collectivités dont le budget ne dépasse pas un seuil fixé par arrêté du Ministre chargé des Finances. De fait, l'Arrêté n° 00863 du 22.01.2015 a prévu que ce budget annuel initial doit être inférieur à 300 millions de francs CFA. Ces collectivités disposent d'un délai plus long pour transmettre leurs plans de passation de marchés à la Direction centrale des Marchés publics et la publication des avis généraux de passation de marchés, jusqu'au 30 avril de chaque année. Elles bénéficient également de formalités de publicité et de cahiers des charges adaptés. Notamment en cas de procédures de DRP simple ou à compétition restreinte, ces Autorités contractantes peuvent solliciter des prix par écrit auprès de trois candidats au minimum (au lieu de 5).

Une remarque générale s'impose, avant d'entrer dans le détail de chaque pilier des APD dans le CMP : l'absence de référence ou d'utilisation de critères autres que celui du prix dans la majorité des procédures d'achats publics au Sénégal. En effet, si l'article 59 du CMP définit largement l'offre la moins-disante²⁹, en faisant appel à des critères qualitatifs, le contenu des DTAO et la pratique (voir le chapitre 4) attestent que les AC se contentent dans la très grande majorité des cas de ne retenir que le prix le plus bas. Or il s'agit d'un obstacle majeur à la mise en œuvre des APD. Les documents support à destination des Acheteurs publics ne permettent pas de compléter ces critères d'évaluation, sauf avec le Guide des APD de 2020 qui aborde les critères environnementaux mais consacre relativement peu d'analyses aux autres piliers des APD. Le site de l'ARMP propose par ailleurs un Guide du soumissionnaire - Accès des PME à la commande publique (2015, 84 p.) mais ce dernier ne contient aucune recommandation ou explication relative aux caractéristiques environnementales ou sociales des candidatures (à part le rappel que les candidats doivent être en règles en matière de cotisations sociales).

Les dispositions du droit des marchés publics appropriées à l'ancrage des piliers des APD sont présentées dans les 4 paragraphes ci-dessous, accompagnés de tableaux récapitulatifs, reprenant successivement les 3 volets des APD, volet social, économique et environnemental. Toutefois, et afin de refléter une préoccupation plus récente en faveur du « contenu local », un 4ème paragraphe isole les mesures envisagées ou promulguées dans ce but.

§ 2 -1 Aucune disposition en faveur des groupes vulnérables dans le Code des Marchés Publics



Concernant le volet social, aucune disposition du CMP de 2014 ne vise les groupes vulnérables en général ou les femmes, les jeunes, ou les personnes atteintes de handicap en particulier, afin de leur offrir un accès spécifique à l'emploi, encore moins à des formations. Il n'existe pas non plus de disposition qui assure

l'égalité des genres, ou qui introduise des mesures de discrimination positive en faveur de certains groupes vulnérables. Par exemple, la catégorie particulière des PME dirigées par des femmes, dites PME à direction féminine ne bénéficie d'aucune reconnaissance et encore moins de mesures préférentielles. Il existe ainsi un vide dans le droit de la commande publique alors que, par ailleurs, comme on le verra dans la Section suivante sur « l'eco-système juridique » des APD, des initiatives législatives et des programmes gouvernementaux en faveur de groupes spécifiques et des entreprises dirigées par des femmes en particulier se sont multipliés ces dernières années. Tout au plus peut-on mentionner les « groupements d'ouvriers, aux coopératives ouvrières de production, aux groupements et coopératives d'artisans, aux coopératives d'artistes et aux artisans individuels suivis par les Chambres consulaires ainsi qu'aux organismes d'étude, d'encadrement ou de financement agréés », ensemble hétéroclite à mi-chemin entre le répertoire social et le répertoire économique, à qui a été reconnu le bénéfice d'une marge de préférence dans les AON, mais qui n'a pratiquement jamais été mise en œuvre.

Mesure ADP	Source	Disposition
Préférence pour certains groupements d'ouvriers, d'artisans ou d'artistes	CMP 2014 art. 50	Dans le cadre d'un Appel d'offres national, la même préférence est accordée uniquement, à qualité équivalente et à délais de livraison

²⁹ Article 59 : « La détermination de l'offre la moins-disante est effectuée soit sur la base du prix le plus bas, soit sur la base du prix et d'autres critères, tels que le coût d'utilisation, les performances techniques, les mesures de protection de l'environnement, le délai de livraison ou d'exécution, qui doivent être énumérés dans le dossier d'Appel à la concurrence et être exprimés en termes monétaires ou sous la forme de critères éliminatoires. Il est tenu compte, le cas échéant, des préférences mentionnées à l'article 50 du présent décret ».

		comparable, aux groupements d'ouvriers, aux coopératives ouvrières de production, aux groupements et coopératives d'artisans, aux coopératives d'artistes et aux artisans individuels suivis par les Chambres consulaires ainsi qu'aux organismes d'études, d'encadrement ou de financement agréés. (à condition que leurs offres ne soient pas supérieures de plus de 15 % à celle du moins-disant)
Exonération de la garantie de soumission	CMP (2014) art.114	Dans le cas « des groupements d'ouvriers, les coopératives ouvrières de production, les coopératives d'artistes et les artisans individuels suivis par les Chambres consulaires, les organismes d'études, d'encadrement ou de financement agréés sont dispensés de fournir une garantie de soumission quand la valeur de soumission ne dépasse pas 50.000.000 F CFA. »

§ 2- 2 Les dispositions existantes du Code des Marchés Publics en faveur de l'accès des PME



Le CMP de 2014 comprend relativement peu d'articles directement en faveur des PME et autres petites structures commerciales ou artisanales. Par dispositions directes, on entend les mesures qui s'adressent explicitement aux PME ou autres acteurs économiques à besoins spécifiques, tels que les coopératives et groupements d'artisans, ouvriers ou artistes. Ainsi, au titre des dispositions explicites en faveur des PME, on recense dans le CMP l'article 8 sur la division en lots et l'article 48 sur la sous-traitance (voir tableau ci-dessous). De son côté, l'article 50.1 organise une préférence, restreinte au cas des Appels d'Offres Nationaux, en faveur des « *groupements d'ouvriers, aux coopératives ouvrières de production, aux groupements et coopératives d'artisans, aux coopératives d'artistes et aux artisans individuels suivis par les Chambres consulaires ainsi qu'aux organismes d'étude, d'encadrement ou de financement agréés* »³⁰. On doit mentionner ici les exemptions concernant la soumission anticipée de documents dans certaines DRP ainsi que des dispositions financières particulières.

Concernant les garanties financières, l'Arrêté fixant les seuils en dessous desquels il n'est pas requis de garantie de soumission, pris en application de l'article 114 du Code des Marchés publics a ouvert à l'AC la faculté de ne pas exiger la fourniture d'une garantie de soumission pour les marchés d'un montant estimé inférieur à 80 millions de francs CFA TTC pour les marchés de fournitures et de services autres que des prestations intellectuelles et à 100 millions de francs CFA TTC pour les marchés de travaux. Uniquement pour ces catégories susvisées, le CMP envisage la dispense de soumettre une garantie de soumission quand cette dernière ne dépasse pas 50 000 000 FCFA (art. 114). On notera que ces articles ouvrent des possibilités à la discrétion des A.C. mais aucune obligation de privilégier les PME et autres entités.

Avance forfaitaire de démarrage : Suivant l'Article 97 du CMP de 2014, une avance forfaitaire de démarrage peut être accordée à l'entreprise titulaire des travaux quel qu'elle soit mais c'est une solution intéressante pour la PME qui va ainsi disposer de trésorerie pour le démarrage des travaux. Cette avance forfaitaire de démarrage est plafonnée à 20% du montant TTC du marché initial, si la durée du marché ne dépasse pas 12 mois. Si la durée d'exécution est plus longue, cette avance est calculée sur le montant des prestations à exécuter au cours des 12 premiers mois.

Garantie de bonne exécution : De son côté, l'Arrêté n° 00866 du 22.01.2015 fixe un seuil minimal, puisqu'il réserve l'exigence d'une garantie de bonne exécution pour les marchés de fournitures et de services dont le montant est égal ou supérieur à 70 millions FCFA TTC, contre initialement 25 millions FCFA TTC, et pour les marchés de travaux et de prestations intellectuelles dont le montant est égal ou supérieur à 100 millions FCFA TTC, contre initialement 35 millions FCFA TTC. Ces dispositions peuvent jouer en faveur des PME à direction féminine, des entreprises sociales, GIE et Artisans, mais, dans les deux cas il s'agit d'une faculté et non d'une obligation laissée à la discrétion de l'AC.

³⁰ Le texte intégral des articles mentionnés figure dans le tableau récapitulatif ci-dessous.

Si ces dispositions semblent offrir un support minimal suffisant pour appuyer une politique en faveur des PME, elles sont longtemps restées sous-utilisées, soit en raison d'une incertitude d'ancrage notionnel (une définition claire de la PME a fait défaut jusqu'à la loi du 7 janvier 2020 voir *infra* Section 2), de même que la définition des autres catégories énumérées, soit en raison de l'absence de textes d'application adoptés dans le champ de la commande publique. Pivot majeur de cette politique, l'incertitude autour de la définition même de la PME a bloqué la mobilisation des programmes et l'utilisation optimale des régimes préférentiels qui avaient été envisagés dans le CMP.

Le même constat de timidité doit être dressé à propos des dispositions qui peuvent indirectement favoriser les PME. Ces dispositions ne limitent pas leur champ d'application aux PME mais leur mobilisation pourrait contribuer à stimuler les candidatures des PME. Au titre de ces dispositions indirectes figurent la possibilité de diviser le marché en lots ou, pour les candidats, de constituer des groupements d'entreprises (art. 47) qui, conjoints ou solidaires, peuvent permettre à des PME de s'associer entre elles ou avec une entreprise plus importante, afin de répondre avec succès à un appel d'offres. C'est un outil potentiellement puissant pour promouvoir des PME qui n'ont pas l'assise suffisante pour remporter seules un marché mais qui peuvent ainsi en devenir des partenaires titulaires et acquérir une expérience salutaire. De fait plusieurs articles du CMP font référence aux groupements, notamment pour bénéficier de préférence et accéder en tant que groupements d'entreprises communautaires (UEMOA) et non communautaires à des marchés par entente directe (art. 52). Mais, s'ils peuvent être mobilisés par les PME et autres entités, ces dispositifs ne leur sont pas réservés.

Mesure APD – pilier économique	Source	Disposition existante
Préférence dans les AON en faveur des ouvriers, artisans, artistes organismes d'étude, d'encadrement ou de financement agréés	CMP (2014) Art. 50 al 2.	<i>Dans le cadre d'un Appel d'offres national, la même préférence est accordée uniquement, à qualité équivalente et à délais de livraison comparable, aux groupements d'ouvriers, aux coopératives ouvrières de production, aux groupements et coopératives d'artisans, aux coopératives d'artistes et aux artisans individuels suivis par les Chambres consulaires ainsi qu'aux organismes d'étude, d'encadrement ou de financement agréés.</i>
Allotissement	CMP (2014) Article 8	Art 50 al 1 et 2. <i>Les travaux, fournitures ou services peuvent être répartis en lots donnant lieu chacun à un marché distinct lorsque cette division est susceptible de présenter des avantages économiques, techniques ou financiers, y compris en vue de faciliter la candidature des petites et moyennes entreprises. Ce choix ne doit pas avoir pour objet ou pour effet de soustraire les marchés aux règles qui leur sont normalement applicables en vertu du présent décret</i>
Priorité aux PME sénégalaises ou communautaires dans la sous-traitance locale des marchés publics	CMP (2014) Article 48	<i>Le titulaire d'un marché public de travaux ou d'un marché public de services peut sous-traiter l'exécution de certaines parties du marché jusqu'à concurrence de 40 % de son montant en recourant en priorité à des petites et moyennes entreprises de droit sénégalais ou à des petites et moyennes entreprises communautaires à condition d'avoir obtenu l'accord préalable de l'Autorité contractante.</i>

Marge de préférence dans la sous-traitance locale des marchés des coll. Loc. ou étab. Pub local.	CMP (2014) article 48	<i>Dans le cas d'un marché d'une collectivité locale ou de l'un de ses établissements publics, le candidat au marché qui aura prévu de sous-traiter au moins 30 % de la valeur globale du marché à une entreprise locale pourra bénéficier d'une marge de préférence qui ne pourra être supérieure à 5 %, cumulable avec la préférence visée à l'article 50 du présent décret (AOI et AON)</i>
Possibilités de Groupements	CMP Article 47 : (Groupements conjoints & groupements solidaires)	
Suppression de la garantie de soumission pour les marchés sous certains seuils	CMP (2014) art. 114 et Arrêté du 22/01/2015 fixant les seuils en dessous desquels il n'est pas requis de garantie de soumission, pris en application de l'article 114 du Code des Marchés publics	<i>En application de l'article 114 du Code des Marchés publics, l'autorité contractante peut ne pas exiger la fourniture d'une garantie de soumission pour les marchés d'un montant estimé inférieur aux seuils ci-après : • 80 millions de francs CFA toutes taxes comprises pour les marchés de fournitures et de services autres que des prestations intellectuelles ; • 100 millions de francs CFA toutes taxes comprises pour les marchés de travaux.</i>
Suppression de la garantie de bonne exécution	CMP (2014) art. 115 et Arrêté 22/01/2015 n° 00866 DU 22.01.2015 Arrêté pris en	Concernant la garantie de bonne exécution, elle n'est obligatoire que : - pour les marchés de fournitures et de services dont le montant est égal ou supérieur à 70 millions FCFA TTC, contre initialement 25 millions FCFA TTC, et ;

	application de l'article 115 du Code des Marchés Publics	- pour les marchés de travaux et de prestations intellectuelles dont le montant est égal ou supérieur à 100 millions FCFA TTC, contre initialement 35 millions FCFA TTC.
Avance forfaitaire de démarrage	CMP (2014) article 97	Cette disposition n'est pas spécifique aux PME : 1. Il peut être accordé une avance forfaitaire de démarrage. Cette avance de démarrage est versée dans les délais de paiement normalement requis après réception de la demande de paiement accompagnée de la garantie correspondante. 2. Le montant de l'avance de démarrage ne peut excéder 20 % calculé soit sur le montant initial du marché, taxes comprises lorsque la durée d'exécution de celui-ci est inférieure ou égale à un an, soit lorsque la durée d'exécution est supérieure à un an sur le montant des prestations à réaliser au cours d'une première tranche de douze mois.

§ 2-3 L'apparition de la dimension locale dans le droit des marchés publics sénégalais



La question de la nationalité et/ou du caractère local de l'entreprise a progressivement émergé en tant que critère à part entière. A cet égard, la politique des APD peut être un vecteur pour promouvoir la dimension locale des achats, soit en faveur d'une origine « locale » des produits soit en faveur d'entreprises « locales ». Il faut néanmoins clarifier quelques notions avant d'expliquer les procédures mobilisables.

L'origine des entreprises candidates. Les différents articles du CMP de 2014 instaurant des marges de préférences, à partir des Directives marchés publics de l'UEMOA, ont multiplié les adjectifs « communautaire », « local » ou « national »³¹ alors que ces notions pouvaient ne pas être nettement définies par le droit positif. Récemment, comme on le verra avec l'étude de « l'écosystème juridique » complémentaire des APD (infra), la loi du 7 janvier 2020 est enfin venue préciser les définitions de ces différentes catégories d'entreprises identifiées suivant un critère géographique. On peut néanmoins continuer à relever qu'il n'existe pas, en droit sénégalais de la commande publique, une dimension véritablement « locale » au sens d'un terroir d'implantation ou de production. En l'état du droit positif, il n'est pas possible à une AC de vouloir privilégier les entreprises de telle ou telle région du pays ; ce qui poserait d'ailleurs des questions d'égalité au regard des règles d'accès à la commande publique. L'adjectif « local » signifie par conséquent : « sénégalais ».

Les Directives de l'UEMOA, appliquant l'interdiction de la discrimination des entreprises en fonction de leur nationalité ont tenté de remplacer les préférences nationales par des préférences communautaires, qui seraient opposables par toute entreprise venant d'un Etat partie à l'UEMOA. L'article 26 de la Directive de l'UEMOA 2005/05 a néanmoins prévu la possibilité d'une marge de préférence de 5 % en faveur du candidat à un marché « local » au sens de territorial (sans précision de sa nationalité) qui aurait prévu de sous-traiter auprès d'une entreprise « locale » : « *Dans le cas d'un marché d'une collectivité locale ou de l'un de ses établissements publics, le candidat au marché qui aura prévu de sous-traiter au moins trente pour cent (30 %) de la valeur globale du marché à une entreprise de l'Etat membre dans lequel le marché est exécuté pourra bénéficier d'une marge de préférence qui ne pourra être supérieure à cinq pour cent (5 %), cumule avec la préférence visée à l'article 62 de la présente Directive* ». Le marché sous-traité peut ainsi bénéficier à une entreprise nationale, avec une forte probabilité qu'il s'agisse d'une entité implantée « localement » à proximité de l'Autorité contractante qui doit être une collectivité locale ou un établissement public local. Cette disposition a été reprise dans le CMP de 2014. Autre manifestation éventuelle de la nationalité, l'entente directe est réservée aux seules entreprises sénégalaises et communautaires régulièrement à jour du paiement de la patente ou exemptées et inscrites au registre du commerce et du crédit mobilier ou au registre des métiers au Sénégal ou dans l'un des Etats membres de l'UEMOA.

Concernant la preuve de l'origine de l'entreprise candidate ou des produits, l'art. 51 du CMP dispose que : « *Pour bénéficier de la préférence prévue ci-dessus les candidats doivent joindre (...) une déclaration par laquelle ils demandent à bénéficier desdites dispositions, en même temps qu'ils apportent toutes justifications sur l'exercice de leurs activités au Sénégal ou dans un pays membre de l'UEMOA, sur l'origine sénégalaise ou communautaire des produits ou sur leur existence et leur enregistrement conforme à la réglementation qui leur est applicable* ». Il conviendra

³¹ Les articles mentionnés dans ces paragraphes sont reproduits dans le table récapitulatif ci-dessous.

par conséquent d'introduire dans le CMP les distinctions consacrées par la récente loi sur les PME en raison du critère de nationalité géographique.

On note cependant dans les CCAG des DTAO (ex : DTAO Grands travaux) la mention d'un « critère d'origine » en vertu duquel « *Sauf disposition contraire figurant au CCAP, les titulaires de marchés dont le financement est prévu par les budgets des Autorités contractantes soumises au Code des Marchés publics, doivent être des entreprises sénégalaises ou d'un Etat membre de l'UEMOA régulièrement patentées ou exemptées de la patente et inscrites au registre du commerce et du crédit mobilier ou au registre des métiers au Sénégal ou dans l'un desdits Etats.* » Cette disposition définit une éligibilité restrictive qui empêche l'AOI au-delà du cadre communautaire.

En revanche, il n'existe pas de disposition sur l'origine ou le caractère local dans les petits marchés ni dans le CMP de 2014, ni dans le DTAO sur les marchés de moins de 25 Millions de FCFA dans les Communes à budget annuel inférieur à 300 Millions. Si elle est volontaire, cette absence peut s'expliquer par la volonté de simplifier les procédures locales en évitant aux AC le calcul compliqué de la marge de préférence, renforcée par la supposition que le montant modeste du marché n'intéressera que des entreprises « locales » au sens de proches géographiquement. Sous les seuils de trois millions FCFA, il n'y a aucune contrainte : le choix de l'entreprise est libre et la négociation est libre. Il n'est pas nécessaire d'annoncer officiellement la possibilité de marché, de préparer un appel d'offres officiel ou d'utiliser des documents d'appel d'offres standard, ni d'approcher un grand nombre de fournisseurs potentiels. Néanmoins, cette procédure très souple ne garantit pas l'achat auprès des fournisseurs locaux même lorsque la production locale existe en quantité suffisante. Le cas a notamment été relevé pour les achats de denrées alimentaires par les cantines scolaires (Rapport FAO, p. 22). Ce Rapport constate qu'il n'existe pas non plus de Circulaire interne³² exigeant l'achat auprès des petits producteurs locaux. Comme on le verra ci-dessous, la récente loi sur les PPP du 2 mars 2021 a au contraire prévu des préférences locales, c'est-à-dire sénégalaises et communautaires, sous des seuils qui restent à définir. Le CMP révisé devrait s'aligner sur la même position.

L'origine des produits ou des services. En application de l'article 50.1 du CMP de 2014 relatif aux Appels d'Offres Internationaux, les modalités de calcul de la marge de Préférence en fonction de la règle d'origine des produits ont été envisagées par le DTAO Accord-cadre fourniture connexe (janv. 2020), le DTAO Passation des marchés de fournitures (Mai 2017) et le DTAO Acquisition de Manuels Scolaires Selon L'Approche Par les Compétences, (Mai 2017). Ils témoignent d'une approche harmonisée qui simplifie la tâche des AC, voire des entreprises candidates et qu'il faudrait étendre aux autres DTAO susceptibles d'être concernés.

Marge de préférence dans les AOI pour les entreprises locales ou communautaires	CMP (2014) Article 50 .1.	<i>Pour les marchés passés sur Appel d'offres international, une préférence est accordée aux candidats de droit sénégalais ou de pays membres de l'UEMOA (...), à condition que leurs offres ne soient pas supérieures de plus de 15 % à celle du moins-disant.</i>
Préférence dans les ententes directes pour les entreprises sénégalaises ou communautaires ou venant d'Etats appliquant le principe de réciprocité	CMP (2014) article 52 (Toutefois on peut s'interroger quant à l'appréciation effective du principe de réciprocité)	<i>Lorsque, du fait de l'envergure financière du marché et/ou de la complexité technique des travaux, fournitures ou services, la faible concurrence locale ne garantit pas une compétition transparente ou une exécution économique et diligente du marché.(...). Dans ce cas, une préférence est obligatoirement accordée aux entreprises communautaires et aux groupements conjoints susvisés, proportionnellement à la participation des entreprises communautaires, conformément aux dispositions de l'article 50 du présent Code. Un arrêté du ministre chargé des Finances définit les modalités d'application du régime préférentiel</i>
Marge de préférence dans la Sous-traitance locale des marchés des Collectivités territoriales ou Etablissement public local.	CMP (2014) art. 48	<i>Dans le cas d'un marché d'une collectivité locale ou de l'un de ses établissements publics, le candidat au marché qui aura prévu de sous-traiter au moins 30 % de la valeur globale du marché à une entreprise locale pourra bénéficier d'une marge de préférence qui ne pourra être supérieure à 5 %, <u>cumulable avec la préférence visée à l'article 50 du présent décret</u></i>
Priorité aux PME sénégalaises ou communautaires dans la sous-	CMP (2014) Article 48	<i>Le titulaire d'un marché public de travaux ou d'un marché public de services peut sous-traiter l'exécution de certaines parties du marché jusqu'à concurrence de 40</i>

³² Malgré l'existence de directives couvrant d'autres aspects du programme d'alimentation scolaire (telles que le guide des cantines scolaires élaboré en partenariat avec le PAM14 et l'ONG Counterpart International et le guide pour l'élaboration des menus préparé avec l'appui de la FAO pour la région de Sédhiou : TCP/SEN/3602: Approche intégrée de filets sociaux productifs, d'alimentation scolaire et de nutrition au Sénégal.

traitance locale des marchés publics		% de son montant en recourant en priorité à des petites et moyennes entreprises de droit sénégalais ou à des petites et moyennes entreprises communautaires à condition d'avoir obtenu l'accord préalable de l'Autorité contractante.
Marge de Préférence dans les AOI pour les produits locaux ou UEMOA	CMP (2014) art. 50 + modalités de calcul prévues dans les DTAO : Accord cadre fourniture connexe janv. 2020 ; DTAO Passation des marchés de fournitures (Mai 2017) et DTAO Acquisition de Manuels Scolaires Selon L'Approche Par les Compétences, (Mai 2017)	Art 50 : « et aux candidats dont les offres ne comportent que des produits d'origine sénégalaise ou de pays membres de l'UEMOA par rapport aux candidats de droit non communautaire, à condition que leurs offres ne soient pas supérieures de plus de 15 % à celle du moins-disant.
Contrôle de l'utilisation de produits locaux ou communautaires dans les PPP	Loi PPP (2021) Article 44. AOI – AON	(...) d) le contrôle du respect par le titulaire des conditions contractuelles relatives à (...) l'utilisation des produits nationaux ou communautaires ;

§ 2 - 4 L'entrée remarquée de la dimension environnementale dans le droit des marchés publics sénégalais



Le CMP de 2014 contenait déjà quelques dispositions en faveur de la protection de l'environnement dans les marchés publics. Ces modalités, qui interviennent à divers stades de l'opération de l'achat public, sont retracées dans le tableau ci-dessous. Par ailleurs, le Guide des APD (2020) ayant largement développé cette dimension des APD, le présent Rapport ne reprendra pas ses explications et renvoie au Guide.

Critères de qualification du candidat au marché public	CMP art 44 l'al. 1	« Sous réserve du respect de ses droits en matière de protection de la propriété intellectuelle ou industrielle et de la confidentialité des informations concernant ses activités, tout candidat à un marché public doit justifier qu'il dispose des capacités juridiques, techniques, financières et <u>environnementales</u> requises pour exécuter le marché (...). » A ce titre, il doit présenter « des renseignements sur le savoir-faire du candidat en matière de protection de l'environnement, le cas échéant ; » (Cf.44.h) ;
Critères d'attribution- d'évaluation des offres de marchés publics	CMP Art 59 :	« 1. La détermination de l'offre la moins-disante est effectuée soit sur la base du prix le plus bas, soit sur la base du prix et d'autres critères, tels que le coût d'utilisation, les performances techniques, les mesures de protection de l'environnement, le délai de livraison ou d'exécution, qui doivent être énumérés dans le dossier d'Appel à la concurrence et être exprimés en termes monétaires ou sous la forme de critères éliminatoires....2. La qualification du candidat qui a présenté l'offre évaluée la moins-disante au regard des capacités juridiques, techniques, <u>environnementales</u> et financières requises est examinée indépendamment du contenu de son offre, au vu des justifications qu'il a soumises...» ;
Cycle de vie (définition)	CMP (liste des définitions) Art 4.11	Cycle de vie : l'ensemble des étapes. successives que peut connaître un produit, à savoir la recherche et le développement, le développement industriel, la production, la réparation. la modernisation, la modification, l'entretien et la maintenance, la logistique, la formation, les essais, le retrait et l'élimination
L'avis de la DCMP sur la poursuite de la procédure de passation après une offre spontanée	CMP art 81	L'avis que donne la DCMP pour la poursuite de la procédure de passation d'un marché public faisant suite à une offre spontanée est effectué sur la base d'un Rapport d'expertise portant <u>notamment sur les aspects environnementaux</u> en cas d'offre spontanée.
Cas de résiliation pour faute du marché public	CMP Art. 129.1.	Tout marché public peut faire l'objet d'une résiliation totale ou partielle à l'initiative de l'Autorité contractante : a) en cas de manquement grave du titulaire à ses obligations contractuelles, notamment en matière <u>environnementale</u> ;

§ 3 De rares dispositions en faveur des APD dans les Documents type d'appels d'Offres

L'analyse des DTAO existants au printemps 2021 fait ressortir leurs faiblesses et leurs lacunes dans la perspective de l'essor des APD au Sénégal. 21 Documents-types³³ sont accessibles sur le site de l'ARMP devenue ARCOP³⁴, totalisant plus de 2000 pages qui sont en plus assorties de documents explicatifs³⁵. Récents, puisqu'adoptés entre 2016 et 2020, la grande majorité en 2017, ces documents s'inspirent souvent des Documents standards de la Banque Mondiale de l'époque qui ne traduisaient pas encore une orientation marquée en faveur des APD.

3 faiblesses principales peuvent être relevées dans les DTAO actuels :

- L'obligation de conformité de l'exécution aux règles sociales, environnementales, d'hygiène, de santé et de sécurité n'est pas mentionnée de manière systématique dans les DTAO ;
- L'exigence de capacités en matière environnementale reste sporadique dans les DTAO alors qu'elle est pourtant mentionnée dans le CMP³⁶ ;
- Les critères d'attribution et la méthode d'évaluation de l'offre la moins-disante ne permettent pas d'orienter le marché vers les APD.

§ 3-1 L'obligation de conformité aux règles existantes n'est pas mentionnée de manière systématique dans les DTAO

Concernant les achats responsables, la conformité avec les règles existantes est rarement exigée, en-dehors des règles d'éthique. A cet égard, la référence à la Charte de Transparence et d'Ethique est présente dans pratiquement tous les DTAO, non la Charte elle-même (mention par prétérition), mais la plupart attache le modèle d'acte d'engagement à respecter la Charte qui doit être signé par le candidat, ainsi que l'énumération des sanctions encourues en cas de manquement, notamment des sanctions prononcées par le CRD (Introduction des Instructions aux candidats). Toutefois cette exigence ne concerne pas les plus petits marchés puisque la référence à la Charte et l'engagement corollaire sont absents des Dossiers-types de Demande de renseignement de prix (DRP) Travaux et Fournitures.

Dans les DTAO qui se préoccupent les questions environnementales et/ou sociales incluant les questions hygiène et sécurité, la santé n'est pas mentionnée et les obligations sont très disparates entre des DTAO prescriptifs et détaillés et d'autres qui demeurent très allusifs.

- DTAO Passation des Marchés de Travaux (Grande taille) (2021, 205 p.) et le DTAO Passation des Marchés de Travaux (de taille moyenne) (Mai 2017, 126 p.) c'est-à-dire pour des marchés d'un montant compris entre 100 millions et 300 millions de FCFA³⁷, comprend non seulement un PGES assorti d'un plan hygiène et sécurité mais également des clauses types à propos du respect de la législation du travail et des conditions d'hygiène et de traitement sanitaire³⁸.

³³ Ainsi que le cahier des prescriptions techniques applicable aux prestations de désherbage des accotements qui ne paraît pas à sa place dans cette page du site de l'ARMP.

³⁴ DAO Type Accord cadre Fournitures et services connexes ; DAO Type Accord cadre Travaux ; DP Type Accord cadre Prestations Intellectuelles ; Passation d'un contrat de délégation de service public ; DAO fourniture- services Communes ; DAO fournitures scolaires ; DAO Fournitures ; DAO Services physiques ; DAO Travaux clés en main ; DAO Travaux Communes ; DAO travaux Grande taille ; DAO Travaux Taille moyenne ; Dossier standard préqualification ; DRP fournitures ; DRP travaux ; Gestion et l'Entretien des routes par Niveaux de Service (GENIS) ; PI - Dossier standard pré sélection ; PI - Marchés importants ; PI - marchés moins de 5 000 000 CI ; PI - Formulaire évaluation des propositions PI - Marché de petits montants ; Prescriptions techniques Désherbage

³⁵ Lignes directrices sur Accords-cadres ; Directives en matière d'analyse de la capacité financière

³⁶ « Le code des Marchés publics est complété par un ensemble d'arrêtés et des dossiers types. Toutefois, les clauses environnementales et sociales ne sont prises en charge que dans certains dossiers types » (ARMP Guide d'APD, p. 21)

³⁷ Deux autres dossiers d'appel d'offres types ont été préparés, l'un intitulé « Dossier d'Appel d'Offres type Passation des Marchés de Travaux de grande taille » prévu pour les marchés dont la valeur est supérieure ou égale à 300 millions FCFA ou dont la valeur est inférieure à 300 millions mais qui nécessitent une pré qualification, et (b) « Dossier-type d'appel d'offres (version communes dont le budget annuel initial est inférieur à 300 millions de francs CFA) » prévu pour des marchés dont la valeur est inférieure à 50 millions FCFA.

³⁸ « 1.07 MAIN-D'OEUVRE : L'Entrepreneur est soumis à la réglementation du travail et à la législation sociale applicables.

Il s'y conformera notamment dans les domaines suivants :

- horaires et conditions de travail (embauche et licenciement);
- salaires et charges sociales;
- règlements sanitaires, mesures de sécurité et hygiène;
- emploi de main-d'oeuvre étrangère.

La main-d'oeuvre nécessaire à l'exécution des travaux est recrutée par l'Entrepreneur sous sa responsabilité. Le Maître d'ouvrage ou l'Ingénieur ont le droit d'exiger de l'Entrepreneur le changement ou le renvoi du chantier des agents ou ouvriers de l'Entrepreneur pour insubordination, incapacité ou

- Dans le DTAO Gestion et entretien des routes par niveaux de service (GENIS - Marchés à obligation de résultats) (175 p.) qui est publié par AGEROUTE, « Réduire l'impact des travaux sur l'environnement » figure d'emblée dans la définition des prestations. Les clauses du CCAG relatives à l'obligation d'assurer la protection des personnes, des biens, et de l'environnement pendant l'exécution des travaux (art. 5.10) et « *prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger l'environnement tant sur le site qu'en dehors et pour éviter tous dégâts ou dommages aux personnes ou propriétés publiques ou autres qui résulteraient de la pollution, du bruit ou autres inconvénients résultant des méthodes mises en œuvre pour la réalisation des travaux* » (art. 5.103). S'y ajoutent une clause relative aux « sujétions spéciales » afin de réduire les nuisances et les pollutions liées à la réalisation des travaux³⁹ et une Section 6 « Cahier des Clauses environnementales » mais qui est vide. Rien de particulier n'est exigé dans les critères de qualification.
- En revanche, le DTAO Passation de marchés de travaux (pour les communes dont le budget annuel initial est inférieur à 300 millions de FCFA) (Mai 2017, 45 p.), qui régie les petits marchés de moins de 50 millions de F. CFA, prévoit l'obligation générale pour « *l'Entrepreneur de respecter la réglementation en vigueur en matière d'hygiène, de sécurité et de protection de l'environnement* » (Article 30)⁴⁰ tandis que l'Article 31 rappelle que « *l'Entrepreneur est soumis pour l'emploi de la main-d'œuvre à la législation du travail en vigueur et en particulier à la Convention Collective dans le secteur des BTP* ».
- **Seul le DTAO sur le Marché clé en main, c'est-à-dire celui qui fait peser l'essentiel de la responsabilité sur l'opérateur privé, (Mai 2017, 183 p.) détaille largement des obligations et mentionne la santé en plus des questions d'hygiène et sécurité.** Outre la réalisation des études environnementales et de faisabilité dont la méthodologie doit être présentée dans la proposition technique (Instruction aux candidats 17.1), et un PGES assorti d'un plan Hygiène et sécurité, suivant les clauses contractuelles du contrat de construction, l'entrepreneur devra « *assumer la responsabilité générale du respect des Lois concernant la santé et la sécurité des travaux de construction à l'emplacement de l'Ouvrage* ». En revanche, pour les travaux hors contrats, ce rôle reviendra pleinement au Maître d'ouvrage.
- Bien que récents, **aucune mention de préoccupation sociale, environnementale, ou même d'hygiène, santé et sécurité** ne figure dans le DTAO Passation d'accords-cadres pour des Marchés de Travaux (Janvier 2020, 122 p.).

§ 3 -2 L'exigence de capacités des opérateurs en matière environnementale reste sporadique dans les DTAO

La possibilité d'apprécier les capacités environnementales des candidats est très peu reprise dans les DTAO en vigueur. Déjà la rédaction de l'alinéa (h) de l'article 44 du CMP 2014 qui dresse la liste des attestations et justifications à fournir par les candidats, ne rend pas cette formalité obligatoire en évoquant : « *des renseignements sur le savoir-faire du candidat en matière de protection de l'environnement, le cas échéant* ». L'examen des différents DTAO va confirmer l'absence de prise en considération des capacités environnementales.

- Aucune exigence de capacité environnementale et/ou sociale dans le Dossier Standard de préqualification Passation des marchés de Travaux, de fournitures et de services (Mai 2017 – 76 p.)

défaut de probité. L'Entrepreneur demeure dans tous les cas responsable des fraudes ou malfaçons qui seraient commises par eux dans la fourniture et l'emploi des matériaux.

1.08 HYGIENE - SURVEILLANCE SANITAIRE : L'Entrepreneur devra prévoir sans paiement supplémentaire les soins immédiats sur le chantier et les moyens d'évacuation rapide de toute personne accidentée, à l'établissement de soins le plus proche du lieu des travaux. Il devra disposer sur le chantier d'une personne capable d'assurer les soins consécutifs à de petits accidents et des moyens en produits pharmaceutiques correspondants. - L'Entrepreneur signalera, sans délai, au Maître d'Ouvrage tous cas de maladie suspecte survenue sur ses chantiers. »

³⁹ 31.7. Sujétions spéciales pour les travaux exécutés à proximité de lieux habités, fréquentés ou protégés

Sans préjudice de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, lorsque les travaux sont exécutés à proximité de lieux habités ou fréquentés, ou méritant une protection au titre de la sauvegarde de l'environnement, l'Entrepreneur doit prendre à ses frais et risques les dispositions nécessaires pour réduire, dans toute la mesure du possible, les gênes imposées aux usagers et aux voisins, notamment celles qui peuvent être causées par les difficultés d'accès, le bruit des engins, les vibrations, les fumées, les poussières

⁴⁰ Art. 30 : Hygiène, Sécurité, et protection de l'environnement : L'Entrepreneur devra se conformer à la réglementation en matière d'hygiène, de sécurité, et de protection de l'environnement en vigueur. Il prendra en tous temps et à ses propres frais, toutes les précautions nécessaires pour la protection et la sécurité de toutes les personnes présentes sur le chantier et appliquera tous les règlements et instructions que le Maître d'Ouvrage ou son Maître d'Ouvrage pourra exiger en cette matière. L'Entrepreneur prendra à ses frais toutes les mesures d'ordre de sécurité nécessaires pour assurer la circulation routière. - Il est tenu d'exécuter les travaux objet du présent Marché en respectant les mesures de protection de l'environnement requises par la réglementation en vigueur ou prescrites dans les Prescriptions techniques ou les plans.

Concernant les 9 DTAO relatifs aux travaux : seuls deux comportent des critères d'attribution détaillés qui mentionnent des préoccupations environnementales et/ou sociales.

- **Dans le Dossier-type pour les DSP :** une DSP peut inclure la réalisation de travaux tels que la construction d'un ouvrage public. Ainsi dans le DT Passation d'un contrat de Délégation de Service Public (144 p) d'octobre 2016, seule la préoccupation environnementale apparaît dans l'Instruction aux Candidats en tant que critère d'évaluation des offres, et elle est également accompagnée de « *critères sociaux de promotion de l'emploi* » dans la Section 3 : Données particulières de l'appel d'offres (DPAO).

Aucun des 6 DTAO portant sur les marchés de fournitures n'impose d'exigences environnementales ou sociales :

- DTAO Passation d'accords-cadres pour des marchés de fournitures et services connexes (Janvier 2020, 101p) ;
- DTAO Passation des Marchés de Services Physiques, (Mai 2017, 109 p.) ;
- DTAO Passation des Marchés de Fournitures et/ou Services (pour les communes dont le budget annuel initial est inférieur à 300 millions de F CFA) (Mai 2017, 45 p.), qui régie les petits marchés de moins de 25 millions de F. CFA (Mai 2017, 19 p.) ;
- DTAO Passation des marchés de fournitures (Mai 2017, 111 p.) ;
- DT DRP Passation des Marchés de Fournitures, (Mai 2017, 12 p.).
- On mentionnera à part, le DTAO Acquisition de manuels scolaires selon l'approche par les compétences, (Mai 2017, 122 p.). Le contenu socio-culturel, la place des femmes et la protection de l'environnement sont examinés comme « critères d'évaluation de la conformité » du contenu des ouvrages à acquérir mais rien n'est mentionné à propos des caractéristiques matériels des ouvrages, notamment on ne relève aucune exigence particulière à propos de la qualité du papier ou des encres.

Quant au DTAO relatif à la Passation des Marchés de Services Physiques (Mai 2017, 109 p), il ignore totalement ces considérations.

Du côté des 4 Documents-type relatifs aux marchés de prestations intellectuelles : les mêmes constats s'imposent. Bâti sur le modèle des DTAO de la Banque Mondiale d'avant 2017, les préoccupations sociales et environnementales ne sont jamais mentionnées dans ces DTP, ni dans le Dossier standard de présélection, Passation des marchés de Prestations intellectuelles (Mai 2017, 11 p) qui comprend un modèle d'Appel public à manifestation d'intérêt et un modèle de Rapport d'analyse ou dans le Formulaire de préparation du Rapport d'évaluation des propositions (Mai 2017, 31 p) qui les accompagnent les documents-types.

Il existe 3 modèles de DTP suivant le montant des marchés, auxquels s'ajoute un DT pour les accords-cadres de marchés intellectuels.

- DTP Passation des Marchés de Prestations intellectuelles Consultants individuels (montant inférieur à 5 000 000 FCFA) (Mai 2017, 72 p.)
- DTP Marchés de moins de 35 millions FCFA
DTP Passation des Marchés de Prestations intellectuelles (Marchés de petits montants) (Mai 2017 – 74 p). *Toutefois, pour les marchés de prestations complexes de montant inférieur à 35 millions de FCFA ou aux conséquences potentielles importantes, notamment en termes de responsabilité, il conviendrait d'utiliser la DTP correspondant aux marchés importants.*
- DTP Passation des Marchés de Prestations intellectuelles (Marchés importants au-delà de 35 Millions FCFA) (Mai 2017- 156 p)
- Demande de propositions standard - Passation d'accords-cadres pour des Marchés de Prestations intellectuelles (Janvier 2020, 110 p.)

Les différents modes de sélection de consultants décrits dans le Code des Marchés publics (article 80 Alinéa g), à savoir la sélection sur la base de la qualité technique et du montant de la proposition (sélection qualité coût), la sélection dans le cadre d'un budget prédéterminé (sélection budget fixé), la sélection sur la base de la meilleure proposition financière (sélection moindre coût) et la sélection sur la base de la qualité technique de la proposition (sélection qualité seule), font appel à des critères qualité. A propos des considérations d'exécution, on signalera toutefois que, dans le DTP Passation

des Marchés de Prestations intellectuelles (Marchés importants au-delà de 35 Millions FCFA) (Mai 2017-156 p), ainsi que dans la Demande de propositions standard - Passation d'accords-cadres pour des Marchés de Prestations intellectuelles (Janvier 2020, 110 p.), si aucune obligation environnementale n'est incluse, quelques clauses portent sur les modalités de calcul des charges sociales et le détail des obligations sociales de l'opérateur vis-à-vis de ses employés à retenir lors de la négociation financière. Si ces éléments contribuent à la conformité du titulaire envers les cotisations sociales, ils restent loin de combler les attentes en termes d'impact positif des APD.

§ 3 - 3 Les critères d'attribution et l'évaluation de l'offre la moins-disante limitent l'essor des APD

A l'heure actuelle, la méthodologie retenue pour l'évaluation dans les DTAO relatifs aux marchés de travaux est très restrictive et oriente les AC vers la seule considération du prix, ce qui ne peut pas permettre de faire émerger des solutions responsables et durables :

- Le DTAO Passation des Marchés publics de grande taille (Mai 2017) enferme l'évaluation des offres dans les critères et méthodes exclusivement orientés sur le prix (Inst. aux candidats, art. 32) « 1.2 Pour évaluer une offre, l'Autorité contractante n'utilisera que les critères et méthodes définis dans la présente clause à l'exclusion de tous autres critères et méthodes. 1.3 Pour évaluer une offre, l'Autorité contractante prendra en compte les éléments ci-après : a) le prix de l'offre (...); b) c) d) les ajustements apportés au prix ». Sans que ce soit explicite, l'I.C. fait allusion à d'autres critères qui pourraient éventuellement être retenus « e) les ajustements résultant de l'utilisation des facteurs d'évaluation additionnels indiqués aux DPAO, le cas échéant ».
- Le DTAO Passation des Marchés publics de taille moyenne (Mai 2017) reprend la même approche ;
- Le DTAO Passation des Marchés de Travaux clé-en-main assortis d'un montage financier (Mai 2017)
- Le DTAO pour les communes dont le budget annuel initial est inférieur à 300 millions de F CFA détaille encore moins les éléments liés au prix et ne précise pas ce qu'est une offre « moins-disante ».

Face à l'absence d'explications relatives à l'appréciation des mérites des offres, au-delà du prix, seules les AC suffisamment aguerries peuvent avoir recours à des critères autres que ceux du prix. Cette approche est non seulement préjudiciable à l'évaluation des offres les mieux-disantes mais elle empêche de faire valoir des critères représentatifs des APD. **En revanche dans le Dossier-type Passation d'un contrat de DSP (Oct. 2016), place est faite à d'autres considérations pour évaluer « l'offre économiquement la plus avantageuse » :**

« 33.2 Pour évaluer une Offre, l'Autorité déléguée sélectionnera l'offre économiquement la plus avantageuse. Elle n'utilisera pour cela que les critères et méthodes définis dans la présente clause, à l'exclusion de tous autres critères et méthodes.

33.3 Pour évaluer une Offre, l'Autorité déléguée prendra en compte les éléments ci-après :
c)[préciser : spécifications et normes de performance prévues ou proposées, la qualité des services publics, les stipulations visant à assurer leur continuité, les tarifs imposés sur les usagers ou la redevance reversée, le montant de subvention sollicitée, le respect des normes environnementales, le coût, le montant et la rationalité du financement offert, toute autre recette que les équipements existants ou réalisés procureront à l'Autorité déléguée et la valeur de rétrocession des installations, etc.] »

Enfin, le DTAO Passation des marchés de fournitures (33.4 des I.C.) adopte une position intermédiaire en listant quelques critères qui peuvent être considérés mais aucun n'aborde les considérations sociales ou environnementales : « Pour évaluer le montant de l'offre, l'Autorité contractante peut devoir prendre également en considération des facteurs autres que le prix de l'offre indiqué en application de la clause 14 des IC, dont les caractéristiques, la performance des Fournitures et Services connexes et leurs conditions d'achat. Les facteurs retenus, le cas échéant, seront exprimés en termes monétaires de manière à faciliter la comparaison des offres. Les facteurs à utiliser et la méthode d'application seront comme indiqué à la clause 33.3 (d) des IC ».

Section 3 Les avancées du nouveau cadre juridique des PPP en faveur du développement durable et du « contenu local »

L'histoire des PPP au Sénégal a débuté avec la loi n° 2004-13 du 1er mars 2004 relative aux contrats de construction-exploitation-transfert d'infrastructures, dite loi CET, modifiée par les lois n° 2009-21 du 04 mai 2009 et n° 2011-11 du 28 avril 2011. Puis la loi n° 2014-09 du 20 février 2014 relative aux contrats de partenariat, modifiée par la loi n° 2015-03 du

12 février 2015, est venue abroger et remplacer la loi CET. **Le nouveau dispositif législatif du 2 mars 2021 répond à un souci de rationalisation des procédures et des institutions** : il vient unifier le régime des PPP puisqu'il couvre aussi bien les PPP à paiement public (contrats de partenariat) que les PPP à paiement privé (DSP, concessions, affermage et régies intéressées), il vient s'ancrer sur la panoplie institutionnelle existante pour les marchés publics, enfin il organise une prise en compte du développement durable et des entreprises locales. A cet égard, les auteurs de la loi du 2 mars 2021 ont adopté tantôt une approche globale du développement durable, avec un certain nombre d'articles de la loi qui ne précisent pas quel pilier est visé, tandis que d'autres dispositions définissent davantage les obligations envisagées, notamment pour la dimension locale (voir *supra*) ou environnementale. La loi du 2 mars 2021 relative aux PPP reconnaît, parmi les principes fondamentaux mis en exergue dans son article 4 « **h) le respect de la réglementation en matière environnementale, sociale et du travail ; et i) la responsabilité des opérateurs économiques de respecter les droits de l'homme** ». Par ces prescriptions, le législateur rappelle aux acteurs des PPP qu'ils doivent se conformer aux législations existantes en matière environnementale, sociale, du travail et plus largement du respect des droits de l'homme. En résumé, la loi du 2 mars 2021 jette les bases de PPP responsables, c'est-à-dire des PPP qui s'efforcent d'être conformes à la réglementation existante.

Le nouveau cadre juridique des PPP issu de la loi du 2 mars 2021 et de son décret d'application du 15 novembre 2021 insistent surtout sur la dimension locale qui vient englober les objectifs économiques, sociaux et territoriaux. Tout au plus peut-on déduire de quelques dispositions, par exemple celle relative à la sous-traitance locale, que ce dispositif législatif prend en considération la démarche durable dans sa généralité⁴¹.

§ 1 Les dispositions du cadre juridique PPP relatives à la dimension sociale des APD



Le nouveau cadre juridique des PPP issu de la loi du 2 mars 2021 et de son décret d'application du 15 novembre 2021 insistent sur la dimension locale mais cela ne concerne pas spécifiquement le volet social. La loi a prévu dans son article 44 que l'Autorité contractante a l'obligation de vérifier lors de l'exécution la réalité de « *l'emploi de la main d'œuvre nationale ou communautaire et l'utilisation des produits nationaux ou communautaires* ». En revanche, seul le critère géographique est retenu dans la loi, sans faire mention de la vulnérabilité spécifique de certains groupes, alors que des mesures ponctuelles ont été adoptées par des législations collatérales en faveur de ces groupes vulnérables, mesures qu'il conviendrait dès lors de veiller ultérieurement à incorporer dans le périmètre des PPP, grâce notamment au plan local qui doit être exigé.

Dans le décret d'application n° 2021-1443 du 15 novembre 2021 portant application de la loi n° 2021-23 du 02 mars 2021 relative aux contrats de partenariat public-privé, la dimension sociale apparaît en faveur des femmes et des jeunes sans que les personnes handicapées ne soient mentionnées.

Les femmes et les jeunes bénéficient également de préférences spécifiques pour la participation à la commande publique des entreprises qui les emploient.

Mesures APD – pilier social (emploi)		
Emplois locaux et communautaires	Loi PPP art. 44	<i>Outre les opérations de contrôle qui peuvent être mentionnées dans le contrat de partenariat public-privé, l'autorité contractante est tenue d'effectuer les opérations suivantes (...) d) le contrôle du respect par le titulaire des conditions contractuelles relatives à (...) l'emploi de la main d'œuvre nationale ou communautaire.</i>
Plan de contenu local	Décret PPP art 30 Plan de contenu local	<i>Le plan qui élaboré par le titulaire, mis à jour une fois par an, contient « au moins, les axes suivants : a) la promotion de l'emploi des femmes et de la formation professionnelle, notamment l'emploi des jeunes et des femmes ; »</i>
Marges de préférence	Décret PPP art. 29	<i>-2 % max pour tt candidat dont l'actionnariat est détenu à 50 % ou plus par des femmes ressortissantes d'un Etat de l'UEMOA ou dont 50 % de son personnel est composé de personnes âgées de moins de 35 ans ressortissantes de l'UEMOA.</i>

⁴¹ Par contraste, la loi de la Côte d'Ivoire sur les PPP de 2018 dans son article 9 prône : « (e) la promotion des PPP comme outil de développement d'un tissu d'entreprises ivoiriennes sur l'ensemble du territoire, notamment des petites et moyennes entreprises, de croissance et d'emploi, en particulier à travers l'insertion des jeunes et le renforcement des compétences et des capacités des acteurs locaux ; . (f) l'équilibre économique, financier et social des intérêts des parties aux contrats de PPP, tant dans le développement du projet que dans l'exécution du contrat au service de ses bénéficiaires ou usagers » : Décret n° 2018-358 du 29 mars 2018 déterminant les règles relatives aux contrats de partenariats public-privé, Chapitre III : principes constitutifs du cadre de gouvernance des PPP.

§ 2 Les dispositions du cadre juridique des PPP relatives à la dimension économique des APD



La loi PPP du 2 mars 2021 prévoit uniquement des dispositions en faveur des PME et des Artisans au stade de la sous-traitance. En effet, les PPP sont des contrats relativement complexes, de longue durée, à vocation globale avec des prestations fort différentes à assurer, et avec un financement privé initial, autant de caractéristiques qui les placent hors de portée des PME. La division par lots n'y a pas de sens et ce n'est finalement qu'à travers la sous-traitance que des mesures plus favorables aux PME et autres entités peuvent être envisagées. Ainsi l'AC a-t-elle la possibilité de prévoir « *parmi les critères d'attribution énoncés dans le dossier d'appel d'offres, (...) b) les initiatives pour l'intégration des artisans et des petites et moyennes entreprises locales (...)* ». En revanche, le décret réintroduit les marges de préférence lors de l'évaluation des offres qui permettent d'encourager le recours à la sous-traitance nationale ou communautaire.

En cas de sous-traitance, l'article 40 de la loi sur les PPP prévoit une priorité pour certaines entreprises nationales ou communautaires. A cet effet, l'article 28 du Décret d'application du 15 novembre 2021 précise que les opérations de sous-traitance sont prioritairement réservées à ces opérateurs, dans le DAO, « *sauf s'il est établi par le Titulaire que ces deniers ne disposent pas des compétences et qualifications requises pour la mise en oeuvre du projet* ». Mais ce dispositif ne s'applique pas, en cas de contrat de construction de marché clé en main ou de contrat exploitation-maintenance, s'il existe des liens de dépendance entre le Titulaire et le sous-traitant, des liens qui sont eux-mêmes définis par le décret : soit l'une des deux entreprises détient la majorité du capital de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision, soit elles appartiennent toutes deux à une tierce entité. A noter que seulement dans le cas de l'entente directe les contrats de sous-traitance avec lien de dépendance sont transmis à l'AC, qui peut s'y opposer dans les 15 jours avant leur signature.

En outre, l'article 44 de la loi charge l'autorité contractante « *d'effectuer (...) d) le contrôle du respect par le titulaire des conditions contractuelles relatives à la sous-traitance aux petites et moyennes entreprises nationales ou communautaires, (...)* ». Cette dernière disposition souligne aussi la dimension locale conférée à la participation des PME.

§ 3 Les dispositions du droit des PPP favorables à la dimension locale



- 1. La loi PPP du 2 mars 2021 affiche clairement la volonté de juridiciser le critère « local » dans le droit des PPP** puisqu'elle le reprend à différents stades d'élaboration et d'exécution du projet PPP, tandis que le décret d'application du 15 novembre 2021 mentionne 9 fois le terme « local ». La loi distingue ainsi l'Appel d'offres international (AOI) de l'Appel d'offres national (AON) pour lequel elle autorise la possibilité de contrats PPP réservés à des entreprises nationales ou communautaires, ensuite en incorporant des exigences locales dans la structure de la société de projet en charge du PPP, en incluant des conditions locales d'exécution du contrat, notamment en matière de sous-traitance ou d'utilisation de produits locaux, des exigences dont le respect pourra faire l'objet de contrôles spécifiques. Quant au décret d'application n° 2021-1443 du 15 novembre 2021 portant application de la loi n° 2021-23 du 02 mars 2021 relative aux contrats de partenariat public-privé, c'est un chapitre entier de 6 longs articles qu'il consacre à la « *promotion du secteur privé national et communautaire* ». En effet, derrière l'adjectif « local » qui pourrait apparaître discriminatoire, les textes font plutôt référence à la dimension nationale et sous-régionale (ou « communautaire ») à l'échelle de l'UEMOA.
- 2. A titre préliminaire, la loi PPP propose une distinction entre les AOI et AON où chacune de ces notions est dotée d'une définition qui permet de souligner leur dimension géographique.** Constitue un « *appel d'offres international (...) l'appel d'offres utilisant des moyens de publicité au niveau international et s'adressant aux personnes physiques et morales répondant aux critères d'éligibilité et de qualification définis dans le dossier d'appel d'offres* », tandis que l'AON correspond à l'« *appel d'offres utilisant des moyens de publicité au niveau national et s'adressant aux personnes physiques et morales répondant aux critères d'éligibilité et de qualification définis dans le dossier d'appel d'offres.* » Cependant, mise à part l'ampleur de la publicité, ces définitions renvoient aux DAO pour fixer leurs critères d'identification. La notion d'AON peut en revanche retrouver tout son sens lorsque l'AC décide de réserver la participation à des entreprises « locales » pour des « petits » PPP.
- 3. L'alinéa 1^{er} de l'article 25 prévoit, en application de l'art. 26 de la loi, la possibilité de réserver à les « petits PPP » d'une valeur hors taxes inférieure à 5 milliards de FCFA.** Cette rédaction offre ainsi aux AC une marge d'appréciation notable pour déterminer le niveau d'ouverture à la concurrence des contrats de PPP. En cas de

procédure réservée infructueuse, elle sera ensuite ouverte à tous les candidats sans distinction d'origine. Par ailleurs, un autre alinéa du même article 25 du décret énonce que les projets d'initiative privée couverts par l'article 35 du même décret sont également « concernés par les dispositions du présent article ». Et l'alinéa suivant ajoute que les projets réservés aux entreprises nationales ou communautaires peuvent aussi faire l'objet d'une procédure d'attribution qui déroge à l'appel d'offres ouverts (cf section IV du chap. 5 du décret).

4. **Le décret d'application du 15 novembre 2021 précise dans son article 24 les conditions d'identification des entreprises nationales et communautaires bénéficiaires**, ces deux dernières notions apparaissant en effet équivalentes pour éviter de créer une discrimination au seul profit des entreprises nationales. Ainsi « *les dispositions du présent décret bénéficient à tout opérateur économique ayant son siège social au Sénégal ou dans tout autre Etat membre de l'UEMOA depuis au moins 1 an à la date (du lancement de la procédure de passation), dont le personnel dirigeant et le personnel d'exécution est composé, au moins, à 50 % de personnes physiques ressortissantes d'un pays membre de l'UEMOA pour chacune des catégories susmentionnées du personnel* ». Ce faisant, le décret pose une double condition de nationalité : celle de l'entreprise à raison du lieu d'implantation de son siège social et celle de ses employés qui doivent (nouvelle double exigence) être au moins 50 % ressortissants d'un Etat de l'UEMOA, tant pour la catégorie du personnel de direction que pour celle du personnel d'exécution. Par la suite, son article 26 impose la création dans un délai de trois mois à compter de la signature du contrat de PPP d'une société de droit sénégalais dédiée

5. **La société de projet sénégalaise constituée pour gérer le PPP doit réserver 33 % de ses parts à l'actionnariat sénégalais ou communautaire**. Mais ce seuil est ajustable suivant les demandes de l'AC selon l'art. 26 du décret d'application PPP. En effet, l'article 34 de la loi du 2 mars 2021 a prévu que la société doit être constituée sous la forme d'une société de droit sénégalais avec une part de l'actionnariat de la société réservée aux opérateurs économiques nationaux selon les modalités fixées par décret, sauf dispositions spécifiques prévues par le Code général des Collectivités territoriales. Ainsi, d'après l'article 26 du décret d'application, une société de droit sénégalais dédiée doit être constituée dans les 3 mois dont au moins 33 % de l'actionnariat doit être détenu par des opérateurs sénégalais ou communautaires⁴² identifiés selon les double critères posés à l'article 24 (*supra*). L'AC peut également exiger à cette occasion d'inclure dans ce seuil, un actionnariat réservé à une catégorie spécifique de personnes morales de droit public ou de droit privé contrôlées directement ou indirectement par un ou des personnes publiques.
Cependant, au moment de la procédure d'attribution, ce seuil minimal peut être revu tant à la hausse qu'à la baisse sur demande de dérogation motivée de l'AC jointe à sa demande d'autorisation. Dans le cadre de son avis consultatif sur l'évaluation préalable conduite par l'AC, l'UNAPP doit formuler une recommandation quant à ce seuil au Comité interministériel à qui revient la décision finale. On notera que cette variabilité au cas par cas peut créer une situation d'incertitude pour les investisseurs potentiels même si le texte du décret précise que ce seuil minimal d'actionnariat local sera indiqué dans le DAO ou notifié à l'opérateur en cas d'entente directe et qu'il sera exigé pendant toute la durée de la Sté de projet.
Les rédacteurs du texte ont néanmoins pris en compte les difficultés et lenteurs potentielles qui pouvaient accompagner cette constitution d'un seuil minimal d'actionnariat national ou communautaire. Aussi l'article 27, intitulé « sélection des opérateurs économiques nationaux » (sic) organise-t-il un délai supplémentaire pour sa constitution, indiqué dans le DAO et éventuellement dans les clauses mêmes du contrat de partenariat. A défaut de réalisation de ce seuil minimal, le décret prévoit qu'« au plus tard à la fin de la 3^{ème} année suivant la date de réception des ouvrages ou de la date de début de la fourniture des services ou des produits » le titulaire doit ouvrir ces parts, qui étaient destinées à des entreprises nationales ou communautaires, à des fonds populaires ou les introduire en bourse. Leur évaluation doit être effectuée par un expert indépendant désigné par les parties ou à défaut par l'ARCOP, organe de régulation.

6. **L'article 29 du décret revoit l'application, sous forme de points de notation, de la marge de préférence lors de l'évaluation des offres**, et sous réserve de dispositions plus favorables qui seraient prévues dans des textes législatifs ou réglementaires. Ce dispositif tranche avec les marges qui étaient envisagés dans le cadre juridique précédent :

⁴² Toutefois, on notera que l'article 26 s'intitule « actionnariat réservé aux opérateurs économiques nationaux » alors que sa rédaction renvoie aux dispositions relatives aux entreprises nationales ET communautaires. La même ambiguïté prévaut à l'article 27 relatif à la « Sélection des opérateurs économiques nationaux ». Effet d'annonce ou erreur de plume, cette rédaction pourrait soulever des divergences d'interprétation.

- a) Une marge < 2% pour tout candidat qui s'engage à sous-traiter au moins 10 % du marché HT à des PME communautaires ;
 - b) Une marge de < 8 % pour tout candidat qui s'engage à sous-traiter au moins 30 % du marché HT des opérateurs nationaux ou communautaires (suivant la définition de l'article 24) ;
 - c) Une marge de < 2 % à tout candidat dont l'actionnariat est détenu par au moins 50 % de femmes ressortissantes d'un Etat UEMOA ou dont 50 % de son personnel est composé de jeunes de moins de 35 ans aussi ressortissants d'un Etat UEMOA ;
 - d) Une marge < 5 % à tout groupement candidat comprenant au moins une entreprise nationale ou communautaire dont la majorité du capital est détenue par une ou des personnes physiques ressortissantes d'un Etat UEMOA. Les opérateurs individuels dans les mêmes conditions bénéficient également de la même marge ;
 - e) Le cumul des marges ne peut excéder 10 %, sous réserve des dispositions de l'article 105 relatif à l'initiative privée ;
7. **En cas de sous-traitance, comme on l'a vu *supra*, l'article 40 de la loi sur les PPP prévoit également une priorité pour certaines entreprises nationales ou communautaires.** Et ce sera vérifié puisque le titulaire devra soumettre les contrats de sous-traitance à l'AC. Concernant les modalités, l'article 28 du Décret d'application précise que les opérations de sous-traitance sont prioritairement réservées à ces opérateurs, dans le DAO, « *sauf s'il est établi par le Titulaire que ces deniers ne disposent pas des compétences et qualifications requises pour la mise en oeuvre du projet* ». Mais ce dispositif ne s'applique pas, en cas de contrat de construction de marché clé en main ou de contrat exploitation-maintenance, s'il existe des liens de dépendance entre le Titulaire et le sous-traitant, des liens qui sont eux-mêmes définis par le décret : soit l'une des deux entreprises détient la majorité du capital de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision, soit elles appartiennent toutes deux à une tierce entité. A noter que seulement dans le cas de l'entente directe les contrats de sous-traitance avec lien de dépendance sont transmis à l'AC, qui peut s'y opposer dans les 15 jours avant leur signature.
8. **Le contenu local peut également apparaître sous la forme de conditions (locales) d'exécution.** D'après la loi PPP du 2 mars 2021, il s'agit non pas de favoriser directement l'origine locale de certaines entreprises candidates ou produits qu'elles peuvent fournir, mais d'évaluer les actions locales que les candidats se proposent de mener lors de l'exécution du contrat ou dans le cadre des marchés de sous-traitance. Suivant l'article 32 de la loi, « *En fonction de l'objet du projet et du contexte social, économique et environnemental, les Autorités contractantes peuvent prévoir, parmi les critères d'attribution énoncés dans le dossier d'appel d'offres, des exigences liées au contenu local du projet de partenariat public-privé envisagé, notamment : a) les initiatives relatives à l'emploi et à la formation professionnelle ; b) les initiatives pour l'intégration des artisans et des petites et moyennes entreprises locales ; c) les actions et propositions concrètes en matière de développement durable* ». Malgré les apparences, il ne s'agit pas d'un critère d'attribution fondé sur la nationalité. Certes, il se pourrait que ces exigences liées au contenu local avantagent les entreprises locales qui ont une meilleure connaissance du tissu social (pour le volet emploi) du tissu économique (pour la sous-traitance en faveur des PME et artisans locaux) voire « *des actions concrètes en matière de développement durable* » mais on voit surtout poindre derrière cette rédaction autour du contenu local, le but général de la croissance durable dans ses 3 volets : social, économique et environnemental.
9. **Concernant l'organisation des contrôles de l'exécution des contrats, la loi PPP du 2 mars 2021** précise les modalités et l'objet des contrôles qui peuvent être effectuée par l'AC en ce qui concerne, notamment, le respect des conditions locales d'exécution. Suivant l'Article 44 : « *Outre les opérations de contrôle qui peuvent être mentionnées dans le contrat de partenariat public-privé, l'autorité contractante est tenue d'effectuer les opérations suivantes (...)*d) le contrôle du respect par le titulaire des conditions contractuelles relatives à la sous-traitance aux petites et moyennes entreprises nationales ou communautaires, l'emploi de la main d'œuvre nationale ou communautaire et l'utilisation des produits nationaux ou communautaires ». Cette disposition mériterait d'être reprise dans le cadre des marchés publics puisque un régime préférentiel similaire en faveur des PME « locales » et communautaires (UEMOA) s'applique et qu'il est également possible d'exiger, *de facto*, dans les conditions d'exécution du marché le recours à une main d'œuvre locale (par le biais d'une clause sociale d'aide à l'insertion par exemple) et l'utilisation de produits locaux (qui peuvent être imposés au titre des spécifications techniques ou d'un critère exigeant un approvisionnement en circuit-court). La dimension locale trouve ainsi sa place au sein des paramètres APD.

- 10. Le Décret d'application de la loi PPP, dans son article 30, a ajouté l'obligation pour le Titulaire du contrat PPP d'établir un « plan de contenu local », soumis à l'AC et à l'UNAPPP et mis à jour une fois par an afin de décrire les activités portant sur des axes tels que : « la promotion de l'emploi et de la formation professionnelle, notamment l'emploi des jeunes et des femmes ; la promotion des PME et artisans locaux ; la promotion de l'utilisation des biens et services locaux ; le transfert de technologie et de compétences ; la promotion de la recherche-développement ; la promotion de la prestation de services intellectuels nationaux ou communautaires ».** Le suivi du plan local est en revanche déterminé par le contrat lui-même. Si la rédaction de ce dernier le permet, l'exécution du contrat pourrait ainsi contribuer au suivi des ODD dans le périmètre du PPP et mesurer ainsi son impact réel en faveur de la croissance durable.

La dimension « locale », ou plutôt géographique, a ainsi acquis une place reconnue au sein de la commande publique sénégalaise à travers le nouveau cadre juridique des PPP. Ce dernier complète désormais la technique du calcul de la marge de préférence par l'application d'exigences liées à la nationalité maniées à différent stade de l'opération contractuelle. Si cette approche devrait permettre une participation élargie des opérateurs locaux, elle témoigne aussi des liens profonds avec un développement durable inclusif qui prend en compte aussi bien les individus (groupes vulnérables), les entreprises (PME et structure sociales) et l'environnement.

Mesures APD	Source	Disposition
Procédures AON et AOI des PPP : critères d'éligibilité (et donc de nationalité) définis par les DAO	Loi PPP (2021)	Loi PPP. Définitions de l'AON et de l'AOI. Il n'y a des critères d'attribution au sein desquels figurent des éléments tirés de l'offre locale - les AC disposent d'un pouvoir d'appréciation
Contrats PPP réservés aux entreprises nationales ou communautaires Sous un certain seuil	Loi PPP (2021) article 26 (seuil de 5 milliards de FCFA HT fixé par l'art 25 du Décret)	<i>Loi PPP, Article 26.- Projets réservés aux entreprises nationales ou communautaires</i> <i>Les projets de contrat de partenariat public-privé dont la valeur globale estimée hors taxes est inférieure à un seuil défini peuvent être réservés aux entreprises nationales et communautaires. Les conditions et les modalités de mise en œuvre du présent article sont fixées par décret.</i>
Contenu local parmi les critères d'attribution	Loi PPP (2021) article 32,	« En fonction de l'objet du projet et du contexte social, économique et environnemental, les Autorités contractantes peuvent prévoir, parmi les critères d'attribution énoncés dans le dossier d'appel d'offres, des exigences liées au contenu local du projet de partenariat public-privé envisagé, notamment : a) les initiatives relatives à l'emploi et à la formation professionnelle ; b) les initiatives pour l'intégration des artisans et des petites et moyennes entreprises locales ; c) les actions et propositions concrètes en matière de développement durable ».
Constitution de la sté de projet avec une part de l'actionnariat réservée aux entreprises locales	Loi PPP (2021) Article 34.	« Constitution de la société de projet Le titulaire se constitue sous la forme d'une société de droit sénégalais dédiée au contrat de partenariat public-privé. <u>Une part de l'actionnariat de la société est réservée aux opérateurs économiques nationaux selon les modalités fixées par décret.</u> L'application des dispositions de l'alinéa 2 du présent article sont sans préjudice des dispositions spécifiques prévues par le Code général des Collectivités territoriales. »
		CMP
Marges de préférence	Art. 29 Décret PPP	Dans la limite de 10 % en cas de cumul de marges : -2% maximum pour tout candidat qui s'engage à sous-traiter au moins 10 % à des PME locales ou communautaires ; -8 % max pour tt candidat qui s'engage à sous-traiter au moins 30 % ; -2 % max pour tt candidat dont l'actionnariat est détenu à 50 % ou plus par des femmes ressortissantes d'un Etat de l'UEMOA ou dont 50 % de son personnel est composé de personnes âgées de moins de 35 ans ressortissantes de l'UEMOA. - 5 % max pour les groupement de candidats dont au moins une entreprise est possédée majoritairement par un ressortissant UEMOA.
Priorité aux entreprises nationales ou communautaires dans la sous-traitance	Loi PPP Article 40. +art 28 du Décret PPP	<i>Le titulaire peut, dans le cadre de l'exécution du contrat de partenariat public-privé, confier la réalisation de certaines de ses obligations à des tiers placés sous sa responsabilité. Dans ce cas, il est tenu de transmettre à l'autorité contractante une copie des contrats de sous-traitance. <u>Les opérations de sous-traitance sont prioritairement réservées à des entreprises nationales ou communautaires.</u> Les conditions et les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.</i>

Contrôle de la sous-traitance aux PME et MPME nationales ou communautaires	Loi PPP (2021) article 44 d)	<i>le contrôle du respect par le titulaire des conditions contractuelles relatives à la sous-traitance aux petites et moyennes entreprises nationales ou communautaires, l'emploi de la main d'œuvre nationale ou communautaire et l'utilisation des produits nationaux ou communautaires ;</i>

§ 4 Les dispositions existantes du cadre juridique des PPP relatives à la dimension environnementale des APD



Ni la loi sur les PPP du 2 mars 2021, ni son décret d'application du 15 novembre 2022 ne mentionnent la préoccupation environnementale dans les critères d'attribution ou dans les conditions d'exécution des contrats PPP. Ce vide juridique est d'autant plus évident que la loi a bien insisté sur le respect des obligations environnementales parmi les principes fondamentaux qui doivent régir les PPP. Si l'environnement figure dans les motifs à prendre en compte dans la conception du projet par la personne publique, il (ou sa préservation) ne constitue pas un critère énoncé par les textes pour déterminer l'attribution d'un contrat PPP. En l'état actuel du nouveau droit des PPP, la notion de développement durable paraît étrangement amputée de sa dimension environnementale, dimension qui figure pourtant dans ses éléments constitutifs. Si la volonté s'en fait sentir, elle pourra toutefois ressurgir dans les documents d'appels d'offres et les exigences propres aux projets développées par les AC.

Tableau récapitulatif : Dispositions existantes de la loi PPP relatives à la dimension environnementale des APD

Mesures APD – pilier environnemental	Sources	Dispositions
Principes fondamentaux	Loi PPP (2021) Art. 4	Les contrats de PPP, quel que soit le montant, sont soumis aux principes suivants (...) h) <i>le respect de la réglementation en matière environnementale, sociale et du travail ;</i> »
Phases du cycle de projet de partenariat public-privé	Décret PPP (2021) Article 31	Article 31.- « une phase de préparation et d'évaluation préalable du projet permettant à l'autorité contractante de faire ressortir les motifs à caractère économique, environnemental, financier, juridique et social dans un schéma de contrat de partenariat public-privé ; »
Evaluation préalable	Décret PPP (2021) – art. 36	c) <i>une évaluation des solutions envisagées et de leurs impacts économique, social ou environnemental ;</i>
Contenu du dossier dans une offre de co-développement	Décret PPP (2021) -art. 110	<i>à propos du contenu du dossier soumis par le porteur de l'offre de co-développement « une présentation des caractéristiques environnementales et sociales du projet, le cas échéant</i>

Conclusion : Ce chapitre a permis de dresser l'inventaire des règles propices aux APD qui figurent déjà dans le droit positif de la commande publique sénégalaise, ce dernier étant constitué du CMP de 2014, de ses textes d'application, de la nouvelle loi du 2 mars 2021 relative aux PPP avec son décret d'application du 15 novembre 2021, ainsi que des DTAO marchés et DSP. A partir du décret portant CMP de 2014 adossé à la loi portant Code des Obligations de l'Administration, mais surtout, plus récemment, de la loi sur les PPP du 2 mars 2021 émerge progressivement un droit fédérateur de la commande publique avec des institutions et un socle commun partagés par tous ces contrats publics qui permettent la satisfaction d'un besoin d'intérêt général. Les dernières réformes témoignent d'une inclinaison vers la prise en compte des piliers du développement durable, surtout articulés autour de la dimension locale, une tendance qui ne pourrait qu'être marginalement freinée par les Directives UEMOA dans leur rédaction actuelle.

CHAPITRE 2 UN « ECOSYSTEME JURIDIQUE » MOBILISABLE POUR LES APD MAIS SOUVENT IGNORE

L'analyse du contexte juridique dans lequel s'inscrivent les contrats de la commande publique permet d'appréhender plus largement « l'écosystème juridique » des APD au Sénégal à travers une exploration novatrice de leurs domaines juridiques complémentaires. Cet angle d'approche, qui dépasse l'analyse en « silo » du droit de la commande publique, permet de faire resurgir des politiques spécifiques qui n'ont pas eu les effets escomptés faute d'avoir été traduites dans les achats publics. Cette approche englobante permettra de capitaliser sur les initiatives sénégalaises récentes relatives à l'essor local et inclusif, autant d'initiatives qui peuvent bénéficier de la transversalité des APD pour un véritable impact positif du développement durable.

Section 1 Un « écosystème juridique » favorable aux APD

La pénétration du droit de la commande publique par des exigences juridiques complémentaires, provenant d'autres domaines du droit positif, est particulièrement notable à travers le prisme des APD puisque ceux-ci ont une dimension transversale. Si on va, *infra*, présenter plus en détail le droit de l'environnement en raison du pilier proprement environnemental des APD, il convient de rappeler qu'il existe également au Sénégal un Code de l'eau, un Code de l'hygiène, un Code de la Chasse et de la protection de la faune, un Code minier, un Code forestier, un Code de la pêche etc... Un travail préalable d'identification doit donc être effectué pour détecter les dispositions parallèles qui relèvent de champs communs au cadre juridique de la commande publique. Or, un premier constat s'impose : le décret de 2014 portant CMP ne cite dans ses visas aucun texte en-dehors du domaine strict des marchés publics. Cette présentation révèle l'approche « en silo », et elle a le profond inconvénient de concourir à isoler artificiellement les marchés publics des autres dispositions du droit sénégalais qui pourtant les concernent. Loin d'être une pure question de forme, ces mentions dans les « Visas » introductifs du texte permettent de rappeler à tous les acteurs, aussi bien privés que publics, que l'opération du contrat public s'inscrit dans un tissu juridique préexistant et obligatoire qu'il convient de toujours respecter.

Cette démarche permet également de recenser les dispositions législatives ou réglementaires éparées qui ont été adoptées au fil du temps, instaurant par exemple des préférences en faveur de catégories spécifiques (comme les Artisans) sans avoir été suivies d'effets, faute d'avoir été incorporées dans le droit positif de la commande publique.

Le cadre constitutionnel :

La Constitution du Sénégal du 22 janvier 2001 a été révisée en 2016. Elle mentionne clairement le développement durable (art. 25-3) et contient plusieurs dispositions intéressant les fondements constitutionnels des APD dont, en matière sociale et droits humains : l'alinéa 4 de l'article 7 qui proclame l'égalité entre les hommes et les femmes et plusieurs autres articles qui garantissent des droits aux femmes ; l'article 8 qui garantit à tous les citoyens les libertés individuelles fondamentales, les droits économiques et sociaux ainsi que les droits collectifs au titre desquels figure « le droit à un environnement sain ». l'article 25 qui garantit un socle de protection des travailleurs, notamment l'égalité salariale homme-femme et proclame « l'Etat veille aux conditions sanitaires et humaines dans les lieux de travail ».

Obligations internationales : Le 12 mars 2019, le Sénégal a ratifié son adhésion à la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF)- qui autorise la libre circulation des biens et des services sur le continent – et la Zone est devenue effective depuis le 1er janvier 2021 conformément aux engagements pris par les Etats signataires. Toutefois, ces dispositions intéressent *a priori* surtout le commerce international et donc l'entrée ou la sortie de biens et de services, et ne paraissent pas devoir s'appliquer directement aux activités publiques : « Sont exclus du champ d'application du présent Protocole, l'acquisition, par des organes gouvernementaux, de services achetés pour les besoins des pouvoirs publics et non pas pour être revendus dans le commerce »⁴³.

⁴³ Accord portant création de la zone de libre-échange continentale africaine, Article 2, Champ d'application, 4.

Une remarque s'impose cependant au sujet des normes, spécifications, labels, et autres certificats, issus des législations sectorielles et particulièrement nombreux dans le domaine des APD, soit pour attester des capacités des entreprises au stade de la qualification des candidatures soit pour établir des références dans les modalités d'exécution des contrats. L'Article 7 du CMP 2014 prévoit le recours obligatoire aux normes et spécifications nationales ou communautaires, voire, à défaut, internationales. Toutefois le texte accueille de nombreuses dérogations qui viennent fortement tempérer ce caractère obligatoire : a) Si leur utilisation est impossible en l'absence de critère ou de moyens techniques b) Si elles imposent l'utilisation de produits ou de matières incompatibles avec les installations déjà utilisées par l'Autorité contractante ou entraînent des coûts disproportionnés ou des difficultés techniques disproportionnées. En revanche, leur usage peut sembler- t-il être parfois encouragé dans un but innovant : « *Si le projet concerné constitue une véritable innovation pour laquelle le recours à des normes, à des agréments techniques ou à des spécifications techniques nationaux, communautaire ou, à défaut, internationaux existants serait approprié* ». Aussi doit-on comprendre des dérogations prévues à l'article 7 une certaine réticence du rédacteur à imposer le recours à ces normes et références alors que ce refus pourrait engager la responsabilité de l'AC. Ces normes et spécification peuvent en effet être écartées quand elles paraissent en décalage avec les moyens dont disposent les AC (et les entreprises) sénégalaises. Ainsi présentée, cette approche offre une grande souplesse aux AC pour lever le recours aux normes et certifications, une marge de manœuvre qui pourrait éventuellement poser des problèmes de responsabilité pour l'AC en cas d'accident. En effet l'AC doit prendre conscience que sa responsabilité pourra être engagée si, dans l'hypothèse d'un marché de travaux, un dommage était ensuite causé lors de l'exécution ou lors de l'utilisation de l'ouvrage du fait du non-respect des normes de construction (par exemple) par l'entreprise qui se serait basée sur des spécifications techniques rédigées par l'AC ignorant volontairement lesdites normes. La même solution pourrait trouver à s'appliquer dans le contexte d'un marché de fournitures pour lequel l'AC aurait ignoré, volontairement ou non, les exigences minimales de sécurité des produits acquis.

Les AC ne devraient pas disposer d'une telle marge de pouvoir discrétionnaire dans les domaines qui sont déjà techniquement régis par des normes sénégalaises ou communautaires obligatoires (par exemple en matière de normes de construction ou de maîtrise de l'énergie) et, pour les opérations dans lesquelles les normes pourraient éventuellement faire défaut ou être d'une application extrêmement compliquée et très coûteuse, les AC devraient être au moins tenues de justifier par écrit le fait d'écarter le recours aux normes et spécifications techniques. Quant à la formulation de ces exigences techniques, le CMP reprend la disposition traditionnelle dans les textes du commerce international de l'interdiction de la référence à une marque ou une provenance désignée sauf si de telles spécifications sont justifiées par l'objet du marché. L'article 7 permet cependant une telle indication « *accompagnée de la mention "ou équivalent"* » est autorisée lorsque les Autorités contractantes n'ont pas la possibilité de donner une description de l'objet du marché, au moyen de spécifications suffisamment précises et intelligibles pour tous les intéressés ».

Section 2 Un eco-système juridique qui complète le droit des APD

Il s'agit d'identifier les obligations, de nature législative ou réglementaire, qui concernent particulièrement les modalités de réalisation des APD bien qu'elles soient établies en-dehors du droit des marchés publics. Pour les aborder avec plus de clarté, le découpage des 3 piliers constitutifs doit être suivi : le pilier social, le pilier économique et enfin le pilier environnemental.

§ 1 Le cadre juridique en faveur des groupes vulnérables au Sénégal



Portée par de nombreuses législations protectrices, la dimension sociale des APD revêt un aspect polymorphe puisqu'elle peut aussi bien concerner les achats socialement responsables avec la mise en place et la vérification de l'effectivité d'un régime de protection des droits humains et sociaux pour tous les individus participants à l'exécution des marchés (par exemple avec des clauses qui reprennent le droit à l'égalité de traitement hommes-femmes ou rappellent l'interdiction du travail des enfants), que la mise en place de dispositifs de « discrimination positive » visant à favoriser l'accès de certains groupes vulnérables à la commande publique (Jeunes, victimes de handicaps, femmes par exemple). On peut ainsi résumer ces deux aspects en identifiant la dimension sociale dans la commande publique, à distinguer de la dimension sociale par la commande publique. A travers les lois en vigueur, ces deux pans du volet social sont généralement mêlés pour les principales catégories de groupes vulnérables qui vont être examinées ci-dessous : les Femmes, les personnes victimes de handicaps, et les Jeunes.

Le cadre international :

Bien que peu mentionnées en droit sénégalais, les 39 (dont 34 en vigueur actuellement) Conventions de l'Organisation International du Travail (O.I.T.) signées par le Sénégal ont un caractère obligatoire à l'égard de toute relation de travail et doivent par conséquent régir également les conditions de travail dans les contrats de la commande publique. Leur liste figure dans l'annexe 15. Le pays a en effet ratifié les 8 Conventions dites fondamentales (Convention sur le travail forcé ; Convention sur la liberté syndicale ; Convention sur le droit d'organisation et de négociation collective ; Convention sur l'égalité de rémunération ; Convention sur l'abolition du travail forcé ; Convention concernant la discrimination (emploi et profession), Convention sur l'âge minimum⁴⁴ ; Convention sur les pires formes de travail des enfants) mais également 3 sur 4 des Conventions dites de gouvernance (prioritaires) et 28 sur 178 Conventions techniques. Elles ont en principe été transposées dans le droit du travail sénégalais mais ce socle minimal de garanties des droits des travailleurs hommes et femmes doit être rappelé dans le cadre contractuel, notamment pour s'imposer clairement dans les contrats publics qui ont un caractère international en ayant été conclus avec une entreprise étrangère par exemple. A l'instar de ce que font aujourd'hui de nombreux pays dans le monde (*supra*), la référence à ces Conventions signées par le Sénégal devrait être rappelée dans les documents contractuels en étant mentionnée dans les DTAO ou au moins dans la Charte soumise à l'engagement des candidats.

Le cadre législatif existant comprend des dispositifs spécifiques qui intéressent chaque groupe dit vulnérable, dispositions qui vont être examinées ci-dessous.

§ 1-1 Les dispositions en faveur de la promotion et du respect des femmes

Suivant les données chiffrées de l'ANSD Rapportées par le Rapport Carapaces⁴⁵, les femmes exercent essentiellement dans l'économie informelle : « la quasi-totalité des emplois de l'économie sont des emplois informels. En effet, 96,4% des actifs occupés du marché du travail occupent un emploi informel.(...) Globalement, 45,3% des emplois informels sont occupés par des femmes ». La question du genre dans l'économie sénégalaise est un problème à multiples facettes dont le Gouvernement s'est emparé avec plusieurs programmes ciblés.

Des initiatives parallèles à la commande publique ont vu le jour sans pouvoir aboutir. Dès 2008, la loi d'orientation n°2008-29 du 28 juillet 2008 relative à la promotion et au développement des petites et moyennes entreprises, modifiée par la loi n°2012-32 du 31 décembre 2012, avait dans son article 33, prévu : « Des mesures spécifiques destinées à favoriser l'émergence de l'entrepreneuriat féminin sont initiées en accord avec la stratégie du Ministère chargé de l'Entrepreneuriat féminin. Conformément à l'article 17 de la présente loi, 15 % des parts de marchés publics réservés aux PME reconnues sont accordées aux entreprises appartenant aux femmes ». Malheureusement, cette disposition n'a pas été incorporée dans le droit de la commande publique, en particulier dans le CMP de 2014 et finalement est restée lettre morte. Bien que la nouvelle loi sur les PME du 7 janvier 2020 proclame dans ses objectifs (article 2) viser à « instaurer une impulsion durable à la création de PME par les hommes et les femmes et conforter leur ambition entrepreneuriales », et si elle encourage (art. 11) « la création et le développement d'entreprises par les femmes », elle ne prévoit pas de mesures spécifiques en faveur des entreprises dirigées par des femmes. Tout au plus, dans son article 12, charge-t-elle les « Organisations patronales, professionnelles et consulaires (OPC), de « la promotion de l'intégration des spécificités de genre dans les différentes initiatives de soutien aux PME ». Le Guide des APD 2020 a également relevé un certain nombre de difficultés concernant l'effectivité de ces dispositions puisqu'il n'existe pas de mécanisme permettant d'identifier les entreprises dirigées par des femmes, en particulier aucune statistique n'assure ce suivi.

§ 1-2 Les dispositions en faveur de l'emploi des Jeunes

Plusieurs initiatives gouvernementales ont été lancées, dans le cadre du PSE/Jeunesse pour faire face au plus de 100 000 jeunes qui arrivent chaque année sur le marché de l'emploi sans qualification⁴⁶. Après les récents événements qui ont secoué le Sénégal, le Président Macky Sall vient de décider (Conseils des ministres du 10 mars et du 3 avril 2021) de réorienter les priorités autour de la Jeunesse avec au moins 350 Milliards de F CFA qui seront mobilisés entre 2021-2023

⁴⁴ Age minimum spécifié pour le Sénégal : 15 ans. En conformité avec l'article 5, paragraphe 2, de la convention, le Gouvernement a déclaré que cet âge minimum ne s'applique pas aux travaux traditionnels champêtres ou ruraux non rémunérés effectués dans le cadre familial, par des enfants de moins de quinze ans et qui sont destinés à mieux les intégrer dans leur milieu social et dans leur environnement.

⁴⁵ Rapport Carapaces de février 2021, p. 58

⁴⁶ Chiffres indiqués par le Ministre Papa Amadou Ndiaye, Le Soleil 11 mars 2021, p. 9.

pour le financement des Jeunes et des Femmes. Un Conseil National pour l'insertion et l'Emploi des Jeunes est prévu le 10 avril 2021 afin de territorialiser la politique de l'emploi. Ces préoccupations entrent en résonnance avec les 3 piliers des APD, en soulignant la dimension sociale, économique, mais également écologique des grands projets publics lancés en faveur de la jeunesse.

Cadre juridique dédié aux Jeunes :

Sur le plan de la législation, la promotion de l'emploi des jeunes devrait être régie par le code du travail. Dans la pratique, la promotion de l'emploi des jeunes est essentiellement réalisée à l'aide d'instruments en marge du Code du travail comme la Convention Nationale Etat-Employeurs privés pour la Promotion de l'Emploi des Jeunes (CNEE).

L'article 28 de la loi d'orientation de la formation Professionnelle et technique de 2015⁴⁷ prévoit notamment une grille de niveaux de qualification qui peut servir utilement de référence pour déterminer les emplois non qualifiés des Jeunes ou des femmes ouvrant droit à des mécanismes préférentiels (voir *infra* les propositions de ce rapport sur les marchés réservés à l'Economie sociale et solidaire).

Le dispositif HIMO : L'approche transversale HIMO (marchés à haute intensité de main d'œuvre) peut être déployée rapidement pour réaliser des travaux simples (aménagements urbains, construction de pistes, de réservoirs et bassins pour l'hivernage, création de fosses à déchets, reforestation, etc...) ou des services simples à fort besoin de main d'œuvre (collecte et tris des déchets dans les communes). **Ces actions qui combinent travaux publics et emplois des populations éloignées de l'emploi, surtout des jeunes, doivent être menées par les structures en place, qui existent soit sous forme de programmes soit sous forme d'agences, tous soumis aux règles du Code des marchés publics :**

- Le Programme de Modernisation des villes (PROMOVILLES) qui prévoit la réalisation, dans différentes villes du Sénégal, de plus de 300 Km de voiries incluant leurs dépendances (assainissement, éclairage public et aménagement paysager) pour un coût global de 280 milliards. ⁴⁸
- L'ASRGMV : L'agence pour la reforestation a de fortes potentialités d'emplois des Jeunes et des Femmes à travers le projet de la Grande Muraille verte qui a été retenu cette année... et à travers le programme des écovillages
- L'APIX
- L'AGERROUTE a utilisé des marchés (HIMO) (Paragraphe 294 – Axe 1 du PSE)

Il est également possible de mettre en place des dispositifs de formation professionnelle dans le cadre de l'exécution de marchés publics en impliquant les structures orientées vers la formation et l'emploi des jeunes. Les projets sont nombreux mais on peut citer :

- La DER
- 3FPT : Fonds de Financement de la Formation Professionnelle et Technique⁴⁹ :

Mission : Accompagner les entreprises et les organisations professionnelles dans l'identification et la formulation de leurs projets de formation	Contribuer au financement des projets et des actions de formation;
Superviser les activités de formation;	Promouvoir la demande des entreprises et des organisations professionnelles.
Bénéficiaire :	Entreprise;
Organisation professionnelle	Toute entreprise légalement constituée
CONTREPARTIE	Entreprise : 20% du coût de la formation ;
Organisation professionnelle : 10% du coût de la formation.	

- ONFP Office National de formation professionnelle⁵⁰

⁴⁷ <http://www.mfpaa.gouv.sn/wp-content/uploads/2015/08/loi-d-orientation.pdf>

⁴⁸ <http://www.equite.gouv.sn/programme/programme-de-modernisation-des-villes-promovilles>

⁴⁹ <https://3fpt.sn/> et financer.entreprise@3fpt.sn

⁵⁰ onfpsenegal@yahoo.fr Site web www.onfp.sn

- ANEJ Agence nationale pour l'emploi des Jeunes
- ANPEJ Agence Nationale pour la Promotion de l'Emploi des Jeunes
- PDCEJ Projet d'Appui au développement des compétences et de l'entrepreneuriat des jeunes : cofinancé par l'Etat du Sénégal et la BAD sur 5 ans (2019-2023) il forme des jeunes aux métiers du pétrole, de l'agro-alimentaire, du cuir, et du solaire dans des centres de formation qu'il a construits. Il complète le volet formation par un accompagnement à l'incubation d'entreprise avec un partenariat signé avec l'ADEPME.

Il faut également signaler les efforts menés en faveur de la création « d'emplois verts » qui participent à la fois du pilier social et du pilier environnemental des APD. Suivant la Stratégie nationale (SNPEV) qui a été adoptée en 2015⁵¹, la tutelle technique et administrative de l'implémentation de la stratégie devait être assurée par le ministère de l'Environnement et du Développement durable, avec la constitution d'une cellule technique pour assurer la mise en œuvre opérationnelle. La Stratégie préparée est un outil très documenté et intéressant pour recenser les possibilités de création d'emplois verts, malheureusement le potentiel des marchés publics et plus largement des contrats de la commande publique n'y a pas été exploré. Dans le contexte de mobilisation actuelle en faveur de l'emploi des Jeunes, l'accent est aujourd'hui mis sur les actions de l'Agence Sénégalaise de la Reforestation et de la Grande Muraille Verte (ASRGMV) qui peut développer des partenariats avec les collectivités territoriales afin de fournir des emplois aux Jeunes, notamment des emplois verts en lien avec la Direction des Eaux et Forêts.

§ 1-3 La promotion et le respect des droits des personnes en situation de handicap

Concernant l'accès à l'emploi, suivant les données traitées par l'ANSD en 2013, seuls 6,8 % des personnes atteintes de handicaps en âge de travailler étaient effectivement en situation d'emplois⁵², auxquels on peut ajouter 12,2 % qui étaient au chômage après avoir travaillé. Le tableau ci-dessous précise la distribution des occupations professionnelles de ces personnes. Les personnes avec handicaps ne constituent ainsi que 5,8 % des Employeurs et patrons.

Tableau : Prévalence du handicap (%) par sexe selon la situation dans l'occupation en 2013

Situation dans l'occupation	Masculin	Féminin	Ensemble
Travailleur indépendant	6,9	9,5	7,6
Employeur/Patron	5,7	6,5	5,8
Salarié/Employé permanent	7,0	6,5	6,9
Salarié/Employé temporaire	5,4	5,8	5,5
Apprenti	2,5	3,3	2,7
Aide familiale	4,8	7,3	5,7
Autres	8,3	9,3	8,7

Source : ANSD. RGPHAE 2013

Le Sénégal n'est pas partie à la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées entrée en vigueur le 3 mai 2008⁵³ mais il a adopté la **Loi d'orientation sociale n° 2010-15 du 6 juillet 2010 qui porte sur la**

⁵¹ Ministère de l' Environnement, Stratégie nationale pour la promotion des emplois verts au Sénégal, 2015, https://www.un-page.org/files/public/rapport_snpev_version_final.pdf

⁵² Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) Recensement Général de la Population et de l'Habitat, de l'Agriculture et de l'Elevage (RGPHAE 2013) , Chapitre V : « En 2013, cette prévalence du handicap est de 5,9%, ce qui signifie que 59 Sénégalais sur 1000 souffrent d'un handicap quelconque. Les individus de sexe féminin sont les plus concernés avec un rapport de masculinité de 88 hommes pour 100 femmes. Par ailleurs, la forme de handicap la plus répandue concerne les difficultés à marcher et à voir (1,5% de la population chacune) à l'opposé des limitations auditives, des difficultés à se concentrer et des difficultés à prendre soin de soi (respectivement 0,6%, 0,8% et 0,5%). Au niveau régional, les régions de Ziguinchor et Matam enregistrent les taux de prévalence les plus élevés avec 8,1% de handicapés chacune, alors que celles de Diourbel et Kaolack enregistrent les taux de prévalence les plus faibles avec 5% de personnes vivant avec un handicap ».

Personnes en situation de handicap (2014), p. 15. <http://www.ansd.sn/ressources/publications/rgphae-chapitre-handicap.pdf>

⁵³ <http://convoitprot-f.pdfs://www.un.org/disabilities/documents/convent> Cette Convention proclame plusieurs principes qui trouvent à s'appliquer dans le droit de la commande publique, certains parce qu'ils sont relatifs à l'activité économique des personnes handicapées : « La participation et l'intégration pleines et effectives à la société ; Le respect de la différence et l'acceptation des personnes handicapées comme faisant partie de la diversité humaine et de l'humanité ». Ou parce que, telle « l'égalité des chances », ils doivent assurer une égalité de traitement qu'il faudra retrouver dans la vérification des conditions d'exécution du contrat par les employés et personnels des entreprises titulaires et leurs sous-traitantes. En matière de travail et emploi, l'article 27 de la Convention dispose en effet que les Etats doivent : « Protéger le droit des personnes handicapées à bénéficier, sur la base de l'égalité avec les autres, de conditions de travail justes et favorables, y compris l'égalité des chances et l'égalité de rémunération à travail égal, la sécurité et l'hygiène sur les lieux de travail, la protection contre le harcèlement et des procédures de règlement des griefs. La Convention des Nations Unies mentionne enfin un principe qui intéresse particulièrement les spécifications techniques de certains contrats, le principe de « l'accessibilité ». En effet, des spécifications techniques contractuelles doivent prendre en compte la question de l'accessibilité pour les personnes souffrant de divers handicaps

promotion et la protection des droits des personnes handicapées⁵⁴. Son Article 2 « vise à garantir l'égalité des chances des personnes handicapées ainsi que la promotion et la protection de leurs droits contre toutes formes de discrimination » et il admet le principe de la discrimination positive : « Ne sont pas considérées comme discriminatoires, les mesures incitatives spéciales en faveur des personnes handicapées qui visent à garantir l'égalité effective de chance et de traitement ».

La loi de 2008 proclame plusieurs principes qui trouvent à s'appliquer dans le droit de la commande publique, certains parce qu'ils proclament l'accès à l'emploi (art. 15) garanti par l'Etat, d'autres parce qu'ils sont relatifs à l'activité économique des personnes victimes de handicap : ainsi l'Etat sénégalais doit-il apporter son appui à la création d'entreprises individuelles, de coopératives de production ou de PME par les personnes handicapées, notamment par des exonérations fiscales partielles ou totales, temporaires ou permanentes (art. 30). Mais les mesures d'application n'ont pas suivi l'impulsion législative de 2008. Il faudra voir si les dispositions plus récentes de loi sur les PME du 7 janvier 2020 qui encouragent (art. 11) « la création et le développement d'entreprises par les femmes, les jeunes et les personnes en situation de handicap », seront mises en vigueur prochainement.

La loi de 2008 sur le handicap développe enfin le principe de « l'accessibilité » qui intéresse particulièrement la conception des projets d'aménagement et les spécifications techniques des contrats de travaux. En effet, des spécifications techniques contractuelles doivent prendre en compte la question de l'accessibilité pour les personnes souffrant de divers handicaps (par ex. handicap visuel pour des fournitures ou handicap moteur pour l'accès aux bâtiments recevant du public). Ces exigences de spécifications techniques adaptées doivent en principe être définies par des normes particulières et/ou par le droit de la construction. A cet effet, l'article Article 31 dispose que « L'Etat, les Collectivités locales et les Organismes publics et privés ouverts au public, adaptent, chacun dans son domaine, et selon les critères internationaux d'accessibilité, les édifices, les routes, les trottoirs, les espaces extérieurs, les moyens de transports et de communication, de manière à permettre aux personnes handicapées d'y accéder, de s'y déplacer, d'utiliser leurs services et de bénéficier de leurs prestations ». Tandis que l'article 32 énonce l'interdiction de délivrer une autorisation de construire, rénover ou réhabiliter un édifice recevant du public (...) si les plans ne respectent pas ces normes. Les installations sportives, culturelles et artistiques doivent également leur être accessibles (art. 39 et 41). L'article 34 proclame par ailleurs le droit à l'accès aux transports publics, aux moyens de transports adaptés et à un service de conduite adapté. L'accessibilité aux véhicules de transports collectifs doit être assurée, qu'il s'agisse de transports, routiers, ferroviaires, maritimes ou aériens, avec des places qui leur sont réservées. Ces questions devraient être abordées lors de la révision des Codes de l'urbanisme et de la construction qui vient d'être lancée au printemps 2021 mais il faudra ensuite en assurer le respect durant l'exécution des travaux publics.

Sur le plan institutionnel, l'article 48 de la loi de 2008 a prévu la création à la Présidence de la République, d'une Haute Autorité chargée de la Promotion et de la Protection des Droits des personnes handicapées, ayant pour objectif d'appuyer les efforts de l'Etat dans l'élaboration des politiques nationales et les stratégies sectorielles dans tous les domaines touchant le handicap. Si elle est fonctionnelle, elle mériterait d'être consultée dans le cadre de la préparation des textes relatifs à la commande publique.

§ 1-4 La promotion des acteurs de l'économie sociale et solidaire

Le Sénégal s'est orienté vers la reconnaissance du secteur de l'économie sociale et solidaire (ESS), avec la Loi d'orientation n° 2021-28 du 15 juin 2021 relative à l'économie sociale et solidaire. L'ESS correspond aux « activités économiques menées avec une approche centrée sur la personne visant une finalité sociale ou environnementale et réalisées par des coopératives ou mutuelles, des associations entreprenantes, des entreprises sociales ou par des acteurs de l'économie populaire ». La loi précise dans son article 3 qu'elle s'applique « aux catégories : « les sociétés coopératives ou mutualisées ; les associations entreprenantes et responsables ; les entreprises sociales et les acteurs de l'économie populaire ». A cet effet, la loi définit l'entreprise sociale : « entreprise dont l'objet principal est d'avoir une incidence sociale plutôt que de générer du profit pour ses propriétaires ou ses partenaires ; elle opère sur le marché en fournissant des biens et/ou des services de façon entrepreneuriale et utilise ses excédents (gains) principalement à des fins sociales ; elle est

(par ex handicap visuel pour des fournitures ou handicap moteur pour l'accès aux bâtiments recevant du public). Ces exigences de spécifications techniques adaptées doivent en principe être définies par des normes spécifiques pour les fournitures ou par le droit de la construction.

⁵⁴ <http://www.handicap.sn/loi-dorientation-sociale-au-senegal/>

soumise à une gestion responsable et transparente, notamment en associant ses employés, ses clients et les parties prenantes concernées par ses activités économiques ».

Jusque-là, l'absence de reconnaissance d'une notion juridique de l'entreprise sociale⁵⁵ pèsait sur les conditions d'accès à la commande publique d'un certain nombre de structures sénégalaises qui devaient naviguer entre le statut d'association et le statut de la Société par actions simplifiée⁵⁶ (S.A.S) sans avoir trouvé un régime qui prenne en compte leur particularisme, notamment fiscal. La reconnaissance de l'entreprise sociale permet d'offrir un statut de transition intéressant pour la formalisation d'activités économiques qui relèvent du secteur informel. Il en va de même de « l'Association entreprenante et responsable : association constituée conformément aux dispositions du Code des Obligations civiles et commerciales et qui entreprend une activité économique d'innovation sociale et d'intérêt général ». Du côté de la commande publique, le CMP pourrait ainsi prévoir des modalités plus adaptées à l'accès de ces acteurs à la faveur de projets particuliers (marchés réservés ou marge de préférence dans la sous-traitance). Sous réserve de l'obtention de l'agrément « E.S.S. » qui est prévu par l'article 17 de la loi sur l'ESS.

De son côté, la loi du 7 janvier 2020 sur les PME, fait aussi référence à l'économie sociale et solidaire puisque son article 11 affirme que l'Etat va encourager la création et la croissance « d'entreprises dans des secteurs prioritaires, tel que l'économie rurale, l'économie numérique, l'économie sociale et solidaire, l'habitat social, l'économie du sport et l'économie verte ». Mais il reste à finaliser ces annonces par des textes d'application. Afin d'éviter les chevauchements éventuels, la loi sur l'ESS prévoit, en son article 44, que les avantages qu'elle prévoit ne sont pas cumulables avec ceux accordés aux PME par la loi d'orientation sur le développement des PME.

§ 2 Pilier économique des APD et cadre juridique en faveur des PME au Sénégal



Les programmes en faveur des PME se sont multipliés ces dernières années, en application du PSE qui place l'initiative privée au centre de la croissance durable et inclusive. Sur le plan législatif cela s'est traduit récemment par l'adoption de la loi d'orientation n° 2020-02 du 7 janvier 2020, relative aux Petites et Moyennes entreprises⁵⁷ ainsi que la loi sur les Startups du 6 janvier 2020, publiée le même jour. Cette dernière a prévu en son article 13 un régime préférentiel d'accès à la commande publique en faveur des startup labellisées. Elles pourront ainsi bénéficier d'une marge de 5 % en cas de participation à toute procédure de passation de contrats de la commande publique : marchés publics, DSP ou contrats de partenariat. Cumulable avec d'autres préférences, cette marge peut ainsi atteindre 25 %.

La loi du 7 janvier 2020 pose des exigences en termes de capacité juridique des PME qui doivent être reflétées dans les procédures d'évaluation des candidatures aux contrats de la commande publique. En définissant des critères d'identification des différentes catégories de PME, en clarifiant la question de la nationalité des PME, en organisant la procédure d'agrément à partir de laquelle la PME peut bénéficier de mesures qui leur sont réservées, la loi de 2020 a de nombreux impacts sur les conditions de participation examinées lors de la phase d'évaluation des candidatures. Sur le plan de la cohérence législative, la loi sur les PME se positionne expressément par rapport au droit de la commande publique auquel elle fait référence : « il faut préciser que les incitations fiscales, les dispositions d'ordre social, celles relatives à l'accès à la commande publique, restent respectivement régies par les dispositions pertinentes du CGI, du Code du Travail et du Code des Marchés publics. »

⁵⁵ En France, la Loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire s'applique (article 2) aux entreprises dont l'objet social satisfait à titre principal à l'une au moins des quatre conditions suivantes :

1° Elles ont pour objectif d'apporter, à travers leur activité, un soutien à des personnes en situation de fragilité soit du fait de leur situation économique ou sociale, soit du fait de leur situation personnelle et particulièrement de leurs besoins en matière d'accompagnement social, médico-social ou sanitaire, ou de contribuer à la lutte contre leur exclusion. Ces personnes peuvent être des salariés, des usagers, des clients, des membres ou des bénéficiaires de cette entreprise ;

2° Elles ont pour objectif de contribuer à la préservation et au développement du lien social ou au maintien et au renforcement de la cohésion territoriale ;

3° Elles ont pour objectif de contribuer à l'éducation à la citoyenneté, notamment par l'éducation populaire et par la mise en œuvre de modes de participation impliquant, sur les territoires concernés, les bénéficiaires de ces activités. Elles participent ainsi à la réduction des inégalités sociales et culturelles, notamment entre les femmes et les hommes ;

4° Elles ont pour objectif de concourir au développement durable, à la transition énergétique, à la promotion culturelle ou à la solidarité internationale, dès lors que leur activité contribue également à produire un impact soit par le soutien à des publics vulnérables, soit par le maintien ou la création de solidarités territoriales, soit par la participation à l'éducation à la citoyenneté. »

⁵⁶ <https://www.economie.gouv.fr/entreprises/societe-actions-simplifiee-SAS>

⁵⁷ Publiée au JO du 20 janvier 2020, p. 78.

§ 2-1 La définition des PME

Si le Sénégal a multiplié ces dernières années les programmes en direction des PME, l'effectivité de ceux-ci s'est longtemps heurtée à l'absence d'une définition incontestée des PME et plus largement des différentes catégories d'entreprises. Il convient donc d'aborder tout d'abord la question de la définition avant de rechercher les dispositions qui, au fil des législations, ont pu prévoir des mesures en faveur de ces entreprises qui doivent être consolidées dans le droit de la commande publique.

La définition des PME proposée par la Charte des PME de 2003 n'était pas effectivement utilisée⁵⁸, jusqu'à la loi d'orientation n°2008-29 du 28 juillet 2008 relative à la promotion et au développement des petites et moyennes entreprises, modifiée par la loi n°2012-32 du 31 décembre 2012, qui a distingué, au sein des PME, plusieurs sous-catégories sur la base des chiffres d'affaires et des effectifs : les micro-entreprises et les TPE sur la base d'un critère d'effectifs (moins de 21 employés et CA inférieur à 50 millions FCFA), les Petites Entreprises (PE : CA entre 50 et 500 Millions FCFA) et les Moyennes Entreprises (entre 21 et 250 employés et CA entre 500 Millions et 5 Milliards FCFA). La même loi prévoyait dans son chapitre 4 intitulé « *De l'accès aux marchés publics, au foncier et à la promotion de la sous-traitance* » des dispositions générales en faveur des PME dont des marchés réservés et des accords de partenariat en vue de favoriser le transfert de technologie. Faute de mesures réglementaires d'application, ces dispositions n'ont pu remplir le rôle attendu. D'après le recensement de 2016, les entreprises du secteur informel continuaient à constituer 97 % des unités recensées, essentiellement des entreprises individuelles (plus de 80 %), et seulement 1,2% des Petites entreprises et 0,4 % des M.E.

Abrogeant la loi de 2008, la loi d'orientation n° 2020-02 du 7 janvier 2020 relative aux PME, a redéfini la PME et ses sous-catégories. Tout d'abord, son article 3 définit la PME à partir de son chiffre d'affaires : « *toute personne physique ou morale autonome, commerçante ou productrice de biens et/ou services marchands, et dont le chiffre d'affaires hors taxes annuel n'excède pas deux milliards (2.000.000.000) de FCFA* ». Contrairement à d'autres systèmes juridiques, le Sénégal a fait le choix d'écarter le critère tiré des effectifs, encore très utilisé en Europe, mais qui fait l'objet d'une mise en œuvre plus nuancée (avec des effectifs et des CA variables suivant les secteurs) aux Etats-Unis par exemple. Seul le critère du C.A. est retenu, au détriment du nombre d'employés, pour distinguer les sous-catégories au sein des PME :

- « *L'Entrepreneur : un entrepreneur individuel, personne physique qui, sur simple déclaration prévue dans l'Acte uniforme révisé sur le droit commercial de l'OHADA, exerce une activité professionnelle civile, commerciale, artisanale ou agricole ;*
- *La Très Petite Entreprise (TPE) : toute personne, hors entrepreneur, physique ou morale, exerçant une activité professionnelle, civile, commerciale, artisanale, agricole, industrielle ou de prestataire de services, dont le chiffre d'affaires annuel déclaré hors taxes est inférieur ou égal à 100.000.000 FCFA ;*
- *La Petite Entreprise (PE) : toute personne physique ou morale, exerçant une activité professionnelle, civile, commerciale, artisanale, agricole, industrielle ou de prestataire de services, dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes est supérieur à 100.000.000 FCFA et inférieur ou égal à 500.000.000 FCFA ;*
- *La Moyenne Entreprise (ME) : toute personne physique ou morale, exerçant une activité professionnelle, civile, commerciale, artisanale, agricole, industrielle ou de prestataire de services, dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes est supérieur à 500.000.000 FCFA et inférieur ou égal à 2.000.000.000 FCFA ;*

Faute de dispositions équivalentes pour les « grandes » entreprises, il faut comprendre que, par défaut, il s'agit de toutes les entreprises dont le chiffre d'affaires dépassent le seuil de 2.000.000.000 FCFA sauf à appliquer les dispositions de la Charte de 2003⁵⁹. Il en va de même pour l'application par défaut du critère de la nationalité.

Le même article 3 de la loi du 7 janvier 2020 précise les distinctions de candidature à opérer en fonction de la nationalité de la PME, permettant ainsi de clarifier heureusement les dispositions du CMP sur les marges de préférences (voir les analyses sur le « contenu local » *supra*). 3 catégories de PME sont mentionnées :

⁵⁸ art. 2, <http://www.servicepublic.gouv.sn/assets/textes/D-charte-pme.pdf>

⁵⁹ Article 5 : Les Grandes Entreprises (GE) Les grandes entreprises (GE) répondent aux critères et seuils suivants : - Effectif supérieur à deux cent cinquante (250) employés ; - Tenue d'une comptabilité selon le système normal en vigueur au Sénégal et certifiée par un membre inscrit à l'Ordre National des Experts Comptables et Comptables Agréés – ONECCA ; - Chiffre d'affaires hors taxes annuel supérieur à 15 milliards de francs CFA - Investissement net supérieur à 1 milliard de FCFA.

- *La PME de droit communautaire : toute entreprise individuelle, ou une société, immatriculée dans un des pays membres de la CEDEAO et de l'UEMOA dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes est inférieur ou égal à 2.000.000.000 FCFA ;*
- *La PME de droit sénégalais : toute entreprise individuelle ou une société, immatriculée au Sénégal dont le capital est détenu par une ou des personnes physiques ou morales commerciale, artisanale, agricole, industrielle ou de prestataire de services, dont le chiffre quelle que soit leur nationalité et dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes est inférieur ou égal à 2.000.000.000 FCFA ;*
- *La PME nationale : toute entreprise individuelle ou une société de droit sénégalais dont le capital est détenu à 51%, au moins, par une ou des personnes physiques de nationalité sénégalaise ou par une ou des personnes morales de droit sénégalais et dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes est inférieur ou égal à 2.000.000.000 FCFA ».*

La PME doit être légalement déclarée et tenir une comptabilité régulière. « La PME doit être légalement déclarée et tenir une comptabilité régulière, qui s'effectue en particulier pour la Très Petite Entreprise (TPE), la Petite Entreprise (PE) et la Moyenne Entreprise (ME), selon le système normal de présentation des états financiers et de tenue des comptes » (article 3). La déclaration légale renvoie à des formalités différentes selon la forme de l'entreprise : • pour l'entrepreneur à la déclaration d'activité au RCCM ; • pour les personnes physiques et morales commerçantes, à l'immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier ; • pour les sociétés coopératives, à l'immatriculation du Registre des sociétés coopératives. »

La loi de 2020 sur les PME a toutefois prévu un dispositif spécifique simplifié pour les micro-entreprises individuelles appelées « l'entrepreneur ». A ce titre elles doivent, adhérer (art. 30) à l'Institution de protection sociale désignée, créée par décret, pour gérer ce régime spécifique simplifié, contributif ou semi-contributif afin de bénéficier des services dans les différentes branches de protection sociale. L'adhésion, qui donne lieu à un montant forfaitaire de cotisations, est obligatoire dès le 1^{er} salarié. Un barème doit cependant être adopté pour appliquer cette disposition.

La loi du 7 janvier 2020 consacre la volonté d'une reconnaissance officielle de la PME afin de renforcer la sécurité juridique des transactions et des contrats. Cette reconnaissance passe par la voie de l'agrément pour les PME, de la labellisation, et, pour les Moyennes entreprises, de processus de normalisation et de certification. **La reconnaissance du statut de PME doit faire l'objet d'un agrément** qui doit être conféré par le Ministère en charge des PME (art. 4) suivant des modalités, dont « l'octroi des avantages », qui devront être déterminées par décret, (art. 5). Tandis (art. 7) qu'est confié à une « *structure nationale d'exécution des politiques de développements et de promotions des PME* » met en place un « *dispositif de labellisation des entreprises (...) doit permettre de faciliter leur accès aux marchés, à la commande publique et aux financements* »

L'article 15 prévoit un soutien à la normalisation et à la certification pour les Moyennes entreprises (M.E.) qui doit être fourni par la Structure nationale de promotion des PME (qui reste à établir) en coopération avec les institutions de normalisation. Les PME devraient ainsi bénéficier d'un soutien financier par le biais d'un Fonds de promotion pour les frais liés à ces procédures.

La loi du 7 janvier 2020 apporte également une définition de la sous-traitance qui vient éclairer son usage dans le droit de la commande publique (art. 3, liste des définitions): il s'agit d'un « *processus par lequel une entreprise dite « donneur d'ordres », confie la réalisation par une entreprise dite « sous-traitant » (ou « preneur d'ordres »), une ou plusieurs opérations de conception, d'élaboration, de fabrication, de mise en œuvre, de maintenance, etc. Le sous-traitant est tenu de se conformer exactement aux directives ou spécifications techniques (ou encore cahier des charges) du donneur d'ordres auquel il est lié par un contrat spécifique* ». Cette précision est importante dans le cadre des contrats de travaux publics où le titulaire doit assumer la pleine responsabilité de tous les travaux effectués, même sous-traités.

La loi d'orientation n° 2020-02 du 7 janvier 2020 relative aux PME définit également les rôles et responsabilités de la PME dont une partie correspond à la RSE. Elle partage ainsi des objectifs communs avec les APD. D'après son exposé des motifs, elle doit répondre « *aux objectifs d'émergence économique prônés par le PSE et de croissance inclusive et durable* ». A plus d'un titre, cette loi est intéressante pour les APD dans la commande publique. Tout d'abord parce

qu'elle vise, dans son article 2, à « *promouvoir une culture de la responsabilité sociale, fiscale et environnementales des entrepreneurs* ». Son article 10 énonce précisément les « *responsabilités* » que les PME s'engagent à assumer :

- « *la création d'emplois décents, notamment en veillant au respect des interdictions contre les pires formes de travail et le travail des enfants* ;
- *la protection sociale de leurs employés, en particulier dans le domaine de la santé de la sécurité sociale et de la prévoyance retraite* ;
- *la paix sociale, à travers le dialogue et la concertation avec tous les acteurs* ;
- *le recours privilégié à la médiation, à la conciliation et à l'arbitrage, pour le règlement des litiges* ;
- *l'amélioration des recettes fiscales, en veillant au paiement régulier des charges fiscales* ;
- *la protection de l'environnement* ;
- *la fourniture, aux structures publiques, d'informations à des fins statistiques* ;
- *la bonne gouvernance d'entreprise, notamment en s'interdisant tout acte de fraude et de corruption* ;
- *Le respect des obligations contractuelles avec les donneurs d'ordres dans le cadre de la sous-traitance* »

Toutes ces obligations, dénommées « *responsabilités* » par la loi d'orientation des PME forgent ainsi une base légale au concept de RSE dans l'environnement juridique sénégalais, qui a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises, y compris les grandes. L'ordre choisi pour lister ces responsabilités mérite d'être souligné : la protection sociale est clairement priorisée, viennent ensuite la paix sociale et la médiation, le paiement des impôts. La protection de l'environnement figure entre ce dernier et la collecte de statistiques, mais avant la gouvernance d'entreprise dont la loi souligne la lutte contre la corruption et le respect des obligations contractuelles, mais celles-ci sont surtout soulignées dans le cadre de la sous-traitance.

En revanche, comme souligné *supra*, cette loi de 2020 prévoit peu de dispositions spécifiques en faveur des « PME à direction féminine », même si elle encourage (art. 11) « *la création et le développement d'entreprises par les femmes* » avec la possibilité d'accéder prioritairement (à côté des Jeunes) à des *prêts d'honneur* (art. 27). En outre, il n'existe pas de définition de la PME à direction féminine. Pour combler ce vide, le Rapport Carapaces (p. 59) propose de considérer comme PME féminine postulante aux marchés publics, « *toute PME nationale au sens de la Loi d'orientation n° 2020- 02 du 07 janvier 2020 relative aux Petites et Moyennes Entreprises, appartenant à ou contrôlée, directement et inconditionnellement, par une ou plusieurs femmes ou PME féminines et intervenant dans un secteur éligible aux marchés publics* ». L'adverbe « *inconditionnellement* » ayant pour objet d'éviter les PME à « *apparence* » féminine qui seraient constituées avec des prête-noms afin de détourner les mécanismes incitatifs et préférentiels.



Recommandations :

- *CMP : Inclure les nouvelles catégories de PME dans les définitions du CMP (art. 4) afin d'éclairer l'usage des dispositions plus favorables : marges de préférences, marchés réservés, dispense de garanties de soumission ou d'exécution.*
- *Inclure la définition de la PME à direction féminine proposée par le Rapport Carapace*

§ 2-2 Les définitions de l'Artisanat et de l'Artisan

Les APD peuvent également jouer un rôle moteur dans la formalisation des initiatives privées. Tout d'abord en offrant des passerelles de transition tournées vers l'entrepreneuriat social, ou l'artisanat car, suivant le PSE⁶⁰, « *L'objectif visé est d'opérer une transition souple de ce secteur vers l'économie formelle, en augmentant notamment la part des emplois formels et en s'appuyant sur des sous-secteurs tels que l'artisanat* ». Ensuite en offrant des mécanismes incitatifs à la formalisation des entreprises puisque seules les entreprises déclarées et inscrites au registre du commerce, en règle avec leurs obligations fiscales et sociales peuvent accéder à la commande publique en tant que titulaires ou même sous-traitants.

⁶⁰ Axe 1 du PSE, paragraphe 260 –

- **La création du Projet Mobilier National en 2015**, devait ainsi répondre, selon l'exposé des motifs : « A(...) l'option des pouvoirs publics d'ouvrir la commande de l'Etat à la production artisanale révèle la volonté d'impliquer ce secteur, dans le processus d'émergence économique du Sénégal. Dans cet esprit, l'Etat préconise d'aller au-delà de la simple reproduction des 174 prototypes fabriqués du Mobilier National pour ouvrir totalement la commande publique à un secteur disposant d'une grande capacité d'absorption du chômage et de création de richesse, contribuant au Produit Intérieur Brut (PIB) ». Toutefois, le Décret n°2015-397 du 26 mars 2015⁶¹ abrogeant et remplaçant le décret n°97-928 du 27 août 1997 portant création du Projet Mobilier National a essentiellement créé un dispositif institutionnel au sein du Ministère de l'Artisanat autour d'un coordonnateur et d'un Comité consultatif dans lequel siègent des représentants de nombreux ministères mais aucun représentant de l'ARMP désormais ARCOP. Mais aucune conséquence n'a été tirée sur le plan des mécanismes incitatifs ou prescriptifs afin de faciliter l'achat du mobilier national auprès des artisans (par exemple avec la préparation d'un DTAO spécifique à l'achat de mobilier). Un constat qui a été réitéré en Octobre 2020 par le Ministre de l'Artisanat⁶².
- **De fait, si la catégorie juridique de l'artisanat est mentionnée dans le CMP, elle n'y est pas définie**, alors qu'elle bénéficie de marges de préférences dans les AON (art. 50 du CMP). Faute d'avoir été transposée dans le cadre juridique de la commande publique, cette préférence n'a pas pu porter les fruits escomptés :

Par contraste, on peut signaler la formule du CMP tunisien qui organise une priorité pour les Artisans dans l'accès aux activités artisanales : Art. 21.- « Est réservée aux artisans tels que définis par la législation et la réglementation en vigueur, la participation aux travaux, fournitures et services liés aux activités artisanales dans les commandes publiques, sauf impossibilité dûment motivée. L'acheteur public doit préciser dans le Rapport spécial les justifications de cette impossibilité ». L'organe de contrôle a priori émet obligatoirement un avis relatif à ces justifications. »

§ 2-3 La définition de l'Artiste

Si le Code des marchés public de 2014 accorde une marge de préférence aux Artistes, il ne semble pas que le droit sénégalais leur ait créé un statut juridique identifié. Dans la pratique, les artistes relèvent dans une grande majorité de l'informel, parfois ils en sortent en créant une TPE ou en revendiquant le statut d'artisan. Il convient de suivre comment ce statut sera formalisé par la législation afin d'en intégrer dans le futur les exigences dans les procédures d'appels d'offres et de concours qui les concernent. Faute de quoi, ces dispositions ne peuvent être effectives.

Récapitulatif : Dispositions hors CMP relatives à la dimension économique (PME) des APD

Accès à la commande publique	
loi sur les Startups du 6 janvier 2020 Son article 13 instaure un régime préférentiel d'accès à la commande publique en faveur des startups labellisées.	Art 13 : Elles pourront ainsi bénéficier d'une marge de 5 % en cas de participation à toute procédure de passation de contrats de la commande publique : marchés publics, DSP ou contrats de partenariat. Cumulable avec d'autres préférences, cette marge peut atteindre 25 %.
Groupement avec des PME ou startups	
	ART. 13 : « Le candidat à un MP, une DSP ou un contrat de partenariat (...) qui présente une offre en groupement avec une ou plusieurs startups, peut bénéficier d'une marge de préférence de 5%. Cette marge est cumulable avec toute marge prévue par la réglementation en vigueur. »
Sous-traitance des Startups et PME	
	ART. 13 : « Le candidat à un MP, une DSP ou un contrat de partenariat qui accepte de sous-traiter 30 % des prestations objet du contrat à une ou plusieurs startups labellisées (...) peut bénéficier d'une marge de préférence de 5%. Cette marge est cumulable avec toute marge prévue par la réglementation en vigueur. »

⁶¹ http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id_article=10458

⁶² Notes : Ce fut la raison principale de la tenue à Saly de l'atelier sur l'élaboration d'une Stratégie nationale de développement du secteur. Selon le ministre de l'Emploi, de la formation professionnelle et de l'artisanat, qui présidait la clôture de l'atelier, cet exercice est conçu comme le point d'orgue d'un long processus itératif et inclusif. « De plus en plus, plusieurs structures ont été mises en place pour appuyer les artisans et promouvoir le secteur », a déclaré Dame Diop. Il a cité la Direction de l'artisanat, les chambres de métiers et l'Union nationale des chambres de métiers, l'Agence pour la promotion et le développement de l'artisanat (APDA), le projet de mobilier national ainsi que l'Agence nationale de la maison de l'outil. C'est un long travail que nous avons voulu inclusif et participatif. Et nous arrivons aujourd'hui, à ce dernier atelier de partage avec l'ensemble des acteurs pour faire la dernière mouture que nous allons présenter à la haute autorité du pays », a précisé Dame Diop. L'Agence pour la promotion et le développement de l'artisanat qui a été créée pour accompagner les artisans. Mais également sur la réforme du mobilier national qui a permis d'accompagner l'artisanat et qui a permis d'atteindre le taux de 15% de marché des artisans dans la commande publique » (source : Le Soleil, 6 octobre 2020).

Section 3 L'absence de lien entre le droit de l'environnement et le pilier environnemental de la commande publique



La protection de l'environnement s'est illustrée ces dernières années par l'apparition de plusieurs initiatives au Sénégal et l'adoption de plusieurs textes, y compris en-dehors du champ du droit de l'environnement⁶³. Dès la Constitution, l'article 8 garantit à tous les citoyens les droits collectifs au titre desquels figure « le droit à un environnement sain ». L'article 25-1 a ajouté « l'exploitation et la gestion des ressources naturelles doivent se faire dans la transparence et de façon à générer une croissance économique, à promouvoir le bien-être de la population en général et à être écologiquement durables ». Et surtout l'article 25-2 : *Chacun a droit à un environnement sain. La défense, la préservation et l'amélioration de l'environnement incombent aux pouvoirs publics. Les pouvoirs publics ont l'obligation de préserver, de restaurer les processus écologiques essentiels, de pourvoir à la gestion responsable des espèces et des écosystèmes, de préserver la diversité et l'intégrité du patrimoine génétique, d'exiger l'évaluation environnementale pour les plans, projets ou programmes, de promouvoir l'éducation environnementale et d'assurer la protection des populations dans l'élaboration et la mise en œuvre des projets et programmes dont les impacts sociaux et environnementaux sont significatifs.* La protection de l'environnement crée aussi des devoirs pour tous les citoyens : *Tout citoyen a le devoir de préserver les ressources naturelles et l'environnement du pays et d'œuvrer pour le développement durable au profit des générations présentes et futures.*

Les analyses ci-dessous ont pour objet de souligner les liens qui existent entre le droit de l'environnement et le droit de la commande publique. Le droit de l'environnement intéresse en effet la Commande publique de 3 façons : en amont, avec la procédure de l'étude d'impact dont les résultats vont influencer les montages contractuels relatifs aux travaux publics, les modalités d'exécution du futur contrat avec l'interdiction de recourir à certaines techniques et/ou l'exigence de respecter certaines précautions, et enfin, les conséquences de la méconnaissance des obligations environnementales, notamment sous forme de sanctions contractuelles. Ces 3 aspects vont être abordés à travers l'examen du cadre juridique sénégalais.

§ 1 L'étude d'impact à la charnière entre le droit de l'environnement et le droit des contrats de travaux publics

L'encadrement de l'étude d'impact est issu du Code de l'environnement de 2001, lui-même structuré autour de trois titres traitant respectivement de la Prévention et lutte contre les pollutions et nuisances, de la Protection et mise en valeur des milieux récepteurs et des Sanctions et dispositions diverses. Soit 35 pages et 110 articles de nature législative issus de la Loi n° 2001-01 du 15 janvier 2001 portant Code de l'Environnement⁶⁴ auquel s'ajoutent les dispositions réglementaires du décret d'application⁶⁵ du Code de l'environnement n°2001-282 du 12 avril 2001 qui compte six titres traitant respectivement des domaines : - Installations classées pour la protection de l'environnement ; - Etude d'Impact Environnemental (EIE) ; - Pollution de l'eau ; - Police de l'eau ; - Pollution de l'air ; - Pollution sonore. Le texte du Décret renvoie à 5 arrêtés relatifs à l'étude d'impact, dont certains ajoutent (ce qui n'est pas conforme juridiquement) des exigences aux dispositions du décret et de la loi :

- Arrêté ministériel n° 9468 MJEHP-DEEC du 28 novembre 2001 portant réglementation de la participation du public à l'étude d'impact environnemental⁶⁶ ;
- Arrêté ministériel n° 9469 MJEHP-DEEC, du 28 novembre 2001 portant organisation et fonctionnement du Comité technique⁶⁷ (pour l'administration et la gestion de l'étude d'impact environnemental) ;
- Arrêté ministériel n° 9470 MJEHP-DEEC en date du 28 novembre 2001 fixant les conditions de délivrance de l'Agrément pour l'exercice des activités relatives aux études d'impact sur l'Environnement ;

⁶³ Ainsi la loi du 7 janvier 2020 sur les PME fait-elle référence à l'économie verte puisque, dans son article 11, elle affirme que l'Etat va encourager la création et le développement « d'entreprises dans des secteurs prioritaires, tel que l'économie rurale, l'économie numérique, l'économie sociale et solidaire, l'habitat social, l'économie du sport et l'économie verte » tandis que la protection de l'environnement est érigée parmi les « responsabilités » assumées par les PME (art. 10).

⁶⁴ http://www.denv.gouv.sn/images/stories/evaluationenvi/code_environnement.pdf

⁶⁵ Accessible sous la même référence. On notera que c'est sous l'onglet « l'étude d'impact » que l'on peut trouver ces textes de base du droit de l'environnement sur le site de la DEEC.

⁶⁶ <http://www.denv.gouv.sn/images/stories/cadrejuridique/arrete9468.pdf>

⁶⁷ <http://www.denv.gouv.sn/images/stories/cadrejuridique/arreten9469.pdf>

- Arrêté ministériel n° 9471 MJEHP – DEEC en date du 28 novembre 2001 portant contenu des termes de références des études d'impact ;
- Arrêté ministériel n° 9472 MJEHP-DEEC en date du 28 novembre 2001 portant contenu du Rapport de l'Etude d'impact environnemental ;

Il existe également une liste de plus d'une cinquantaine de Bureaux agréés pour réaliser des études d'impact environnemental qui date de 2013⁶⁸.

§ 1-1 Une articulation à définir entre l'étude d'impact et le contrat de la commande publique

L'Etude d'impact impose des obligations procédurales en amont de la procédure contractuelle qui mériteraient d'être actualisées. Le chapitre V de la loi portant Code de l'environnement, dans ses articles 48 à 54, complété par le Titre II du Décret d'application du Code de l'environnement n°2001 – 282, prévoient une « *Etude d'impact sur l'environnement* » dans ses articles R 38 à R 44 dont les résultats (L. 51) doivent être intégrés dans la préparation des grands projets. Mais les dispositions du Code de 2001 paraissent désormais dépassées et présentent des risques juridiques. En effet, l'Etude d'Impact Environnemental n'aborde que le volet environnemental, ignorant les questions contemporaines de l'impact social ou de l'impact sur le genre qui émergent. La procédure devrait être scindée afin de prévoir également une étude allégée pour les chantiers temporaires ou mobiles à côté des projets définitifs. Surtout, la procédure et le financement de l'étude d'impact peuvent présenter des risques de conflits d'intérêts contraires aux exigences de la commande publique.

L'Etude d'Impact Environnemental (EIE) doit céder la place à l'Etude d'Impact Environnementale et Sociale (EIES).

L'article 48 du Code de l'environnement a envisagé de tenir compte des « *capacités, les fonctions des ressources, des systèmes naturels et des systèmes humains afin de faciliter la planification du développement durable et la prise de décision en général* », mais c'est en fait l'article R 39 du décret d'application n°2001 – 282 qui, allant au-delà des termes de la loi, a élargi notablement ce périmètre puisqu'il énonce que « *l'EIE évalue les effets escomptés sur la santé des populations, sur l'environnement naturel et sur la propriété ; elle peut également couvrir les effets sur le plan social, notamment en ce qui concerne les besoins spécifiques des hommes et des femmes, et des groupes particuliers, la réinstallation des personnes déplacées et les conséquences pour les populations locales* ». De fait, figure ensuite dans le même article R.39 un énoncé des nombreux effets à considérer, tels que les effets sur la santé, sur l'agriculture, sur le climat, sur l'utilisation des ressources naturelles, sur/du recyclage et l'élimination des déchets, les aspects connexes tels que la réinstallation des populations, les sites archéologiques, le paysage, les monuments, ainsi que les incidences sociales et les effets en amont, en aval et transfrontaliers. Par-delà cet énoncé, parfois en utilisant les modèles des PTF, l'usage s'est répandu d'envisager également la portée du futur projet sur les populations locales et d'intégrer ainsi des préoccupations économiques et sociales. D'Etude d'Impact Environnemental, l'Etude est progressivement devenue, dans la pratique, une Etude d'Impact Environnementale et Sociale (EIES), comme le confirme l'arrêté relatif aux TDR de l'étude d'impact⁶⁹. Il conviendrait donc de proposer une révision du Code de l'Environnement afin d'y introduire clairement l'EIES en remplacement de l'EIE et d'établir son périmètre d'intervention. Cela permettrait de codifier la procédure et la méthodologie à suivre pour embrasser ces nouvelles dimensions dans une démarche structurée et transparente.

La pluridisciplinarité des équipes d'évaluation doit refléter la pluralité des volets des EEIS. D'une part, les attributions du Comité Technique, dont le secrétariat est assuré par la Direction de l'Environnement et des Installations Classées (DEEC) (art. R.43 du Décret n°2001 – 282), en charge de l'administration et de la gestion de l'étude d'impact auprès du Ministère de l'Environnement devraient mieux refléter les champs disciplinaires que doivent explorer les EIES contemporaines. D'autre part, sa composition doit également être précisée avec la participation systématique d'autres administrations, de même que la possibilité de faire appel à des experts techniques sur des questions particulières (par exemple en matière d'économie d'énergie).

Les compétences des Bureaux d'Etudes chargés des Etudes d'impact doivent être adaptées à la diversité des questions économiques et sociales à traiter dans une EIES. En l'état de la réglementation, pour obtenir leur agrément, ces Bureaux doivent démontrer leurs compétences dans des domaines techniques qui relèvent strictement du droit de l'environnement (art. R.42 du Décret n°2001 – 282) : « *aménagement du territoire & infrastructures, urbanisme, exploitation*

⁶⁸ http://www.denv.gouv.sn/deecsiteold/documents/Liste_Bur_Pers_Agrees_SEPT_2013.pdf

⁶⁹ ARRETE MINISTERIEL n° 9471 MJEHP – DEEC en date du 28 novembre 2001 portant contenu des termes de références des études d'impact.

des ressources renouvelables, mines & carrières, processus industriels énergie et technologie, agro-industries, traitement et stockage des déchets, biotechnologie et diversité biologique ». Ces domaines de compétences, aussi utiles soient-ils pour évaluer l'impact environnemental d'un projet, ne permettent pas de traiter convenablement les questions sociales et économiques qui sont désormais envisagées dans les EEIS contemporaines. Comme cela se fait dans les études financées par les bailleurs, il faudrait inclure un expert ou responsable « genre et développement », souvent sociologue de formation, qui peut aller à la rencontre des populations pour évaluer l'ensemble des aspects du projet (y compris la dimension « violence »). Le capital humain est un élément clé de ces études, et comme souvent dans les marchés des prestations intellectuelles, il faut s'assurer de la disponibilité effective des experts annoncés et de la qualité des travaux menés⁷⁰. Enfin, mais c'est une question plus générale d'accès aux données, d'après la DEEC, les Bureaux d'études peinent parfois à trouver les données actuelles et nécessaires, notamment les données environnementales (par exemple : hydrologiques, climatiques), malgré des collaborations avec les Universités. Cela ralentit le déroulement des études et rend parfois difficile l'obtention à temps du « quitus environnemental » délivré par la DEEC et dont la procédure reste à préciser.

Il conviendrait de prévoir une procédure distincte et une étude allégée pour les chantiers temporaires ou mobiles qui correspondent à des marchés de travaux qui ne débouchent pas sur la création d'une infrastructure pérenne. Dans ce cas, la procédure d'EIES s'avère particulièrement lourde et elle prend en général entre 8 et 12 mois. Autant cette durée paraît adaptée quand il s'agit de construire des infrastructures définitives, autant elle paraît excessive pour des installations temporaires. De la même manière, la procédure de déclaration d'installation classée n'est pas modulable en fonction de l'ampleur et de la durée des chantiers. Cela freine la réalisation des opérations de commande publique alors que des procédures plus adaptées pourraient permettre également de vérifier de façon plus efficiente l'éventuel impact sur l'environnement des lieux d'exécution des travaux.

La procédure et le financement de l'étude d'impact ne sont pas adaptés aux exigences de la commande publique, en particulier au regard du respect de la concurrence et de l'impartialité. En effet, l'article L. 49 du Code de l'Environnement prévoit, dans une rédaction ambiguë, que l'Etude d'impact est à la charge de son « promoteur ». Or si les standards internationaux et les exemples tirés des Etats étrangers prévoient en principe un financement par le Maître d'ouvrage (parfois aidé par un PTF), la pratique sénégalaise a aussi permis des financements par l'entreprise porteuse du projet. La formule de l'article L 49 suppose aussi que l'entreprise qui doit financer l'EIES a déjà été retenue pour l'exécution du futur contrat/projet : *« l'étude d'impact s'insère dans une procédure déjà existante d'autorisation, d'octroi ou d'approbation de concession ; les principaux acteurs qui interviennent dans la procédure de l'étude d'impact sur l'environnement sont le promoteur et les Autorités compétentes »*. En 2001, ce dispositif concordait avec les attributions de gré à gré des concessions mais il est devenu irrégulier à partir du moment où les Directives de l'UEMO de 2005 ont exigé des procédures concurrentielles pour l'attribution des DSP. De nos jours, ce financement des études préparatoires par le porteur du projet persiste dans l'hypothèse d'une « proposition spontanée » à l'initiative de l'entreprise. De manière significative, le DTAO du marché clé en main exige expressément que l'Etude d'Impact et toutes les autres études seront conduites par l'entreprise qui doit en faire part dans sa proposition technique⁷¹. **Il est temps que le droit de l'environnement renoué précise les rôles des différents participants à l'EIES pour assurer son impartialité.** Elle doit toujours être financée par le maître d'ouvrage, ainsi contraint de s'assurer qu'il dispose des crédits suffisants avant de lancer un projet. Dans ce mouvement, la loi du 7 janvier 2020 relative aux PME charge les « ministères sectoriels concernés de mettre en œuvre un programme de subventions des études d'impact environnemental et social des projets des PME ». Prometteuse, cette disposition mériterait d'être expliquée pour préciser le sens desdits « projets » et leur articulation avec des contrats publics futurs.

Recommandations :

- CMP : mentionner le Code de l'environnement dans les Visas du CMP

Travaux futurs :

-Pour le droit de l'environnement, il conviendrait d'inclure dans la révision du Code de l'Environnement des dispositions relatives à l'EIES en remplacement de l'EIE, afin de préciser son périmètre d'intervention. Cela

⁷⁰ Les entreprises contactées pour les questionnaires ont rapporté de nombreux cas de dossiers de piètre qualité.

⁷¹ L'Art 17.1 de l'Instruction aux Candidats énonce que : « La proposition technique inclura en outre une méthodologie relative aux études de faisabilité et études techniques d'exécution devant être menées par la Candidat. Ce volet intègre toutes les études relatives aux volets environnemental et social ».



permettrait de codifier la procédure et la méthodologie à suivre pour embrasser ces nouvelles dimensions dans une démarche structurée et transparente.

-Il faut que le droit de l'environnement rénové précise les rôles des différents participants à l'EIES.

Celle-ci doit être en principe toujours financée par le maître d'ouvrage qui doit disposer des crédits suffisants avant de lancer un projet. L'AC, maître d'ouvrage, pourra ainsi apprécier les tenants et les aboutissants d'un futur projet en commandant une EEIS avant de lancer ensuite une procédure concurrentielle pour attribuer les contrats de mise en œuvre du projet. Il faudra mentionner le PGES (voir infra) qui doit être préparé par les candidats aux marchés de travaux et son articulation avec l'EIES.

-Les TDR des bureaux d'études devraient être revus afin d'assurer la prise en compte non seulement des questions environnementales mais également sociales.

-Il conviendrait de prévoir une procédure distincte et une étude allégée pour les chantiers temporaires ou mobiles.

-Sur le plan institutionnel, des réformes sont également à envisager sur la composition des structures ministérielles pour refléter la pluridisciplinarité des EEIS et des questions environnementales en générale. De même la possibilité de faire appel à des experts techniques sur des questions particulières (par exemple en matière d'économie d'énergie) devrait être encouragée.

-Une collaboration régulière doit être instaurée avec l'ARCOP afin d'harmoniser les exigences qui peuvent avoir une incidence sur le déroulé des opérations de la commande publique.

§ 1-2 L'articulation à définir entre le Plan de Gestion Environnementale et Sociales (PGES) et l'Etude d'Impact Environnemental et Social (EIES)

Le Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) est un document du DAO qui doit reprendre les conclusions de l'EIES. S'il apparaît sous la forme d'un formulaire dans les DTAO relatifs aux travaux importants⁷², il manque de base légale puisqu'il ne figure ni dans les textes généraux de la commande publique, ni dans le Code de l'environnement et ses décrets d'application. Cette présence reste de toute manière parcellaire : ledit « PGES » ne figure pas dans le DTAO Passation d'accords-cadres pour des Marchés de Travaux, ni dans le Dossier-type pour les DSP : Passation d'un contrat de Délégation de Service Public (Oct. 2016, 144 p.). Au contenu du PGES, ajouter la préparation d'un plan de gestion des déchets devient nécessaire⁷³. En fin de compte, formaliser l'existence du PGES permettrait d'asseoir sa méthodologie, son contenu et sa force juridique dans les documents contractuels.

Dans le cadre des projets PPP, l'EIES devrait être intégrée dans les évaluations préalables. Cette analyse s'insère alors au milieu d'autres évaluations qui visent à apprécier les externalités (coûts et bénéfices attendus pour la partie publique) et la soutenabilité budgétaire. On retrouve ce dispositif dans les lois récentes sur les PPP : au Bénin (loi° 2016-24 du 28 juin 2017 sur les PPP), en Mauritanie (Loi n°2017-06 du 6 février 2017 relative au Partenariat Public-Privé (PPP), art. 12⁷⁴) ou encore à Madagascar⁷⁵. Au Sénégal ce rôle pourrait être dévolu à la Cellule d'appui aux PPP en concertation avec le Ministère de l'Environnement qui est en charge de délivrer le certificat de conformité de l'EIES. Enfin, il faut assurer bien entendu que les conclusions de ces études préalables et les mesures qu'elles exigent éventuellement seront bien

⁷² Dans les DTAO marchés de travaux, des documents intitulés « Autres – Documents : Impact Environnemental & social, Prise en compte du genre » ainsi qu'un document intitulé « Hygiène et Sécurité » doivent être produits par les entreprises candidates. Pourtant ces documents, reproduits dans l'annexe n°16, ne sont ni désignés par un titre identifié ni répertoriés dans la liste des formulaires à remplir par les candidats. Tout au plus figurent-ils dans la Section III relative aux « *Formulaires de soumission* », entre le programme/calendrier de construction et les Formulaires de qualification. Ainsi on retrouve les deux mêmes documents dans le DTAO grands travaux, dans le DTAO travaux de taille moyenne (Mai 2017, 126 p) et dans le DTAO marché clé en main (Mai 2015, 172 p.). La formulation de certaines phrases du dit « PGES » ainsi reproduit révèle que ce document est probablement tiré d'un DTAO d'un PTF.

⁷³ Par exemple, en s'inspirant des nouvelles dispositions introduites dans le Code de la construction et de l'habitation en France par la loi contre le gaspillage et pour l'économie solidaire (2020).

⁷⁴ Mauritanie, Loi n°2017- 06 du 6 février 2017 relative au Partenariat Public- Privé (PPP), art. 12 : « Avant de s'engager dans un projet de Contrat de PPP et préalablement à l'évaluation préalable visée à l'Article 13, ci- après, l'Autorité contractante doit effectuer une étude de préféabilité technique, économique, financière, environnementale, sociale, juridique et administrative afin d'évaluer l'intérêt potentiel du projet et l'impact estimé sur le budget de l'Autorité contractante. L'étude de préféabilité définit notamment les paramètres de l'étude d'impact environnementale et sociale devant obligatoirement être réalisée par l'initiateur du projet sous le contrôle de la personne publique compétente ou pour son compte. Le contenu de l'étude de préféabilité est précisé par voie réglementaire. L'étude de préféabilité est transmise par l'Autorité contractante à la Cellule PPP qui doit l'analyser et la transmettre pour approbation au Comité Technique d'Appui »

⁷⁵ Décret n° 2017-149 portant application de la loi N° 2015-039 du 3 février 2016 sur le PPP relatif aux modalités d'application des dispositions concernant la passation des contrats de PPP, Article 7.2. <http://www.droit-afrique.com/uploads/Madagascar-Decret-2017-149-application-loi-ppp-contrats.pdf>

incorporées dans les dispositions du futur contrat de PPP. N'ayant pas connaissance des textes d'application relatifs aux PPP, le présent Rapport ne peut proposer de rédaction spécifique concernant ces éléments.

§ 1-3 Les réglementations environnementales de secteurs ou produits qui font l'objet de contrats publics

La réglementation pyramidale des exigences environnementales s'applique jusque dans les contrats de la commande publique. L'approche adoptée par le Code de l'environnement repose sur une définition matérielle des nuisances ou pollutions des éléments : pollution de l'eau, pollution de l'air et pollution sonore. Il interdit par conséquent toute activité susceptible de nuire à la santé de l'Homme ou de constituer une gêne excessive pour le voisinage ou de porter atteinte à l'environnement. De même il exige que les catégories de déchets, y compris ceux des chantiers, soient gérées par leurs producteurs ou par des entreprises agréées aux frais du producteur (cf. art. L31). Pour la réalisation des ouvrages publics ou d'opérations de travaux publics, il convient également de prendre en compte les dispositions relatives aux installations classées. Conformément à l'article L 9 du Code de l'Environnement, il s'agit des usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières et, d'une manière générale, des installations industrielles, artisanales ou commerciales exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et toutes autres activités qui présentent soit des dangers pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, l'agriculture, la nature et l'environnement en général, soit des inconvénients pour la commodité du voisinage.

Des décrets d'application viennent préciser certaines exigences par secteur ou type de produit : tels que le décret n° 2010-1281 réglementant les conditions d'exploitation du plomb issu des batteries usagées et d'autres sources et de l'utilisation du mercure et le Décret n° 2008-1007 en date du 18 août 2008 portant réglementation de la gestion des déchets biomédicaux⁷⁶. Ou encore le Décret n° 2011-160 du 28 janvier 2011 portant interdiction de l'importation et de la production au Sénégal des lampes à incandescence et promotion des lampes à économie d'énergie. Ces dispositions ont une vocation générale et doivent s'appliquer à toutes les activités commerciales ou de construction. Mais elles intéressent donc particulièrement les marchés publics et PPP.

Des arrêtés complètent ce dispositif réglementaire avec une incidence potentielle dans certains types de marchés de travaux ou de fournitures :

- **L'Arrêté Interministériel n° 009311 du 05 10 2007, portant gestion des huiles usagées**⁷⁷ distingue les opérations de ramassage, de tri, de regroupement, de transport, d'élimination, de traitement (régénération et valorisation, valorisation énergétique, recyclage), qui peuvent être opérées respectivement par les détenteurs, les ramasseurs et les éliminateurs. Il prévoit une procédure d'agrément par l'Etat pour les sociétés autorisées à effectuer l'élimination et/ou la collecte et l'obligation d'établir un « registre vert » annuel pour les entreprises qui produisent au moins 500 litres d'huiles usagées par an.
- **L'Arrêté ministériel n° 003165 du 21 mai 2003 réglementant l'exploitation d'un dépôt de gaz combustible domestique ;**
- **L'Arrêté Interministériel fixant les conditions de rejets des eaux usées** et sa norme d'application⁷⁸. Le droit de l'environnement prévoit également des normes de référence, dont certaines figurent sur le site de la DEEC⁷⁹. Ces normes doivent servir lors de l'élaboration des spécifications techniques des futurs contrats de la commande publique notamment dans les marchés de travaux.
- **La Norme Sénégalaise NS- 05-061 de 2001 relative aux Eaux usées :** normes de rejet⁸⁰ dont l'article 3.1. définit la pollution des eaux : « tout déversement, écoulement, dépôt direct ou indirect d'eaux ou de matières et plus généralement tout fait susceptible d'altérer la qualité des eaux de surface, souterraines ou marines » et (art. 3.6) la pollution chimique toxique : « produit qui peut provoquer l'altération ou la perturbation au niveau des organismes ou sur les niveaux d'intégration inférieurs (organe, cellule, molécule) » et les interdictions (V.) et leurs modalités de contrôle. Son annexe renvoi elle-même à de nombreuses normes sénégalaises (NS).
- **La Norme Sénégalaise NS 05-062 d'octobre 2003 relative à la pollution atmosphérique** - Norme de rejets⁸¹ qui définit la Pollution atmosphérique : « l'émission dans la couche atmosphérique de gaz, fumées ou substances

⁷⁶ <http://www.denv.gouv.sn/images/stories/cadrejuridique/decretdechetsbiomedicaux.pdf>

⁷⁷ http://www.denv.gouv.sn/images/stories/cadrejuridique/arrete_portant_gestion_des_huiles_usees_pdf.pdf

⁷⁸ http://www.denv.gouv.sn/images/stories/cadrejuridique/pdf_Norme_rejets_NS_05_061_2.pdf

⁷⁹ Les auteurs du Rapport ont constaté la difficulté à accéder à ces normes et recommandent un inventaire exhaustif des normes existantes qui intéressent les contrats publics.

⁸⁰ http://www.denv.gouv.sn/images/stories/cadrejuridique/pdf_Norme_rejets_NS_05_061_2.pdf

⁸¹ http://www.denv.gouv.sn/images/stories/cadrejuridique/pdf_Norme_rejets_NS05_062_2.pdf

de nature à incommoder les populations, à compromettre la santé ou la sécurité publique ou à nuire à la production agricole à la conservation des constructions et monuments ou au caractère des sites et écosystèmes naturels ». Elle interdit « *le brûlage à l'air libre des pneumatiques, plastiques et tout autre composé renfermant des produits chimiques* » (art. 8.2) et renvoie à la norme NS 05-060 pour les exigences relatives aux émissions des gaz et fumées des véhicules terrestres à moteur. L'incinération ou la décomposition thermique des déchets n'est autorisée que dans des installations technologiquement destinées à cet effet. Elle renvoie également au Décret n° 98-341 du 21 avril 1998 relatif aux spécifications applicables aux hydrocarbures raffinés.

Sur le plan de la force juridique, toutes ces dispositions du Droit de l'environnement s'imposent évidemment dans le cadre de l'élaboration et de l'exécution des contrats de la commande publique, en fonction de l'objet des contrats, au titre du cadre légal auquel doivent se conformer les parties. La difficulté vient pourtant de leur mise en œuvre très variable, aggravée par la méconnaissance de ces dispositions, une méconnaissance aussi bien partagée par les Autorités contractantes que par les entreprises.

La loi du 7 janvier 2020 relative aux PME, en son article 19, a pris en compte une partie de ces exigences, notamment celles identifiées par l'EIES, puisqu'elle a prévu, pour les PME, « *un programme de subventions destiné au développement des systèmes de gestion de la qualité, de mesures d'hygiène, de sécurité sur les lieux de travail et de gestion de la sécurité des aliments* ». Et c'est aussi le propos de la proposition d'une nouvelle Charte sur l'Ethique et le Développement durable que de rappeler la nécessité de respecter le droit applicable.

Pour assurer la mise en œuvre cohérente de ces prescriptions techniques dans le cadre des contrats publics, il faudra prévoir de développer des DTAO spécifiques ainsi que des Guides pédagogiques et explicatifs. Ces outils élaborés par des équipes pluridisciplinaires comprenant des spécialistes de la commande publique alliés des techniciens des domaines concernés permettront de synthétiser leur logique respective lorsque les conditions de réalisation d'un contrat public peuvent avoir un effet quelconque sur l'environnement.

Le droit de l'environnement recèle ainsi de très nombreuses conséquences obligatoires pour la commande publique sénégalaise. La réforme juridique pour développer les APD au Sénégal doit permettre d'assurer la pleine effectivité de ces exigences au bénéfice du développement durable. Mais il faudra également ajouter une coordination institutionnelle adaptée et pérenne entre l'ARCOP ex-ARMP et la DEEC.

§ 2 Les liens entre le droit de l'urbanisme et le droit de la commande publique

Le droit de l'urbanisme partage des finalités communes avec le droit de l'environnement et il intéresse le droit de la commande publique, en particulier dans le domaine des marchés de travaux, à plusieurs titres. En effet, le Décret no 2009-1450 portant partie réglementaire du Code de l'Urbanisme précise les conditions d'application de la loi n° 2008-43 du 20 août 2008 portant partie législative du Code de l'urbanisme et renvoie au respect de la réglementation environnementale en matière de construction et d'aménagement. Par ailleurs, un certain nombre d'exigences établies par le droit de l'urbanisme impose des procédures spécifiques lors de marchés de travaux, de DSP (PPP à paiement par les usagers) ou de PPP à paiement public qui prévoient une emprise immobilière :

- **Dans la gestion des espaces, le droit de l'urbanisme exige une programmation des projets à travers l'adoption de schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme et de Plans Directeurs d'Urbanisme (PDU)** qui doivent fixer les orientations fondamentales de l'aménagement des territoires concernés, compte tenu des relations entre ces territoires et les régions avoisinantes et de l'équilibre qu'il convient de préserver entre l'extension des agglomérations, l'exercice des activités agricoles, des activités industrielles, et les autres activités économiques et la préservation de l'environnement.
- **Lors de la phase de préparation de l'opération contractuelle, il s'agit en amont des travaux publics envisagés de s'assurer que les plans et implantations futurs respectent les prescriptions d'urbanisme.** Ces exigences s'imposent aussi bien à l'entreprise chargée d'exécuter les travaux qu'à l'Autorité contractante. Cette dernière doit en particulier s'assurer du statut et des titres de propriété sur les parcelles sujettes des futurs travaux. Cette vérification peut également incomber à l'entreprise lors de la préparation du PGES (voir *supra*).

La loi n° 2009-26 du 8 juillet 2009 a modifié l'article 68 de la loi n° 2008-43 du 20 août 2008 portant Code de l'Urbanisme afin de renforcer ces obligations. Le Décret n°2009-1450 portant partie réglementaire du Code de l'Urbanisme énonce en son article R. 195 « Nul ne peut entreprendre, sans autorisation administrative, une construction de quelque nature que ce soit ou apporter des modifications à des constructions existantes sur le territoire des communes, ainsi que dans les agglomérations désignées par arrêté du Ministre chargé de l'Urbanisme. Cette obligation s'impose aux services publics et concessionnaires de services publics de l'Etat, des départements et communes comme aux personnes privées». **Les personnes publiques et leurs concessionnaires doivent donc démontrer le caractère d'utilité publique du ou des ouvrages à réaliser**, les contraintes de délais de leur réalisation, la nature et l'importance de ces projets etc..., ce qui exige des études préalables prenant en compte toutes les considérations techniques et sous la supervision des services de l'Etat. Le droit de l'urbanisme a également introduit des exigences en matière de normes de construction pour renforcer l'efficacité énergétique des bâtiments (voir *infra*).

Enfin le droit de l'urbanisme, et plus précisément l'article R 84 du Décret n° 2009-1450 du 30 décembre 2009 portant partie réglementaire du Code de l'urbanisme, créé une convention de rénovation urbaine qui doit être soumise au CMP⁸², tout comme la convention d'aménagement (R.141).

La collaboration entre les champs juridiques doit également se faire dans les deux sens. A ce titre, le Guide des APD (2020) suggère que les révisions envisagées du Code de l'urbanisme ainsi que du Code de la Construction soient l'occasion de « mieux prendre en compte les aspects liés à l'efficacité énergétique dans le bâtiment, d'élaborer un règlement de construction parasismique et une réglementation thermique que ceux qui sont chargés des marchés de travaux devront respecter ».



Recommandations :

- **CMP : inclure la loi sur le code de l'urbanisme dans les visas**
- **CMP : insérer la convention urbaine et la convention d'aménagement dans le CMP**
- **Mentionner dans les DTAO Travaux le respect des exigences du droit de l'urbanisme – des DTAO spécifiques pourront reprendre les spécifications techniques pertinentes**

§ 3 Le cadre juridique de l'assainissement et le droit de la commande publique

La Loi n° 2009-24 du 8 juillet 2009 portant Code de l'Assainissement s'intéresse en particulier aux contrats de **délégation** qui peuvent prendre la forme « d'une concession, d'un affermage ou d'une régie ». L'art. 7 prévoit qu'un arrêté conjoint des ministres chargés de l'Assainissement et des Collectivités locales fixe le modèle de convention d'assainissement liquide qui permet de répondre aux besoins de collecte et d'évacuation des eaux pluviales, notamment à ciel ouvert. D'une manière générale la loi sur l'assainissement et son décret d'application de 2011 énoncent un certain nombre d'obligations qui doivent être respectées lors de la réalisation d'ouvrages publics, que ce Rapport ne va pas explorer ici en détail, mais qui devront être abordés dans le cadre de travaux futurs liés aux PPP à portée sectorielle.



Recommandations :

- **CMP : inclure le code de l'Assainissement dans les visas**
- **Mentionner dans les DTAO Travaux le respect des règles d'assainissement**

§ 4 Les liens entre la maîtrise de l'énergie et le droit de la commande publique

⁸² L'Etat ou la commune peut confier par convention les opérations de rénovation urbaine à des organismes publics, parapublics ou privés d'aménagement et de construction dont le capital social est égal au moins à vingt-cinq pour cent du coût des travaux et présenter des garanties suffisantes. - Cette convention est approuvée conformément au Code des Marchés publics. - Le contrôle de l'exécution de la convention est assuré au nom de l'Etat ou de la commune par le Maître d'ouvrage délégué.

La nouvelle politique de maîtrise de l'énergie qui est en train d'être mise en place au Sénégal avec la révision en cours de nombreux textes de lois et de décrets (voir ci-dessous) prône l'exigence de performance et l'efficacité énergétique des équipements et des bâtiments. De ce fait, elle impacte directement la définition des caractéristiques techniques des ouvrages dans les marchés de travaux et elle coïncide avec les objectifs des APD, notamment le pilier environnemental. En effet elle vise à :

- Faciliter la politique d'accès à l'énergie avec des économies d'énergie pouvant couvrir les besoins énergétiques de nouvelles zones à électrifier ;
- Renforcer la souveraineté énergétique du pays avec la baisse de la dépendance énergétique vis-à-vis de l'extérieur ;
- Réduire les factures d'électricité et dépenses énergétiques de l'État ;
- réduire la demande énergétique grâce aux économies d'énergie et permettre à l'Etat de limiter les investissements dans la construction de centrales électriques ;
- Contribuer à l'essor des autres secteurs d'activités grâce aux investissements mieux maîtrisés dans le secteur énergétique ;
- Contribuer aux efforts de l'État dans la préservation de l'environnement avec la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le sous-secteur énergétique.

Revue du cadre légal, réglementaire et institutionnel du secteur de la Maîtrise de l'Énergie

1) Le cadre institutionnel :

1.1 Le Ministère du Pétrole et des Énergies (MPE) :

Le MPE définit la politique énergétique nationale incluant celle de la maîtrise de l'énergie et assure le suivi de la mise en œuvre de cette politique auprès des institutions opérationnelles.

1.2 L'Agence pour l'Économie et la Maîtrise de l'Énergie et ses partenaires

En 2011, l'État met en place l'agence nationale de l'économie d'énergie (ANEE) qui deviendra en 2013 l'Agence pour l'Économie et la Maîtrise de l'Énergie. Elle est chargée de promouvoir l'utilisation rationnelle de l'énergie dans tous les secteurs et pour tous les usages. L'AEME est le bras opérationnel du MPE pour la mise en œuvre de la politique nationale de maîtrise de l'énergie. Dans ce cadre, l'AEME assure également la mise en œuvre des dispositions réglementaires. A cet effet, elle appuie l'installation et l'opérationnalisation de laboratoires nationaux de contrôle qualité dont le premier, installé au CERER, porte sur l'éclairage et s'inscrit dans le cadre de la mise en place de la réglementation en cours.

De même, l'ASN (Agence Sénégalaise de Normalisation) est le partenaire clé de l'AEME pour l'élaboration des normes d'efficacité énergétique. Par ailleurs, l'ASN vient en appui à l'AEME pour la mise en place de dispositif de validation de la conformité aux normes des équipements.

2) Le cadre juridique :

2.1 Au niveau de l'UEMOA :

Directive n° 04/2020/cm/UEMOA portant étiquetage énergétique des lampes électriques et des appareils électroménagers neufs dans les États membres de l'UEMOA : Elle énonce des dispositions relatives à l'étiquetage énergétique des lampes électriques et des appareils électroménagers neufs et aux renseignements complémentaires relatifs à ces appareils, dans les États membres de l'UEMOA. Elle est entrée en application depuis sa validation en 2020 et chaque État membre doit en faire la transposition.

Directive n° 05/2020/cm/UEMOA fixant des mesures d'efficacité énergétique dans la construction de bâtiments dans les États membres de l'UEMOA : Elle énonce des dispositions visant l'amélioration des performances énergétiques des bâtiments dans les États membres de l'UEMOA. Elle s'applique aux bâtiments neufs et aux bâtiments existants sujets à une rénovation majeure dans les secteurs résidentiels, publics et commerciaux avec une surface utile minimale de 100 m² pour le résidentiel et de 500 m² pour les autres secteurs. Elle est entrée en application depuis sa validation en 2020 et chaque État membre doit en faire la transposition.

2.2 Au niveau de la CEDEAO :

Normes minimales de performances énergétique (MEPS) adoptées pour l'éclairage, les climatiseurs et les réfrigérateurs ; Travaux en cours sur l'étiquetage énergétique des équipements.

2.3 Au niveau national :

Projet de loi sur la Maîtrise de l'Énergie (en cours)

Loi n°2019-03 du 1er février 2019 portant code pétrolier avec son projet de révision (en cours)

La loi n°98-29 du 14 Avril 1998 qui définit les orientations du sous-secteur de l'électricité (en cours de modification avec le projet de code de l'électricité)

Décret n° 2017-1411 abrogeant le décret n°2011-160 du 28 janvier 2011 ; ce nouveau décret interdit l'importation, la production et la commercialisation des lampes à incandescence classique et promeut les lampes à économie d'énergie ;

Décret n°2017-1333 relatif au contrôle de conformité aux normes des installations électriques intérieures ;

Projet de décret sur l'audit énergétique obligatoire ;

Projet de décret sur l'étiquetage énergétique des équipements électrodomestiques ;

Projets d'arrêtés d'application du décret 2017-1411 sur l'éclairage ;

35 normes en place sur l'efficacité énergétique des équipements et 30 normes sur les bâtiments.

Source : Note de synthèse préparée par l'AME à la demande de auteurs du Rapport (Mars 2021)

Dans l'attente des révisions annoncés, le cadre juridique de la politique énergétique repose sur la Loi n° 83-04 du 28 janvier 1983 relative à l'utilisation rationnelle de l'énergie qui interpelle également le droit de la commande publique. Elle exige en particulier la publication *des normes de construction, d'installation, de fonctionnement et de rendement de certaines catégories d'appareils produisant, transformant ou utilisant de l'énergie, imposer aux constructeurs et aux utilisateurs, en vue de les obliger à se conformer aux normes, promouvoir la production, l'importation, le transport, la distribution, la commercialisation et la récupération des ressources énergétiques et la production ou l'importation d'équipements adaptés à l'utilisation de ces ressources, limiter la consommation abusive d'énergie.*

Par ailleurs, la loi n° 2010-21 du 20 décembre 2010 portant loi d'orientation sur les énergies renouvelables implique, d'ores et déjà, des exigences techniques particulières dans les contrats et marchés publics de travaux. Elle s'est efforcée d'instaurer un cadre incitatif adapté :

- à l'achat et à la rémunération de l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables ;
- à réduire l'utilisation des combustibles fossiles ;
- à favoriser tous les moyens de production, de stockage, de distribution et de consommation pour des besoins domestiques et industriels en milieu urbain tout comme en zone rurale ;
- à contribuer à l'amélioration de la sécurité d'approvisionnement en énergie et lutter contre les émissions de gaz à effet de serre.



Recommandations :

- **CMP : inclure le code de l'Energie et les règles sur la maîtrise de l'énergie dans les visas**
- **Mentionner dans les DTAO Travaux le respect des exigences de la maîtrise de l'énergie**

Tableau récapitulatif des principales sources d'obligations légales à considérer dans la commande publique responsable

Textes	Objet/Type de norme	Marchés de travaux	Marchés de fournitures	Marchés de service
Instruments internationaux				
Conventions de l'O.I.T.	Principes et Conventions internationales Droits humains, droit du travail, droit des enfants, droit des femmes	Marchés internationaux & nationaux	Marchés internationaux & nationaux	Marchés internationaux & nationaux
ZLECAF	Traité de commerce N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
CEDEAO	Normes techniques et de performance	Exécution	Exécution	
UEMOA	Directives obligatoires Normes techniques	Exécution Directives : étiquetage énergétiques -Efficacité énergétique	Exécution Directives : étiquetage énergétiques -Efficacité énergétique	
Normes/labels/standards internationaux	Exigences techniques à caractère social et environnemental	Exécution des marchés Spéc. Techniques	Exécution des marchés Spéc.. Techn.	Exécution des marchés Spécif. Techn.

Labels/ISO des Entreprises	Exigences techniques de capacités à caractère sociale et environnemental	Passation Critère de qualif.	Passation Critères de qualif.	Passation Critères de qualif.
Drôit National	Drôit national	Drôit national	Drôit national	Drôit national
Code de l'environnement + textes d'application + normes sénégalaise	Loi et Règlements Exigences environnementales Règles de l'EIES + PGES	EIES PGES		TDR des bureaux d'études des EIES
Drôit de la maîtrise de l'énergie (Projet) + textes d'application + normes sénégalaises	Loi et Règlements Exigences environnementales	Exécution Spéc.. Techniques	Spéc. Techniques	
Loi 20/12/2010 portant loi d'orientation sur les énergies renouvelables	Loi et Règlements Exigences environnementales	Exécution Spéc.. Techniques	Exécution	
Code de l'urbanisme + textes d'application + normes et labels	Loi et Règlements Exigences environnementales	Exécution Spéc.. Techniques		
Code de la construction + textes d'application + normes et labels	Loi et Règlements Exigences environnementales	Exécution Spéc.. Techniques		
Code de l'Assainissement	Loi et Règlements Exigences environnementales	Exécution Spéc.. Techniques		
Loi sur les PPP	Loi et Règlements	Passation et Exécution	Passation et Exécution	Passation et Exécution
Loi sur les PME 7/1/2020	Loi et Règlements Déf. des PME Déf. de la sous-traitance Marges de préférence Intégration du genre Obligations de la RSE	Passation Critères de qualification Exécution	Passation Critères de qualification Exécution	Passation Critères de qualification Exécution
Loi sur les Startups 6/1/2020	Loi et Règlements Marge de préférence : - Pour l'accès - Pour le groupement - Pour la sous-traitance	Passation : Régime préférentiel pour les startups labellisées	Passation : Régime préférentiel pour les startups labellisées	Passation : Régime préférentiel pour les startups labellisées
Textes sur l'Artisanat Création du Mobilier National (2015)	Loi et Règlements Définition de l'Artisan + marge de préférence	Passation – mesures préférentielles – Exécution	Passation – mesures préférentielles – Exécution	Passation – mesures préférentielles – Exécution
Code du travail		Exécution	Exécution	Exécution
Loi d'orientation sur la formation professionnelle et technique	Loi et Règlements	Exécution	Exécution	Exécution
Loi d'orientation sociale 6/07/2010 Promotion et la protection des droits des personnes handicapées	Loi et Règlements Protections- Accès à l'emploi Obligations d'accessibilité	Passation – mesures préférentielles – Exécution	Passation – mesures préférentielles - Exécution	Passation – mesures préférentielles – Exécution
Loi d'orientation sur l'Economie sociale et solidaire (15/06/2021)	Loi et Règlements Catégories des acteurs de l'ESS concernées – agrément « ESS » Mesures de discrimination positive Définition. de la RSE	Passation : mesures préférentielles Exécution : obligation de formation	Passation : mesures préférentielles Exécution Exécution : obligation de formation	Passation : mesures préférentielles Exécution Exécution : obligation de formation

Conclusion du chapitre 2 : Ce chapitre a permis de présenter les principaux pans du droit sénégalais qui interagissent particulièrement avec le domaine des marchés publics. On y retrouve notamment le droit des PME, les droits des groupes vulnérables, le droit de l'environnement, le droit de l'urbanisme, ou encore le droit de la maîtrise de l'énergie pour le volet environnemental. En sortant de la vision « en silo » de la réglementation des marchés publics, cette approche permet d'identifier les exigences croisées issues de la législation sénégalaise qui doivent être respectées dans la commande publique afin de rendre celle-ci plus responsable et plus conforme au droit existant. L'effet transversal des APD oblige à revisiter la réglementation des marchés publics aussi bien lors de la passation que de l'exécution des contrats, afin d'assurer le respect de ces obligations légales issues du droit sénégalais. A cette condition, les achats publics sénégalais deviendront pleinement « responsables ».

Résultats d'enquêtes conduites entre février et mars 2021 : obstacles et opportunités des APD au Sénégal

Outre les constats portant sur le cadre juridique des APD, le 1^{er} rapport remis en avril 2021 s'était également intéressé aux attentes des acteurs publics et privés en matière d'APD. Ceci devait permettre de tirer des solutions pertinentes dans le contexte sénégalais.

Malgré le nombre limité de réponses obtenues aux questionnaires adressés aux Autorités contractantes, au secteur privé, au secteur associatif et aux Administrations, les résultats en combinaison avec les entretiens et les échanges informels ont permis de tirer certaines conclusions d'ordre général.

- **La plupart des répondants ont conscience de l'importance du développement durable et de l'opportunité d'une prise en compte des relatifs enjeux de durabilité dans la commande publique**, comme la protection de l'environnement et l'inclusion des groupes vulnérables.
- **Des initiatives en matière environnementale et sociale ont été déjà adoptées dans les dernières années**, mais un élargissement de l'étendue de ces initiatives et une consolidation de l'existant au sein de la commande publique semblent être nécessaires.
- **Certains obstacles ont été identifiés**, tels que l'incertitude sur la possibilité d'acheter de manière durable (obstacle juridique et réglementaire), les difficultés d'accès des PME à la commande publique, les difficultés à recenser les PME existantes et les PME dirigées par des femmes, la faible collecte d'information, ou encore la faible connaissance/compétence en matière d'APD. La catégorie particulière des PME à direction féminine, dites PME « féminines », comme le Rapport Carapaces propose de les nommer, ne bénéficie d'aucune reconnaissance et encore moins de mesures préférentielles.
- **Enfin, il a été jugé souhaitable de prévoir un appui institutionnel et de fournir un programme de formation et de renforcement des capacités à l'égard des acheteurs publics, du secteur privé et du secteur associatif afin de réaliser pleinement les APD.**

PARTIE II PROPOSITIONS de REVISION du CADRE JURIDIQUE des MARCHES PUBLICS

Résumé :

Le constat de la 1^{ère} partie a démontré que la politique des APD au Sénégal s'appuie sur un cadre juridique perfectible dans ses trois niveaux : Code des marchés publics, textes d'application et Documents type d'appel d'offres (DTAO). Cette 2^{ème} partie a pour objet de suggérer des propositions de modification de ces textes afin d'engager un déploiement opérationnel et efficace des APD. A cet effet, 3 propositions sont avancées :

- **Chapitre 3 : IMPOSER LES PRINCIPES D'UNE COMMANDE PUBLIQUE RESPONSABLE dans tous les achats publics, sans exception.** Il s'agit de rappeler, au besoin par la mise en oeuvre de nouvelles sanctions, que tout achat public doit se plier aux exigences légales déjà en vigueur en matière de respect du droit du travail, respect du genre, respect des droits des personnes victimes de handicap, respect de l'environnement, respect des règles sur l'efficacité énergétique, respect ou conformité aux normes en vigueur notamment en matière d'hygiène, santé et sécurité. Ce rapport propose une mesure symbolique : **l'adoption d'une nouvelle Charte de l'Ethique et de la commande publique responsable**, afin d'aboutir à des achats publics pleinement « responsables » et exemplaires où les Acheteurs publics et les entreprises s'efforcent de se conformer aux obligations sociales et environnementales existantes.
- **Chapitre 4 : INTRODUIRE DES OPTIONS APD A TOUS LES STADES DE LA COMMANDE PUBLIQUE** afin d'offrir aux Autorités Contractantes la possibilité d'y recourir volontairement pour favoriser les impacts positifs de leurs achats. A cet effet, et dans un objectif de rationalisation et de cohérence du droit applicable, le rapport suggère déjà de consolider dans le droit de la commande publique les dispositions propices aux APD issues d'autres pans du droit sénégalais (par ex. les mesures de protection de l'environnement, les dispositions en faveur des PME, de l'artisanat, ou des startups). Il propose également, en phase avec les réformes récentes des PPP et de l'économie sociale et solidaire, d'introduire des dispositions de modernisation du cadre juridique de la commande publique qui répondent aux enjeux du développement local.
- **Chapitre 5 : REVISER LES DTAO POUR REFLETER L'HARMONISATION ET LA MODERNISATION NECESSAIRES AUX APD.** Pour assurer la mise en œuvre effective des APD au Sénégal, il faut accompagner les AC et les entreprises en révisant les DTAO. D'abord en actualisant les DTAO existants afin de généraliser les obligations de la commande publique responsable puis en proposant une nouvelle série de « DTAO APD » contenant des mesures APD au service des AC qui recherchent un impact réel de leurs marchés publics.

CHAPITRE 3 : IMPOSER UNE COMMANDE PUBLIQUE RESPONSABLE

Pour asseoir une commande publique efficace et exemplaire, la réforme du cadre juridique doit être l'occasion de réaffirmer que les parties, privées et publiques, doivent se conformer aux obligations éthiques, sociales et environnementales qui existent d'ores et déjà dans le droit positif. On peut parler à cet égard d'un devoir de conformité, ou de « compliance », qui pèse sur les entreprises et qui permet d'établir le caractère « responsable » des achats publics. Ces éléments seront rappelés à travers la formulation de nouveaux principes fondamentaux de la commande publique (Section 1), une nouvelle Charte de l'Ethique et de la commande publique responsable qui est proposée à l'adoption (Section 2) ainsi que dans des visas plus explicites mentionnés en tête du Décret révisé portant Code des marchés publics (Section 3).

Section 1 Compléter les principes de la commande publique

Enrichir et actualiser la liste des principes fondamentaux de la commande publique. Le droit Sénégalais connaît une large diversité de contrats publics qui visent à satisfaire les besoins du secteur public, et tous ces contrats doivent obéir aux principes de la commande publique. Ce Rapport a constaté (1ère partie) que l'énoncé des « principes fondamentaux applicables aux achats » à l'article 24 du COA différait de ceux mentionnés par la loi du 21 février 2021 relative aux PPP, et qu'ils ne reflétaient pas la possibilité de prendre en compte les APD. Par conséquent, il est proposé d'enrichir la liste des principes fondamentaux de la commande publique fixé par le CMP en application du COA modifié. Cette nouvelle rédaction se doit d'être conforme au COA actuel ainsi qu'aux autres lois qui seront citées dans les visas, dont certaines ont davantage une portée environnementale ou sociale. A ce stade, la révision du COA, texte de nature législative, n'est pas proposée mais il conviendra de la considérer ultérieurement afin d'harmoniser et de rationaliser l'ensemble des principes et des règles applicables aux contrats de la commande publique sénégalaise.

La prise en compte du principe de proportionnalité, qui ne figure pas aujourd'hui dans les principes de la commande publique au Sénégal, permettrait d'adapter et d'optimiser la configuration des appels d'offres aux caractéristiques du Marché, des différents secteurs économiques, des produits et des fournisseurs. Suivant ce principe de proportionnalité, le choix de la forme des marchés, le choix des procédures d'attribution, le choix des critères de qualification ou des critères d'évaluation doivent être calibrés en fonction du but ou des buts poursuivi(s) par l'AC. Le principe de proportionnalité est donc un fil conducteur pertinent pour identifier, pour chaque futur contrat, les modalités APD à appliquer et comment les évaluer. Les CPM seront ainsi invitées à s'aligner sur les priorités sociales et environnementales nationales et de concevoir ainsi une approche stratégique de leurs achats.

Affirmer la nécessité de prendre en compte le développement durable dans les contrats de la commande publique. L'enrichissement des principes fondamentaux de la commande publique dans les législations modernes témoigne de l'attention portée par les décideurs publics à ce levier fondamental des politiques publiques. A l'instar du décret tunisien n° 2014-1039 du 13 mars 2014, dans son Art. 6, la rédaction doit être simple et fluide : *- Les marchés publics sont régis par les principes suivants : - la concurrence - la liberté d'accès à la commande publique, - l'égalité devant la commande publique - la transparence et l'intégrité des procédures. Les marchés publics obéissent également aux règles de bonne gouvernance et tiennent compte des exigences du développement durable. Ces principes et règles sont consacrés à travers le suivi de procédures claires permettant d'assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne gestion des deniers publics.* Un tel article initial permet d'établir clairement les principes directeurs qui ont une vocation universelle, c'est-à-dire à s'appliquer à tous les contrats régis par le CMP.

Enfin, le respect des droits de l'homme est aussi rappelé par le droit des PPP. La récente loi n° 2021-23 du 2 mars 2021 relative aux contrats de PPP reconnaît, parmi les principes fondamentaux mis en exergue dans son article 4 : « *h) le respect de la réglementation en matière environnementale, sociale et du travail ; et i) la responsabilité des opérateurs économiques de respecter les droits de l'homme* ». Par ces énoncés, le législateur rappelle aux acteurs des PPP qu'ils doivent se conformer aux législations existantes en matière environnementale, sociale, du travail et plus largement du respect des droits de l'homme. On doit souligner l'importance de ce rappel, alors que dans la pratique de nombreux manquements à ces règles sont régulièrement dénoncés. C'est donc un comportement conforme aux règles existantes qui

est requis par la loi et qu'il conviendra de reprendre en miroir dans le CMP. **La Charte envisagée infra permettra de rappeler aux candidats ce devoir de conformité des entreprises.**

Section 2 Prévoir une Charte de l'Ethique et de la commande publique responsable obligatoire dans tous les contrats de la commande publique

Exiger la signature d'une Charte par les candidats renforce le poids symbolique et juridique des obligations qu'elle énonce⁸³. En tant qu'obligations générales, elles ne sont pas propres au marché à conclure : il s'agit de l'engagement des candidats à respecter le droit du travail (notamment à travers le rappel des Conventions O.I.T.⁸⁴), le droit de l'environnement, les droits sociaux et humains, dont la protection des minorités ou encore les règles d'éthique et d'intégrité. Cette technique du renvoi à des lois et principes existants, qui a déjà été suivie au Sénégal pour les questions éthiques, peut tout à fait être reconduite et élargie pour proclamer l'obligation de respecter les prescriptions sociales et environnementales issues du droit existant. **La Charte permettra de rappeler les obligations essentielles imposées par le droit Sénégalais à toute entreprise, a fortiori une entreprise liée par contrat avec une entité publique.** Au-delà de la Charte qui sera systématiquement présente dans les DAO, des obligations plus détaillées pourront figurer le cas échéant dans les documents d'appels d'offres en fonction de l'objet et des montants des contrats. Par exemple, en lien avec les Conventions O.I.T., une clause du futur contrat pourra insister sur l'égalité des genres dans l'exécution du contrat.

Le rappel de la législation en vigueur, et plus particulièrement des obligations qui intéressent directement les conditions de passation et d'exécution des contrats, doit être réalisé de manière à la fois synthétique et symbolique pour renforcer l'efficacité et l'exemplarité de la commande publique. On peut faire appel à la technique du renvoi, qui consiste à rappeler aux parties au contrat qu'elles doivent se conformer à toutes les lois en vigueur, et à celles qui ont un objet social et environnemental en particulier. Cette technique a été utilisée pour la préparation des chartes et autres engagements anti-corruption qui se sont développés ces dernières années un peu partout dans le monde, et au Sénégal également avec la Charte de Transparence et d'éthique en matière de marchés publics adoptée à la suite du Décret n°2005-576 du 22/06/05. Cette rédaction a d'ailleurs préfiguré la Directive n°02/2012/CM/UEMOA du 28 septembre 2012, relative à l'éthique et à la déontologie dans les marchés publics et les DSP.

La Charte deviendra ainsi le socle minimal fixant les obligations éthiques, sociales et environnementales à respecter dans tout contrat public aussi bien pour la partie privée que pour la partie publique. Dès lors que la Charte est soumise à la signature d'un engagement souscrit par le candidat, elle se trouve incorporée au sein des documents contractuels, et elle acquiert ainsi force obligatoire lors de l'exécution du contrat. Tout manquement constituera non seulement une violation de l'obligation légale ainsi rappelée (par ex polluer un site lors de la réalisation de travaux) mais il constituera également une faute contractuelle. Constaté par l'AC, ce manquement pourra faire l'objet d'une sanction contractuelle, qui pourra aller jusqu'à la résiliation (voir infra les remarques sur les sanctions contractuelles) et/ou constituer un motif de suspension, par le Comité de Règlement des Différends de l'ARCOP ex-ARMP, de la participation aux MP. La Charte aura la vertu de rappeler les exigences minimales à l'attention de la partie publique. Bien que l'AC ne soit pas signataire de la Charte, l'engagement du futur Titulaire à la respecter implique pour la partie publique d'exercer un devoir de vigilance durant l'exécution du contrat. En renforçant le devoir de vigilance et de surveillance de la personne publique, cette charte contribuera à bâtir une commande publique responsable et exemplaire.

La Charte portant sur la commande publique responsable doit incorporer la Charte existante relative à la Transparence et l'Ethique. Cette solution présente plusieurs avantages : elle permettra d'éviter d'alourdir inutilement la procédure d'appel d'offres en ajoutant un nouveau document à signer par les candidats et un document unique soulignera la complémentarité des objectifs poursuivis. C'est pourquoi ce Rapport préconise l'adoption d'une seule et unique Charte, intitulée « Charte de l'Ethique et de la commande publique responsable ». Bien que l'« intégrité » ait un champ d'application plus vaste par rapport à l'« éthique », le terme « éthique » étant déjà entré dans le vocabulaire sénégalais de la commande publique, il est préférable de marquer une continuité en conservant la formulation d'usage.

⁸³ Cette idée avait été proposée par le Guide des APD, 2019, p. 39, sous la forme d'une Charte circonscrite à l'environnement, à la suite « d'un entretien avec un acteur de la place ».

⁸⁴ Les principales Conventions de l'OIT ont été ratifiées par le Sénégal en vertu de la loi n° 62-46 du 13 juin 1962 autorisant le Président de la République à ratifier les conventions internationales du travail n° 10, 12, 19, 52, 81, 89, 96, 99, 100, 101 et 102. Elles figurent en annexe à ce rapport.

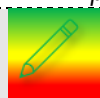
La Charte continuera à être exigée dans toutes les procédures de passation où la Charte de l’Ethique et de la Transparence l’était déjà. Son application sera même étendue à la faveur de la révision du CMP, puisque les Dossiers type des Demandes de Renseignement de Prix (DRP) pour les marchés de travaux et de fournitures devront désormais inclure la lettre d’engagement à la Charte⁸⁵. Seuls les cas de tout petits marchés non écrits ne permettra pas de la soumettre à signature. Cette diffusion large est importante pour rappeler aux candidats, et donc au futur titulaire du marché ainsi qu’à ses sous-traitants, les obligations d’intégrité et de conformité qui s’imposent en général à toute entreprise qui participe à la commande publique.

Dans le cas des marchés de travaux importants, soumis au DTAO Grands Travaux, la nouvelle Charte et le PGES ont vocation à se compléter : les deux documents ont une valeur contractuelle. La Charte rappelle les obligations générales de respect de la réglementation, tandis que le PGES a pour objet de préciser les mesures spécifiques à prendre lors du déroulé du marché concerné. Ces mesures devront être établies à partir des constats actés par le certificat à l’issue de l’EIES exigé dans les grandes opérations en application du Code de l’Environnement.

Ce rappel général des normes et règles à respecter fait écho au concept de la RSE, puisque les entreprises qui s’y soumettent s’engagent à agir de manière « responsable » en se conformant aux obligations éthiques, sociales et environnementales qui s’imposent dans leur secteur professionnel. Certaines entreprises candidates qui signeront la Charte auront peut-être, au nom de leur RSE, leurs propres chartes déontologiques ou labels /normes ISO qui leur ajouteront des obligations et des règles internes de fonctionnement (codes d’éthique, formations du personnel etc..). Surtout, ce principe d’un engagement juridique des entreprises d’avoir un comportement « responsable », c’est-à-dire conforme au droit en vigueur, ne doit pas être confondu avec d’éventuels programmes dits de « RSE » que les entreprises pourraient avoir à financer durant l’exécution du contrat ou suivant les termes de conventions annexes de partenariat conclues avec des collectivités locales bénéficiaires.

Par décret, et en remplacement du décret n° 2005-576 du 22 juin 2005 portant Charte de transparence et d’éthique en matière de marchés publics, il convient d’adopter une « Charte de l’éthique et de la commande publique responsable » qui sera soumise à la signature de tous les candidats aux contrats, marchés publics et PPP inclus. Aux manquements énumérés par l’acte d’engagement à la Charte sur la Transparence et l’Ethique actuel, il est proposé d’ajouter les éléments suivants (ajoutés en italiques ci-dessous) :

- « activités corruptrices à l’égard des agents publics en charge de la passation du marché ;
- manœuvres frauduleuses en vue de l’obtention du marché ;
- ententes illégales ;
- renoncement injustifié à l’exécution du marché si notre soumission est acceptée ; et,
- défaillance par rapport *au droit applicable* et aux engagements que nous aurons souscrits, *en particulier* :
 - *violation des règles d’hygiène, de santé et de sécurité ;*
 - *violation de la réglementation sociale et du droit travail tels qu’ils figurent dans les Convention de l’O.I.T. ratifiées par le Sénégal (notamment non-respect de l’égalité homme-femme, interdiction du travail des enfants) ;*
 - *violation de la réglementation environnementale (notamment : dégradation de l’environnement, pollutions, nuisances sonores, utilisation de substances toxiques, atteinte à la biodiversité et aux ressources naturelles, déforestation) ;*
 - *violation de la réglementation sur l’efficacité énergétique ;*
 - *violation des obligations socio-économiques (atteinte aux droits des populations locales, atteinte au patrimoine naturel, culturel, architectural et touristique). »*



Recommandations :

- **CMP remplacer les références à la Charte sur l’Ethique et la Transparence ;**
- **Adopter un nouveau décret portant Charte de l’Ethique et de la commande publique responsable**

⁸⁵ Comme relevé dans la 2^{ème} partie, la référence à la Charte et l’engagement corollaire sont actuellement absents des Dossiers-types de Demande de renseignement de prix (DRP) travaux et Fournitures.

Section 3 Toiletter les Visas du décret portant Code des marchés publics

En tête du décret, les Visas mentionnent les textes de référence qui ont été consultés. Doivent être visés les textes qui servent de fondement juridique aux dispositions du projet de décret ainsi que les textes qui y sont cités ou mentionnés. Les visas doivent mettre en évidence les textes dont le projet de décret doit faire application ou qu'il doit transposer. Il peut aussi être utile de viser un texte qui détermine le champ d'application d'une disposition du projet, par exemple un texte qui définit les catégories de personnes pour lesquelles le projet crée des droits ou des obligations (par ex., la notion de PME ou de Startups). Les visas doivent aussi citer le CMP de 2014 puisque le projet va l'abroger partiellement.

Afin de procéder à la consolidation des dispositions qui ont été adoptées dans des textes extérieurs à la commande publique, il conviendra d'ajouter aux références :

- La Directive n° 04/2012/CM/UEMOA relative à l'éthique et à la déontologie dans les marchés publics et les délégations de service public au sein de l'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine
- La Directive n° 02/2014/CM/UEMOA relative à la réglementation de la maîtrise d'ouvrage public déléguée au sein de l'Union Economique Monétaire Ouest Africaine

Au titre des actes législatifs :

Les codes :

- Le Code de l'Environnement,
- Le Code de la Construction
- Le Code de l'Urbanisme

Les Lois :

- la Loi d'orientation sociale n° 2010-15 du 6 juillet 2010 sur la promotion et la protection des droits des personnes handicapées ;
- La loi d'orientation n° 2020-02 du 7 janvier 2020 relative aux PME,
- La loi du 6 janvier 2020 relative aux Startups
- La loi n° 2021-23 du 2 mars 2021 relative aux contrats de PPP et son décret d'application (infra)
- La loi du 15 juin 2021 relative à l'Economie sociale et solidaire

Sous réserve de leur adoption :

- La loi relative aux économies d'énergie et à l'efficacité énergétique ;

Au titre des actes réglementaires :

Il convient d'inclure également les références manquantes, notamment les décrets de 2007 relatifs à l'ARMP (désormais remplacé par le Décret du 21 octobre 2021 relatif à l'ARCOP) et la DCMP, ainsi que celui relatif à l'application de la loi PPP (15 novembre 2021). Enfin, il faudra, au moment de l'adoption, actualiser les références aux textes d'application dont la modification est également proposée par ce Rapport : *Le décret n° 2021-... du.... portant Charte de l'Ethique et de la commande publique responsable.*

Section 4 Compléter les définitions incluses dans le CMP

§1 Remarques préliminaires

Langage inclusif : Le langage employé dans les propositions de révision s'efforcera d'être le plus inclusif possible⁸⁶, dans le CMP tout comme les modifications des DTAO qui suivront. Il s'agit d'éviter de rédiger exclusivement au masculin et d'indiquer la version féminine lorsqu'elle est possible afin de sensibiliser les différents acteurs à la politique d'égalité de genre et de promotion des femmes dans la commande publique.

⁸⁶ Voir la suggestion du Rapport Carapaces sur le genre dans les MP, Fév. 2021, p. 42

Application différée. Afin d'organiser un changement progressif du droit applicable, il pourrait être envisagé de prévoir une entrée en vigueur différée de certaines nouvelles dispositions du CMP révisé. Ce délai serait en cohérence avec la durée du plan national d'action pour les achats publics durables et permet de laisser le temps aux services de l'État d'élaborer des outils et méthodes destinés à accompagner les Acheteurs et les entreprises dans l'appropriation de ces nouvelles obligations. Les articles concernés seront expressément signalés à cet effet à la fin du (projet de) décret portant CMP.

Un autre point à préciser en amont du CMP révisé, concerne la prise en compte de l'économie circulaire dans la commande publique. L'achat circulaire, qui permet le réemploi de produits déjà disponibles éventuellement transformés ou recyclés peut être pris en compte dès la formulation du besoin et la rédaction du cahier des charges dans les marchés de fournitures. Cette clarification va permettre également de préciser le rôle du **cycle de vie**, notion qui figure dans les définitions du CMP de 2014⁸⁷ mais sans avoir été ensuite reprise dans les articles ni dans les textes d'application du CMP. A la définition initiale qui n'est guère opérationnelle et n'a jamais été reprise dans les DTAO : « *Le CCV est une méthode d'évaluation des coûts totaux du groupe de produits ou du service. Il tient compte de tous les coûts d'achat, du coût total des opérations de nettoyage, de maintenance, de fonctionnement, man d'œuvre, et de tous les coûts d'élimination des déchets produits. L'utilisation de cette méthode dans les procédures de passation de marchés publics écologiques peut aider à déterminer les coûts les plus bas lors de l'évaluation des offres. Ces coûts doivent être ajoutés au prix de vente pour obtenir une estimation complète du CCV* », nous proposons d'ajouter l'explication suivante qui laissera aux AC la possibilité d'utiliser ou non ce mode de calcul des coûts et donc des prix : *la prise en compte de l'ensemble des coûts liés au cycle de vie complet du produit permet de faire apparaître tous les coûts de fabrication, d'usage et de disparition du produit (recyclage, transformation, traitement des déchets).*

§2 Introduire une définition de la RSE

Il s'agit d'introduire une définition : *La Responsabilité sociétale des entreprises (RSE) désigne l'ensemble des actions mises en place par une entreprise afin de se conformer au respect de la réglementation existante, notamment à ses obligations éthiques, sociales et environnementales, à l'égard de son personnel et de l'impact de ses activités sur son environnement. Une telle définition s'inscrit dans la logique de celle portée loi du 15 juin 2021 relative à l'économie sociale et solidaire : « actions d'un organisme pour assumer la responsabilité de l'impact de ses actions sur la société et l'environnement pour autant que ces actions soient cohérentes avec les intérêts de la société et du développement durable et fondées sur un comportement éthique et le respect de la loi en vigueur ».*

Les deux concepts RSE et APD partagent un socle commun, mais ils divergent dans leur mise en œuvre et dans leurs destinataires. Les objectifs finaux sont les mêmes puisqu'il s'agit d'atteindre la réalisation des ODD, dans leurs aspects environnementaux, sociaux ou économiques. D'ailleurs les 6 principes de l'ISO 26 000, qui constitue le standard international de la RSE, englobent parfaitement les 17 Objectifs de Développement Durable (ODD). Ces deux concepts sont intimement liés. Pour les entreprises, la RSE consiste à adopter un comportement « responsable » c'est-à-dire à dire une exécution conforme aux droits existants (sociaux, humains, éthiques, et environnementaux), à ce titre l'entreprise peut s'efforcer de prévenir les impacts négatifs de leurs activités en engageant des activités auprès des populations concernées. Dans le cadre des APD, cela correspond au respect des règles applicables en participant à une « commande publique responsable ». Mais les APD vont plus loin puisqu'ils s'efforcent d'avoir un véritable impact positif sur le développement durable. Du côté du secteur privé, cette dimension se retrouve dans les entreprises que l'on appelle parfois « entreprises à impact », qui vont financer des actions en cherchant à agir positivement dans la société, sur la base du volontariat.

Malgré la proximité des notions, il faut éviter toute confusion entre les APD et la RSE. La politique de RSE suivie par une entreprise peut, par exemple, constituer un critère de qualification. Lors de la phase de vérification des capacités (juridiques, financières matérielles et environnementales) des entreprises, un critère portant sur la RSE peut permettre de vérifier que l'entreprise candidate s'est déjà dotée en interne d'une charte ou d'un code d'éthique pour prévenir la corruption, qu'elle a une politique d'égalité de traitement salariale, qu'elle a mis en place un système de collecte de ses déchets, qu'elle vérifie également le respect des obligations RSE de ses sous-traitants etc... **En revanche, la politique de RSE des entreprises candidates ne peut pas constituer un critère d'attribution en tant que tel au moment de l'examen des offres déposées.** Si l'entreprise peut volontairement contribuer à son insertion dans la communauté, grâce à des actions

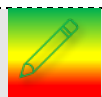
⁸⁷ « Cycle de vie : l'ensemble des étapes, successives que peut connaître un produit, à savoir la recherche et le développement, le développement industriel, la production, la réparation, la modernisation, la modification, l'entretien et la maintenance, la logistique, la formation, les essais, le retrait et l'élimination ».

d'améliorations sociales et locales (telles que la construction ou réfection de salles de classes ou d'autres installations publiques), le marché ne peut pas confier à l'entreprise des tâches précises extérieures à l'objet du contrat. Un critère d'attribution relatif aux actions RSE de l'entreprise serait illégal, dans la mesure où le critère d'attribution doit être seulement lié à l'objet du marché précisément en cause ou à ses conditions d'exécution⁸⁸. Il est donc possible d'adopter des critères plus précis qui évaluent les aspects environnementaux, ou/et sociaux des offres ou exiger des conditions d'exécution qui veillent (par exemple) à lutter contre les discriminations ou à assurer des conditions décentes de travail. De surcroît ces tâches accessoires ne doivent pas donner lieu à des coûts répercutés sur le prix final du contrat. D'ailleurs, l'article 15 du CMP 2014, l'interdit : « 1. Les prix des marchés sont réputés couvrir toutes les dépenses qui sont la conséquence nécessaire et directe des travaux, de la fourniture ou du service, y compris tous droits, impôts et taxes applicables, sauf lorsqu'ils sont expressément exclus du prix du marché ou font l'objet d'une exonération. Les prix sont réputés assurer un bénéfice au titulaire. » Il n'est donc pas possible d'imputer à l'entreprise en cours d'exécution des dépenses hors marché qui ne sont ni nécessaires ni directement liés aux travaux du marché, au nom de la « RSE »⁸⁹.

CHAPITRE 4 : INTRODUIRE DES OPTIONS APD A TOUS LES STADES DE LA COMMANDE PUBLIQUE

Les propositions de révision du cadre juridique qui sont suggérées infra s'appuient sur des exemples étrangers pertinents ainsi que sur les constats à propos de l'état du droit sénégalais des APD et de sa pratique.

La révision du CMP de 2014 doit être l'occasion de faciliter le déploiement des APD tout au long du déroulé des contrats. En raison de leur malléabilité et adaptabilité, les 3 piliers des APD peuvent être pris en compte lors des différents stades de l'opération contractuelle, depuis la préparation jusqu'aux contrôles des conditions d'exécution du contrat, en passant par le choix du type de contrat, la définition des critères de sélection ou d'attribution. A cet effet, les principes énoncés en tête du CMP doivent être complétés afin d'énoncer expressément la possibilité de prendre en compte les objectifs du développement durable.



Recommandation :

- CMP : Ajouter un alinéa sur les principes à l'article 1er

Les marchés publics sont régis par les principes suivants : la concurrence, la liberté d'accès et l'égalité devant la commande publique, la transparence et l'intégrité des procédures. Dans leur attribution, les personnes désignées à l'article 2 obéissent également aux règles de bonne gouvernance, d'efficacité et de bonne gestion des deniers publics. Elles tiennent compte des exigences et des objectifs du développement durable dans ses dimensions sociales, environnementales et économiques.

L'intégration des dimensions sociales, environnementales et économiques des APD restent optionnelle, sauf choix politique contraire, et l'AC devra déterminer si elle entend poursuivre une finalité de développement durable et comment elle compte l'introduire dans la procédure d'attribution à partir des options offertes par le CMP, ses textes d'application et les DTAO. En outre, les 3 piliers, comme on l'a vu dans la 1^{ère} partie sont indépendants, ce qui signifie qu'ils peuvent être déployés seuls ou combinés, par exemple en associant la finalité sociale et la finalité environnementale. Il conviendra de compléter la révision du CMP dans le guide explicatif des marchés publics à destination des AC tout en pensant à actualiser

⁸⁸ A titre d'exemple, la décision du Conseil d'Etat français : CE, 25 mai 2018, Nantes métropole, n° 417580 : un critère de sélection pondéré à hauteur de 15 % de la note totale et ayant pour objectif d'évaluer la politique générale des candidats en matière sociale est illégal et doit être annulée.

⁸⁹ A défaut de mention dans le marché public, la signature d'une convention de partenariat entre l'entreprise, l'Autorité contractante et un village bénéficiaire peut constituer une alternative juridique sécurisé pour accompagner un projet RSE.

les documents et manuels à destination du secteur privé, notamment le Guide du soumissionnaire – accès des PME à la commande publique de 2015.

Afin de faciliter les repères chronologiques de l'opération contractuelle, et de mieux situer quel type de mesure APD peut être insérée, la frise ci-dessous accompagnera les explications à suivre.



Section 1 Introduire les APD dans la phase de préparation en amont du contrat



La phase de préparation en amont du contrat regroupe les actions que doit mener l'AC en matière de collecte d'informations utiles pour la définition des besoins à satisfaire et l'élaboration des futurs contrats à dimension APD ainsi que les actions qu'elle devra conduire en matière de communication pour informer les citoyens de sa politique APD dans un processus inclusif et transparent.

§1 La définition des besoins en termes de développement durable doit entrer dans le CMP

En vue d'adresser un signal clair aux Acheteurs publics, il convient d'inclure la prise en compte des considérations environnementales, sociales et économiques dans la définition des besoins. La définition des besoins est une étape juridiquement obligatoire et essentielle pour assurer l'adéquation de la future prestation aux attentes de l'AC. La préoccupation de réaliser des APD doit apparaître clairement dès ce stade, en amont de la procédure d'attribution. Une telle préoccupation peut déjà être prise en compte à partir de la rédaction très générale de l'Article 5 § 1 du CMP 2014 consacré à : « *la nature et l'étendue des besoins à satisfaire* ». Ainsi les APD qui ont déjà été réalisés au Sénégal se sont appuyés sur une interprétation constructive de l'Article 5 § 1. Toutefois, et afin de mettre en avant la volonté de développer les APD au Sénégal, il serait opportun de modifier cette formulation pour inclure les objectifs de développement durable et leurs dimensions déclinées dans le champ de la commande publique. A cet effet la nouvelle rédaction suivante est proposée pour l'article 5 §1 :

« Avant tout Appel à la concurrence, consultation, DRP, ou négociation, l'Autorité contractante est tenue de déterminer aussi exactement que possible la nature et l'étendue des besoins à satisfaire en prenant notamment en compte les objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale. Les fournitures, services ou travaux qui font l'objet de marchés doivent répondre exclusivement à ces besoins ».

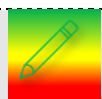
La définition actuelle des besoins ne répond pas à une méthodologie construite, malgré les indications déjà fournies dans le Guide d'Application de 2018 (point V.1. p. 59) pour calculer le montant d'une opération de travaux ou la définition d'une catégorie homogène de fournitures. Une méthodologie doit accompagner la personne publique afin de structurer la démarche de la définition des besoins : quel produit ou service est-il envisagé d'acquérir ? Quels sont les paramètres à considérer en termes de délais, de qualité, d'origine, de performance, de prix ? Comme le relève le Guide des APD (p. 27) : « *L'achat public durable implique la mise en place d'une véritable réflexion en amont de l'achat : (i) sur les conditions d'usages des produits en lien avec les services Acheteurs et les utilisateurs finaux ; et (ii) au regard de son coût global, c'est-à-dire l'ensemble des coûts inhérents à celui-ci : acquisition, utilisation et élimination, choisir un produit respectueux de l'environnement peut in fine être plus cher qu'un produit ordinaire à l'achat mais moins coûteux sur le long terme (ex : véhicules consommant moins de carburant, ampoules basse consommation).* »

Structurer la méthodologie de la définition des besoins doit ainsi permettre de passer en revue les solutions possibles, y compris l'option de ne pas acheter un bien. La décision de ne pas acheter peut se conformer à une politique générale relative à une catégorie de biens ou de services déterminés, à l'instar du décret n° 2020-474 du 19 février 2020 portant suspension de toute commande de véhicules administratifs par l'Etat, ses démembrements ainsi que les autres organismes publics⁹⁰. La décision de ne pas acheter peut également être prise par le service prescripteur en préférant, au titre d'une politique de développement durable, privilégier le réemploi d'un bien qu'il possède déjà (par exemple véhicule ou mobilier de bureau) ou dont une autre administration n'a plus l'usage⁹¹.

L'identification de marchés APD obligatoires. En outre, une liste de marchés obligatoirement verts (par exemple l'achat de produits moins polluants dans les marchés de fournitures de produits pour l'agriculture) ou à vocation sociale (le recours systématique à des artisans pour des fournitures de bureau en petite quantité) peut être définie par décret à la faveur des choix de politiques publiques.

Si la volonté de mener une politique d'APD a été clairement affichée par l'AC, par exemple à travers des consignes et des quotas, exprimés au moyen de pourcentages d'APD à atteindre dans le Plan annuel de passation de marchés (voir infra), la CPM va pouvoir conduire une réflexion à propos de la manière de décliner les objectifs de DD au moyen du futur contrat. Cela permettra d'enrichir la phase de préparation d'une réflexion préalable sur la possibilité de tenir compte de l'une ou de plusieurs de ces dimensions dans le futur marché. Cela devra conduire l'AC à vérifier l'opportunité de ce nouveau marché, du volume envisagé, des caractéristiques techniques attendues. Ainsi à engager une véritable réflexion qui, comme souligné par le PNAPD : « *Du point de vue de la bonne utilisation des deniers publics, il y a un intérêt évident à inscrire la politique d'achats publics durables au sein d'une démarche plus générale de responsabilité individuelle et collective.* » Derrière la reformulation, c'est également un changement de paradigme qui est opéré puisque la prise en compte du DD doit obliger à une analyse systématique

Enfin, si la décision de favoriser la durabilité est retenue, la CPM devra traduire cette orientation dans le déroulement de la procédure d'attribution du futur contrat : en retenant un objet spécifique, en définissant des critères particuliers de qualification des entreprises candidates, en rédigeant les spécifications techniques etc... Autant de choix qui doivent être appréciés et pesés lors de la définition des besoins et pour lesquelles les CPM doivent être outillées avec une méthodologie rigoureuse de la définition des besoins.



Recommandation :

- Pour la définition des besoins, ajouter au CMP la prise en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale.

Nouvelle rédaction proposée : Article 5 § 1 du CMP 2014 : « Avant tout Appel à la concurrence, consultation, DRP, ou négociation, l'Autorité contractante est tenue de déterminer aussi exactement que possible la nature et l'étendue des besoins à satisfaire en prenant notamment en compte les objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale. Les fournitures, services ou travaux qui font l'objet de marchés doivent répondre exclusivement à ces besoins ».

Travaux futurs :

***Rédiger une méthodologie de la définition des besoins à insérer dans le Guide explicatif du CMP. Cette méthodologie devra expliquer comment prendre en compte les objectifs de développement durable et réaliser des APD.**

§2 L'Acheteur public doit afficher sa politique APD

⁹⁰ Décret qui n'a pas été abrogé à ce jour.

⁹¹ Cette solution suppose l'existence d'un service des domaines qui collecte les données et conserve un inventaire rigoureux des biens meubles et immeubles acquis par les services de l'Etat.

L'AC doit inscrire ses choix contractuels dans les « politiques socioéconomiques de développement durable » prônées par l'Etat, c'est-à-dire les politiques environnementales, sociales, économiques et autres, dans le périmètre de ses compétences (entité nationale, locale ou sectorielle), tout en respectant les principes fondamentaux de la commande publique énoncés dans le CMP. L'AC doit se tenir constamment informée des besoins de la collectivité dans les 3 piliers du développement durable (économique, social et environnemental). Si la collectivité (par exemple une commune) souhaite profiter de ses futurs marchés publics pour satisfaire un objectif social identifié, tel que la réduction du chômage des jeunes, elle doit se rapprocher des Services et institutions en charge de ces questions (un Centre de formation par exemple) afin de repérer les jeunes en situation de décrochage scolaire. Ainsi la mise en place d'un dispositif de formation des Jeunes (ex : apprentissage) à travers l'exécution de marchés publics doit-il être anticipé. Pour aider les AC dans la programmation des actions APD, un outil d'évaluation des besoins et solutions APD pourrait être développé à la suite de ce Rapport.

Déjà, devant les attentes de la population et la volonté nationale de promouvoir le développement durable, les AC doivent veiller à la transparence de leurs actions en communiquant largement au sujet de leur politique APD, en particulier avant de lancer des projets importants à fort impact sur l'environnement, l'économie et le social. A cet effet, les AC sénégalaises devraient s'appuyer sur des outils à publier :

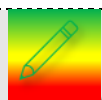
- un outil structurel : le plan annuel de passation de marchés qui devra annoncer la part que l'AC entend consacrer aux APD (en respectant un minimum de 20 %) ;
- un outil conjoncturel : l'études d'impact environnementale et sociale (EIES) avant des opérations d'envergure qui doit désormais suivre une procédure normalisée ;
- éventuellement une stratégie APD déclinée au niveau de l'entité concernée.

§2-1. La publication des objectifs annuels d'APD dans le Plan de passation de marchés

L'article 6 du CMP de 2014 prévoit l'obligation pour les AC de prévoir un plan annuel de passation de marchés auquel il convient d'ajouter désormais une dimension APD, en application de l'article Article 56 énonce : « 1. Les Autorités contractantes sont tenues de publier chaque année un avis général recensant les marchés publics dont les montants estimés atteignent les seuils mentionnés à l'article 53 du présent décret qu'elles prévoient de passer par Appel à la concurrence durant l'exercice budgétaire, sur la base du plan de passation des marchés établi conformément à l'article 6 du présent décret. » Ce plan est à la fois un outil de programmation budgétaire et un outil d'information pour les entreprises, notamment les PME qui peuvent ainsi prévoir un calendrier de candidatures. Lors de l'établissement du budget annuel des AC doivent évaluer le montant total des marchés de fournitures, par catégorie de produits, des marchés de services, par catégorie de services, et des marchés de travaux, qu'elles envisagent de passer au cours de l'année. Ce plan de passation est préparé suivant un modèle-type qui a été établi par l'ARMP (désormais ARCOP). Il doit être transmis à la DCMF au plus tard le 1er décembre de l'année précédant l'année budgétaire afin qu'elle vérifie la conformité du document et en assure la publication dans les 3 jours francs suivant. A cette occasion les AC pourraient ainsi définir la manière dont elles vont se conformer à leurs objectifs de développement durable.

Pour identifier précisément les besoins à satisfaire à l'occasion des futurs marchés, et parmi ces besoins ceux qui pourraient déboucher sur des APD, l'AC doit instaurer des mécanismes de veille et de collaboration, avec tous les services impliqués, qui doivent être prévus dans les Guides explicatifs. Dans le contexte du Sénégal, afin d'identifier au plus près les besoins (et les capacités) des populations sur le terrain, il serait avisé d'associer les ONG à la définition des besoins.

Les Acheteurs publics sénégalais les plus importants devraient être soumis à l'obligation de publier dans leur plan annuel de marchés une part minimale de 20 % consacrés aux APD (voir infra : appuis institutionnels).



Recommandations :

- **CMP un alinéa 2 est ajouté à l'article 6 du CMP relatif au plan annuel de passation de marchés.**
« Les Autorités contractantes qui ont un budget annuel supérieur à un montant défini par arrêté du Ministre de l'Economie et des Finances sont tenues de consacrer au moins 20 % de la valeur totale de leur marchés annuels aux achats publics durables ».

- **Texte d'application :**

Un nouveau formulaire modèle de plan de passation est établi pour tenir compte de la part du développement durable dans les marchés envisagés.

- **Travaux futurs :**



-Il serait souhaitable, dans le cadre de la préparation des futurs textes d'application sur les PPP, de prévoir une obligation similaire et à terme de prévoir un plan annuel unique de « commande publique », qui s'appuierait sur les objectifs nationaux déterminés dans le plan national (ou une Charte nationale)

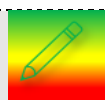
-Concevoir un outil d'évaluation des besoins APD à destination des AC

§3 La définition des besoins par l'AC devra prendre en compte les APD



§ 3-1 L'identification des besoins de développement durable lors de l'élaboration d'un marché précis

Une fois les objectifs annuels fixés à travers le plan annuel de passation de marchés et les contacts établis avec les institutions pertinentes, l'acheteur devra identifier dans lequel (ou lesquels) de ses marchés les modalités APD pourront être mobilisées. Dans l'hypothèse d'un marché HIMO ou à dimension sociale avec un dispositif de formation à insérer, l'AC devra concevoir un format de marché adapté : il faut que le marché soit suffisamment long (au moins six mois) pour que la formation soit utile aux apprenants. Cela peut constituer un marché spécifique ou un lot au sein d'un marché plus important (ex travaux horticoles autour de la création d'une infrastructure). Ensuite l'AC devra informer la structure de formation de son intention d'insérer une clause de formation dans le marché en préparation. La structure aura ainsi le temps de rechercher puis de proposer un profil de jeune à l'entreprise remportera le marché.



Recommandation :

Des conseils sur le « sourcing » ou la connaissance de l'Offre sur le Marché, figurent dans le Chapitre 7 sur les appuis institutionnels

Travaux futurs : Ces outils n'appellent pas de dispositions particulières dans le CMP mais ils devront faire l'objet d'explications incluses dans un nouveau Guide explicatif

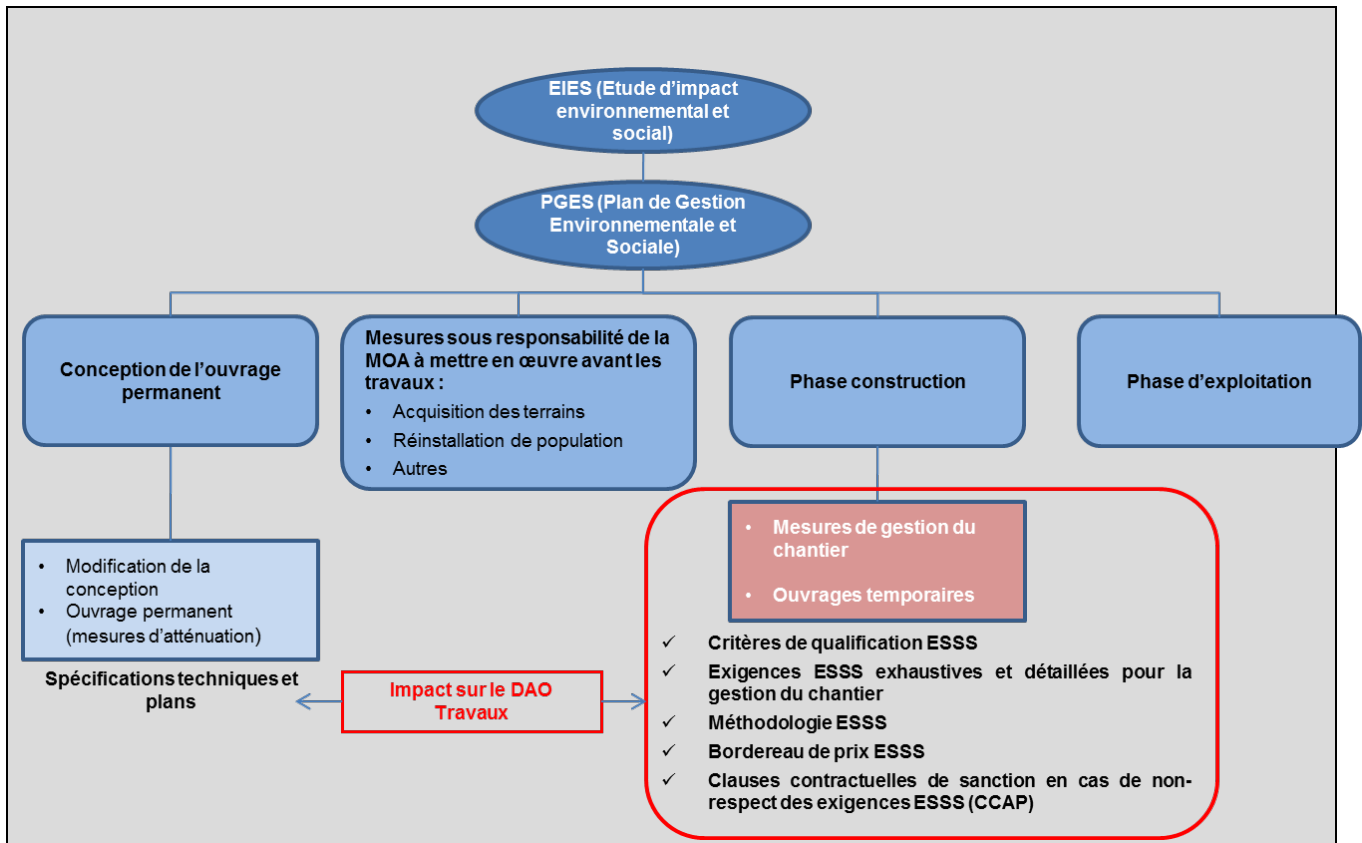
§ 3-2. Une étude d'impact environnemental et social renouvelée pour les grands projets

L'EIES, régie par le droit de l'environnement dans des conditions discutables (v. p...) doit être articulée avec le Plan de gestion environnemental et social (PGES) qui est une exigence du droit de la commande publique. Comme il a été relevé dans la 2^{ème} partie du Rapport, cette étape essentielle de la préparation en amont des grands projets, doit être formellement reprise dans les conditions d'exécution du contrat. Par conséquent, la révision du CMP doit préciser qu'il y aura lieu pour le candidat de fournir éventuellement un PGES parmi les documents d'appel d'offres lorsque le projet a été précédé d'une EIES ou à défaut une fois le contrat attribué. Une disposition similaire devra figurer dans les DTAO concernés. Elle permettra de détailler plus avant le contenu du PGES. Les mesures à prendre en compte dans le PGES peuvent être de deux types :

- les mesures d'atténuation qui conduisent à une modification de la conception de l'ouvrage permanent et qui induisent une modification des spécifications techniques et des plans de l'ouvrage permanent ;

- les mesures et précautions à prendre dans le cadre de la gestion du Chantier et de l'exécution du contrat. On doit y ajouter le plan de gestion des déchets. Ces mesures peuvent également être compilées dans le DAO au sein des Spécifications Environnementales, Sociales, Santé et Sécurité (ESSS).

A cet égard, le schéma proposé par l'AFD (DTAO Travaux AFD 2019) permet de résumer l'articulation entre, l'EIES qui est régie par le droit de l'environnement, et le PGES qui relève du droit de la commande publique :



Recommandations :



- Dans le CMP,

-définir le Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES) : document exigé dans les marchés de travaux importants ayant un impact sur leur entourage (social et environnemental). Il est inclus dans le DAO et doit reprendre les conclusions de l'Etude d'Impact Environnemental et Social (EIES) lorsque celle-ci a été réalisée en application de la réglementation issue du Code de l'Environnement.

-Mentionner le PGES parmi les DTAO des marchés de travaux.

A l'article 58 b) les pièces constitutives du futur marché, notamment projet, date de soumission, Cahier des prescriptions spéciales, Cahier des clauses administratives générales, Cahier des clauses techniques générales, autres pièces requises en fonction de l'objet du marché, telles que le Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES dans les marchés qui ont été précédés d'une Etude d'Impact Environnementale et sociale ;

Travaux futurs :

-Modifier le Code de l'environnement afin de prévoir une Etude d'Impact Environnemental et Social avant la réalisation de projets ou programmes d'envergure, qu'ils soient ensuite réalisés par des marchés de travaux ou des PPP. Les nouvelles dispositions devront également prévoir un mécanisme de financement autonome de l'EIES.

Section 2 Choisir le type de contrat qui encourage les APD



Une fois définie en tant qu'objectif à suivre lors de l'opération contractuelle à venir, la prise en compte de la durabilité peut passer par plusieurs vecteurs qui doivent être considérés lors de la phase de préparation et de « calibrage » du marché : au moment de la définition de l'objet du marché, de la forme du marché, des considérations spécifiques pour favoriser les achats innovants. Ce sont autant de nouvelles modalités qui commandent des révisions des textes de la commande publique.

§ 1 L'objet du marché « APD » à distinguer des marchés intégrant des mesures APD

L'objet du futur marché, qu'il s'inscrive dans le cadre d'un marché de travaux, de fournitures ou de services, est arrêté à la faveur de la réflexion sur les besoins. Mais cette étape peut amener la CPM à considérer que l'objet du contrat lui-même peut correspondre à un des buts des APD, par exemple un marché « environnemental » ou « écologique », tel qu'un marché de fourniture de produits « bios » pour un marché d'achats de semences agricoles ou un service de restauration collective dans les établissements scolaires. L'objet explicitement écologique du marché est à distinguer des exigences environnementales qui peuvent figurer dans les spécifications techniques, les obligations de performance, ou les conditions d'exécution d'un marché « ordinaire ».

Autre exemple, le marché peut être qualifié de « social » car il aura pour vocation à faire travailler du personnel chômeur ou victime de handicap. Un marché « d'insertion » pourra viser l'emploi de Jeunes sans aucune formation. Pour accompagner les AC dans cette voie, il conviendra de rédiger une méthodologie à suivre lors de la définition des besoins, notamment dans le cadre du Guide actualisé d'application du CMP.

Contrats de maintenance

Programmer des marchés de maintenance pour garantir la durabilité des infrastructures existantes participe d'une politique de développement durable et de bonne gestion des deniers publics. Pourtant, le Sénégal fait face à un problème récurrent, celui de l'absence ou de l'insuffisance de la maintenance qui conduit à l'obsolescence accélérée des installations et anéantit le bénéfice des investissements réalisés. Elle oblige à reconstruire et à recommencer inlassablement les mêmes investissements (infrastructures de remplacement) sans réels impacts bénéfiques sur le long terme pour la situation socio-économique. L'absence de maintenance et d'entretien des installations aboutissent à détourner des financements qui auraient pu être sinon consacrés à des infrastructures nouvelles contribuant à améliorer les services aux populations. Lors de l'inauguration des nouveaux locaux de l'hôpital Fann en décembre 2020, le Président Macky Sall a souligné l'importance de cette préoccupation : « *il faut que la question de la maintenance de nos infrastructures soit une priorité* ». Relevant que le budget du ministère de la santé était de 216 milliards de FCfa, il a exigé de « *prévoir 4 ou 5 milliards pour la maintenance des infrastructures* »⁹².

La nouvelle réglementation pourrait prévoir un pourcentage minimum de marchés de maintenance à inscrire chaque année dans le plan de passation de l'AC. La politique d'APD offre une solution aux besoins de maintenance et d'entretiens des installations exploitées en incitant les AC à intégrer un financement pour la maintenance dans leur prévisions budgétaires, ainsi que dans leur plan annuel de marchés. Assurer l'entretien régulier des bâtiments et installations dont elle a la charge doit être une préoccupation systématique de l'AC, à retrouver également dans les clauses et conditions d'exécution des contrats de construction, y compris pour la formation des personnels chargés de la maintenance (voir *infra*).

⁹² Le Soleil, 30 déc. 2020.

§ 2 Promouvoir les innovations qui servent les préoccupations du développement durable

§ 2-1 Développer les achats innovants

Alors que les découvertes technologiques se multiplient, notamment dans le domaine de la protection de l'environnement, le droit de la commande publique doit pouvoir accueillir ces innovations en s'appuyant d'une part sur un dispositif en amont d'accompagnement des startups, et d'autre part en offrant des procédures adaptées à des achats qui présentent des risques particuliers d'incertitude. Si le CMP de 2014 a défini la « Recherche & développement : ensemble d'activités regroupant la recherche fondamentale, la recherche appliquée et le développement expérimental, ce dernier pouvant comprendre la réalisation de démonstrateurs », peu d'articles et encore moins de mesures d'application ont permis d'accompagner la R&D par la commande publique. Il n'existe pas de catégorie dédiée au « marché innovant » mais seulement une procédure d'AO restreint suivant l'article 73 qui énonce : « sont susceptibles de faire l'objet d'AO restreints, b. Les marchés de travaux, fournitures ou services qui ne sont exécutés qu'à titre de recherches, d'essais, d'expérimentation ou de mise au point », tandis que l'article 75, uniquement relatif à l'AO avec concours, s'intéresse à la question de la propriété des brevets futurs⁹³. Ces dispositifs, insuffisants, ne permettent pas de mobiliser la commande publique pour faire émerger des produits ou services innovants.

§ 2-2 Faciliter les variantes

Le terme de variante correspond à une modification des spécifications techniques de la solution de base, tout en satisfaisant le besoin conformément au cahier des charges. Il sert en fait à désigner : - les variantes à l'initiative des soumissionnaires, définies par la jurisprudence française comme « des modifications, à l'initiative des candidats, de spécifications prévues dans la solution de base décrite dans les documents de la consultation » ; - les variantes imposées par les Acheteurs, qui peuvent définir précisément ou non la variante attendue (ex : éléments techniques sur lesquels doit porter la variante).

Pour mémoire, les variantes se distinguent des prestations supplémentaires éventuelles (PSE) et des options :

Variante	PSE	Option
•Peut être à l'initiative du candidat ou de l'acheteur. •Correspond à une modification des spécifications techniques de la solution de base.	•A l'initiative de l'acheteur uniquement •Correspond à des prestations (en lien avec l'objet du marché), qui peuvent être commandées ou non à la signature du contrat. •S'ajoute à la solution de base sans s'y substituer.	•A l'initiative de l'acheteur uniquement •Correspond à des prestations susceptibles de s'ajouter, sans remise en concurrence si prévues dans le marché initial (principalement : marchés dits "similaires", tranches optionnelles).

A propos de l'intérêt des variantes, la Direction française des affaires juridiques relève : « Les variantes permettent, d'une part, aux entreprises de faire valoir leur savoir-faire et leur capacité d'innovation et, d'autre part, aux administrations d'optimiser la réponse à leurs besoins par des procédés alternatifs plus performants, qui n'ont pas nécessairement été envisagés au départ (en particulier dans les domaines évolutifs). La variante prend tout son sens lorsque l'acheteur n'a pas été en mesure de réaliser un sourcing approfondi ou qu'il a rédigé un cahier des charges très précis prescrivant une solution particulière, au lieu de décrire seulement le résultat à atteindre. Elle est d'autant plus utile que l'acheteur dispose de moyens contraints en amont de la procédure et constitue un « filet de sécurité » pour permettre aux entreprises de présenter la réponse la plus adaptée au besoin ».

- La possibilité de présenter des variantes peut être un moyen efficace d'intégrer la protection de l'environnement au stade des spécifications techniques, sans que l'acheteur ait nécessairement à spécifier de manière précise ses

⁹³ « La Personne responsable du marché se réserve le droit de faire exécuter tout ou partie des projets en achetant à l'amiable ou après expertise une licence d'utilisation pour son propre usage des brevets, dessins ou modèles qu'ils contiennent. Toutefois, le programme du concours pourra, après avis de la Direction chargée du contrôle des marchés publics, prévoir au profit de l'auteur du projet que ce programme indiquera soit une option pour l'exécution du projet ou pour les premières commandes, soit une redevance sur les objets fabriqués en utilisant la licence, soit une indemnité en tenant lieu. »

exigences en la matière. Par exemple, au moyen d'une variante, l'entreprise pourrait proposer des solutions bas-carbone, des techniques de valorisation des déchets ou des process d'économie circulaire.

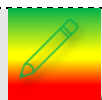
- Ainsi, l'acheteur peut préciser qu'il est disposé à accueillir des offres répondant à certaines variantes plus écologiques, par exemple, sur la teneur en substances dangereuses des produits proposés.

De fait, le Guide des APD 2020 retient également cette approche (p. 36) : « Lorsque le critère d'attribution est celui de l'offre « économiquement la plus avantageuse », les Autorités contractantes peuvent demander aux soumissionnaires de proposer des « variantes ». Les variantes consistent en des offres distinctes de la soumission principale proposant des alternatives aux prescriptions techniques ou aux conditions juridiques ou financières d'un projet de base, décrit dans le cahier des charges ».

Or, le CMP sénégalais, dans sa rédaction actuelle, limite la possibilité de recourir aux variantes puisque l'art. 59 al. 3 énonce : « *Seule la variante du soumissionnaire ayant proposé l'offre de base évaluée conforme et moins-disante pourra être prise en considération* ». Et l'Article 62 ajoute : « *Il peut être prévu que les candidats présentent une offre comportant des variantes par rapport aux spécifications des cahiers des charges qui ne sont pas désignées comme des exigences minimales à respecter. Une variante ne peut être proposée qu'avec une offre de base. Les exigences minimales à respecter ainsi que les modalités de soumission des variantes doivent être indiquées dans l'Avis d'Appel à la concurrence ainsi que dans le dossier d'Appel à la concurrence* ». Dans la pratique, les variantes ne sont quasiment jamais demandées ni acceptées.

Si on veut encourager les variantes, leur traitement va obliger à une méthode d'analyse différente des solutions techniques : Il est donc nécessaire de prévoir à l'avance le traitement des variantes dans les documents de la consultation : - en autorisant explicitement les variantes quelle que soit la procédure, ce qui nécessite cependant de disposer des moyens et les compétences permettant une évaluation rigoureuse des différentes solutions ; - en déterminant les exigences minimales ou les éléments du cahier des charges qu'elles devront respecter, et les modalités de leur présentation ; - en retenant des critères (et sous-critères) d'attribution identiques, qui permettront d'évaluer à la fois les offres de base et les variantes ; - inciter les entreprises à décrire et justifier avec précision l'amélioration technique ou l'économie générée(s) par la variante par rapport à la solution de base. Afin de classer les offres, la seule méthode consiste à examiner chaque proposition indépendamment des autres, qu'il s'agisse d'offres de base ou de variantes, pour dresser ensuite un classement unique, selon la note obtenue. Les offres de base et les variantes sont ainsi jugées en une seule fois sur la base des mêmes critères et selon les mêmes modalités. Enfin, le respect, par la personne publique, de la plus stricte confidentialité est essentiel pour que les prestataires puissent, en confiance, présenter leurs solutions les plus innovantes dans une consultation.

Sur des marchés plus exploratoires, par exemple pour développer des techniques ou des produits écologiques, il est recommandé de faciliter la proposition de variantes qui vont attirer davantage les PME innovantes, notamment les Startups, en leur évitant d'avoir à préparer 2 offres. Exiger systématiquement le dépôt d'une offre de base conduit également à alourdir le travail de l'acheteur. Afin d'encourager le recours aux APD innovants, le droit des marchés publics sénégalais pourrait accepter les variantes à caractère APD, même déposées seules (sauf exigence contraire explicite), sans une offre conforme à la solution de base. En revanche, l'AC pourra imposer des spécifications techniques et des clauses de performance qui vont guider la formulation des offres. Cette solution restant difficile à mettre en pratique, elle n'est pas reprise pour l'instant dans les recommandations formulées par ce rapport.



Recommandations :

- **CMP, art 62 : (ajouter un alinéa 2) : Afin d'encourager les solutions environnementales ou sociales innovantes, l'Autorité contractante peut, lorsque le critère d'attribution est celui de l'offre « économiquement la plus avantageuse », demander aux candidats de proposer une variante répondant à des exigences techniques minimales pour laquelle ils devront justifier avec précision l'amélioration technique ou l'économie générée par la variante par rapport à la solution de base.**

§ 3 Adapter la forme du marché aux modalités APD

§ 3-1 Le recours à l'allotissement

Il est prévu par l'article 8 du Code des Marchés publics 2014 et il doit être encouragé afin de faciliter la candidature des PME ou structures à vocation sociale ou éducative. L'allotissement est une technique primordiale pour encourager la participation directe des PME et TPE car (1) le volume des marchés est mieux adapté à leurs capacités et (2) un certain nombre d'autres exigences vont se retrouver allégées telles que le montant des garanties bancaires, le montant des assurances et le volume de chiffre d'affaires qui seront requis. L'allotissement facilite ainsi le financement des PME candidates. Mais dans le CMP actuel, c'est une simple faculté offerte aux AC. D'autres pays ont fait le choix de rendre le recours à l'allotissement obligatoire, sauf exceptions. La Tunisie a notamment inscrit dans son décret de 2014 : « *L'acheteur public doit, lors de l'élaboration des cahiers des charges prendre en considération la capacité des entrepreneurs, des producteurs, des prestataires de services et des bureaux d'études nationaux et les objectifs du développement durable. L'allotissement des commandes est obligatoire lorsqu'il est de nature à favoriser la participation des entreprises nationales ou lorsqu'il est susceptible de présenter des avantages d'ordre technique, financier ou social. Les cahiers des charges précisent la nature et la masse de chaque lot (...)* ». Cette rédaction permet de laisser une marge d'appréciation des considérations APD. Une autre option, plus contraignante en termes d'allotissement, peut être recommandée dans le cadre du Sénégal : poser le principe du recours à l'allotissement mais laisser aux AC la possibilité de s'écarter de cette exigence en justifiant précisément le recours à un marché traditionnel ou même global.

§ 3-2 Les marchés à bons de commande

L'article 25 du CMP indique que si l'Autorité Contractante ne peut déterminer à l'avance le volume et le rythme des commandes de fournitures ou de services courants nécessaires à ses besoins, elle peut utiliser un marché à bons de commande ou un marché de clientèle. Ces marchés sont conclus pour une durée égale à un an, renouvelable par avenant, sans pouvoir dépasser 3 ans. L'utilisation des marchés à bons de commande doit être recommandée dans le Guide explicatif, puisque dans une perspective durable ils permettent d'éviter la surconsommation et le stockage des produits. Dans la même logique, les groupements de commandes peuvent également permettre d'optimiser les transports et les livraisons afin de réduire l'empreinte écologique mais aussi d'obtenir des prix plus intéressants.



Recommandations :

- Réviser l'article 8 du CMP, afin d'imposer le principe du recours à l'allotissement mais laisser aux AC la possibilité de justifier le recours à un marché traditionnel ou global en fonction des caractéristiques de l'opération envisagée.

Nouvel Article 8 : Dans la mesure du possible, les travaux, fournitures ou services peuvent doivent être repartis en lots donnant lieu chacun à un marché distinct. La division en lots permet de faciliter la candidature des petites et moyennes entreprises et des structures à vocation sociale. Ce choix ne doit pas avoir pour objet ou pour effet de soustraire les marchés aux règles qui leur sont normalement applicables en vertu du présent décret. Cependant, à condition de justifier son choix, l'Autorité contractante peut estimer que le marché unique ou global présente des avantages économiques, techniques ou financiers en fonction des caractéristiques de l'opération envisagée.

Travaux futurs :

**Insérer dans le Guide explicatif des incitations à utiliser les marchés à bons de commandes*

Section 3 Choisir la procédure qui encourage les APD



Il ne s'agit pas de revenir ici sur les conditions de recours à telle ou telle procédure mais d'expliquer comment les procédures de passation peuvent éventuellement permettre de favoriser les APD, notamment les DRP et d'introduire la notion de marchés réservés pour les acteurs de l'économie sociale et solidaire.

§ 1 Prévoir des marchés réservés à l'économie sociale et solidaire

L'opportunité d'introduire dans le CMP une notion de marchés réservés aux acteurs de l'économie sociale et solidaire mérite d'être explorée, à l'instar des solutions du SBA américain (le Small Business Act) en faveur des PME. Le marché réservé est un dispositif qui permet en effet de n'admettre que les candidatures appartenant à des catégories relativement homogènes. Si le dispositif des marchés réservés, parfois appelés *quotas*, porte *a priori* atteinte à la concurrence et au principe du libre accès à la commande publique, il s'agit d'un dispositif de discrimination positive qui peut être déployé à condition d'être encadré. Sa justification se fonde sur la réalité économique de structures à vocation sociale ou éducative qui emploient un nombre important de groupes vulnérables et qui ne peuvent remporter des marchés dans des conditions normales de concurrence, notamment en raison d'une productivité plus faible ou de délais d'exécution plus longs imposés par des employés plus fragiles ou en phase d'apprentissage. Dans un but social, le mécanisme des marchés réservés est plus avantageux que celui de la marge de préférence puisque, avec le marché réservé, la concurrence qui subsiste dans une forme allégée, ne réunit que des « entreprises sociales » ayant des caractéristiques similaires. Avec le mécanisme de la marge de préférence, les « entreprises sociales » se retrouvent face à des entreprises ordinaires et seuls les prix qu'elles proposent vont être artificiellement abaissés de manière limitée, alors qu'elles font face à des contraintes en matière sociale et des coûts spécifiques supplémentaires (aménagement des postes de travail, alternance formation/emploi pour les Jeunes, par ex). Le dispositif du marché réservé permet ainsi d'ajuster la commande publique et de viser un groupe social déterminé, identifié par l'AC dans l'avis d'appel à concurrence.

Ces marchés peuvent tout d'abord s'insérer dans le cadre juridique existant, en portant sur des objets très spécifiques et pour des montants sous des seuils modestes. Le Rapport de la FAO a notamment exploré la possibilité de prévoir de tels marchés de denrées alimentaires sous le seuil de 3 millions, puisque l'on constate des difficultés tenant, d'une part, au manque de connaissances et d'expérience des Autorités contractantes locales sur les questions contractuelles et, d'autre part, aux caractéristiques des petits producteurs qui ne peuvent s'engager que sur de petites quantités.

Par ailleurs, il existe désormais une tentative de structuration du secteur de l'économie sociale et solidaire (l'ESS) depuis l'adoption de la loi sur l'économie sociale et solidaire le 15 juin 2021. Aussi, le nouveau CMP pourrait-il déjà prévoir des marchés réservés aux « structures de l'économie sociale et solidaire » à définir dans le CMP et qui regrouperaient : les entreprises sociales, les groupements de type GIE, concept bien implanté au Sénégal, voire GIE de femmes fondé sur un critère de genre, et les sociétés coopératives d'ouvriers ou d'Artisans. Un nouvel article du CMP sur les marchés réservés pourrait renvoyer à un Arrêté la possibilité d'organiser des marchés réservés au profit des entreprises sociales ou des structures à vocation sociale et éducative.

Pour renforcer l'exigence sociale, les marchés réservés peuvent aussi être circonscrits aux structures de l'économie sociale et solidaire mais également aux PME, dès lors qu'elles emploient au moins 30 % de personnes victimes de handicap, ou 50 % de femmes ou 50 % de Jeunes non qualifiés. Etablir un seuil de pourcentage d'emplois des groupes vulnérables est en effet un standard international largement admis.



Recommandations :

- CMP : introduire la notion de marchés réservés
- CMP Art. 50, créer un nouvel alinéa pour les Marchés réservés : marché de travaux, de fournitures ou de services non intellectuels, d'un montant sous les seuils définis par arrêté ministériel, pour lequel les candidatures éligibles sont restreintes aux structures sociales et éducatives et de l'économie sociale et solidaire telles que les Associations, Coopératives ouvrières ou artisanales, GIE, et entreprises sociales, Artisans individuels.

Les marchés réservés peuvent également être ouverts aux structures de l'économie sociale et solidaire ou aux PME à conditions qu'elles emploient au moins 30 % de personnes victimes de handicap, ou 50 % de Jeunes non qualifiés ou 50 % de femmes.

§ 2 Les potentialités de la procédure de DRP

La DRP, relativement flexible, ouvrant la possibilité d'instaurer des préférences ou des marchés réservés, constitue un outil à privilégier pour favoriser les PME « locales », l'artisanat, et d'une manière générale l'accès à la commande publique des structures de l'économie sociale et solidaire. Le montant des marchés, la réduction des exigences formalistes par rapport aux appels d'offres, la diffusion de cette procédure dans les collectivités territoriales, en

font une procédure de choix pour satisfaire les objectifs du développement durable tout en encourageant la participation des plus modestes. Cependant, ces procédures DRP présentent également un certain nombre d'inconvénients : de nombreux seuils et des formalités différentes rendent le dispositif compliqué à saisir et à utiliser par les acteurs aussi bien publics que privés. Si on prend en compte les combinaisons entre les seuils, les types de marchés et les catégories d'AC, il existe 17 procédures de DRP. Alors que la diversité des procédures déployées répond au souci d'adapter les modalités de passation aux besoins des AC, celles-ci risquent d'éprouver des difficultés à déterminer la procédure optimale. Il faudrait ainsi flécher les DRP les plus adaptées en fonction des objectifs d'APD. Un accompagnement adapté doit leur être proposé non seulement à travers un Guide explicatif actualisé mais également auprès d'un « Guichet » de conseils à instaurer au sein du Ministère des collectivités territoriales (voir chapitre 7). Par ailleurs, seule la DRP à compétition ouverte peut faire l'objet d'une procédure de recours : la limitation du droit au recours ne trouve pas de justification si ce n'est celle des délais de passation puisque la possibilité du droit au recours s'accompagne d'une entrée en vigueur différée du marché. Il n'en reste pas moins que cette impossibilité d'exercer un recours dans les procédures des plus petits marchés peut alimenter une méfiance de la part des opérateurs privés, voire des dérives de la part des AC dans le choix des titulaires. Il serait souhaitable de lever ce verrou et d'ouvrir la possibilité du recours pour tous les marchés quel que soit leur montant afin de répondre aux principes de transparence et d'égalité de traitement qui justifient le droit au recours. Dans la pratique, le risque d'une multiplication des recours et d'une paralysie demeurent très hypothétiques.

§ 3 Prévoir des procédures dédiées pour l'achats de denrées alimentaires et de semences

Les procédures classiques d'achats publics ne sont pas adaptées aux particularismes des achats de produits vivants ou périssables. Des procédures spécifiques sont désormais mises en place dans de nombreux pays, suivant des modèles diversifiés, comme l'explique la FAO dans son Rapport de 2020 ⁹⁴. Si la proposition des marchés réservés est validée, ils pourront servir à l'achat auprès des petits producteurs locaux relevant des structures de l'économie sociale et solidaire (ex GIE, entreprises sociales) ou des petits accords-cadres pourraient également être envisagés à l'échelon local.

Rapport FAO 2020, p. 17 : *Au Brésil par exemple, une part des achats publics de produits alimentaires est réservée aux petits agriculteurs familiaux selon une méthode particulière qui déroge à la règle d'appel à la concurrence établie par la législation brésilienne sur la passation des marchés publics. Les fournisseurs éligibles ne sont pas tenus de soumettre une offre et d'être mis en concurrence sur la base du prix le plus bas et de la meilleure qualité. Au lieu de cela, les entités adjudicatrices lancent un appel d'offres public concernant l'achat de produits alimentaires qui définit les produits, les quantités, les exigences en termes de qualité et les conditions de livraison. Les fournisseurs intéressés qui répondent aux critères de l'agriculture familiale soumettent une proposition indiquant les produits et les quantités qu'ils souhaitent vendre aux institutions gouvernementales. Les prix sont fixés par le gouvernement et ils sont censés refléter les prix du marché. Les fournisseurs sont sélectionnés sur la base de la proximité géographique et de la qualité de leurs propositions.*

A l'heure actuelle, la FAO prépare un nouveau rapport ainsi qu'un DTAO pour les marchés alimentaires à destination de l'ARMP/ARCOP : le présent rapport soutient cette initiative et renvoie à ce travail pour définir une procédure adaptée et rapide pour l'achat de denrées alimentaires. Le présent rapport recommande également que cette nouvelle procédure et/ou ce nouveau marché soit étendu à l'achat de semences agricoles, en particulier biologiques, afin de respecter la saisonnalité de ces produits.

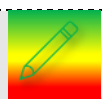
Ouvrir la possibilité de réduire le nombre minimal de participants en raison de l'objet écologique du marché. Adapter la procédure à la taille pertinente du Marché, faire face au nombre réduit de producteurs ou de prestataires capables de répondre à des marchés écologiques (notamment pour l'achats de produits alimentaires ou semences biologiques), ajuster les achats à la saisonnalité des produits, autant de contraintes qui doivent conduire l'AC à pouvoir opter pour des exigences allégées lors de l'achat de certains produits. Par exemple, réduire le nombre minimal de participants dans certaines procédures de DRP. Ainsi la DRP à compétition restreinte devrait pouvoir faire appel à 3 voire 2 candidats au lieu de 5 lors d'achats expressément biologiques qui devront être justifiés. Ceci permettrait de résoudre une difficulté importante rencontrée par l'ASRGMV dans l'achat de semences de reforestation. La nouvelle rédaction doit permettre à l'AC de pouvoir justifier qu'elle n'a pu trouver le nombre minimal requis, en raison de l'offre insuffisante dans le Secteur privé. Si le nombre

⁹⁴ FAO, Renforcer les politiques sectorielles pour améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition, Achats publics de produits alimentaires, 2020. <http://www.fao.org/3/ca2281fr/ca2281fr.pdf>

d'entreprises spécialisées dans les produits écologiques ou biologiques augmente dans les années à venir, ce qui est probable, cette exception pourra disparaître. Le Décret relatif aux procédures DRP devra être modifié en conséquence.

§ 4 Monter de petits accord-cadres locaux

Enfin, il pourrait être envisagé de développer les petits accords cadre et les achats centralisés de petits volumes étalés sur une certaine durée. Ce dispositif, que l'on pourrait, par exemple, retrouver dans le domaine d'achats de produits alimentaires (pour les cantines scolaires, les restaurants administratifs, les buffets événementiels), de semences (pour les redistributions auprès des agriculteurs, les programmes de reforestation ou de développement rural), ou de mobiliers scolaires ou de bureaux pour les Artisans permettrait de sélectionner de petits producteurs locaux qui seraient ainsi assurés d'obtenir au moins une commande dans les 4 années suivant la signature de l'accord-cadre. Au fur et à mesure de ses commandes, l'acheteur public pourra contacter les participants à l'accord cadre afin d'obtenir les fournitures recherchées en ajustant les quantités et la périodicité à ses besoins, tout en tenant compte des capacités de production des petits acteurs locaux. Le CMP envisage déjà les accords-cadres mais il faut en développer la pratique locale. Par ailleurs, l'article 26 du CMP actuel est restrictif puisqu'il exige de passer par la procédure lourde de l'appel à concurrence : *Article 26 : Les accords-cadres, les marchés à commande, les marchés de clientèle et les marchés à tranches conditionnelles ne peuvent être conclus que dans le cadre d'une procédure d'appel à la concurrence, dans les conditions fixées par le présent décret.* Sous certains seuils de marchés, ce dispositif pourrait être allégé afin de recourir à la DRP.



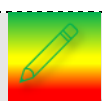
Recommandations :

- CMP – art. 78 : Prévoir une procédure spécifique et accélérée pour les achats de denrées alimentaires et les semences en raison de la saisonnalité des approvisionnements qui sera mise en œuvre par arrêté.
- CMP. Alléger les exigences des DRP (nombre minimum de candidats) pour les achats de produits biologiques (sur justification)
- CMP : Réviser l'article 26 afin de prévoir la possibilité d'accords-cadres après une DRP pour les petits marchés

§ 5 Le recours à la négociation

Puisque le recours à la procédure de gré et à gré demeure une tendance marquée au Sénégal, il convient d'en utiliser les aspects positifs dans le cadre d'une politique de promotion des APD. Négocier les offres ne doit pas se limiter au plan financier mais s'intéresser également au qualitatif. Cet angle de négociation pourra permettre d'exiger la prise en compte de critères de durabilité. La négociation peut en effet permettre d'envisager la satisfaction du besoin de façon fonctionnelle (certaines performances environnementales ou objectifs sociaux à atteindre), autoriser les variantes, laisser le temps nécessaire aux opérateurs pour formuler une réponse bien construite. La négociation peut également éviter de focaliser l'évaluation uniquement sur le critère du prix et laisser ainsi la place à des éléments qualitatifs.

Toutefois, lorsque la négociation est menée simultanément avec plusieurs entreprises, ou également dans un dialogue compétitif (comme il est envisagé dans la nouvelle loi sur les PPP du 2 mars 2021), il faut s'interdire tout changement de critères d'évaluation en cours de discussions. Une bonne préparation de la négociation doit permettre d'éviter ces écueils, notamment par le recours à la collégialité et à la traçabilité des échanges. Par exemple, la communication de la même liste de thématiques adressée à tous les candidats, l'utilisation de comptes rendus ou l'établissement d'une grille de négociation peuvent s'avérer utiles, afin de faciliter le suivi et le choix final de l'offre. Cette documentation permettra de prouver, le cas échéant, que l'ensemble des candidats a été invité à négocier sur les mêmes critères et dans des conditions identiques.



Recommandation :

- Travaux futurs : Guide méthodologique : enrichir les explications relatives aux différentes procédures au regard des APD y compris de la procédure négociée

Section 4 Rédiger l'avis d'appel à concurrence en intégrant les buts des APD



La rédaction de l'avis d'appel d'offres doit être l'occasion d'envoyer un signal fort en faveur des APD. Ainsi, dans la mesure du possible, l'Avis doit-il comporter des considérations à caractère social ou environnemental. L'objet APD identifié doit ainsi être annoncé dès la publication de l'avis de marché et apparaître dans la dénomination du marché : cette mention permet d'informer les entreprises, d'attirer l'attention de celles qui ont une vocation sociale, ou environnementale le cas échéant, et cela permet également d'envoyer un signal à la population concernant les engagements forts de l'Acheteur public en faveur d'un impact positif en matière de développement durable, (tels que « le marché écologique ») ou permettre de souligner les objectifs sociaux du marché, par exemple :

- Faire apparaître la dimension de genre ;
- Faire apparaître la dimension emploi (par ex, « marché HIMO », à Haute intensité de main d'œuvre) ;
- Faire apparaître la protection de l'environnement ;
- Faire apparaître la dimension locale.

Exemple de rédaction d'Avis pour un marché de travaux et d'insertion :

Afin de combattre le chômage des jeunes sans formation, le (nom de l'acheteur) souhaite mobiliser les entreprises dans le cadre de sa politique d'Achats responsables. Le marché public de travaux pour la réalisation de... est un marché d'insertion.

En application de l'article ... du CMP relatif aux marchés publics responsables, les candidats doivent obligatoirement proposer une action permettant la formation d'un ou plusieurs jeunes en situation de décrochage scolaire, de 16 à 25 ans, suivi(s) par la structure...du ministère chargé de l'Education nationale.

Une offre qui ne présenterait pas une action d'insertion et de formation sera considérée irrégulière.

§1 Publicité de l'Avis

L'Arrêté n° 00863 du 22.01.2015 détermine les procédures applicables aux marchés passés par les communes dont le budget annuel initial est inférieur à 300 millions « *Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, les Autorités contractantes peuvent, conformément aux dispositions du Code des Marchés publics, procéder à la publication des avis soit dans un journal quotidien, soit sur le portail des marchés publics du Sénégal, ou par voie radiophonique ou par affichage au niveau des gouvernances, des chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture et de tout autre lieu public situé sur le territoire de la collectivité locale concernée* ». D'une manière générale, il conviendrait d'encourager la diffusion des offres également sur la plateforme des APD (à créer – cf. chap. 7 Appuis institutionnels). **La diffusion du recours à des techniques dématérialisées, au moins en ce qui concerne la diffusion de l'appel d'offres et des DAO devraient progressivement monter en puissance.** La révision du CMP doit anticiper sur ces futures évolutions en offrant a possibilité aux AC de réduire les délais lorsque des procédures dématérialisées auront été utilisées.

Mais ceci ne nécessite pas de disposition dans le CMP.

§2 Délais de préparation des offres

L'utilisation des délais prévus par la réglementation reste souvent marquée par la rigidité. Dans la plupart des cas, les AC retiennent mécaniquement les délais minimaux comme base de référence, quel que soit l'achat concerné. Or le facteur temps est important dans la prise de décision des entreprises potentiellement candidates, soit parce que le délai peut paraître trop court ou bien trop long en fonction de plusieurs variables. **Il convient de prévoir des délais adaptés, en particulier si le marché envisagé doit permettre d'attirer davantage de PME et TPE.** L'avis doit ainsi prévoir des délais suffisamment longs pour laisser aux PME TPE qui n'ont pas de capacités importantes de préparer leurs offres.

Il faut distinguer les délais minimaux des délais nécessaires, surtout quand une solution innovante est espérée. Surtout, une meilleure anticipation des procédures, par exemple dans le cadre d'une programmation annuelle ou pluriannuelle des

achats, devrait permettre d'allonger progressivement les délais de réponse afin de stimuler la concurrence, de consolider la qualité des offres, mais aussi d'améliorer l'attractivité de la commande publique auprès des PME.

En fixant les délais de remise des offres, l'AC doit également tenir compte de l'objet de la prestation ou de la nature du produit. L'achat de produits naturels répond à des exigences particulières de rapidité souvent peu compatibles avec les délais prévus pour les fournitures ordinaires. Les discussions avec l'ASRGMV Rapportant les calendriers d'achats difficile à établir précisément à l'avance en raison des aléas climatiques ou le pourrissement des semences non collectées à temps, ont montré la nécessité d'adapter les délais pour les achats de denrées alimentaires ou les semences, *a fortiori* quand il s'agit d'achats auprès de petits producteurs locaux peu ou mal équipés pour la conservation desdits produits.



Recommandations :

- CMP et décret dédié : Prévoir des délais spécifiques pour l'achat de denrées alimentaires ou de semences agricoles

Travaux futurs :

Guide explicatif : La communication autour des APD doit être expliquée aux AC (rédaction des AO) – publicité en ligne

Expliquer l'intérêt de la modulation des délais

Section 5 Rédiger les documents du marché en intégrant les buts des APD



L'étape de la rédaction du DAO ouvre de multiples possibilités pour intégrer des éléments en faveur des APD, qu'il s'agisse de prévoir des clauses ou spécification techniques ciblées, ou le recours à des labels ou certifications techniques. Il appartiendra à l'AC de choisir comment les insérer en fonction des objectifs qui auront été arrêtés lors de la phase initiale de préparation. Ensuite, la rédaction même de l'avis d'appel d'offres doit également retenir l'attention en raison des informations qu'il va diffuser. Cependant, la conception des modalités de mise en œuvre des objectifs de développement durable peut paraître délicate pour l'AC. C'est pourquoi la rédaction des dispositions APD devrait être vérifiée par une ou des entités spécialisées dans ces domaines. Une assistance devrait être apportée à ce stade aux AC afin d'assurer la pertinence des critères, la qualité de la rédaction des documents d'appels d'offres et surtout l'acuité des exigences (voir *infra*, Chapitre 7 : l'appui institutionnel).

§ 1 L'insertion de spécifications techniques adaptées aux APD

Plusieurs types de spécifications techniques (ST) peuvent permettre d'introduire des considérations de durabilité dans les contrats de la commande publique. A ce titre, il faut distinguer les ST classiques des ST fonctionnelles, et indiquer qu'il existe désormais une nouvelle catégorie de ST dédiées : les Spécifications Environnementales, Sociales, Santé et Sécurité dites ESSS. Le CMP révisé doit prévoir des dispositions relatives à ces différents types de Spécifications techniques qui figureront dans les DTAO et leurs cahiers des clauses techniques.

La rédaction actuelle de l'article 7 du CMP relatifs aux normes et spécifications obligatoires laisse une grande marge d'appréciation aux AC (voir 2ème partie) qui peuvent les écarter a) si leur utilisation est impossible en l'absence de critères clairs ou de moyens techniques adaptés b) si elles imposent l'utilisation de produits ou de matières incompatibles avec les installations déjà utilisées par l'Autorité contractante ou entraînent des coûts disproportionnés ou des difficultés techniques disproportionnées. En revanche, on doit souligner que le recours à ces normes et spécifications est encouragé pour les projets innovants. Cependant la possibilité d'utiliser la procédure dérogatoire visée au a) ou b) devrait être encadrée au moins par l'exigence d'une justification fournie par l'Autorité contractante. En effet une telle marge de pouvoir

discrétionnaire peut sinon devenir préjudiciable dans les domaines qui sont déjà bien balisés par des normes sénégalaises ou communautaires obligatoires (par exemple en matière de normes de construction ou de maîtrise de l'énergie). Ainsi les AC devraient être au moins tenues de justifier par écrit le fait d'écarter le recours aux normes et spécifications techniques obligatoires.

De surcroît, les ST qui figurent dans les DAO peuvent servir à promouvoir les APD de différentes manières puisque les offres qui ne rempliront pas ces exigences seront rejetées car jugées non conformes. La préparation des différentes spécifications techniques offre l'opportunité d'intégrer des considérations relatives à l'économie, à l'innovation, à l'environnement, au domaine social ou à l'emploi. L'article 12 du CMP doit être complété pour inclure ces différentes formes de spécifications techniques.

Les spécifications techniques "ordinaires"

- Les ST d'interdiction : en proscrivant l'utilisation de certains produits ou techniques que la réglementation a désigné comme étant dangereux, ces ST permettent d'éliminer de la commande publique l'utilisation de substances ou de pratiques nuisibles à la santé des travailleurs et du public, et à l'environnement. En matière de commande publique, il faut ainsi tenir compte des lois existantes, (voir le chapitre 3 pour d'autres références)
 - La loi n°2020-04 du 8 janvier 2020 relative à la prévention et à la réduction de l'incidence sur l'environnement des produits plastiques
 - Le Décret n° 2017-1411 portant interdiction de l'importation et de la production et de la commercialisation au Sénégal des lampes à incandescence et promotion des lampes à économie d'énergie.
- Les ST prescriptives, exigeant certaines techniques lors de la réalisation de la prestation, par exemple au titre des normes de construction, telle que la prise en compte des besoins des personnes atteintes de handicap dans la conception et la réalisation des accès au bâtiment.
 - Pour des ST relatives aux conditions de travail : *Les fournitures (...) doivent être produites dans des conditions de travail décentes sur les propres sites de production du fournisseur ou de n'importe lequel de ses sous-traitants. Les conditions de travail décentes sont définies comme celles qui respectent les standards des conventions de l'Organisation Internationale du Travail (O.I.T.) et le droit du travail sénégalais mais également incluant le paiement d'un salaire minimum de.../heure et le respect de la durée légale de travail de x... heure par semaine avec au moins un jour de repos hebdomadaire.*
- Les ST imposant des exigences minimales : dans le registre de la protection de l'environnement, ces ST peuvent permettre d'exiger un niveau de qualité minimale pour les futures prestations, voire introduire des techniques plus protectrices de l'environnement (ex « *Toutes les offres doivent proposer la fourniture de produits qui contiennent au moins 60% de matériaux recyclés* »)
- L'AC doit éviter la formulation d'exigences techniques trop floues et préférer indiquer des éléments quantifiables ou mesurables (ex : temps de résistance au feu, degré de résistance à la chaleur, quantités produites...).

§1-1 Les spécifications techniques fonctionnelles ou de performance

Le recours aux spécifications fonctionnelles, plus récentes, peut permettre de faire émerger des solutions innovantes favorables à la durabilité. En effet, l'AC va définir non pas les moyens ou techniques à mettre en œuvre, mais plutôt le résultat et les performances attendus (par exemple le nombre de jeunes formés et certifiés ou les volumes de déchets recyclés). Si cela semble particulièrement approprié pour des services nouveaux et innovants, une telle formulation des besoins peut également stimuler la concurrence et renouveler les propositions concernant des produits et services traditionnels en prenant en compte des considérations environnementales et/ou sociales plus novatrices. Dans cette configuration, l'AC peut dévoiler aux candidats le montant prévisionnel de commandes afin d'éclairer les entreprises sur les solutions qu'elles pourront proposer. Elle peut également distinguer les prestations ou exigences prioritaires (ex : respect du calendrier de livraison) pour renseigner les candidats. Lorsque le DAO n'entre pas dans les détails techniques mais qu'il appartient aux candidats de proposer eux-mêmes des solutions pour atteindre des objectifs, les documents doivent lister précisément la réglementation à respecter, les difficultés liées au contexte de la future prestation.

§1-2 Les Spécifications Environnementales, Sociales, Santé et Sécurité (ESSS)

Les Spécifications Environnementales, Sociales, Santé et Sécurité (ESSS) au sein des DTAO permettent de formuler des exigences adaptées à l'objet du futur contrat qui s'imposeront au futur titulaire. On y retrouve, notamment, les obligations d'hygiène et de sécurité qui s'imposent depuis plusieurs années sur les chantiers mais auxquelles s'ajoutent

désormais la prévention médicale ou l'ergonomie des postes de travail, au titre de la santé, et qui s'étendent à tous les types de marchés.

Une mise en oeuvre progressive est nécessaire. Ces exigences techniques que le Titulaire devra suivre sous peine de commettre une faute contractuelle et d'encourir une sanction prévue au contrat (voir infra) résultent de réglementations sectorielles de plus en plus prescriptives et souvent internationales. Bien qu'au Sénégal, ces législations ne soient pas encore complètes au regard des standards internationaux (par ex en matière de collecte et recyclage des déchets), il existe cependant des secteurs déjà bien régulés ou en passe de l'être, notamment le secteur de la consommation énergétique. Pour tenir compte de l'état d'avancement de ces réglementations sectorielles et des techniques disponibles sur le territoire pour s'y conformer, il convient de recommander la mise en oeuvre progressive de ces exigences.

Par le biais des ESSS, l'AC peut ainsi amplifier l'impact vert des APD en prônant le recours à certaines techniques ou en interdisant les plus dangereuses ou les plus polluantes. Par exemple imposer des éclairages LED ou du bois durable (c'est-à-dire du bois cultivé de manière durable dans des plantations forestières soumises à des normes d'exploitation), exiger du papier produit sans utilisation de chlore (TCF), ou imposer dans un marché de cantines une nourriture issue de l'agriculture biologique (sans utilisation de pesticides et de fertilisants chimiques), l'utilisation d'électricité produite à partir de sources d'énergies renouvelables ou l'achat de véhicules prenant en compte les incidences énergétiques et environnementales. Au titre des ESSS, dans les marchés de maintenance, le DAO pourra imposer certains niveaux de consommation d'énergie qui seront calculés et incorporés dans le prix final, afin de créer une incitation à l'économie d'énergie.



Recommandation :

- CMP : revoir la rédaction de l'article 7 afin d'introduire l'obligation d'une justification par écrit en cas d'utilisation de la procédure dérogatoire ;
- CMP (art. 12) et DTAO : introduire le concept de Spécifications techniques fonctionnelles dans le cahier des charges (CCTG) ;
- CMP (art 12) et DTAO : introduire le concept de Spécifications Environnementales, Sociales, Santé et Sécurité pour une mise en œuvre progressive en fonction de l'avancement de la réglementation et des techniques disponibles.

§ 1-3 Le recours aux labels et eco-certifications dans les spécifications techniques

L'utilisation du référentiel des labels et certificats pour attester de certaines exigences techniques pourrait permettre de compléter utilement les spécifications techniques. Les labels vont alors servir de preuves. Cependant, il n'est pas possible d'exiger un label précis. En règle générale, toute mention restrictive dans les spécifications techniques est susceptible d'être jugée discriminatoire. Si l'Acheteur souhaite mentionner une norme spécifique ou un label particulier, il doit faire figurer la mention « ou équivalent » afin d'éviter toute restriction de la concurrence. Aussi l'AC peut-elle se contenter de reprendre les exigences techniques des labels, mais sans nommer ces derniers, dans l'appel public à concurrence.

Non seulement cette rédaction est moins restrictive mais elle laissera aussi aux entreprises locales le temps de s'adapter à ces exigences. A noter que le PNAPD a relevé un effort important en matière de normalisation avec la montée en puissance de « l'Association sénégalaise de normalisation » (ASN) qui veut développer la certification des produits et services avec la mise à niveau des auditeurs dans les Comités de certification de produits, dans le cadre du Projet d'appui institutionnel à la mobilisation des ressources et à l'attractivité des investissements⁹⁵. L'ASN est par exemple en charge d'un laboratoire avec l'Agence de la maîtrise des Energies afin de délivrer des labels et certificats sénégalais.

Enfin, on a relevé *supra* la nécessité d'encadrer le pouvoir discrétionnaire qui est reconnu aujourd'hui à l'AC par la rédaction de l'article 7 du CMP. Les AC ne devraient pas pouvoir écarter l'application de normes techniques internationales ou régionales (UEMOA).

⁹⁵ PAIMRAI de 280 millions FCFA. (Journal Le Soleil 29 déc 2020).

**Recommandation :**

- CMP : Ajouter à l'article 7 CMP 2014, la référence à des Labels et eco-labels certifiés

Si une AC souhaite mentionner une norme spécifique ou un label particulier, elle doit utiliser la mention « ou équivalent » afin d'éviter toute restriction de la concurrence.

§ 2 L'insertion des conditions d'exécution des APD

**Les conditions d'exécution sont définies par l'Acheteur et énoncées dans les pièces du marché (CCAP, CCTP, ...).**

Elles doivent refléter les préoccupations de durabilité dans les obligations contractuelles mais sans avoir d'effet discriminatoire à l'égard des candidats potentiels. Elles ne sont pas mentionnées dans les critères d'attribution qui permettent d'évaluer les offres. Ces conditions d'exécution doivent cependant rester liées à l'objet du marché. Elles figurent dans le DAO sous forme de clauses du contrat et elles doivent être rédigées de manière à permettre leur respect au moment de l'exécution par n'importe quelle entreprise : tous les opérateurs économiques doivent être capables d'y satisfaire qu'elles prévoient des obligations de moyens ou des obligations de performance. Les opérateurs sont donc tenus d'accepter ces conditions : s'ils les refusent ils s'exposent au rejet de leur offre, jugée non conforme. Et lors de l'exécution du contrat, le Titulaire qui les méconnaît s'expose à subir des sanctions pour manquement à ses obligations contractuelles.

La réglementation peut prévoir que certaines de ces considérations APD seront obligatoires. A ce propos, en France, l'article 35 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (loi « Climat et Résilience ») imposera aux autorités contractantes, à partir de 2026, de prévoir un critère de sélection prenant en compte les caractéristiques environnementales des offres et aux concessionnaires de décrire dans le rapport annuel communiqué à l'autorité concédante les mesures mises en œuvre pour garantir la protection de l'environnement et l'insertion par l'activité économique dans le cadre de l'exécution du contrat ⁹⁶.

Les clauses relatives aux conditions d'exécution du contrat :

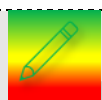
Il s'agit de conditions d'exécution du contrat qui s'imposent au cocontractant, titulaire du marché ainsi qu'à ses sous-traitants. Elles créent des obligations contractuelles qui doivent être respectées sous peine de sanction voire de résiliation du contrat.

- Ex : clause dite « de genre » : veiller à ce que, dans le cadre de l'exécution du marché, il soit toujours tenu compte de l'interdiction des discriminations fondées sur le genre et, à l'inverse, que des dispositions soient éventuellement prises pour tenir compte des différences entre les femmes et les hommes (ex : installations sanitaires réservées aux femmes sur un chantier) ;
- Ex : clauses sociales :
 - Clauses d'insertion
 - *L'objectif est de faire en sorte que l'entreprise attributaire du marché réserve une partie des heures générées par le marché à des personnes en difficulté d'insertion (groupes vulnérables). L'AC ne peut imposer à l'entreprise la façon dont celle-ci mettra en œuvre la clause sociale. L'entreprise est libre de choisir la méthode de recrutement la plus adaptée à son fonctionnement.*
 - Clause de formation des jeunes ou personnes éloignées de l'emploi (voir supra et dans les DTAO, infra)
 - Imposer l'embauche locale pour certains postes : par exemple un minimum de 20 % des postes créés seront destinés aux résidents du quartier puis aux zones alentours.
 - Obligation de reprise du personnel de l'ancien opérateur qui gèrera l'activité⁹⁷

⁹⁶ Le décret est en préparation.

⁹⁷ Une clause plus fréquente dans les PPP qui sont des contrats de longue durée avec des changements possibles affectant le partenaire en charge du contrat. Par exemple, Loi n°2018-40 du 05 juin 2018 portant régime des Contrats de Partenariat Public-Privé au NIGER, art 22.

- Ex : clauses environnementales :
 - Réduction des déchets : Les produits doivent être livrés en vrac et non par unité ; L'entreprise doit utiliser des conteneurs réutilisables pour la livraison des produits ; ou elle doit collecter les emballages ainsi que les produits en fin de vie qui ont été fournis dans le cadre du marché en vue de leur recyclage ou réutilisation ;
 - Réduction de la pollution : Tous les produits doivent porter des indicateurs de dosage pour éviter toute surconsommation ;
 - Les services devront être effectués conformément aux procédures et aux critères édictés dans le système de management environnemental (SME) de l'organisation.
- Ex : clauses « économiques » : Intégrer, parmi les clauses contractuelles, dans les cas où c'est un marché gagné par une grande entreprise, qu'une partie du marché (jusqu'à 30% ?)⁹⁸ sera sous-traitée à des structures nationales (PME, GIE, ONG locales, Associations).



Recommandations :

- CMP ajouter un article sur les clauses environnementales et sociales : « Les conditions d'exécution d'un marché ou d'un accord-cadre peuvent comporter des éléments à caractère social ou environnemental qui prennent en compte les objectifs de développement durable en conciliant développement économique, protection et mise en valeur de l'environnement et progrès social. Ces conditions d'exécution ne peuvent pas avoir d'effet discriminatoire à l'égard des candidats potentiels. Elles sont indiquées dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation. »

-Insérer ces clauses sociales et environnementales dans les DTAO CCAG et CCAP

Travaux futurs :

-Prévoir un accompagnement explicatif : « Clause sociale et environnementale : mode d'emploi »⁹⁹

§ 2-1 Les clauses de performance

Les clauses de performances sont introduites dans les contrats pour lesquels les résultats à atteindre en termes de durabilité constituent un facteur essentiel. Pour le volet environnemental, dans un marché de fournitures cela prendra la forme d'exigences en termes d'emballages (par exemple) ou de quantité de produits utilisés dans un marché de services de nettoyage (par exemple), ou comment les déchets et le recyclage seront assurés. Il est important que les clauses de performance demeurent liées à l'objet du contrat et qu'elles aient été mentionnées dans l'appel d'offres. La mise en place de telles clauses suppose que des objectifs de performance aient été préalablement établis et qu'ils soient quantifiables / mesurables sur une période de temps et un champ bien définis, en référence à une situation minimale.

Les clauses de performance peuvent être utiles pour inciter le titulaire à atteindre ou dépasser certains objectifs chiffrés.

Par exemple, des clauses incitatives¹⁰⁰ peuvent figurer dans un marché de collectes de déchets afin de promouvoir l'optimisation du tri en fonction du type de déchet. Plus les déchets à potentiel sont récupérés, plus les gains de la collectivité augmentent et donc la rémunération du titulaire augmentera. C'est un mécanisme de prime. A l'inverse, la clause peut également être pénalisante : si les quantités attendues ne sont pas atteintes, la rémunération du titulaire diminuera suivant une formule figurant dans la clause.

Ce principe peut aussi trouver à s'appliquer pour inciter à améliorer les délais d'exécution, à rechercher une meilleure qualité des prestations ou à réduire les coûts de production ou de fonctionnement. Les clauses incitatives permettent ainsi une répartition équitable entre les deux parties des bénéfices tirés d'une situation meilleure que le minimum prévu par le marché. Des écarts maximaux sont généralement prévus : - à 10 % du montant annuel du marché de l'année n pour les gains, - à 7 % du montant annuel du marché de l'année n pour les pertes. Ces clauses fonctionnent et attirent

<http://www.finances.gouv.ne/index.php/actualites/publications-du-ministere/file/412-loi-2018-40-du-05-juin-2018-portant-regime-des-contrats-de-partenariat-public-privé-cppp>

⁹⁸ Pour reprendre le pourcentage figurant dans la Directive 2005/5 de l'UEMOA.

⁹⁹ On verra plus loin comment le respect de ces clauses doit être suivi par l'équipe achats, dans le cadre du marché public.

¹⁰⁰ France, DAJ : Guide pratique pour faciliter l'accès des TPE/PME à la commande publique, 2019, https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/guide_de_bonnes_pratiques.pdf

les entreprises performantes si elles ne remettent pas en cause le principe du prix définitif et si elles ne constituent pas une part déterminante de la rémunération.

§ 2-2 Clauses de maintenance

La maintenance est, par définition, une activité essentielle pour assurer la durabilité des installations, notamment dans le secteur des infrastructures. L'AC devra déjà prévoir, dans son plan de passation, des marchés de maintenance pour assurer l'entretien régulier des bâtiments et installations dont elle a la charge (voir supra). La politique des APD peut également s'appuyer sur l'insertion de clauses de maintenance dans le DTAO qui obligent à l'entretien, la maintenance, la formation des personnels techniques qui seront employés sur le long terme, la mise à disposition de pièces détachées. Ces clauses peuvent figurer dans les PPP mais également dans les marchés publics de travaux, notamment de réalisation d'ouvrage clé en mains.



Recommandation :

- CMP : Insérer dans le CMP le principe de la clause de maintenance ;
- Insérer dans les DTAO des clauses relatives à la maintenance, à la formation des personnels techniques et à la mise à disposition de pièces détachées. – éventuellement une obligation de démontage et de remise en état après la fin du contrat (dans les PPP)

§ 2-3 Créer une prime d'innovation sociale ou environnementale

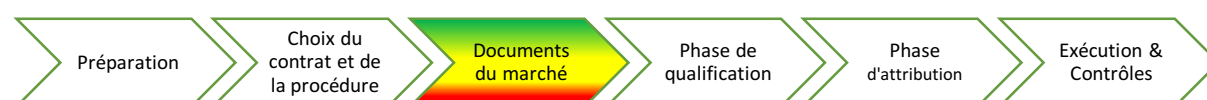
Alors qu'il existe déjà dans le droit des marchés publics sénégalais des primes pour inciter à l'exécution rapide des contrats conclus, (Article 137¹⁰¹ du CMP), il conviendrait d'ajouter un mécanisme de prime en cas d'innovation sociale et/ou environnementale lors de l'exécution. Cette prime ne serait pas accordée pour le simple respect des obligations contractuelles (ce qui relève seulement de la bonne exécution « normale ») mais lorsque le titulaire va au-delà des obligations contractuelles et légales. Par exemple, s'il propose durant l'exécution une nouvelle technique qui va économiser davantage d'émission de CO2 ou s'il embauche finalement plus de publics vulnérables que ce qui était exigé par le contrat initial. Il est suggéré que la décision sur le droit à obtenir la prime ne soit pas prise seulement par l'AC mais par le **Fonds pour la promotion des APD** (cf Chap. 7 Appuis institutionnels). Ce dernier pourrait également être chargé de payer la prime afin d'encourager les AC à faire part des bons résultats obtenus ou des innovations réalisées.



Recommandation :

- CMP, art 137 : créer une prime pour innovation sociale ou environnementale lors de l'exécution du contrat. *« Chaque fois que cela apparaît nécessaire à l'autorité contractante, des primes pour récompenser des innovations sociales ou environnementales intervenues lors de l'exécution peuvent être prévues dans les marchés. Avant la mise en paiement, la demande formulée par l'autorité contractante sera adressée aux Autorités en charge du Fonds pour la promotion des achats publics durables. »*

§ 3 L'insertion de conditions d'exécution favorables aux PME et petites structures



Le système juridique doit organiser des mesures adaptées qui vont viser des aspects complémentaires de la question de l'innovation, tout en facilitant la participation des PME : forme juridique des entreprises candidates (ex les

¹⁰¹ Art. 137 CMP 2014 : « : Chaque fois que cela apparaît nécessaire à l'Autorité contractante, des primes pour réduction des délais contractuels réalisée à la demande de l'Autorité contractante peuvent être prévues dans les marchés. Le taux journalier de ces primes ne pourra en aucun cas dépasser celui des pénalités pour retard. De plus, la réduction des délais contractuels au titre de laquelle pourront être attribuées de telles primes ne saurait excéder le 1/10ème du dmztélai contractuel. »

startups), catégorie de marché adaptée (ex : « marchés innovants » ou « partenariat d'innovation »), procédure de qualification adaptée (par ex : les exigences en termes d'expérience antérieure doivent être levées en cas de marché innovant), procédure d'attribution adaptée (exigences en termes d'obligation de performance), appel aux variantes, ou encore financement adaptés, et contrôles de l'exécution calibrés pour le suivi de tâches exploratoires. Toutes ces voies ne méritent pas d'être explorées simultanément. Dans le contexte du Sénégal, où la notion de *startup* a fait l'objet d'une loi particulière (loi du 6 janv. 2020), il paraît surtout utile de faciliter les variantes en cas d'innovations environnementales ou sociales et d'insister sur les obligations de performance.

§ 3-1 Clauses d'assurance

Les niveaux d'assurance exigés par les contrats doivent être proportionnés à l'ampleur du marché et aux capacités financières des entreprises. Les opérateurs économiques doivent en principe souscrire des assurances pour couvrir les conséquences des dommages potentiels qui pourraient survenir à l'occasion des prestations qu'elles réalisent mais les montants apparaissent souvent coûteux, voire dissuasifs, en particulier pour les petites structures. Pour ne pas écarter les PME de la commande publique, il est recommandé de ne pas exiger des niveaux d'assurances excessifs dans les DAO. A défaut, les candidats risquent de renoncer ou de répercuter ce surcoût sur le prix final ce qui va rendre la prestation très onéreuse pour l'acheteur public. Une alternative peut être de fournir une assurance ou une garantie publique par le biais d'un organisme de soutien financier aux PME (voir chapitre 5 appui institutionnel).



Recommandation :

- Dans les DTAO, modérer le montant des assurances ;
- Dans le guide explicatif, expliquer aux AC l'importance d'ajuster le montant des primes d'assurances pour faciliter la participation des PME

§ 3-2 Faciliter les conditions des avances dans les marchés APD

L'avance est essentielle pour attirer les PME et entreprises sociales, artisanales etc... qui n'ont souvent aucune trésorerie disponible. Comme le relève le guide pour les PME et TPE préparé par la DAJ française, « L'avance facilite l'exécution des marchés publics et participe de l'égal accès à toutes les entreprises, en s'assurant qu'elles disposent d'une trésorerie suffisante pour débiter l'exécution des prestations. Cette mesure, annoncée dès la publicité, doit aussi créer une économie pour l'acheteur, car les titulaires ne seront pas contraints de chercher un préfinancement et ne répercuteront pas cette charge dans leurs prix ». Bien que prévue par l'article 94 du CMP 2014, l'avance n'est pas toujours versée aux nouveaux titulaires. Ce constat conduit les PME qui ne disposent pas des fonds disponibles pour réaliser les dépenses de lancement des travaux ou de la prestation (achat de matériels, embauches, procédure d'obtention de permis, etc...) à multiplier les contrats parallèles, afin de reporter sur l'un le financement obtenu sur l'autre, ce qui conduit à une exécution très lente de la prestation attendue. Le Code prévoit une avance d'un montant maximal de 20 % mais il est au contraire recommandé de prévoir une avance proportionnée à l'objet du marché, ce qui ne correspond pas nécessairement au minimum légal, et de verser cette avance dès la date de notification.



Recommandations :

- Dans le CM, augmenter le montant maximal des avances pour les PME et petites structures ;
- Dans le guide explicatif, expliquer aux AC l'importance d'ajuster le montant de l'avance (et de la verser) pour faciliter la participation des PME et structures de l'économie sociale et solidaire

§ 3-3 Alléger les garanties

La garantie de soumission (CMP art. 114) et la garantie de bonne exécution (CMP art. 115) sont en principe exigées, sauf sous certains seuils définis par arrêtés¹⁰² du Ministre chargé des Finances. La garantie de bonne exécution doit

¹⁰² Arrêté MFEP 2015 860 de 2015 01 22 Article 1er : En application de l'article 114 du Code des Marchés publics, l'Autorité contractante peut ne pas exiger la fourniture d'une garantie de soumission pour les marchés d'un montant estimé inférieur aux seuils ci-après : • 80 millions de FCFA toutes taxes comprises pour les marchés de fournitures et de services autres que des prestations intellectuelles; • 100 millions de FCFA toutes taxes comprises pour les marchés de travaux et Arrêté MFEP 2015 866 de 2015 01 22 / Article 1 : En application de l'article 115 du Code des Marchés publics, une

être constituée en totalité lors de la signature du marché. Son montant est fixé par les cahiers des charges sans pouvoir dépasser 5 % du montant du marché augmenté ou diminué, le cas échéant, du montant des avenants (art 116, CMP 2014). Ces sommes peuvent être considérables pour les petites structures aussi convient-il d'alléger cette charge qui les détourne de se porter candidates à la commande publique. Une dispense de garantie de soumission est déjà prévue par le CMP (art 114) dans le cas des groupements d'ouvriers, les coopératives ouvrières de production, les coopératives d'artistes et les artisans individuels suivis par les Chambres consulaires, les organismes d'études, d'encadrement ou de financement agréés quand la valeur de soumission ne dépasse pas 50.000.000 FCFA. Elle doit être étendue. Au-delà du critère financier, cette dispense de garantie pourrait également être accordée aux candidats et titulaires des marchés réservés pour les catégories suivantes : artisans, entreprises sociales et éducatives, GIE. Ce Rapport propose d'en faire une simple faculté pour les AC mais on pourrait envisager de la rendre obligatoire. Alternativement, les garanties pourraient être fournies par un organisme d'appui institutionnel aux PME et structures de l'ESS.



Recommandation :

- CMP art 114 : Ajouter : Pour les marchés réservés aux structures de l'économie sociale et solidaire, l'Autorité contractante a la faculté de ne pas exiger de garantie de soumission afin de faciliter leur accès à la commande publique.
- CMP, art 115 : Ajouter : Pour les marchés réservés aux structures de l'économie sociale et solidaire, l'Autorité contractante a la faculté de ne pas exiger de garantie de bonne exécution.

§3-4 Faciliter les paiements

La question de la régularité des paiements est évidemment cruciale pour attirer des PME et des « entreprises à structures sociales ou éducatives » vers la commande publique. Or plusieurs entreprises consultées lors des entretiens (Partie 2) ont confié avoir réduit voire envisager de ne plus candidater aux marchés publics en raison des retards considérables de paiement auxquelles elles avaient dû faire face. Ce constat doit alerter alors que le CMP prévoit déjà des dispositions en vue d'accélérer les paiements. Des blocages viennent pourtant de certains services payeurs qui ne tiennent pas compte des dispositions de la commande publique¹⁰³, sans que le dispositif des intérêts moratoires qui s'ajoutent à la dette publique au prorata des jours de retard de paiement ne soit appliqué ou estimé suffisamment dissuasif. Les mêmes difficultés surgissent à l'occasion du remboursement des retenues de garantie qui est dû dès l'expiration du délai de garantie ou à la levée des réserves éventuelles. Des améliorations ont toutefois été constatées en ce qui concerne les paiements des primo-contractants. En revanche des retards préjudiciables aux PME persistent dans la relation entre le Titulaire et ses sous-traitants. L'Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie a relevé à propos de l'année 2018¹⁰⁴ que : « Les délais de paiement des fournisseurs (128 jours) ont dépassé ceux de règlement des clients (77 jours), induisant un impact positif sur les besoins en fonds de roulement ». Pour tenir compte des difficultés particulières subies par les PME, le Code révisé pourrait prévoir une disposition ouvrant des délais de paiement plus courts aux PME ou dans le cadre des marchés réservés ». Ou, alternativement, prévoir un mécanisme d'affacturage ou de nantissement des créances devant un organisme financier public de soutien aux PME.



Recommandations :

- le Code révisé pourrait prévoir une disposition ouvrant des délais de paiement plus courts aux PME ou dans le cadre des marchés réservés ».
- Ou, alternativement, prévoir un mécanisme d'affacturage ou de nantissement des créances devant un organisme financier public de soutien aux PME.

garantie de bonne exécution doit être fournie par le titulaire de tout marché d'un montant supérieur ou égal aux seuils ci- après : • 70 millions de FCFA toutes taxes comprises pour les marchés de fournitures et de services autres que les prestations intellectuelles; • 100 millions de FCFA toutes taxes comprises pour les marchés de travaux et de prestations intellectuelles.

¹⁰³ CMP Article 107 : (Délais de paiement) 1. Le règlement doit intervenir dans le délai de 45 jours compté, suivant le cas, à partir du jour où le créancier a régularisé son dossier, suivant la notification qui lui en a été faite dans les conditions prévues à l'article précédent. Le défaut de règlement dans ce délai de 45 jours fait courir de plein droit et sans autres formalités des intérêts moratoires calculés depuis le jour qui suit l'expiration dudit délai jusqu'au jour du règlement.

¹⁰⁴ (ANSD) ANSD, BANQUE DE DONNEES ECONOMIQUES ET FINANCIERES Version définitive 2017 et provisoire 2018, Mars 2020, http://www.ansd.sn/ressources/publications/BDEF_version%20definitive%202017%20et%20provisoire%202018.pdf

Section 6 Qualifier les entreprises au regard des exigences APD



La phase de qualification est essentielle pour assurer que les candidats sélectionnés disposeront des aptitudes nécessaires pour accomplir le futur marché dans le respect des obligations légales et contractuelles. Dans le cadre d'une politique APD, il importe que lors de cette phase, l'AC puisse apprécier leurs capacités à respecter les obligations environnementales et sociales, tout d'abord en écartant les candidats qui auraient pu être (notamment) sanctionnés du fait d'atteintes antérieures spécifiques à ces obligations, puis en vérifiant si les candidats disposent des capacités leur permettant de faire face à ces obligations.

§ 1 Les interdictions de candidater en lien avec les APD

En miroir au rappel de l'obligation générale de se conformer à la législation sénégalaise, notamment en matière sociale, environnementale qui est rappelée dans la Charte de l'Ethique et de la commande publique responsable, les conditions d'éligibilité des opérateurs admis à participer aux procédures d'attribution doivent élargir les interdictions de candidater aux condamnations pour violation des obligations sociales et environnementales.

Ce dispositif d'exclusion a un effet d'affichage désormais bien identifié, porté par la menace d'une publicité négative, puisque les listes d'entreprises interdites sont accessibles sur le site de l'ARCOP ex-ARMP. On doit cependant relever que les deux seules interdictions qui figurent sur le site sont déjà anciennes aussi il conviendrait de renforcer l'effectivité de ce dispositif, en particulier en cas de manquement aux obligations de la commande publique responsable.

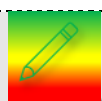
L'exclusion sera obligatoire si elle trouve son fondement dans une condamnation définitive prononcée par une juridiction. Cette sanction particulièrement sévère interviendra lorsque, par exemple, l'entreprise candidate aura subi une condamnation judiciaire : (art 43 - g) *Les personnes physiques ou morales ayant fait l'objet d'une condamnation pour violation du droit du travail (notamment pour conditions de travail dégradantes, travail illégal des enfants ou discrimination des femmes), de la protection sociale et du droit de l'environnement (notamment pour faits de pollution, usage de produits toxiques, déforestation illégale).* L'interdiction de candidater pourrait d'ailleurs être directement prononcée par le juge pénal **si le Code pénal sénégalais** le permet. Sinon, il appartiendra à l'ARCOP de tirer les conséquences de la condamnation de l'entreprise au titre de l'article 43 (d) :

- Interdiction des entreprises qui auront été condamnées pour violation de la législation du travail, notamment : travail non déclaré, conditions dégradantes, manquements graves aux règles d'hygiène et sécurité, discrimination et violation de l'égalité professionnelle ;
- Interdiction des entreprises qui auront été reconnues coupables de délits d'atteinte à l'environnement, par exemple pour des faits de pollution toxique ;
- Interdiction des entreprises qui aurait fraudé pour bénéficier des avantages accordés à certaines catégories de candidats (PME, PME féminines, structures à vocation sociales).

En dehors des cas de condamnation judiciaire, et en application du principe de proportionnalité en matière de commande publique, l'exclusion peut être facultative. Dans la mesure où la sanction doit être proportionnelle à la gravité de la faute constatée, l'exclusion ne sera pas nécessairement prononcée à l'encontre d'entreprises qui ont fait preuve de négligence et qui, par exemple, ont pu être sanctionnées par la résiliation ou la mise en régie d'un contrat antérieur. En particulier, si le soumissionnaire ou le candidat peut démontrer que des mesures ont été prises pour corriger le manquement qui avait été constaté (par exemple formation des personnels, adoption d'un code d'éthique), l'AC doit pouvoir en tenir compte pour admettre sa candidature.

Quant à l'AC, elle se doit de vérifier les capacités juridiques des entreprises candidates et donc elle doit veiller à obtenir les documents nécessaires (par exemple un extrait de casier judiciaire) attestant que l'entreprise n'a pas fait l'objet

d'une telle condamnation. Toutefois, une attestation sur l'honneur peut être admise en attendant la production du document officiel qui sera demandé seulement à l'entreprise qui a été retenue pour obtenir le contrat. A termes, la dématérialisation devrait faciliter ces formalités.



Recommandations :

- Réviser l'article 43 CMP pour ajouter des motifs d'exclusion afin de préciser que les entreprises condamnées pour manquement à leurs obligations environnementales ou sociales doivent ou peuvent être exclues;

Article 43.- Ne sont pas admises à prendre part aux marchés publics, quel que soit le mode de passation du marché : a) les personnes physiques en état de faillite personnelle ; b) les personnes physiques ou morales admises au régime de la liquidation des biens; (...) g) Les personnes physiques ou morales ayant fait l'objet d'une condamnation pour violation du droit du travail (notamment pour conditions de travail dégradantes, travail illégal des enfants ou discrimination des femmes), de la protection sociale et du droit de l'environnement (notamment pour faits de pollution, usage de produits toxiques, déforestation illégale).

§ 2 La vérification des capacités ESS des candidats



L'Article 59 al 2¹⁰⁵ du CMP de 2014 a déjà inclus un critère de qualification relevant des APD avec l'examen des **capacités environnementales des candidats en plus des capacités juridiques, techniques et financières**. Ainsi, tout candidat à un marché public doit justifier qu'il dispose des capacités juridiques, techniques, financières et environnementales requises pour exécuter le marché. Ces capacités doivent être appréciées tant sur le plan quantitatif que qualitatif à travers les critères de qualification qu'il faut détailler davantage. Sur ce point, la Loi-type sur les marchés publics de la CNUDCI de 2011 précise, dans son article 9 : « les critères (...) que l'entité adjudicatrice juge appropriés et pertinents dans les circonstances de la passation de marché concernée: a) Avoir les qualifications professionnelles, techniques et environnementales, les compétences professionnelles et techniques, les ressources financières, les équipements et autres moyens matériels, les compétences de gestion, la fiabilité, l'expérience et le personnel nécessaires pour exécuter le marché; ». En revanche le CMP 2014 n'envisage pas les capacités « sociales » du candidat qu'il faudra dès lors ajouter.

Attention : une fois utilisés au stade des candidatures, ces critères de sélection ne peuvent plus l'être en principe au stade de la remise des offres en tant que critères d'attribution.

Concernant les capacités juridiques, il importe de préciser dans le CMP que certaines entreprises doivent disposer d'un agrément en application de la législation sur les PME ou sur les Artisans. L'article 4 de la loi du 7 janvier 2020 organise ainsi un agrément facultatif au statut de PME. A défaut, et pour faciliter les candidatures, le CMP peut prévoir un mécanisme de déclaration sur l'honneur du statut revendiqué, seule l'entreprise sélectionnée se verra ensuite réclamer les justificatifs nécessaires. Ces vérifications permettront également d'établir si le candidat entre dans une catégorie pour bénéficier d'une préférence.

Dans l'hypothèse où une préférence serait établie en faveur des entreprises féminines, le Rapport Carapaces (p. 59) propose de considérer comme PME féminine postulante aux marchés publics, « toute PME nationale au sens de la Loi d'orientation n° 2020- 02 du 07 janvier 2020 relative aux Petites et Moyennes Entreprises, appartenant à ou contrôlée,

¹⁰⁵ « La qualification du candidat qui a présenté l'offre évaluée la moins- disante au regard des capacités juridiques, techniques, environnementales et financières requises est examinée indépendamment du contenu de son offre, au vu des justifications qu'il a soumises, en application des dispositions de la Section 2 du Chapitre 2 du présent Titre. »

directement et inconditionnellement, par une ou plusieurs femmes ou PME féminines et intervenant dans un secteur éligible aux marchés publics ». On suggère de reprendre cette définition dans la liste des définitions du CMP mais de remplacer « inconditionnellement » par « effectivement ». On doit cependant souligner les risques de contournement potentiel des règles de qualification afin de profiter des avantages préférentiels consentis à certains groupes. Cependant, l'obligation de déclarer le bénéficiaire effectif pourrait permettre de lutter contre ce type de dévoiement. Enfin, une sanction a été prévue (supra) pour ce type de fraude aux dispositions préférentielles.

Pour activer le dispositif des marchés expressément réservés (exploré supra), un critère de qualification calibré doit permettre d'identifier des catégories spécifiques de candidats (Artisans par exemple). La création d'un agrément ESS par la loi du 15 juin 2021 doit permettre d'identifier les candidats qui peuvent prétendre à un traitement préférentiel dans la commande publique : les entreprises sociales, les GIE, les groupements et coopératives d'ouvriers et d'artisans ou les sociétés coopératives ou mutualistes. Ces structures ont de surcroît vocation à satisfaire implicitement l'exigence locale. Cette action s'articule avec la recommandation faite supra de publier dans le plan annuel de passation des marchés publics, la part en pourcentage qui sera consacrée aux marchés réservés, ou encore appelés *quotas*.

Par ailleurs des PME pourraient également bénéficier de marchés « sociaux » réservés à d'en remplir les critères exigés à propos de leurs personnels. Ainsi au Kenya¹⁰⁶, le gouvernement alloue depuis 2013, 30 % de ses dépenses de passation de marchés aux fins de l'acquisition de biens, de travaux et de services auprès de micro et petites entreprises appartenant à des jeunes, des femmes et des personnes en situation de handicap. Ainsi l'article 50 pourrait mentionner la possibilité pour les PME d'accéder à des marchés réservés à condition d'employer au moins 30 % de personnes victimes de handicap ou 50 % de jeunes sans qualification ou 50 % de femmes.

Concernant les capacités environnementales et sociales des candidats, l'Ac peut se tourner vers des « *Dispositifs d'assurance de la qualité et normes de gestion environnementale et sociale* », qui se sont multipliés ces dernières années et qu'il convient d'ajouter au CMP. La rédaction de l'alinéa (h) de l'article 44 du CMP 2014 qui dresse la liste des attestations et justifications à fournir par les candidats, ne rend pas cette formalité obligatoire en demandant : « *des renseignements sur le savoir-faire du candidat en matière de protection de l'environnement, le cas échéant* ». Pourtant de nombreuses données à caractère sociale ou environnementale devraient être collectées à ce stade. De fait le Rapport Carapace propose d'adopter « *un sous-critère distinct ou une référence à la connaissance de l'aspect dimension de genre peut être ajoutée à un critère général sur l'organisation, les qualifications et l'expérience de l'équipe.* » Ainsi l'AC peut-elle apprécier la mise en place par l'entreprise de règlement intérieur, code d'éthique, plan d'action sociale, mesures de protection de l'environnement.

Pour les marchés de services et de travaux dont la réalisation aura un impact sur l'environnement, il est possible de demander la mise en place de mesures de gestion Systèmes de Management Environnemental (SME), par exemple EMAS, ou ISO 14001. Il existe ainsi des normes ISO 9001, et OHSAS 18001. Compte tenu des particularités des marchés, peuvent être aussi intégrés d'autres systèmes de management tels de l'énergie (ISO 50001) et la lutte de contre la corruption (ISO 37001). Dans le secteur privé, les termes varient mais certaines entreprises font référence au référentiel QSE (Qualité, Sécurité, Environnement) qui regroupe le management de la qualité, de l'environnement et de la santé et sécurité au travail, auquel on peut ajouter les notions d'éthique et de développement durable, voire les ressources humaines. Il existe également un label dédié à la « Responsabilité sociale des entreprises : l'ISO 26000. Tandis que les anglo-saxons ou grandes multinationales font souvent référence au label « B Corp » qui signifie Benefit Corporation Certification¹⁰⁷. Toutes ces exigences sont parfois combinées dans un système dit de management intégré (SMI) qui permet la prise en compte d'exigences internes et externes multiples¹⁰⁸ : qualité, sécurité, environnement, exigences légales et réglementaires et d'autres exigences des référentiels propres à l'activité concernée (industrie, services, santé notamment). La plupart de ces références sont sollicitées volontairement par les entreprises mais elles reprennent aussi souvent des prescriptions de la réglementation technique et sectorielle qui, par exemple, interdit certains process de production.

¹⁰⁶ Source : Rapport Carapaces

¹⁰⁷ IISD BRIEF #12 The Evolution of Private Sector Action in Sustainable Development Dina Hestad February 2021 : <https://www.iisd.org/system/files/2021-02/still-one-earth-private-sector.pdf>

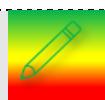
¹⁰⁸ Lagdim Soussi Lalla Hind., Le système de management intégré QSE appliqué à une PME, International Journal of Advanced Research (IJAR), 2018, Ecole nationale de commerce et de gestion-Agadir, [Univtps://www.academia.edu/36183979/LE_SYSTEME_DE_MANAGEMENT_INTEGRE_QUALITE_SECURITE_ENVIRONNEMENT_APPLIQUE_A_UNE_PME](https://www.academia.edu/36183979/LE_SYSTEME_DE_MANAGEMENT_INTEGRE_QUALITE_SECURITE_ENVIRONNEMENT_APPLIQUE_A_UNE_PME)

Le recours à la certification (sous la forme de certificats environnementaux) et aux labels des entreprises candidates doit être encouragé dans une démarche proportionnée et progressive. Proportionnée en fonction du montant du contrat : à montant élevé, exigences élevées. Dans le contexte des grands marchés de travaux, réclamer que les entreprises soient certifiées et disposent de Labels reconnus sera un gage de qualité. En revanche sur les petits marchés ou d'envergure moyenne, les demandes peuvent être plus limitées, au moins pendant quelques années, le temps que le secteur privé s'adapte. Pour ce laps de temps, le Guide d'APD, (p. 39) a ainsi proposé : « **un système de quitus environnemental** comme une démarche volontaire avec le contrôle de la DEEC et d'une Commission Technique qui va attribuer le quitus environnemental comme outil de certification de conformité par rapport aux critères retenus et d'engagement des entreprises nationales en faveur de la protection de l'environnement et des ressources naturelles ». Toutefois, dans le domaine de l'économie d'énergie, l'installation en cours d'un laboratoire dédié rattaché au Ministère de l'environnement permet d'envisager la délivrance de certificats nationaux. Enfin, la possibilité d'un label officiel en matière d'égalité de traitement hommes-femmes pourrait être explorée au Sénégal. A l'instar de la France qui a instauré deux labels (label Diversité et label « Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes ») propriétés de l'Etat sont délivrés par l'AFNOR Certification, afin d'évaluer puis de labelliser les Entreprises qui ont mis en place des politiques particulières. Au Sénégal, l'ASN en partenariat avec le Ministère de la femme pourraient être à terme chargées de la délivrance d'un tel label.

A défaut de mentionner directement ces labels, signalés ci-dessus, au stade de la qualification des candidats, parce que le type de marché ne s'y prête pas ou que l'AC estimerait que le tissu industriel local n'est pas encore capable de répondre à ces exigences, les critères énumérés par ces références peuvent eux-mêmes servir de modèles pour rédiger les critères de qualification. Des déclarations d'intégrité, d'éligibilité, de responsabilité environnementale et sociale, ou des attestations de clients antérieurs, peuvent être aussi exigées des soumissionnaires afin qu'ils attestent de leurs compétences et qu'ils s'engagent à respecter et à faire respecter par l'ensemble leurs sous-traitants les normes environnementales et sociales applicables.

Vérification des candidatures : Pour faire face aux difficultés rencontrées par les PME ou TPE qui ne disposent pas du personnel suffisant pour consacrer beaucoup de temps à la préparation d'un dossier de candidature, ce qui constitue un frein indéniable à leur participation, la soumission des attestations et certificats exigés de la part des candidats, pourrait, dans l'avenir, reposer sur un système de coffre-fort numérique, dans lequel l'entreprise peut classer tous ses documents, certificats et labels éventuels et donner un accès momentanée à l'autorité contractante lors des candidatures à des marchés publics. Ce dispositif qui a été utilisé au Maroc, permet de gagner un temps précieux mais permet également d'assurer l'intégrité des démarches en réduisant les possibilités de fraude.

Vérification a posteriori des attestations : Enfin, il pourrait être envisagé de n'examiner que les documents fournis par l'entreprise qui a été sélectionnée pour remporter le marché. Lors du dépôt de candidatures, les candidats n'auraient à déposer que les documents en leur possession et le reste sous la forme de récépissés de demandes de documents auprès des administrations concernées et/ou d'attestation sur l'honneur (qui engagerait la responsabilité de son auteur en cas de tentative de fraude). Cela permettrait de lutter contre les lenteurs chronophages liées à la collecte des documents auprès des administrations qui ont été dénoncées lors des entretiens avec le secteur privé. Et du côté des Autorités contractantes, cela offrirait également un gain de temps considérable pour l'examen des candidatures, réduisant ainsi les délais pour attribuer les marchés.



Recommandations :

- CMP : Introduire un alinéa 2 à l'article 46, au titre des preuves des capacités juridiques : les PME et les startups, les entrepreneurs et entrepreneuses, les Artisans et Artistes, doivent fournir les attestations d'agrément ou de labellisation prévues par la réglementation applicable.
- CMP ; Réviser l'alinéa (h) de l'article 44 pour inclure le savoir-faire en matière sociale : « des renseignements sur le savoir-faire du candidat en matière de protection de l'environnement, du respect des mesures d'hygiène, de santé, de sécurité, de genre, de développement social, le cas échéant ».
- CMP : Réviser l'article 44 du CMP 2014 pour inclure un nouvel alinéa (i) au sujet : des labels, certifications et autres quitus attestant des processus suivis par le candidat ou, à défaut, par équivalence, l'explication des méthodes adoptées et des dispositions prises pour atteindre le niveau d'exigence requis par les critères de qualification mentionnés dans les documents d'appels d'offres ;

- Une déclaration sur l'honneur ou une attestation par une tierce personne peut être acceptée jusqu'à la vérification desdits certificats ou labels pour l'entreprise qui aura remporté le marché ;

-Vérification a posteriori : Lors du dépôt de leur dossier, les candidats remettent tous les attestations, quitus et certificats en leur possession et, à défaut, les récépissés de demandes de ces documents auprès des administrations concernées. Les documents prévus aux alinéas a) à f), et éventuellement h), i) et j), non fournis ou incomplets seront tous exigibles auprès du seul candidat sélectionné lors de l'attribution provisoire. Les tentatives de fraudes qui pourraient être décelées à ce stade entraîneront l'exclusion de l'attribution des marchés publics prononcée par l'ARCOP, la confiscation de la garantie de soumission, sans préjudice d'éventuelles actions en réparation des dommages causés par les retards éventuels qui pourraient affecter la procédure d'attribution.

Travaux futurs :

- La DEEC peut ainsi délivrer un « quitus environnemental » aux entreprises non labellisées.
- En matière d'économie d'énergie, un certificat national pourra être bientôt délivré par l'AME

Section 7 La phase d'attribution



La phase d'attribution constitue une nouvelle étape dans l'opération contractuelle qui va permettre d'utiliser des critères d'attribution et d'évaluation des offres au service des objectifs d'APD. Au lieu de réduire le choix à l'offre proposant le prix le plus bas, le recours à des critères multiples peut en effet permettre d'intégrer des critères qualitatifs, ou de durabilité fondés sur des aspects sociaux ou environnementaux liés à l'objet du marché concerné. Il s'agit ainsi de passer d'un mode de sélection de l'offre fondé uniquement sur le prix le plus bas à la possibilité de rechercher le meilleur Rapport qualité/prix en introduisant la notion « d'offre économiquement la plus avantageuse » en lieu et place de « l'offre évaluée la moins-disante ».

§ 1 « L'offre économiquement la plus avantageuse » nécessaire aux APD

A l'étranger, le critère unique du prix n'est pratiquement plus retenu dans les systèmes contemporains de commande publique, ou alors seulement pour des achats simples sur devis ou demande de prix. Le seul critère du prix, souvent privilégié par les AC en manque de capacités, a démontré son inefficacité car il conduit à privilégier des achats de qualité sous-optimale et qui seront souvent produits dans de mauvaises conditions sociales et environnementales. Peu fiables, et parfois même contraires aux normes de sécurité, ils vont se détériorer plus rapidement et obliger l'AC à relancer de nouveaux marchés plus tôt qu'escompté. Dans la très grande majorité des cas, le prix le plus bas entraîne ainsi des dépenses budgétaires plus élevées sur le long terme. Il faut proposer une alternative qui apporte des éléments d'appréciation autres que le seul prix. Introduire des paramètres pour prendre en compte la durabilité de la fourniture ou de la qualité des travaux constitue ainsi souvent un choix financier plus judicieux pour la dépense publique.

Au Sénégal, c'est trop souvent le critère du seul prix qui domine, malgré la rédaction du CMP 2014 dans son Article 59 qui permet théoriquement le recours à l'offre la « moins-disante » avec des critères qualitatifs, dont le critère environnemental : « 1. La détermination de l'offre la moins-disante est effectuée soit sur la base du prix le plus bas, soit sur la base du prix et d'autres critères, tels que le coût d'utilisation, les performances techniques, les mesures de protection de l'environnement, le délai de livraison ou d'exécution. Cette présentation des critères n'a pas été suivi d'effets notables, faute d'être complétée par des explications et des dispositions de mise en œuvre dans les DTAO. Les AC se sont essentiellement référées au prix le plus bas pour choisir les offres.

Options entre le critère unique et la pluralité de critères

Critère unique du moins-disant :	Pluralité de critères :	Conditions

- le prix, pour l'achat de services ou fournitures standardisés ; - le coût, déterminé selon une approche globale qui peut être fondée sur le coût du cycle de vie.	- le prix ou le coût ; - la qualité (valeur technique, performances environnementales, caractère innovant...) ; - les délais d'exécution ; - le personnel (organisation et qualification) ; - etc.	-Critères (et pondération) annoncés dans les documents de la consultation -Critères non discriminatoires et liés à l'objet du marché -Critères applicables aux offres de base et aux variantes
--	--	--

Le remplacement de l'offre « la moins-disante » par « l'offre économiquement la plus avantageuse » dans le CMP. Le changement de vocabulaire qui est proposé par ce Rapport n'est pas seulement cosmétique : il vise à envoyer un signal fort aux AC que leur choix ne doit pas être limité au prix le plus bas. Si l'article 59 définit largement l'offre la moins-disante¹⁰⁹, en faisant appel à des critères qualitatifs, le contenu des DTAO et la pratique (voir Partie 2 de ce Rapport) attestent que les AC se contentent dans la très grande majorité des cas de ne retenir que le prix le plus bas. Cette nouvelle expression de l'« offre économiquement la plus avantageuse » était déjà utilisée dans le DTAO pour les DSP (voir supra 2^{ème} partie) et elle est reprise par la nouvelle loi n° 2021-23 sur les PPP du 2 mars 2021 : harmoniser le vocabulaire utilisé contribuera à la rationalisation des procédures de la commande publique.

Comme remarqué dans le chapitre 3 à propos du cadre actuel de la commande publique, la rédaction de la grande majorité des DTAO (au moins tous les DTAO portant sur les travaux, le DTAO sur les marchés de services physiques) ne permet pas d'éclairer les AC sur les critères à retenir en-dehors de ceux liés au prix. Seul le DT du contrat de DSP retient « l'offre économiquement avantageuse » illustrée par des critères de performance et de qualité, ainsi que le respect des normes environnementales. Tandis que le DTAO Passation des marchés de Fournitures (Mai 2017) insiste sur le critère des performances parmi les autres critères que le prix qui peuvent être mobilisés pour déterminer « l'offre la moins-disante ». Et mentionne plus loin le « critère d'origine ». Dans les marchés de prestations intellectuelles, il convient en revanche de faire appel à des critères de qualité pour évaluer les propositions techniques (DTAO marchés importants de Mai 2017).

Il ne s'agit pas de supprimer le critère du prix mais de proposer une voie alternative, plus élaborée et plus adaptée aux caractéristiques sociales et environnementales du futur projet. Le prix demeurera un critère unique si l'AC le décide, et la documentation explicative devra orienter vers ce critère pour les achats simples et de petits montants. Alternativement, l'AC pourra décider de recourir à l'offre économiquement la plus avantageuse en choisissant des critères appropriés à ses besoins.

L'identification des offres anormalement basses doit permettre à l'AC de déceler si les conditions de travail et les conditions environnementales minimales ont bien été respectées. Les offres dites anormalement basses, c'est-à-dire les offres qui présentent un prix manifestement sous-évalué sont de nature à compromettre la bonne exécution du marché. Dans un tel cas, l'AC doit pouvoir rejeter cette offre à la suite d'une procédure contradictoire qui permet de demander par écrit au candidat des compléments d'informations, notamment pour enquêter sur un risque financier potentiel ou un risque de défaillance. Dans le cadre d'une politique d'APD, cette interrogation du candidat va également servir à vérifier si le prix proposé ne cache pas la volonté de recourir au travail dissimulé (informel) ou à la sous-traitance cachée, à la violation des droits des travailleurs avec des salaires en-dessous des minimums légaux, ou le non-respect des conditions de travail exigées par la loi. La même démarche peut également révéler les réductions de coûts que le candidat entendait réaliser au détriment de la protection de l'environnement (utilisation de matériaux dégradés, transports polluants, etc...).

L'offre économiquement plus avantageuse permet à la fois de souligner la dimension financière mais également la balance entre plusieurs paramètres. Il faut ici se référer à la Loi-type de la CNUDCI sur les marchés publics de 2011, dans son article 11.2, qui a énoncé précisément les critères d'attribution (dits « d'évaluation ») à mentionner dans le CMP : « 2. Les critères d'évaluation liés à l'objet du marché peuvent comprendre: a) Le prix; b) Le coût de l'utilisation, de l'entretien et de la réparation des biens ou des travaux; le délai de livraison des biens, d'achèvement des travaux ou de fourniture des services; les caractéristiques de l'objet du marché, telles que les caractéristiques fonctionnelles des biens ou

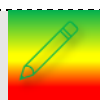
¹⁰⁹ Article 59 : « La détermination de l'offre la moins-disante est effectuée soit sur la base du prix le plus bas, soit sur la base du prix et d'autres critères, tels que le coût d'utilisation, les performances techniques, les mesures de protection de l'environnement, le délai de livraison ou d'exécution, qui doivent être énumérés dans le dossier d'Appel à la concurrence et être exprimés en termes monétaires ou sous la forme de critères éliminatoires. Il est tenu compte, le cas échéant, des préférences mentionnées à l'article 50 du présent décret ».

des travaux et les caractéristiques environnementales de l'objet; et les conditions de paiement et les conditions de garantie relatives à l'objet du marché; c) Lorsque cela est pertinent (...) l'expérience, la fiabilité et les compétences professionnelles et managériales du fournisseur ou de l'entrepreneur et du personnel devant participer à la fourniture de l'objet du marché.

3. Outre les critères énoncés au paragraphe 2 du présent article, les critères d'évaluation peuvent comprendre: a) Tout critère dont les règlements en matière de passation des marchés ou d'autres dispositions de la législation du présent État autorisent ou exigent la prise en compte; b) Une marge de préférence accordée aux fournisseurs ».

Dans les marchés de prestations intellectuelles, le critère 'qualité' comprend souvent des éléments qui évaluent la manière dont le marché est exécuté (la méthodologie utilisée, la forme proposée...).

En France, Projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, n° 3875 rectifié. – « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse sur la base d'un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution. Les modalités d'application du présent alinéa sont prévues par voie réglementaire ».



Recommandations :

- CMP (art. 59) : Remplacer l'offre moins-disante par l'option entre le prix ou l'offre économiquement la plus avantageuse afin d'éviter que les AC ne se contentent du prix le plus bas.

Il faut que les DTAO Travaux mentionnent également la possibilité de recourir à cette diversité des critères qualitatifs et de durabilité qui peuvent être pris en compte au moment de l'attribution.

Travaux futurs :

-Expliquer la méthode de l'offre la plus avantageuse dans le Guide explicatif

§ 2 Inclure des critères d'attribution en faveur des APD



La détermination des critères d'attribution est toujours une opération délicate. Or le choix judicieux de ces critères, qui seront mentionnés dans le CMP, va dans une large mesure déterminer le succès de l'implémentation des APD au Sénégal. Comme ils vont orienter l'analyse des offres, il est important de prévoir des critères clairs, vérifiables et non discriminatoires pour les produits et les services. Ils doivent assurer une balance équilibrée entre les performances environnementales et sociales et les considérations de coûts, de disponibilité sur le Marché et de facilités de vérification et de contrôle. Ces critères doivent être en lien avec l'objet du contrat tout en contribuant à l'impact positif d'une politique sociale et environnementale identifiable.

Le critère « qualité » permet d'inclure des éléments de durabilité.

Exemple français, Code de la commande publique, Article R2152-7 :

Pour attribuer le marché au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, l'acheteur se fonde :

1° Soit sur un critère unique qui peut être :

a) Le prix, à condition que le marché ait pour seul objet l'achat de services ou de fournitures standardisés dont la qualité est insusceptible de variation d'un opérateur économique à l'autre ;

b) Le coût, déterminé selon une approche globale qui peut être fondée sur le coût du cycle de vie défini à l'article [R. 2152-9](#) ;

2° Soit sur une pluralité de critères non-discriminatoires et liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. Il peut s'agir des critères suivants :

a) La qualité, y compris la valeur technique et les caractéristiques esthétiques ou fonctionnelles, l'accessibilité, l'apprentissage, la diversité, les conditions de production et de commercialisation, la garantie de la rémunération équitable des producteurs, le caractère

innovant, les performances en matière de protection de l'environnement, de développement des approvisionnements directs de produits de l'agriculture, d'insertion professionnelle des publics en difficulté, la biodiversité, le bien-être animal ;

b) Les délais d'exécution, les conditions de livraison, le service après-vente et l'assistance technique, la sécurité des approvisionnements, l'interopérabilité et les caractéristiques opérationnelles ;

c) L'organisation, les qualifications et l'expérience du personnel assigné à l'exécution du marché lorsque la qualité du personnel assigné peut avoir une influence significative sur le niveau d'exécution du marché.

D'autres critères peuvent être pris en compte s'ils sont justifiés par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution.

Les critères d'attribution retenus doivent pouvoir être appliqués tant aux variantes qu'aux offres de base.

Des sous-critères environnementaux ou sociaux liés aux conditions d'exécution du contrat peuvent également être ajoutés. Ces sous-critères qualitatifs vont permettre de faire le lien avec les spécifications techniques ou fonctionnelles. Ils contribueront à limiter la marge d'appréciation et à atténuer le caractère nécessairement « subjectif » de l'analyse des offres. Quelques critères fréquemment rencontrés sont à ranger dans cette catégorie : les délais de livraison ou d'intervention, les modalités de maintenance ou de garantie, l'exigence esthétique ou ergonomique, les moyens humains ou techniques mis en œuvre pour l'exécution des prestations, etc. C'est également à ce stade, à propos de l'organisation que l'entreprise entend mettre en place pour assurer sa prestation, ou des qualification et expériences attendues de ses personnels, que peut apparaître le critère de l'égalité des genres, s'il n'a pas été mentionné auparavant, comme l'a suggéré le Rapport Carapace : « Dans ce cas, un sous-critère distinct lié à un score propre peut être ajouté ou une référence à la connaissance de l'aspect dimension de genre peut être ajoutée à un critère général sur l'organisation, les qualifications et l'expérience de l'équipe.(...) Dans cette dernière option, on n'est pas obligé d'attribuer des scores distincts pour l'intégration de la dimension de genre, mais on peut néanmoins récompenser les soumissionnaires qui accordent une attention à la dimension de genre dans leur proposition. »

Les critères d'attribution retenus peuvent combiner des aspects qualitatifs, environnementaux et/ou sociaux, à condition a) qu'ils respectent toujours les principes généraux de transparence, de non-discrimination et d'égalité de traitement ; b) qu'ils soient liés à l'objet du marché ; c) qu'ils soient objectivement quantifiables ; d) que toute forme de preuve de conformité soit acceptée.

- **Le critère social, parfois appelé critère du « mieux-disant social »** : il peut avoir de multiples facettes, telles que la performance en matière d'insertion professionnelle des publics en difficulté qui concourent à l'exécution du marché. Appliquer le critère du mieux disant social. En Grande-Bretagne, le Gouvernement vient de publier son programme de réforme du droit des marchés publics après le Brexit dans le « *Green paper on public procurement* ». Il y affirme sa volonté de prévoir un critère social d'attribution obligatoire dans tous les marchés publics qui doit représenter 10% du score final. Ce dispositif a déjà été mis en œuvre pour les Acheteurs publics étatiques (PPN 06/20). Mais la nouvelle mouture permettra de prendre en compte l'effet « social » au-delà de l'objet du contrat.
- **Le critère de l'insertion des publics vulnérables** : Par ex, les candidats devront obligatoirement proposer une action permettant l'embauche et la formation d'un ou plusieurs jeunes en situation de décrochage scolaire, de 16 à 25 ans, suivi(s) par la structure X du ministère chargé de l'Education nationale. Dans le cahier des charges, cette exigence se présente sous la forme d'un volume horaire minimum et constitue une condition d'exécution du marché.
- **Le critère du genre** : Le Rapport Carapaces a ainsi proposé (p. 72) : « Si l'intégration de la dimension de genre constitue un des objectifs du marché et s'il est demandé dans le cadre du critère d'attribution « qualité » de tenir compte de la dimension de genre, il est important que l'équipe qui exécute le marché puisse démontrer qu'elle dispose des capacités nécessaires ».
- **Le critère de l'expérience et de la qualité du personnel** : Lorsque la qualité du personnel employé est déterminante pour l'exécution du marché, l'AC doit pouvoir utiliser comme critère d'attribution l'organisation, les qualifications et l'expérience du personnel assigné à l'exécution du marché en question, étant donné qu'elles peuvent affecter la qualité de l'exécution du marché et, par conséquent, la valeur économique de l'offre.
- **Le critère environnemental** : très polymorphe, il peut être décliné sous de nombreuses exigences en fonction de l'objet du marché (voir 1^{ère} partie). Il commandera des actions concrètes qui devront être annoncées par le candidat dans son offre. On peut citer comme exemples de critères en matière sociale et environnementale : la réduction des émissions de CO2 des véhicules utilisés dans le cadre du marché, la valorisation et le recyclage des déchets issus de l'exécution du marché, l'innovation en matière de procédés, l'utilisation de produits et matériaux moins nocifs pour l'environnement (ex : certains produits biosourcés...) utilisés pour l'exécution du marché, etc.

Ne peuvent constituer des critères d'attribution :

- **Le critère local, en tant que tel, pose des difficultés particulières.** Ce critère peut paraître en opposition frontale avec l'exigence de concurrence et d'égalité d'accès. A ce titre il est contraire aux règles de l'UEMOA qui s'appliquent au-dessus de certains seuils de montants de marchés. Sous les seuils il peut être envisagé mais avec des précautions. Son objet mérite également d'être précisé, car exiger un marché « local » ne signifie pas nécessairement que les produits obtenus seront fabriqués localement (ils pourraient être importés) ou que l'achat bénéficiera aux producteurs et aux petits exploitants locaux.
 - **On peut reprendre l'énoncé des critères d'attribution de l'article 32 de la loi n° 2021-23 sur les PPP du 2 mars 2021 :** « En fonction de l'objet du projet et du contexte social, économique et environnemental, les Autorités contractantes peuvent prévoir, parmi les critères d'attribution énoncés dans le dossier d'appel d'offres, des exigences liées au contenu local du projet de partenariat public-privé envisagé, notamment : a) les initiatives relatives à l'emploi et à la formation professionnelle ; b) les initiatives pour l'intégration des artisans et des petites et moyennes entreprises locales ; c) les actions et propositions concrètes en matière de développement durable ».
 - **Le recours aux structures sociales et éducatives locales :** La part d'exécution du contrat que le candidat s'engage à confier à des entreprises de droit local détenues majoritairement par des nationaux pourrait être envisagée. Ainsi l'article 59 pourrait inclure un nouveau critère d'attribution : « les mesures de protection de l'environnement, les initiatives pour l'intégration des entreprises, des artisans ou structures sociales locales en tant que sous-traitants ».
- Pour éviter toute ambiguïté dans les attentes locales, il vaut mieux renvoyer aux spécifications techniques qui, par exemple, exigeront l'approvisionnement de produits locaux auprès de producteurs locaux.
- **La responsabilité sociale des entreprises (RSE), en tant que politique générale de l'entreprise, ne peut constituer un critère d'attribution** selon une jurisprudence constante ¹¹⁰ car elle n'est pas liée à l'objet du marché. En revanche, la politique RSE de l'entreprise pourra être appréciée au stade de la qualification ou sollicitée dans les spécifications techniques et les modalités d'exécution. Faute d'encadrement au Sénégal, la RSE s'organise à l'heure actuelle au cas par cas : certaines entreprises incorporent au titre de travaux supplémentaires les demandes de RSE qui sont formulées pendant l'exécution des travaux par le maître d'ouvrage. Or il ne s'agit pas d'une véritable RSE puisque ces travaux supplémentaires seront finalement payés par l'AC. Des conventions de partenariat sont parfois signées avec les collectivités locales pour formaliser les demandes de travaux ou de financement qui ont été directement adressées à l'entreprise une fois sur le terrain.

L'ordre des critères doit être annoncé dans l'avis d'appel à concurrence et être respecté par la suite, sans aucun changement. Ces critères et l'ordre dans lequel ils seront appréciés doivent figurer dans l'Avis. Cette règle vaut également pour les sous-critères.

Les modalités de calcul du poids respectif de chaque critère doivent être précisées dans le CMP. A cet effet plusieurs techniques sont envisageables. La technique de la notation des critères, peut être organisée suivant diverses modalités (ex : pourcentage, coefficient, attribution de points, fourchette...). Elle n'est pas utilisée au Sénégal pour les marchés de fournitures ou de travaux mais elle est déjà pratiquée pour les marchés de prestations intellectuelles. La technique de la pondération, qui s'appuie sur la notation des critères qui vont être affectés de pourcentages, est envisagée par le Guide d'APD (p. 42) : « L'autorité contractante base l'attribution de son offre à la fois sur un critère technique, un critère environnemental ou social et un critère prix ou coût, chacun assorti de pondérations raisonnables. Il aura la garantie que les produits ou services achetés mêleront qualité, performance environnementale et/ou sociale, et un coût correspondant. » Cette technique permet à l'AC de faire varier le poids du ou des critères de durabilité suivant l'impact attendu ainsi que l'état du Marché. Mais si le critère du prix a un poids qui dépasse largement 50 %, l'AC s'expose à un risque de sous-qualité de la prestation. Enfin, il est possible d'avoir recours à la technique de la transformation en éléments monétaires de tous les critères et de leurs résultats : cela permet de jouer sur l'offre financière, en renchérissant ou en diminuant les offres des soumissionnaires à chaque écart (en moins ou en plus) par rapport aux critères exprimés. C'est la technique d'évaluation des offres et de calcul des critères appliquée par de nombreux PTF à la suite de l'exemple de la Banque Mondiale. C'est également celle qui est retenue dans le DTAO des grands travaux. Toutefois, la pratique montre que cette technique

¹¹⁰ A titre d'exemple, dans l'affaire CE, 25 mai 2018, Nantes métropole, n° 417580 : un critère de sélection pondéré à hauteur de 15 % de la note totale et ayant pour objectif d'évaluer la politique générale des candidats en matière sociale a été sanctionné par le juge administratif français.

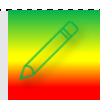
relativement sophistiquée se révèle peu adaptée pour de petits marchés passés par des AC aux capacités limitées. Elle conduit souvent à une stratégie d'évitement de la part des Acheteurs publics qui vont se reporter sur le prix le plus bas.

Sur le plan de la force juridique, le critère de durabilité (dans ses différentes déclinaisons), doit avoir un caractère facultatif : l'AC n'est pas en principe obligée d'y avoir recours. Et si elle décide d'y avoir recours, le poids qu'elle va consacrer à ce critère (par application d'un facteur de pondération par exemple) va déterminer son poids réel dans le choix de l'offre. Ensuite, il faudra que le critère soit effectivement décliné dans les spécifications techniques ou les conditions d'exécution pour être véritablement contraignant lors de l'exécution. C'est du moins l'option qui a été explorée par le Guide des APD.

Toutefois, il pourrait être décidé de mentionner dans le CMP l'obligation d'inclure au moins un critère de durabilité (le critère social ?) parmi les critères d'attribution. L'effet d'annonce auprès des Acheteurs publics, du secteur privé et de la société civile serait manifeste. Sur le plan des procédures, cela interdirait le recours au critère unique du prix, au moins pour les contrats les plus importants si cette configuration est imposée au-dessus de certains seuils. Cette obligation peut néanmoins laisser le choix aux AC de déterminer le critère (et donc l'objectif APD : social, économique ou environnemental) qu'elles entendent privilégier au cas par cas. Mais il est également possible que le Gouvernement décide de cibler une politique particulière qu'il entend prioriser à travers la commande publique : par exemple le critère « social » dans le but de créer des emplois. Alors tous les appels d'offres devraient ajouter un critère social aux critères envisagés. C'est l'option que vient de prendre la France mais uniquement en faveur du critère environnemental¹¹¹. Pour atténuer l'effet sur les petites collectivités de ce changement majeur de la politique de la commande publique, l'obligation pourrait être modulée suivant un critère organique afin de d'identifier quelles AC seraient concernées, un critère matériel (pour quels types de marchés ?), ou temporel (à partir de quand imposer cette obligation ?) et avec la possibilité de justifier le renoncement au dit critère.

Concernant l'entrée de ces critères dans le cadre juridique de la commande publique sénégalaise, ainsi que leur acceptabilité par les acteurs, une démarche progressive doit être recommandée afin de laisser aux entreprises le temps de s'adapter à la nouvelle politique d'achats publics. La généralisation de cette dernière prendra du temps et sera pertinente dès lors qu'il y aura convergence entre l'offre et la demande. Il faut enrichir le CMP d'explications concernant l'appréciation de l'offre économiquement la plus avantageuse, ainsi que le Guide explicatif. L'Offre économiquement la plus avantageuse autorise en effet l'AC à s'appuyer sur plusieurs critères et sous-critères tels que la qualité (notamment la qualité environnementale et/ou architecturale), l'innovation, l'expérience du personnel, la politique sociale, l'assistance technique ou la maintenance, le service de livraison.

Pour harmoniser le cadre juridique de la commande publique, le présent Rapport recommande de reprendre les termes de la récente loi du 2 mars 2021 sur les PPP. Elle énonce dans son Article 32, intitulé « Contenu local » : « *En fonction de l'objet du projet et du contexte social, économique et environnemental, les Autorités contractantes peuvent prévoir, parmi les critères d'attribution énoncés dans le dossier d'appel d'offres, des exigences liées au contenu local du projet de partenariat public-privé envisagé, notamment : a) les initiatives relatives à l'emploi et à la formation professionnelle ; b) les initiatives pour l'intégration des artisans et des petites et moyennes entreprises locales ; c) les actions et propositions concrètes en matière de développement durable* ». Large, cette formulation des critères devrait être reprise dans le CMP. On suggère toutefois d'y ajouter la mention des structures de l'économie sociale et solidaire en tant que sous-traitants potentiels et la prise en compte éventuelle des transferts de technologie et de la maintenance, l'accessibilité pour les personnes victimes de handicap le cas échéant, le délai de livraison ou d'exécution, qui doivent être énumérés dans le dossier d'appel à la concurrence et être exprimés en termes monétaire ou sous la forme de critères éliminatoires.



Recommandations :

¹¹¹ « il est ajouté à l'article L. 2152-7 (du Code de la commande publique) qu'au moins un des critères de sélection « prend en compte les caractéristiques environnementales de l'offre ». Cette formulation impose donc à l'acheteur d'intégrer l'environnement dans le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse. Ceci favorise l'analyse de la valeur économique d'une offre à l'aune de ses vertus écologiques et la prise en compte des externalités environnementales de la prestation. Cela impliquera désormais l'impossibilité de recourir au critère unique du prix ». Source : Projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, n° 3875 rectifié, présenté par M. Jean Castex, Premier ministre, et par Mme Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, 4 mars 2021.

- Art. 59 du CMP Prévoir des critères d'attribution clairs, vérifiables et non-discriminatoires. Inclure de nouveaux critères d'attribution :

Soit sur la base du prix,

Soit sur la base du prix et d'autres critères, voire sous-critères, tels que le coût d'utilisation, les performances techniques et énergétiques, les mesures concrètes de protection de l'environnement, les délais de livraison et d'exécution, la maintenance, l'accessibilité pour les personnes victimes de handicap le cas échéant. Dans le cadre de leurs achats publics durables à impact sur le contexte social, économique et environnemental, les Autorités contractantes peuvent prévoir, parmi les critères d'attribution énoncés dans le dossier d'appel à concurrence, des exigences liées au contenu local notamment : a) les initiatives relatives à l'emploi et à la formation professionnelle ; b) les initiatives pour l'intégration des artisans, des structures de l'économie sociale et solidaire, des petites et moyennes entreprises locales ; c) les actions et propositions concrètes en matière de développement durable dont la gestion des déchets». Ces critères et éventuellement sous-critères doivent être énumérés dans le dossier d'appel à la concurrence et être exprimés en termes monétaire ou sous la forme de critères éliminatoires.

-Art. 66 du CMP : Mentionner l'obligation de faire figurer ces critères dans l'avis d'appel à concurrence dans un ordre déterminé et non modifiable par la suite.

-Prévoir une entrée en vigueur progressive en renvoyant à un décret d'application et en utilisant dans ce dernier des dispositions d'entrée en vigueur différées (par seuils, par secteurs ou par produits)

§ 3 Introduire la possibilité d'un calcul des prix prenant en compte la durabilité



Le PNAPD a souhaité l'abandon progressif du seul critère du prix au profit de l'adoption du calcul du coût de cycle de vie (CCV). Cela signifie pour l'AC de ne pas uniquement considérer le prix final proposé dans l'offre mais d'inclure tous les coûts adjacents qui accompagnent la production (ou l'importation) d'une fourniture ou d'un service jusqu'à intégrer le coût de son recyclage ou de sa destruction. Cette approche dite en coût global requière néanmoins la maîtrise de paramètres qui peut être encore délicate à appréhender pour les AC. On ne peut envisager une entrée en vigueur prochaine de ce type de mode de calcul, sauf appui institutionnel dédié. Une montée forte en capacité sera nécessaire de la part des AC avant de développer le recours au CCV. En revanche, une exploration sélective peut être envisagée sur certains secteurs ou certains produits.

§ 3-1 Le calcul du coût complet de cycle de vie

Le prix du marché doit permettre de prendre en compte le coût complet du cycle de vie : La méthode du calcul du coût complet doit être développée dans le CMP car elle peut permettre de révéler que les produits biologiques ou fabriqués suivant des process qui prennent en compte la protection de l'environnement ne sont pas nécessairement plus chers que les produits classiques, comme les AC ont trop souvent tendance à le croire, comme l'ont révélé les entretiens menés. A l'heure actuelle, il n'existe qu'une définition partielle du « cycle de vie » dans le CMP qu'il convient d'approfondir. Il s'agit, suivant la définition mentionnée : de l'ensemble des étapes successives que peut connaître un produit, à savoir la recherche et le développement, le développement industriel, la production, la réparation, la modernisation, la modification, l'entretien et la maintenance, la logistique, la formation, les essais, le retrait et l'élimination. A laquelle il faut ajouter : La prise en compte de l'ensemble des coûts liés au cycle de vie complet du produit permet de faire apparaître dans le prix tous les coûts de fabrication, d'usage et de disparition du produit (recyclage, transformation, traitement des déchets). Ensuite un article du CMP doit renvoyer à cette méthode de calcul de prix. La méthodologie de calcul devra être expliquée dans les documents pédagogiques car c'est une méthode de calcul très récente et encore peu répandue. Mais il faut profiter de la

révision du CMP pour préciser son usage qui pourrait se développer dans certains secteurs (matériels informatiques à fort potentiel de recyclage par ex). Il s'agit de toutes façons d'une simple faculté laissée à l'appréciation des Acheteurs publics.



Recommandations :

- **CMP, Compléter la définition du CCV pour la rendre opérationnelle lors du calcul des prix**
- **art. 15 (Ajouter un alinéa) Dans le cadre des achats publics durables, l'Autorité contractante pourra signaler dans l'Avis d'appel à concurrence que les prix devront être calculés en appliquant la méthode de calcul du cycle de vie (CCV).**

- **CMP : Introduire dans le chapitre 4 « PRIX DES MARCHÉS » du CMP 2014 une définition et un mode d'emploi du prix à coût complet. (...) ; ainsi que dans l'Article 54 relatif au calcul de la valeur des marchés.**

Travaux futurs :

- **Dans le Guide explicatif, insérer la méthode de calcul du coût complet de cycle de vie ainsi que des exemples de son utilisation.**

Pour les mêmes raisons, l'introduction des principes de l'Economie circulaire doit être considérée avec prudence, même si certains volets peuvent être inscrits rapidement dans le droit positif. On peut ainsi prévoir dans les sous-critères environnementaux la possibilité pour l'AC d'exiger une certaine part de réemploi des produits. Par exemple dans l'hypothèse d'un marché de démolition ou de démolition/construction, le DAO pourrait exiger que certaines parties des ouvrages détruits soient réutilisées, y compris sous forme de gravats pour réaliser des remblais (en conformité avec les règles de construction).



Recommandations :

- **CMP : introduire et définir à l'article 4 le concept d'économie circulaire en renvoyant aux DAO la possibilité de s'y référer**

Travaux futurs :

- **Dans le Guide explicatif, insérer des explications et exemples d'économie circulaire**

§ 4 Utiliser les marges de préférence au profit des PME



Les marges de préférence sont appliquées à partir des prix proposés par les offres. Ce calcul (qui consiste à diminuer artificiellement le prix d'une offre, en fonction d'un pourcentage dit de « marge de préférence », avant de le comparer aux autres offres) intervient au moment de la phase d'attribution lors de l'évaluation des offres. Comme on l'a noté dans le Chapitre 1, le Sénégal a eu largement recours à cette technique pour créer des préférences au profit de certaines catégories d'entreprises, soit en fonction de leur nature (PME/ coopératives et groupements d'artisans) soit en fonction de leur origine (nationale ou communautaire/UEMOA), soit en combinant ces deux éléments. La préférence communautaire UEMOA (15%) s'applique en cas d'appel d'offres international (art. 50.1 CMP), tandis que la préférence (15%) en faveur des groupements d'artisans et autres (art. 50.1 §2 du CMP) doit intervenir lors des AON. Cependant, en l'absence de texte d'application, elle a été peu utilisée.

Pour instaurer ces marges de préférences dans la commande publique, la législation nationale s'est appuyée sur le cadre des Directives de l'UEMOA qui prévoit une marge de 15 % maximum en faveur des entreprises communautaires UEMOA¹¹² (ainsi qu'une marge pour les sous-traitants) mais elle a ajouté au CMP de 2014 une marge de 15% en faveur

¹¹² Dir. UEMOA 2005/04, Article 62 : De la préférence communautaire Lors de la passation d'un marché public ou d'une délégation de service public, une préférence doit être attribuée à l'offre présentée par une entreprise communautaire. Cette préférence communautaire remplace les préférences nationales existant dans les Etats membres. Elle doit être quantifiée sous forme de pourcentage du montant de l'offre. Un tel pourcentage ne peut en aucun cas excéder quinze (15) pour cent. La marge de préférence communautaire doit être prévue au dossier d'appel d'offres.

des artisans et autres structures de groupements dans le cadre des AON. Depuis, et en-dehors du cadre de la commande publique, la législation nationale s'est enrichie de plusieurs dispositions législatives pour multiplier les accès préférentiels à la commande publique. Toutefois, ces dispositions figurant dans des lois extérieures au CMP n'ont pas été reprises dans le CMP et n'ont pas été opérationnalisées. Pourtant, lorsque ces créations de marge de préférence sont de nature législative, elles s'imposent dans le cadre réglementaire des marchés publics régit par le décret de 2014. L'effort de consolidation doit donc conduire à les intégrer dans le CMP. En revanche, la loi sur les Startups dans son article 13 relatif aux marges de préférences instaurées en faveur des groupements ou de la sous-traitance avec des startups, n'a pas indiqué à quel niveau d'Appel d'offres cette marge devait jouer. Il faut en conclure qu'elle doit s'appliquer aussi bien pour les AOI que pour les AON.

D'autres marges de préférence pourraient être introduites, dans le respect des règles de l'UEMOA, c'est-à-dire en ne posant pas la condition de la nationalité sénégalaise pour en bénéficier, au moins dans les AOI, notamment en fonction de la catégorie des entreprises. Il existe déjà une marge en faveur des « *groupements d'ouvriers, aux coopératives ouvrières de production, aux groupements et coopératives d'artisans, aux coopératives d'artistes et aux artisans individuels suivis par les Chambres consulaires ainsi qu'aux organismes d'étude, d'encadrement ou de financement agréés* ». Cette marge doit conduire à augmenter les prix des offres des entreprises « classiques » de 15% à des fins d'évaluation. Si une entreprise « classique » et une de ces structures soumettent toutes deux des offres de 100 000 000 FCFA, l'autorité contractante appliquera un surcoût de 15% à l'offre « classique » qui passera à 115 000 000 FCFA. Si les deux offres remplissent les critères techniques, et que l'appel d'offres prévoit l'attribution au moins-disant, la petite structure obtiendra le marché. Mais la pratique a montré que ce dispositif ne fonctionnait pas car la marge ainsi accordée à ces structures ne compense pas les surcoûts auxquels elles sont exposées : leur offre demeure trop élevée même après application du rabais. Pour encourager ces structures, il vaut mieux rétablir une concurrence encadrée entre des candidats appartenant à des catégories similaires. Aussi :

- **Ce Rapport propose de supprimer cette marge de préférence de l'art. 50.1 §2 et de la remplacer par 2 dispositifs : celui des marchés réservés à ces catégories (regroupées sous l'appellation générique « structures de l'économie sociale et solidaire ») et de renforcer également leur accès à la sous-traitance (voir infra).**
- **Ce Rapport propose de réserver la marge de préférence de 15 % au profit des PME lors des Appels d'Offres Nationaux (AON) et d'instaurer une marge supplémentaire de + 5 % pour les PME dirigées par des femmes.**

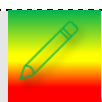
Le Rapport Carapaces (p. 56) avait en effet suggéré la prise en compte d'une marge de préférence « genre » en faveur des « PME dites féminines ». Cette marge pourrait jouer uniquement dans le cadre des AON, en cas d'égalité entre une PME nationale et une autre PME. « *Toutefois, dans le cadre de la préférence octroyée, si deux offres sont jugées de valeur égale, celle proposée par une entreprise féminine est considérée comme la moins-disante* ». Ce Rapport propose d'aller plus loin en appliquant une marge supplémentaire de 5% à l'offre des PME dirigées par des femmes.

Comme relevé supra, pour pouvoir actionner ce mécanisme, il faudra inclure dans le CMP une définition de la « PME à direction féminine » conforme à la définition de la PME nationale issue de la loi de 2020 relative aux PME. Le Rapport Carapace a suggéré : « *sera considérée comme PME féminine toute PME détenue et contrôlée directement et inconditionnellement à 51 % au moins par une ou plusieurs femmes ou entreprises féminines* ». En d'autres termes, la propriété doit être directe et ne peut être soumise à des conditions. Une femme doit gérer les opérations quotidiennes de l'entreprise et elle doit prendre les décisions à long terme pour l'entreprise. Ce Rapport propose de reprendre cette définition dans le CMP, de les nommer PME à « direction féminine » et de remplacer l'adverbe « inconditionnement » par « effectivement ».

Les systèmes de préférences, ou du moins certains d'entre eux, peuvent devenir obligatoires. C'est-à-dire que le CMP pourrait imposer le recours à la marge de préférence pour les PME sauf à l'Autorité contractante à démontrer pourquoi elle ne pouvait y avoir recours, en se fondant sur les caractéristiques du futur contrat ou sur l'état de secteur privé. C'est la ligne suivie par le SBA américain : poser un principe de recours aux PME avec l'obligation pour le *Contracting officer* de se justifier s'il décide de ne pas faire appel à des PME. La formulation du décret Tunisie de 2014 est à cet égard intéressante pour accompagner l'argumentaire justificatif : « *En cas d'impossibilité de réserver les marchés sus-indiqués au profit des petites entreprises dans la limite du pourcentage précité, pour des considérations techniques ou pour cause de défaut de petites entreprises pouvant être chargées de l'exécution desdits marchés, l'acheteur public doit en indiquer les raisons dans*

un Rapport qui sera transmis à l'organe de contrôle a priori. Ce Rapport est transmis à la haute instance de la commande publique ».

Cependant, il convient de remarquer que la loi sur les PPP du 2 mars 2021 vient d'abandonner le concept de marge de préférence qu'elle aurait pu perpétuer, au moins pour les DSP qui sont en principe toujours soumises aux Directives de l'UEMOA. Alors que se pose la question de l'harmonisation des règles au sein d'un régime des contrats de la commande publique, le débat autour du maintien des marges de préférences dans le droit des marchés publics mérite d'être posé. C'est la raison pour laquelle ce Rapport prend le parti de simplifier le dispositif des marges de préférences en le réservant aux PME, Startups (qui sont une sous-catégorie de PME) et PME dirigées par des femmes. Par cette simplification, les marges de préférences bénéficient seulement aux PME et sont dès-lors assimilées à des mesures qui participent de l'impact économique des APD. *A contrario*, les marchés réservés aux structures de l'économie sociale et solidaire (dans lesquelles figurent les Artisans, les sociétés coopératives, les GIE, les entreprises sociales) seront alors clairement associées au volet social des APD.



Recommandations :

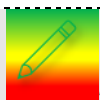
- Consolider dans le CMP les marges de préférences prévues par la législation sur les Startups :
- Loi sur les Startups du 6 janvier 2020 : Art. 13 : « *Le candidat à un MP, une DSP ou un contrat de partenariat (...) qui présente une offre en groupement avec une ou plusieurs startups, peut bénéficier d'une marge de préférence de 5%. Cette marge est cumulable avec toute marge prévue par la réglementation en vigueur.* »
- Réviser l'art 50.1 §2 pour l'accès à la commande publique, supprimer la marge de préférence en faveur des groupements ouvriers, artisans etc... et la remplacer par une marge de préférence en faveur des PME et startups. Ajouter une marge de préférence supplémentaire de 5 % en faveur des PME dirigées par une femme.
- Introduire dans le CMP une disposition relative aux marchés réservés aux structures de l'économie sociale et solidaire.
- Ajouter des dispositions pour l'accès des structures de l'économie sociale et solidaire à la sous-traitance
- *CMP définitions : inclure la définition de la PME dirigée par une femme.*

§ 5 Clarifier l'accès des PME à la sous-traitance

Le dispositif instauré, au fil du temps, en matière de marges de préférence conditionnées par la sous-traitance est relativement complexe, ce qui peut expliquer qu'il soit peu ou pas utilisé par les AC. Il faut en effet distinguer (1) les règles relatives aux marges de préférence applicables aux offres lorsque les candidats aux marchés peuvent s'engager sur les conditions des futurs sous-traitants, des (2) règles relatives à l'accès préférentiel à la sous-traitance pour certaines catégories d'entreprises. Les secondes dépendent des 1ères mais elles ont des conditions supplémentaires et elles pourraient permettre également d'élargir les bénéficiaires aux catégories que le Gouvernement souhaiterait vouloir encourager : les structures de l'économie sociale et solidaire ainsi que les PME à direction féminine.

Par ailleurs, et toujours selon l'article 48, *le titulaire d'un marché public de travaux ou d'un marché public de services peut sous-traiter l'exécution de certaines parties du marché jusqu'à concurrence de 40 % de son montant en recourant en priorité à des petites et moyennes entreprises de droit sénégalais ou à des petites et moyennes entreprises communautaires (UEMOA) à condition d'avoir obtenu l'accord préalable de l'Autorité contractante.* Mais ce dispositif ne prévoit pas de mesures précises d'implantation de cette préférence locale. Afin de combler ce manque, il est proposé d'indiquer à l'article 48 la possibilité d'accorder une marge de préférence cumulable de 5% au candidat qui s'engage à sous-traiter auprès des PME à direction féminine ou auprès de structures de l'économie sociale et solidaire.

Recommandations :



- CMP Consolider les préférences en matière de sous-traitance :- Loi sur les Startups du 6 janvier 2020 : Art. 13 : « Le candidat à un MP, une DSP ou un contrat de partenariat qui accepte de sous-traiter 30 % des prestations objet du contrat à une ou plusieurs startups labellisées (...) peut bénéficier d'une marge de préférence de 5%. Cette marge est cumulable avec toute marge prévue par la réglementation en vigueur. »

-CMP, art. 48 créer une marge de préférence pour encourager la sous-traitance des PME à direction féminine: Le candidat à un marché public qui aura prévu de sous-traiter 30 % des prestations objet du contrat à une PME (ou des PME) à direction féminine pourra bénéficier d'une marge de préférence de 5 cinq pour cent (5%). Cette marge est cumulable avec toute marge prévue par la réglementation en vigueur.

-CMP art. 48, créer une marge de préférence pour encourager la sous-traitance au profit des structures de l'économie sociale et solidaire.

Section 8 Organiser le contrôle des obligations de durabilité pendant l'exécution du marché



Pour assurer une commande publique responsable, il faut que les obligations sociales et environnementales soient effectivement respectées durant l'exécution du contrat. A cet égard il convient d'aligner le droit des marchés publics sur l'exigence prévue à l'article 44 de la loi n° 2021-23 sur les PPP du 2 mars 2021 qui charge l'autorité contractante « d'effectuer (...) d) le contrôle du respect par le titulaire des conditions contractuelles relatives à la sous-traitance aux petites et moyennes entreprises nationales ou communautaires, (...) ». Le respect des clauses contractuelles mais également la conformité aux exigences légales et aux spécifications et normes techniques ainsi que la mise en œuvre effective du PGES dans les marchés de travaux où il est exigé devront être contrôlés par l'AC, ou, le cas échéant, par son maître d'œuvre. Il en va bien évidemment de même de toutes les mesures à impact positif qui ont pu être insérées dans le contrat. Toutes ces dispositions ont un caractère obligatoire pour le Titulaire et les sous-traitants qui doivent s'efforcer de s'y conformer.

§ 1 L'obligation d'informer l'AC en cours d'exécution du contrat

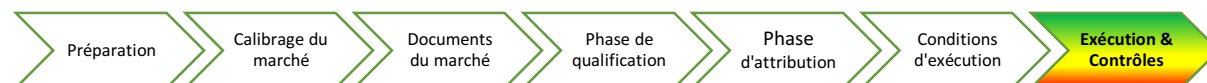
Dans les projets complexes du type PPP, l'entreprise doit remettre un Rapport annuel d'exécution. Ce Rapport constitue un moyen d'information et de contrôle de la personne publique. Il est en principe exigé dans le cadre des PPP à financement public¹¹³ ou dans les DSP, c'est-à-dire les PPP à financement par les usagers. Cependant, une telle exigence qui s'apparente à du « reporting » en matière de conformité ou compliance, pourrait également figurer dans les DAO des marchés de travaux les plus importants dont l'exécution s'étale sur plusieurs mois voire années.

Le CMP, et les DTAO correspondants pourraient être révisés pour inclure cette obligation de fournir un Rapport d'information dans le cas de marchés de travaux au-dessus de certains seuils et dont la durée d'exécution dépasse 1 an : « l'AC doit pouvoir être informée, notamment du respect des obligations contractuelles ainsi que des dispositions prises en matière de développement durable, de règles relatives à la santé, à la sûreté et la sécurité et à la protection de l'environnement ». Inclure un mécanisme de sanction en cas de non-respect de cette obligation d'information peut également être contemplé, comme l'organise la loi n°2018-40 du 05 juin 2018 portant régime des Contrats de Partenariat Public-Privé au Niger dans son art. 13 : « des pénalités sont prévues dans le contrat pour sanctionner les entraves aux contrôles exercés par l'autorité contractante ainsi que les manquements aux obligations contractuelles d'information et de communication mises à la charge du cocontractant ». Toutefois, à ce stade, il ne paraît pas opportun de faire peser cette

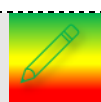
¹¹³ Voir la loi de la Mauritanie sur les PPP, ou l'article 29 (identique) du décret n° 2017 – 149 Portant application de la loi n°2015-039 du 3 février 2016 sur le PPP <http://www.droit-afrique.com/uploads/Madagascar-Decret-2017-149-application-loi-ppp-contrats.pdf>

nouvelle obligation à la fois sur l'entreprise qui doit fournir les informations et sur l'AC qui doit les collecter et les vérifier. Une telle disposition pourra être ajoutée si elle paraît nécessaire après quelques temps d'application du CMP révisé.

§ 2 Contrôle des conditions de la Sous-traitance et des régimes préférentiels



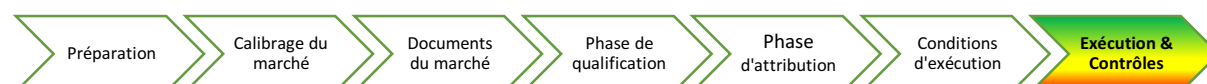
Il faut charger l'AC de contrôler la réalité de la sous-traitance au profit des catégories favorisées par la réglementation, notamment les PME locales et PME à direction féminine, ainsi que les structures de l'économie sociale et solidaire qui peuvent bénéficier des marchés réservés. En cas de violation des engagements pris, il faudra appliquer des pénalités sévères, voire prononcer la résiliation du contrat. L'article 44 de loi n° 2021-23 relative aux contrats PPP du 2 mars 2021 a d'ailleurs chargé l'autorité contractante « d'effectuer (...) d) le contrôle du respect par le titulaire des conditions contractuelles relatives à la sous-traitance aux petites et moyennes entreprises nationales ou communautaires, (...) ». Par ailleurs, afin de mieux piloter la sous-traitance et de lutter contre la sous-traitance non déclarée pour les projets d'envergure faisant appel à une multiplicité de prestataires, il est conseillé de partager un tableau de suivi régulièrement mis à jour, qui indique la nature et le montant des prestations sous-traitées par le titulaire.



Recommandations :

-CMP créer un nouvel alinéa à l'article 51 : *Suivant le régime préférentiel, l'Autorité contractante contrôle le respect par le titulaire des conditions contractuelles relatives à la sous-traitance, aux petites et moyennes entreprises nationales ou communautaires, aux structures de l'économie sociale et solidaire, l'emploi de la main d'œuvre nationale ou communautaire et l'utilisation des produits nationaux ou communautaires.*

§ 3 Faire respecter les obligations sociales et/ou environnementales



L'effectivité des mesures APD passe par la mise en place de contrôles lors de l'exécution du contrat. Ce contrôle doit porter sur les actions du titulaire afin de vérifier qu'il remplit effectivement ses obligations contractuelles. Mais s'ajoute également un contrôle sur les décisions prises par l'AC en matière d'APD.

§ 3-1 La vérification du respect des obligations APD par le Titulaire

Pendant l'exécution du marché, l'AC et ses services devront veiller à vérifier si le titulaire remplit effectivement ses obligations sociales et environnementales, qu'elles soient d'origine légale ou contractuelle. A défaut, l'AC devra prendre des mesures de rappel à l'ordre, de mise en demeure, de sanction contractuelle, voire de saisine du juge pénal en cas d'infractions graves à la réglementation. Si, dans l'exercice de son pouvoir de direction et de contrôle de l'exécution des obligations contractuelles, l'AC constate des manquements voire des violations manifestes, elle doit pouvoir disposer de plusieurs moyens, graduels, pour amener le Titulaire à faire face à ses responsabilités.

§ 3-2 L'incitation financière

L'incitation du Titulaire à remplir ses engagements peut être tout d'abord financière, en faisant du respect de toutes les clauses et spécifications sociales et environnementales une condition de paiement des factures de l'entreprise titulaire et de ses sous-traitants bénéficiant d'un paiement direct. Pour faciliter la vérification par l'AC, une liste des contrôles face aux prestations attendues peut être transmise à l'entreprise qui devra la remplir : après vérification par l'AC, les paiements

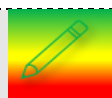
pourront ainsi être diminués, suspendus (sous forme de retenues provisoires) ou refusés si les justificatifs attestant du respect des normes sociales ou environnementales sont absents, insuffisants ou douteux.

La possibilité de créer une prime incitative dont l'ajout est proposé à l'article 137 doit également être considérée pour stimuler l'innovation du Titulaire en matière environnementale ou sociale. Afin de vérifier si l'obtention de la prime est bien justifiée, mais également pour aider l'AC dans sa tâche, la demande de prime sera adressée aux Autorités en charge du Fonds pour la promotion des achats publics durables dont la création pourrait être envisagée (infra Chap. 6 et 7).

§ 3-3 Le certificat de bonne exécution

L'autre incitation efficace passe par la délivrance d'un certificat de bonne exécution après vérification complète. Délivré après la fin du marché, c'est un élément qui devrait jouer un rôle important pour de futures candidatures. Les entreprises, notamment les PME qui débute dans la commande publique, vont être incitées à exécuter convenablement leurs prestations si elles veulent obtenir un certificat positif. La délivrance du certificat de bonne exécution tiendra compte du comportement du Titulaire. Le rappel à l'ordre et la crainte d'une publicité négative devrait inciter fortement les entreprises à se conformer à ces obligations.

Il faut d'ailleurs veiller à ce que ce mécanisme soit également mis en place pour constater la bonne exécution des parts sous-traitées : les PME sous-traitantes peuvent ainsi obtenir les justifications d'expérience qui leur seront par la suite nécessaires pour candidater directement aux marchés publics. L'AC doit donc veiller à remplir correctement le document qui pourra être décisif pour de futurs contrats.



Recommandations :

- S'inspirer, dans le CMP, de la disposition prévue dans la loi du 2 mars 2021 sur les PPP : **« le contrôle du respect par le titulaire des conditions contractuelles relatives à la sous-traitance aux petites et moyennes entreprises nationales ou communautaires, (...) ».**

-CMP : instaurer un certificat de bonne exécution

-CMP art 137 instaurer une prime : 2. Chaque fois que cela apparaît nécessaire à l'autorité contractante, une prime pour récompenser les innovations sociales ou environnementales intervenues lors de l'exécution peut être prévue dans les documents du marché. Avant la mise en paiement, la demande formulée par l'autorité contractante sera adressée aux Autorités en charge du Fonds pour la promotion des achats publics durables.

Travaux futurs :

Etablir un modèle de liste de vérifications pour le respect des obligations sociales, environnementales, d'hygiène, santé et sécurité

§ 3-4 Les Sanctions contractuelles

Le CMP devrait prévoir un cas de résiliation pour manquement aux obligations sociales. Actuellement le CMP organise, comme il est coutume, des pénalités forfaitaires en cas de retard du cocontractant¹¹⁴. Les autres sanctions correspondent à des hypothèses d'inexécution grave : exécution aux frais du titulaire dans les marchés de fournitures ou de transport, substitution d'entreprise (soit sous forme de mise sous séquestre du concessionnaire soit de mise en régie du titulaire du marché de travaux)¹¹⁵ et résiliation. On peut concevoir que ces sanctions soient appliquées pour des manquements graves aux obligations sociales, environnementales et d'hygiène, santé et sécurité. D'ailleurs le CMP confère

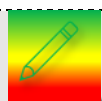
¹¹⁴ Article 134 : Pour assurer le respect des délais contractuels, les marchés doivent prévoir une clause de pénalités pour retard dont le montant est fixé, pour chaque catégorie de marchés, dans les Cahier des clauses administratives générales. Article 135 : A moins que le marché en dispose autrement, les pénalités pour retard sont appliquées sans mise en demeure préalable, sur la simple confrontation de la date d'expiration des délais contractuels d'exécution et de la date de réception. Le montant des pénalités infligées aux titulaires d'un marché vient en atténuation de la dépense. Dans le cas où le montant des pénalités ne peut être retenu sur les sommes dues, les pénalités sont versées en recettes au budget ayant supporté la charge du marché.

¹¹⁵ Code des obligations, Article 84 : « L'Administration peut, en cas de faute grave, substituer une autre personne au co- contractant défaillant pour assurer la continuité du service public. Cette sanction peut être appliquée en dehors de toute stipulation contractuelle ». Article 85, Les modalités de la substitution sont : - la mise sous séquestre du concessionnaire; - la mise en régie de l'entrepreneur; - l'exécution par défaut dans le marché de fournitures ou de transport. Voir aussi Article 136 CMP 2014.

à l'AC la possibilité de résilier unilatéralement le marché « notamment » en cas de manquement grave aux obligations contractuelles (seulement) environnementales. Le manquement grave à ces obligations pourra également constituer un cas d'interdiction qui pourrait conduire à écarter l'entreprise candidate à un futur contrat de la commande publique. Par ailleurs, en cas de manquement grave, il appartient à l'AC de signaler aux Autorités compétentes la violation qui a été constatée. Par exemple signaler aux inspecteurs du travail des conditions indignes pour les travailleurs ou des atteintes graves à la sécurité sur un chantier.

En revanche, il n'existe pas de mécanisme de sanction financière pour frapper les atteintes aux obligations sociales et environnementales du titulaire qui, sans aller jusqu'à justifier la résiliation, mériteraient néanmoins d'être 1) constatées 2) de faire l'objet d'une mise en demeure et 3) éventuellement d'une sanction financière. Outre le message fort que ce dispositif permettrait de porter à propos de l'importance du respect des exigences environnementales et sociales dans la commande publique, une telle sanction aurait le mérite d'étoffer l'éventail d'actions possibles et proportionnées offertes à l'AC. Faute de quoi, celle-ci ne peut qu'hésiter à manier les sanctions très lourdes que sont la mise en régie, la mise sous séquestre ou l'exécution aux frais du titulaire. Dans la pratique des marchés publics, on constate souvent une frilosité des AC à utiliser ces sanctions qui paraissent disproportionnées au regard des défauts d'exécution à réprimer.

L'acheteur ne peut toutefois appliquer des pénalités au titulaire du marché que si la méconnaissance des obligations contractuelles lui est imputable ou à l'un de ses sous-traitants et qu'elle a été dûment constatée. Une mise en demeure est donc nécessaire. Dans l'hypothèse d'atteinte aux règles d'hygiène, santé et sécurité ou de non-respect des obligations sociales et environnementales, le recours à une sanction financière forfaitaire, sur le modèle des pénalités pour retard, aurait de surcroît un caractère fortement incitatif puisqu'elle serait calculée par jour, jusqu'à la réparation du manquement. Elle permettrait ainsi d'obliger le titulaire à réparer au plus vite, en se conformant aux obligations contractuelles, sous peine de voir sa rémunération finale fortement diminuée.



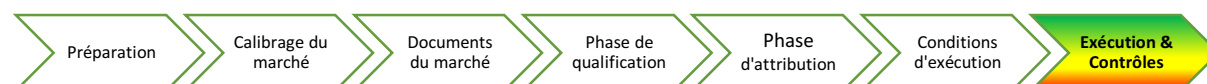
Recommandations :

- CMP : Introduire dans l'article 129 relatif à la résiliation pour faute, la possibilité de sanctionner **l'entreprise en cas de manquement grave à ses obligations contractuelles, notamment environnementales ou sociales.**

CMP : Créer un nouvel article après le titre du chapitre 2 relatif aux sanctions et primes : « Sans préjudice d'éventuelles poursuites pour violation des législations concernées, le non-respect des obligations sociales, environnementales ou d'hygiène, santé et sécurité, par le titulaire ou par son sous-traitant, peut conduire l'autorité contractante, après mise en demeure, à prononcer une sanction financière sous la forme d'une retenue forfaitaire journalière qui sera prélevée jusqu'à la cessation du manquement constaté.

Cette sanction est par ailleurs ajoutée à la liste des cas d'interdictions de candidater (art. 148).

§ 4 La vérification de l'effectivité des engagements des AC en faveur des APD



§ 4-1 Le contrôle a priori de l'engagement des AC en faveur des APD

D'après la suggestion de ce Rapport (**infra p...**) les AC vont devoir fixer, et atteindre, un objectif d'au moins 20 % de marchés APD dans leur plan annuel de passation de marchés. Pour l'instant, cette obligation qui n'entrera en vigueur qu'à partir du 1^{er} janvier 2022 ne concerne que les plus grandes AC (celles dont le budget dépassent un montant que les Pouvoirs publics devront fixer), tandis que les autres pourront volontairement se fixer un objectif annuel ou bien décider au cas par cas lors du lancement de leurs marchés d'adopter des dispositions APD.

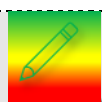
Afin d'atteindre ces objectifs, les AC doivent pouvoir bénéficier d'une aide ciblée pour déterminer les mesures APD adaptées à l'objet du futur contrat. Les AC, et particulièrement leurs cellules de passation de marchés, ne disposent à l'heure actuelle que d'une expertise très limitée voire inexistante en matière de développement durable. Certes, des programmes de formation seront déployés dans le cadre de la mise en œuvre du PNAPD mais il faut également leur apporter un service de conseils pour les accompagner dans leur démarche APD. Dès lors, il faut instaurer un bureau de conseil en APD à destination des AC auquel elles pourront soumettre leur projet de plan de passation de marchés afin de vérifier si les actions envisagées rentrent bien dans le dispositif des APD. Ensuite, et au cas par cas, et en fonction de leurs besoins, elles pourront également se tourner vers cette structure lors de la préparation des documents d'appel d'offres. Cette procédure doit rester facultative pour éviter des lourdeurs et blocages de l'attribution des contrats. Le recours à une structure d'appui permettra de concentrer l'expertise, encore trop rare, et d'assurer une montée en puissance des capacités. On peut en effet imaginer que des spécialistes de passation de marché venant d'autres ministères pourront effectuer des séjours de formation au sein de cette entité avant de retourner dans leurs CPM.

La localisation de cette aide ciblée au sein de l'appareil institutionnel doit être déterminée avec soins car il ne s'agit pas de créer un niveau supplémentaire de contrôle *a priori*, qui relèverait sinon de la DCMP, mais bien d'apporter une aide effective aux CPM lors de la phase de préparation de leurs documents d'appels à concurrence sous la forme d'un avis simple. Un avis qui n'engagera pas la responsabilité de la structure d'appui qui doit rester un service interne à l'administration active. Aussi, le service d'appui conseil de la DCMP pourrait être considéré à condition de :

- Former les agents de la DCMP aux APD ;
- Recruter au moins un spécialiste des APD dédié à ces questions ;
- Organiser une collaboration (à travers un Réseau interministériel qui devrait être piloté par l'ARMP (devenue ARCOP) avec la DEEC, l'AME, et le Ministère de l'Economie sociale et solidaire par des réunions régulières, afin d'évoquer les questions soulevées par les marchés. Cette collaboration doit également passer par la codirection de la plateforme dédiée aux APD (voir *infra*).

Dans le domaine des PPP, la vérification *a priori* des obligations sociales et environnementales à mettre en œuvre dans le cadre des projets PPP, devrait être confiée à l'organe d'appui en charge de superviser la préparation des contrats, éventuellement appuyée par des experts extérieurs. Au Bénin, ce rôle a été attribué à la Cellule d'Appui au Partenariat Public-Privé en République (art. 5 de la loi PPP)¹¹⁶. Elle doit notamment émettre un avis sur « *la part réservée aux opérateurs nationaux et communautaires dans la mise en œuvre du projet, le potentiel de création d'emplois pour les nationaux, les modalités de transfert de technologie* » et « *les mesures de protection de l'environnement et de promotion du développement durable* ».

Une autre option pourrait consister à concentrer toute l'expertise en un seul point focal qui assurerait le soutien pour tous les types de contrats de la commande publique, tout en animant la plateforme des APD qu'il faudra mettre en place au Sénégal pour accompagner les Acheteurs publics (voir *infra*).



Recommandations :

- CMP Art. 141, Ajouter : Dans le cadre de l'appui conseil, la Direction chargée du contrôle des marchés publics peut également accompagner la cellule de passation de l'autorité contractante sur les dossiers qu'elle lui soumet spontanément. Elle conseille, avec l'aide de la DEEC du Ministère de l'Environnement et du développement durable, sur les mesures relatives aux achats publics durables que l'autorité contractante souhaite introduire dans ses marchés.

+ Réviser les attributions de la DCMP via le décret n°547 du 25 avril 2007 portant création la Direction centrale des Marchés publics

¹¹⁶ Décret 2018-156, 2 mai 2018, portant attributions, composition et modalités de fonctionnement de la Cellule d'Appui au Partenariat Public-Privé en République du Bénin, art. 5.

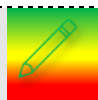
Travaux futurs :**Former les agents de la DCMP****Organiser un Réseau interministériels des APD**

§ 5-2 Le contrôle *a posteriori* des résultats atteints en matière d'APD

Le contrôle du respect des objectifs APD du marché : Le Guide des APD (2020) a suggéré (p. 59) de dresser un bilan régulier de la mise en œuvre des modalités APD qui ont été prévues pour chaque marché. Cette revue doit avoir lieu pendant l'exécution, à intervalle régulier, en vérifiant sur pièce et sur place que l'entreprise se conforme à ses engagements, en particulier pour éviter les engagements sociaux et environnementaux de façade et plus largement les tentatives de fraude. Après la fin du marché viendra également l'heure du bilan pour tirer les leçons de l'expérience menée, aussi bien dans ses aspects positifs (le nombre de personnes formées, les économies d'énergie réalisée, la satisfaction des riverains etc..) que négatifs (les retards éventuels et les surcoûts par exemple). Une réunion de fin de marché pourra permettre d'établir ce bilan global, en présence de tous les acteurs qui ont participé à son élaboration puis à sa réalisation, et ainsi recueillir les suggestions d'amélioration.

Le contrôle du respect des objectifs annuels : Si certaines AC, les plus importantes suivant leur budget, sont obligées de déterminer dans leur plan annuel de passation la liste des marchés relevant des APD à raison de leur objet ou de leurs modalités, elles seront également tenues d'atteindre une part minimale de 20 % de la valeur totale de leurs marchés consacrée aux APD. Par conséquent, elles devront faire apparaître les résultats atteints dans leurs Rapports annuels à envoyer à l'ARCOP ex-ARMP et à la DCMP. Mais il faut également saisir l'occasion de ce Rapport pour demander aux AC, du moins les plus importantes d'entre elles qui seront astreintes à cet exercice, un compte-rendu sur le respect des objectifs d'APD fixés dans le Plan annuel de passation de marchés. Cela permettra de réunir des données en matière d'APD, suivant un modèle de collecte et d'indicateurs à établir.

La DCMP étant chargée de collecter les données en provenance des AC, il convient de lui confier la tâche de collecter également les données relatives aux résultats des APD. Dans la mesure où, d'après l'article 144 du CMP, chaque CPM doit établir un Rapport annuel avant le 31 mars de chaque année, envoyé à l'AC dont elle relève, ainsi qu'à l'ARCOP ex-ARMP et à la DCMP, ce Rapport doit devenir l'occasion de faire un bilan sur les objectifs annuels d'APD.

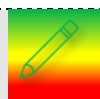
**Recommandations :**

- CMP Art 144 : *Chaque cellule de passation des marchés établit avant le 31 mars de chaque année à l'intention de l'autorité dont elle relève, de l'Organe chargé de la régulation des marchés publics et la Direction chargée du contrôle des marchés publics, un Rapport annuel sur l'ensemble des marchés publics passés l'année précédente. Entre autres informations, ce Rapport fournit la liste des entreprises défaillantes, précise la nature des manquements constatés, vérifie le respect des obligations sociales et environnementales par les titulaires et donne un compte rendu détaillé des marchés passés par entente directe. Ce Rapport doit également faire figurer les résultats obtenus dans la mise en œuvre des APD. Prévoir des objectifs chiffrés d'APD dans les PAPM et leurs résultats qui devront apparaître dans le Rapport annuel établi par la Cellule de passation des marchés de chaque AC. Réviser l'article 2 du Décret n° 2007-547 du 25 avril 2007 portant création la Direction centrale des Marchés publics afin de collecter des données des données et statistiques notamment celles relatives à l'attribution de marchés entrant dans les dispositifs APD (marchés réservés par catégories, données sur les sous-traitants, critères APD).*

Travaux futurs :**Etablir un modèle de collecte de données APD pour les AC****Inclure ces éléments dans les Guides explicatifs**

§ 5-3 Impliquer le contrôle *a posteriori* de l'ARCOP (ex-ARMP) et des audits

L'ARCOP participera au contrôle du respect des engagements APD des AC. L'effectivité de la prise en compte du développement durable dans la commande publique, en particulier lors du contrôle *a posteriori* des marchés exécutés, doit devenir un indicateur de résultats à mesurer dans les futurs audits commandés par l'ARCOP. Le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 charge en effet l'ARMP, dans son article 2.8 : « *de faire réaliser des audits techniques et/ou financiers en vue de contrôler et suivre la mise en œuvre de la réglementation en matière de passation, d'exécution et de contrôle des marchés et conventions ; dans ce cadre, l'ARMP commande, à la fin de chaque exercice budgétaire, un audit indépendant sur un échantillon aléatoire de marchés et conventions* ». Dès lors que la réglementation applicable aux marchés publics va être modifiée pour intégrer les dispositions favorables aux APD, il appartiendra à l'ARCOP de vérifier que ces éléments seront bien pris en compte par les futurs audits qu'elle lancera. Ces audits pourront ainsi examiner le respect par les Titulaires des obligations sociales et environnementales. A son tour, chargée de préparer et de « *transmettre au Président de la République, (...), au Président de l'Assemblée Nationale et au Président de la Cour des Comptes, un Rapport annuel sur l'efficacité et la fiabilité du système de passation, d'exécution et de contrôle des marchés publics (...), assorti de toutes recommandations susceptibles de l'améliorer* », l'ARCOP devra intégrer ces indicateurs qui contribueront à restituer une vision macro juridique des APD.



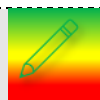
Recommandations :

- CMP Art 145 : - Ajouter au Rapport annuel préparé par l'ARCOP : « Ce Rapport doit également faire figurer les résultats obtenus dans la mise en œuvre des APD ».

Ajouter à l'article 2.8 du décret n° 2007-546 du 25 avril 2007, relatif aux audits techniques lancés par l'ARCOP, la vérification du respect des obligations sociales et environnementales des entreprises en charge de l'exécution des contrats.

§ 5-4 Envisager la possibilité de sanction financière contre les AC récalcitrantes

Afin d'obliger les AC à respecter leurs engagements en matière d'APD, une forme de pénalité financière pourrait être instaurée : les AC qui n'auront pas respecté l'obligation de consacrer 20 % de leurs achats annuels à des APD devront verser une contribution financière au Fonds en faveur de la promotion des APD. Le principe de la sanction des AC réticentes à suivre les objectifs d'APD s'inspire du modèle canadien. Sans aller jusqu'à la sanction individuelle des agents qui n'ont pas respecté ces objectifs, le modèle est intéressant à suivre dans la mesure où il démontre que la responsabilisation financière de l'AC peut avoir un effet dissuasif et éviter des négligences à répétition. Au Canada, la sanction peut prendre la forme d'une réduction de l'autonomie de dépenser de l'AC pour qui le seuil de contrôle *a priori* de ses décisions d'achats sera abaissé. Alternativement, on peut prévoir une retenue sur le budget alloué à l'AC, retenue qui pourra être versée au Fonds en faveur de la promotion des APD si ce dernier est créé.



Recommandations :

- CMP : TITRE VII – Sanctions applicables pour non-respect de la réglementation des marchés publics

Article XXX : Les AC soumises à l'obligation d'allouer 20 % de leurs marchés à des achats publics durables s'exposent à une sanction financière prononcée par l'ARCOP en cas de non-respect de leur objectif annuel. Les modalités de calcul du montant de la sanction seront fixées par arrêté et versées au Fonds de promotion des APD.

Travaux futurs :

Prévoir des objectifs chiffrés d'APD dans les Plans annuels de passation de marchés. Leurs résultats devront apparaître dans le Rapport annuel établi par la Cellule de passation des marchés de chaque AC transmis à la DCMP.

Adopter un décret portant création du fonds de promotion des APD géré par l'ARCOP

Tableau de synthèse des propositions de révision du CMP en faveur des APD

(Les propositions de révision sont surlignées en jaune)

Mesures APD	Sources	Dispositions
L'évaluation préalable des contrats de partenariat public-privé	Loi PPP (2021) article 21	Les projets de contrat de partenariat public-privé donnent lieu à une évaluation préalable, réalisée par l'autorité contractante et soumise à l'avis consultatif de l'UNAPPP. Les offres d'initiative privée font également l'objet d'une contre-expertise revue par l'UNAPPP. L'évaluation préalable fait apparaître les motifs à caractère économique, financier, juridique et administratif qui conduisent l'autorité contractante à engager la procédure de passation d'un tel contrat. Cette évaluation comporte une analyse comparative de différentes options, notamment en termes de coût global, de partage des risques et de profits, <u>ainsi qu'au regard des préoccupations de développement durable.</u> (...)
Principes de la commande publique (Absents du CMP Incomplets dans le COA)	CMP Art. 1	<u>Les marchés publics sont régis par les principes suivants : la concurrence, la liberté d'accès et l'égalité devant la commande publique, la transparence et l'intégrité des procédures. Dans leur attribution et gestion, les personnes désignées à l'article 2 obéissent également aux règles de bonne gouvernance, d'efficacité et de bonne utilisation des deniers publics. Elles tiennent compte des exigences et des objectifs du développement durable dans ses dimensions sociales, environnementales et économiques.</u>
DEFINITIONS		
Achat public durable (Nouvelle définition)	CMP Art. 4	<u>Achat public durable (APD) : achat par lequel l'Autorité contractante vise à répondre à son besoin tout en tenant compte d'une ou de plusieurs dimensions du développement durable : la dimension économique (favoriser l'accès des PME et des acteurs de l'économie sociale et solidaire), la dimension sociale (encourager la protection et l'accès à l'emploi des groupes vulnérables : femmes, jeunes, personnes victimes de handicap), la dimension environnementale (privilégier des achats écologiques et des techniques réduisant l'impact nocif sur l'environnement), acteurs de l'économie sociale et solidaire).</u>
Achat public responsable (Nouveau)	CMP Art. 4	<u>Tout achat public doit se conformer aux obligations existantes imposées par le droit sénégalais. Le candidat ou titulaire du marché est tenu de respecter les règles d'éthique, les dispositions du droit du travail notamment l'égalité de traitement homme-femme et l'interdiction du travail des enfants, les règles d'hygiène, de santé et de sécurité, les règles de protection de l'environnement et les règles techniques propres à l'objet du marché. L'engagement du candidat et titulaire est formalisé par l'adhésion à la Charte de l'Ethique et de la commande publique responsable.</u>
Appel d'offres international (AOI) (définition issue de la loi PPP du 2 mars 2021)	CMP Art. 4	<u>Correspond à l'appel d'offres qui utilise des moyens de publicité au niveau international et qui s'adresse aux personnes physiques et morales répondant aux critères d'éligibilité et de qualification définis dans le dossier d'appel d'offres</u>
Appel d'offres national (AON) (définition issue de la loi PPP du 2 mars 2021)	CMP Art. 4	<u>Correspond à l'appel d'offres qui utilise des moyens de publicité au niveau national et s'adresse aux personnes physiques et morales répondant aux critères d'éligibilité et de qualification définis dans le dossier d'appel d'offres.</u>
Circuit court local (Nouveau)	CMP Art. 4	<u>Exigence technique environnementale qui peut figurer dans le dossier d'appel d'offres afin de promouvoir l'utilisation de produits et de savoir-faire proches du lieu de consommation dans le but de réduire les transports et l'impact nocif sur l'environnement.</u>
Charte de l'Ethique et de la commande publique responsable (Nouveau)	CMP Art. 4	<u>: Engagement souscrit par le candidat lors du dépôt de son offre, par lequel le futur titulaire reconnaît qu'il devra exécuter le contrat en se conformant à la législation applicable sous peine</u>

		d'engager sa responsabilité contractuelle, sans préjudice d'autres responsabilités et condamnations éventuelles.
Cycle de vie (complément de définition pour la rendre opérationnelle)	CMP Art 4 Repris à l'art 15	l'ensemble des étapes successives que peut connaître un produit, à savoir la recherche et le développement, le développement industriel, la production, la réparation, la modernisation, la modification, l'entretien et la maintenance, la logistique, la formation, les essais, le retrait et l'élimination. La prise en compte de l'ensemble des coûts liés au cycle de vie complet du produit permet de faire apparaître dans le prix tous les coûts de fabrication, d'usage et de disparition du produit (recyclage, transformation, traitement des déchets).
Entreprise communautaire (définition issue de la loi du 7 janvier 2020 sur les PME)	CMP Art. 4	Entreprise dont le siège social est situé dans un Etat membre de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine. La PME de droit communautaire : toute entreprise individuelle, ou une société, immatriculée dans un des pays membres de la CEDEAO et de l'UEMOA dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes est inférieur ou égal à 2.000.000.000 FCFA.
Labels, normes, certificats, quitus, ou certifications (Nouveau)	CMP Art. 4	peuvent être exigés afin d'attester des compétences techniques, sociales ou environnementales. Internationaux ou nationaux, ils sont délivrés par des tiers suivant des procédures reconnues. Toutefois, l'autorité contractante doit veiller à offrir aux candidats la possibilité de proposer des attestations équivalentes.
Marché réservé (Nouveau)	CMP Art. 4	marché de travaux, de fournitures ou de services non intellectuels, d'un montant sous les seuils définis par arrêté ministériel, pour lequel les candidatures éligibles sont restreintes aux acteurs de l'économie sociale et solidaire telles que les Associations, Coopératives ouvrières ou artisanales, GIE, et entreprises sociales, ou les PME employant au moins 30 % de personnes victimes de handicap, ou 50 % de jeunes non qualifiés ou 50 % de femmes.
PME de droit sénégalais (définition issue de la loi sur les PME du 7 janvier 2020)	CMP Art. 4	: toute entreprise individuelle ou une société, immatriculée au Sénégal dont le capital est détenu par une ou des personnes physiques ou morales commerciale, artisanale, agricole, industrielle ou de prestataire de services, dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes est inférieur ou égal à 2.000.000.000 FCFA
PME à direction féminine : (définition inspirée du Rapport Carapace)	CMP Art. 4	« toute PME nationale au sens de la Loi d'orientation n° 2020-02 du 07 janvier 2020 relative aux Petites et Moyennes Entreprises, appartenant à ou contrôlée, directement et effectivement, par une ou plusieurs femmes ».
PME nationale (définition issue de la loi sur les PME du 7 janvier 2020)	CMP Art.4	toute entreprise individuelle ou une société de droit sénégalais dont le capital est détenu à 51%, au moins, par une ou des personnes physiques de nationalité sénégalaise ou par une ou des personnes morales de droit sénégalais et dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes est inférieur ou égal à 2.000.000.000 FCFA »
Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES) (Nouveau)	CMP Art. 4	document exigé dans les marchés de travaux importants ayant un impact social et/ou environnemental. Il est établi par le Titulaire à partir du modèle inclus dans le DAO, il est approuvé par l'Ingénieur, le maître d'œuvre ou le maître d'ouvrage, le cas échéant. Il doit reprendre les conclusions de l'Etude d'Impact Environnemental et Social (EIES) lorsque celle-ci a été réalisée en application de la réglementation issue du Code de l'Environnement. Les mesures à prendre en compte dans le PGES peuvent être de deux types : les mesures d'atténuation qui conduisent à une modification de la conception de l'ouvrage permanent et qui induisent une modification des spécifications techniques et des plans de l'ouvrage permanent ; ou bien les mesures et précautions à prendre dans le cadre de la gestion du chantier temporaire et de l'exécution du contrat, en y incluant le plan de gestion des déchets.
Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE)	CMP Art. 4	L'ensemble des actions mises en place par une entreprise afin de se conformer au respect de la réglementation existante, notamment à ses obligations éthiques, sociales et environnementales, à l'égard de son personnel, des autres entreprises participantes, et en tenant compte de l'impact de ses activités sur son environnement
Définition des besoins Insérer la prise en compte des ODD	CMP art. 5	Avant tout Appel à la concurrence, consultation, DRP, ou négociation, l'Autorité contractante est tenue de déterminer aussi exactement que possible la nature et l'étendue des besoins à satisfaire en prenant notamment en compte les objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale. Les fournitures, services ou travaux qui font l'objet de marchés doivent répondre exclusivement à ces besoins.

Plan annuel de passation de marchés (Insérer une nouvelle obligation de consacrer 20 % aux APD)	CMP art. 6	Nouvel alinéa 2 : Les Autorités contractantes qui ont un budget annuel supérieur à un montant défini par arrêté du Ministre de l'Economie et des Finances sont tenues de consacrer au moins 20 % de la valeur totale de leur marchés annuels aux achats publics durables.
Insérer une référence aux Labels et écolabels (nouveau)	CMP art 7 (dernier alinéa)	Ces normes, agréments, labels, écolabels et spécifications doivent être expressément mentionnés dans les cahiers des clauses techniques. L'Autorité contractante doit justifier le recours aux procédures dérogatoires mentionnées ci-dessus.
Division en lot (devient prioritaire)	CMP art. 8	Dans la mesure du possible, les travaux, fournitures ou services doivent être repartis en lots donnant lieu chacun à un marché distinct. La division en lots permet de faciliter la candidature des petites et moyennes entreprises et des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Ce choix ne doit pas avoir pour objet ou pour effet de soustraire les marchés aux règles qui leur sont normalement applicables en vertu du présent décret. Cependant, à condition de justifier son choix, l'Autorité contractante peut estimer que le marché unique ou global présente des avantages économiques, techniques ou financiers en fonction des caractéristiques de l'opération envisagée.
Pièces constitutives du marché (Nouveau - ajout de la Charte de l'Ethique et du DD)	CMP art. 11	et en général l'engagement de respecter les dispositions de la Charte de l'éthique et de la commande publique responsable adoptée par décret n° 2021....
Objet des Cahiers des charges (Ajout des SESS)	CMP art. 12	Les CCTG peuvent également prévoir des Spécifications fonctionnelles et des Spécifications Environnementales, Sociales, Santé et Sécurité (SESSS) qui définissent des obligations contractuelles que devra respecter le futur titulaire en matière environnementale, sociale, d'égalité de genre, de santé, d'hygiène et de sécurité.
Alinéa sur les sanction en cas de manquement aux obligations énoncées par la Charte	CMP art. 13	les pénalités et autres sanctions liées au manquement aux obligations énoncées par la Charte de l'Ethique et de la commande publique responsable ;
Contenu et caractère général des prix (Nouveau)	CMP art. 15	Dans le cadre des achats publics durables, l'Autorité contractante pourra signaler dans l'Avis d'appel à concurrence que les prix devront être calculés en appliquant la méthode de calcul du cycle de vie (CCV).
Interdiction de candidater aux marchés (Nouveau cas)	CMP art. 43 (g)	Les personnes physiques ou morales ayant fait l'objet d'une condamnation pour violation du droit du travail (notamment pour conditions de travail dégradantes, travail illégal des enfants ou discrimination des femmes), de la protection sociale et du droit de l'environnement (notamment pour faits de pollution, usage de produits toxiques, déforestation illégale).
Justification des capacités des candidats (insertion d'éléments d'appréciation des capacités sociales et environnementales des candidats)	CMP art 44	b) une note présentant le candidat et indiquant notamment ses moyens humains et techniques, sa démarche RSE le cas échéant, toutes informations utiles sur les activités et marchés réalisés de même nature que le marché concerné ; f) une déclaration attestant qu'il a pris connaissance des dispositions Une lettre d'engagement à respecter la Charte de l'éthique et de la commande publique responsable adoptée par décret et qu'il s'engage à les respecter ; h) des renseignements sur le savoir-faire du candidat en matière de protection de l'environnement, du respect des mesures d'hygiène, de santé, de sécurité, de genre, de développement social, le cas échéant . i) des labels, certifications et autres quitus attestant des process suivis par le candidat ou, à défaut, par équivalence, l'explication des méthodes adoptées et des dispositions prises pour atteindre le niveau d'exigence requis par les critères de qualification mentionnés dans les documents d'appels d'offres ; Le défaut de fournir la garantie de soumission à l'ouverture des plis, en-dehors des cas de dispense, entraîne le rejet de l'offre.
Justificatifs (nouveau : contrôle complet uniquement des documents de l'entreprise retenue)	CMP art 44	Rédaction alternative : Lors du dépôt de leur dossier, les candidats remettent tous les attestations, quitus et certificats en leur possession et, à défaut, les récépissés de demandes de ces documents auprès des administrations concernées. Les documents prévus aux alinéas a) à f), et éventuellement h), i) et j), non fournis ou incomplets seront tous exigibles auprès du seul candidat sélectionné lors

		de l'attribution provisoire. Les tentatives de fraudes qui pourraient être décelées à ce stade entraîneront l'exclusion de l'attribution des marchés publics prononcée par l'ARMP, la confiscation de la garantie de soumission, sans préjudice d'éventuelle action en réparation des dommages causés par les retards éventuels qui pourraient affectés la procédure d'attribution.
Attestations professionnelles (alignement sur les lois PME 2020 et Startups 2020)	CMP Art 46	Nouvel alinéa 2 : Pour les PME et les startups, les entrepreneurs et entrepreneuses doivent fournir les attestations d'agrément ou de labellisation prévues par la réglementation applicable.
Marge de préférence pour le groupement avec des startups (Nouveau – issue de la loi du 6/01/2020 sur les startups).	CMP art 47.9	Nouvel alinéa. Le candidat à un marché public qui présente une offre en groupement avec une ou plusieurs startups, peut bénéficier d'une marge de préférence de cinq pour cent (5%). Cette marge est cumutable avec toute marge prévue par la réglementation en vigueur.
Sous-traitance (rectification - Priorité aux PME locales)	CMP Art. 48	Le titulaire d'un marché public de travaux ou d'un marché public de services peut sous-traiter l'exécution de certaines parties du marché jusqu'à concurrence de 40 % de son montant en recourant en priorité à des petites et moyennes entreprises de droit sénégalais ou à des petites et moyennes entreprises communautaires à condition d'avoir obtenu l'accord préalable de l'Autorité contractante.
Sous-traitance (Nouveau – issu de la loi du 6/01/2020 sur les startups)	CMP Art. 48	Nouvel alinéa : Le candidat à un marché public qui aura prévu de sous-traiter 30 % des prestations objet du contrat à une ou plusieurs startups labellisées pourra bénéficier d'une marge de préférence de 5 cinq pour cent (5%). Cette marge est cumutable avec toute marge prévue par la réglementation en vigueur.
Sous-traitance (Nouveau – PME à direction féminine)	CMP Art. 48	Nouvel alinéa. Le candidat à un marché public qui aura prévu de sous-traiter 30 % des prestations objet du contrat à une ou des PME à direction féminine pourra bénéficier d'une marge de préférence de cinq pour cent (5%). Cette marge est cumutable avec toute marge prévue par la réglementation en vigueur.
Sous-traitance (Nouveau – Acteurs de l'économie sociale et solidaire)	CMP Art. 48	Nouvel alinéa. Le candidat à un marché public qui aura prévu de sous-traiter 30 % des prestations objet du contrat à un acteur ou des acteurs de l'économie sociale et solidaire pourra bénéficier d'une marge de préférence de 5 cinq pour cent (5%). Cette marge est cumutable avec toute marge prévue par la réglementation en vigueur.
Marge de préférence (Nouveau – PME à direction féminine)	CMP Art. 50.1 §2	Nouvel alinéa. Dans le cadre d'un Appel d'offres national, il est instauré une marge de préférence dite « genre » en faveur des PME à direction féminine. En cas d'égalité entre une PME nationale et une autre PME, une marge de 5 % sera appliquée à l'offre présentée par la PME féminine. Cette marge est cumutable avec toute marge prévue par la réglementation en vigueur.
Marge de préférence (Nouveau – Startups- groupement)	CMP Art. 50	Nouvel alinéa. Pour tous les appels d'offres, en application de la Loi sur les Startups du 6 janvier 2020, en son Art. 13, le candidat à un marché public qui présente une offre en groupement avec une ou plusieurs startups, peut bénéficier d'une marge de préférence de 5%. Cette marge est cumutable avec toute marge prévue par la réglementation en vigueur
Contrôle par l'AC du régime préférentiel (Nouveau – inspiré par la loi PPP 2/3/21)	CMP 51	Nouvel alinéa 3. Suivant le régime préférentiel, l'Autorité contractante contrôle le respect par le titulaire des conditions contractuelles relatives à la sous-traitance aux petites et moyennes entreprises nationales ou communautaires, l'emploi de la main d'œuvre nationale ou communautaire, l'utilisation des produits nationaux ou communautaires ou la direction effective des PME par des femmes.
Marchés réservés (Nouveau)	CMP Art. 52	Nouvel alinéa. 2. La participation aux Marchés réservés est restreinte aux structures de l'économie sociale et solidaire telles que les Associations, Coopératives ouvrières ou artisanales, GIE, et entreprises sociales, Artisans individuels, disposant de l'agrément ESS. L'Autorité contractante peut également recourir aux marchés réservés en invitant uniquement les acteurs de l'économie sociale et solidaire ou les PME employant au moins 30 % de personnes victimes de handicap, ou 50 % de jeunes non qualifiés ou 50 % de femmes. Un arrêté ministériel définit les seuils sous lesquels les marchés réservés sont possibles ainsi que la procédure de DRP à respecter.
Pièces constitutives du marché (Nouveau – PGES)	CMP Art. 58 b	les pièces constitutives du futur marché, notamment projet, date de soumission, Cahier des prescriptions spéciales, Cahier des clauses administratives générales, Cahier des clauses

		techniques générales, autres pièces requises en fonction de l'objet du marché, telles que le Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES) dans les marchés qui ont été précédés d'une Etude d'Impact Environnementale et sociale, ou qui sont susceptibles d'avoir un impact important sur leur lieu d'exécution.
Critères d'attribution- d'évaluation des offres de marchés publics (nouveau – remplacement de l'offre la moins disante par l'offre économiquement la plus avantageuse, ajout du critère social)	CMP Art 59 : Et correction aux articles 71, 72, 73, 74	La détermination de l'offre la moins disante économiquement la plus avantageuse est effectuée : 1. Soit sur la base du prix, 2. Soit sur la base du prix et d'autres critères, voire sous-critères, tels que le coût d'utilisation, les performances techniques et énergétiques, les mesures concrètes de protection de l'environnement, les délais de livraison et d'exécution, la maintenance, l'accessibilité pour les personnes victimes de handicap le cas échéant. Dans le cadre de leurs achats publics durables à impact sur le contexte social, économique et environnemental, les Autorités contractantes peuvent prévoir, parmi les critères d'attribution énoncés dans le dossier d'appel à concurrence, des exigences liées au contenu local notamment : a) les initiatives relatives à l'emploi et à la formation professionnelle ; b) les initiatives pour l'intégration des artisans, des structures de l'économie sociale et solidaire, des petites et moyennes entreprises locales ; c) les actions et propositions concrètes en matière de développement durable dont la gestion des déchets». Ces critères et éventuellement sous-critères doivent être énumérés dans le dossier d'appel à la concurrence et être exprimés en termes monétaire ou sous la forme de critères éliminatoires.
Critères de qualification des candidats (Pour plus de clarté, il serait recommandé d'introduire un article distinct portant uniquement sur la qualification)	CMP 59 al. 3.	2. La qualification du candidat qui a présenté l'offre évaluée la moins disante économiquement la plus avantageuse au regard des capacités juridiques, techniques, environnementales, sociales et financières requises est examinée indépendamment du contenu de son offre, au vu des justifications qu'il a soumises, en application des dispositions de la Section 2 du chapitre 2 du présent titre.
Offre anormalement basse	CMP 59 al. 4	.La commission des marchés compétente peut rejeter, par décision motivée, une offre qu'elle juge anormalement basse, si elle détermine que son montant ne correspond pas à une réalité économique par rapport à la prestation offerte, ou qu'elle ne respecte pas la réglementation en matière sociale et environnementale , après avoir demandé au candidat toutes précisions utiles concernant en particulier les sous détails des prix
Variante (Nouveau – solution environnementale ou sociale innovantes)	CMP Art. 62	Nouvel alinéa. Afin d'encourager les solutions environnementales ou sociales innovantes, l'Autorité contractante peut, lorsque le critère d'attribution est celui de l'offre « économiquement la plus avantageuse », demander aux candidats de proposer une variante répondant à des exigences techniques minimales pour laquelle ils devront justifier avec précision l'amélioration technique ou l'économie générée par la variante par rapport à la solution de base.
Avis d'appel à candidature (nouveau – ordre des critères)	CMP Art. 66	L'avis d'appel d'offres, établi conformément au modèle spécifié par décision de l'Organe chargé de la régulation des marchés publics, fait connaître au moins : a) l'objet du marché ; b) Les critères, dans un ordre déterminé et non modifiable par la suite, qui seront utilisés afin d'évaluer les offres
Evaluation des critères	CMP Art. 70	Elle propose à l'autorité contractante dans un délai maximum de quinze (15) jours à compter de la séance d'ouverture des plis, l'attribution du marché au candidat qui a l'offre conforme évaluée considérée comme la moins disante économiquement la plus avantageuse après évaluation des critères d'attribution et qui est reconnu réunir les critères de qualification mentionnés dans le dossier d'appel à la concurrence.
Critères de préqualification (nouveau critère)	CMP Art. 71	2. La préqualification des candidats s'effectue exclusivement en fonction de leur aptitude à exécuter le marché de façon satisfaisante et selon les critères suivants : a) références concernant des marchés analogues ; b) moyens matériels et humains dont les candidats disposent pour exécuter le marché ; c) capacité financière. d) capacités à gérer les obligations sociales et environnementales, le cas échéant
Achats de denrées alimentaires ou de semences (Nouveau)	CMP Art. 78	Pour l'achat de denrées alimentaires ou de semences, l'autorité contractante peut recourir à une procédure spécifique de DRP qui est déterminée par arrêté ministériel

Offre spontanée dans le domaine des APD (nouveau)	CMP Art. 81	(En Lien avec la loi sur les PPP) Ajouter un article pour encourager les offres spontanées de marchés publics portant sur le Développement Durable (DD) avec des seuils plus faibles inférieurs à 5 milliards. Le processus d'évaluation et de sélection de l'offre spontanée étant le même que celui de la loi PPP avec une évaluation mettant l'accent sur les dispositions spécifiques environnementales et sociales (un focus pourra être apporté sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre).
Garantie de soumission (Nouveau -exemption pour les marchés réservés)	CMP Art. 114	Pour les marchés réservés aux acteurs de l'économie sociale et solidaire et aux Artisans individuels, l'Autorité contractante a la faculté de ne pas exiger de garantie de soumission afin de faciliter leur accès à la commande publique. S'ajoute à : Les groupements d'ouvriers, les coopératives ouvrières de production, les coopératives d'artistes et les artisans individuels suivis par les chambres consulaires, les organismes d'études, d'encadrement ou de financement agréés, sont dispensés de fournir une garantie de soumission quand la valeur de soumission ne dépasse pas 50.000.000 de francs CFA.
Garantie de bonne exécution (Nouveau – exemption pour les marchés réservés)	CMP Art. 115 + modification de l'Arrêté N° 00866 du 22 janvier 2015	Pour les marchés réservés aux acteurs de l'économie sociale et solidaire et Artisans individuels, l'Autorité contractante a la faculté de ne pas exiger de garantie de bonne exécution afin de faciliter leur accès à la commande publique.
Cas de résiliation pour faute du marché public (Ajouter la résiliation pour manquement aux obligations sociales)	CMP Art. 129.1.	Tout marché public peut faire l'objet d'une résiliation totale ou partielle à l'initiative de l'Autorité contractante : a) en cas de manquement grave du titulaire à ses obligations contractuelles, notamment en matière environnementale ou sociale;
Pénalités pour non-respect des obligations sociales, environnementales ou d'hygiène-santé et sécurité (nouveau)	CMP Art. 133 (création nouveau)	Après le titre du chapitre 2 : des sanctions et des primes Sans préjudice d'éventuelles poursuites pour violation des législations concernées, le non-respect des obligations sociales, environnementales ou d'hygiène, santé et sécurité, par le titulaire ou par son sous-traitant, peut conduire l'autorité contractante, après mise en demeure, à prononcer une sanction financière sous la forme d'une pénalité forfaitaire journalière qui sera prélevée jusqu'à cessation du manquement constaté. Son montant est fixé, pour chaque catégorie de marchés, dans les cahiers des clauses administratives générales.
Prime (Nouveau – innovations sociales et environnementales)	CMP Art. 137	Nouvel alinéa : 2. Chaque fois que cela apparaît nécessaire à l'autorité contractante, une prime pour récompenser des innovations sociales ou environnementales intervenues lors de l'exécution peut être prévue dans les documents du marché. Avant la mise en paiement, la demande formulée par l'autorité contractante sera adressée aux Autorités en charge du Fonds pour la promotion des achats publics durables.
Sanctions des fautes commises par les candidats ou titulaires (Nouveau)	CMP Art. 148	f) a été convaincu d'avoir violé délibérément les obligations légales en matière de droit du travail, protection des salariés et respect des règles hygiène-santé-sécurité, ou les obligations relatives à la protection de l'environnement ;
APPUI INSTITUTIONNEL		
DCMP (Nouveau – appui conseil sur les APD avec la DEEC)	CMP Art. 141 + Réviser le décret n°547 du 25 avril 2007 portant création la Direction centrale des Marchés publics	Ajouter : Dans le cadre de l'appui conseil, la Direction chargée du contrôle des marchés publics peut également accompagner la cellule de passation de l'autorité contractante sur les dossiers qu'elle lui soumet spontanément. Elle conseille, avec l'aide de la DEEC du Ministère de l'Environnement et du développement durable, sur les mesures relatives aux achats publics durables que l'autorité contractante souhaite introduire dans ses marchés.
ARMP – contrôle a posteriori (Nouveau – prise en compte des APD)	CMP Art 145	Dans le Rapport annuel, l'ARMP devra dresser un bilan des résultats en matière d'APD b) peut initier et procéder avec ses moyens propres ou faire procéder à tout moment à des contrôles externes ou enquêtes portant sur la transparence et les conditions de régularité des procédures d'élaboration et de passation ainsi que des conditions d'exécution des marchés

	Révision du Décret n° 2007-546	publics et du respect des obligations sociales et environnementales par les titulaires et leurs sous-traitants ; article 2.8, relatif aux audits techniques lancés par l'ARMP, ajouter la vérification du respect des obligations sociales et environnementales des entreprises en charge de l'exécution des contrats.
Sanction financière des AC (Nouveau – pénalité)	CMP - création Art. 145 ??	création d'un article après le TITRE VII – SANCTIONS APPLICABLES POUR NON-RESPECT DE LA REGLEMENTATION DES MARCHES PUBLICS Les AC soumises à l'obligation d'allouer 20 % de leurs marchés à des achats publics durables s'exposent à une sanction financière prononcée par l'ARMP en cas de non-respect de leur objectif annuel. Les modalités de calcul du montant de la sanction seront fixées par arrêté après adoption du Décret portant création du Fonds de promotion des APD qui sera destinataire de la pénalité.
DCMP (Nouveau – collecte de données APD)	Décret n° 2007-547 du 25 avril 2007 portant création la Direction centrale des Marchés publics	Réviser l'article 2 afin de collecter des données des données et statistiques notamment celles relatives à l'attribution de marchés entrant dans les dispositifs APD (marchés réservés par catégories, données sur les sous-traitants, critères APD).

Tableau récapitulatif des textes d'application à réviser

DCMP (Nouveau – appui conseil sur les APD avec la DEEC)	Réviser le décret n°547 du 25 avril 2007 portant création la Direction centrale des Marchés publics	Ajouter : Dans le cadre de l'appui conseil, la Direction chargée du contrôle des marchés publics peut également accompagner la cellule de passation de l'autorité contractante sur les dossiers qu'elle lui soumet spontanément. Elle conseille, avec l'aide de la DEEC du Ministère de l'Environnement et du développement durable, sur les mesures relatives aux achats publics durables que l'autorité contractante souhaite introduire dans ses marchés.
DCMP (Nouveau – collecte de données APD)	Décret n° 2007-547 du 25 avril 2007 portant création la Direction centrale des Marchés publics	Réviser l'article 2 afin de collecter des données des données et statistiques notamment celles relatives à l'attribution de marchés entrant dans les dispositifs APD (marchés réservés par catégories, données sur les sous-traitants, critères APD).
ARMP – contrôle a posteriori (Nouveau – prise en compte des APD)	Révision du Décret n° 2007-546	Dans le Rapport annuel, l'ARMP devra dresser un bilan des résultats en matière d'APD b) peut initier et procéder avec ses moyens propres ou faire procéder à tout moment à des contrôles externes ou enquêtes portant sur la transparence et les conditions de régularité des procédures d'élaboration et de passation ainsi que des conditions d'exécution des marchés publics et du respect des obligations sociales et environnementales par les titulaires et leurs sous-traitants ; article 2.8, relatif aux audits techniques lancés par l'ARMP, ajouter la vérification du respect des obligations sociales et environnementales des entreprises en charge de l'exécution des contrats.
Charte de Transparence et d'Ethique replacée par la Charte de l'éthique et de la commande publique responsable	Révision Arrêté N°00861 du 22 janvier 2015	Arrêté fixant le modèle d'engagement des candidats à respecter les dispositions de la Charte de Transparence et d'Ethique en matière de Marchés publics, pris en application de l'article 44-f du Code des Marchés publics. Arrêté pris en application de l'article 115 du Code des Marchés publics

Seuil de dispense de la garantie de soumission	Révision N°00860 du 22 janvier 2015	Arrêté fixant les seuils en dessous desquels il n'est pas requis de garantie de soumission, pris en application de l'article 114 du Code des Marchés publics Arrêté fixant les seuils en dessous desquels il n'est pas requis de garantie de soumission
Seuil de dispense de la garantie de bonne exécution	Révision	Arrêté pris en application de l'article 115 du Code des Marchés publics Introduire la dispense pour les acteurs de l'économie sociale et solidaire ainsi que les Artisans
Création d'une procédure DRP pour les marchés de denrées alimentaires et les semences	Création	A partir de l'Arrêté DRP N° 00106 du 07 janvier 2015 Arrêté relatif aux modalités de mise en œuvre des procédures de demande de renseignements et de prix

Nouveaux formulaires

Plan de passation de marchés		Un nouveau formulaire modèle de plan de passation est établi pour tenir compte de la part du développement durable dans les marchés envisagés.

Chapitre 5 : REVISER LES DTAO POUR REFLETER L'HARMONISATION ET LA MODERNISATION NECESSAIRES AUX APD

La révision des DTAO en faveur de l'insertion de mesures ADP oblige à distinguer la prise en compte des mesures relatives à la commande publique responsable, des mesures de la commande publique à impact. Autrement dit, il faut distinguer les modifications qui doivent avoir un caractère obligatoire et général, et qui se traduiront alors par la révision de tous les DTAO, de celles qui demeureront optionnelles, à la discrétion des AC en fonction de leur stratégie APD. Afin de préserver la liberté de choix des AC, et de les accompagner vers une intégration progressive des objectifs et des techniques des APD, ce Rapport s'attache à proposer de rédiger des « DTAO APD » alternatifs, disponibles lorsque l'AC souhaite s'inscrire dans une démarche de développement durable. Ces « DTAO APD » conserveront un caractère alternatif mais les Autorités nationales pourront les rendre obligatoires si elles le décident. On attire néanmoins l'attention de l'ARCOP (ex-ARMP) sur la nécessité qu'il y aura à « toiletter » les DTAO « classiques » si les révisions ADP prônées pour le CMP sont mises en vigueur (notamment pour introduire l'obligation de conformité aux achats publics responsables considérée comme un socle minimal d'exigences).

Par ailleurs, il paraît nécessaire d'adopter une approche proportionnée en tenant compte du montant des contrats envisagés : plus les montants seront élevés plus les dispositions en faveur des APD pourront être nombreuses et prescriptives. Il faut également intégrer les niveaux très variables de capacités des AC dans la maîtrise des mesures APD. Aussi, pour respecter cet impératif d'adaptation du degré d'exigence et des attentes en matière de développement durable, suivre une démarche progressive permettra d'optimiser les résultats. En effet, entre les DTAO très simplifiés et les DTAO des grands marchés de travaux, il existe toute une gradation d'obligations et d'exigences dont il faudra tenir compte dans les prescriptions relatives aux APD. D'une part les DTAO révisés devront tous rappeler le socle de dispositions obligatoires auxquelles le Titulaire et ses sous-traitants doivent se conformer, mais dans un format allégé pour les petits marchés, et d'autre part les DTAO devront s'enrichir de mesures organisant les APD, dans une approche graduelle adaptée aux montants des marchés.

Concernant le fonds de la réforme, il existe 21 DTAO au Sénégal dont la grande majorité ne contient pas de dispositions adaptées aux APD (v. Chapitre 2). Au regard du respect des obligations légales, notamment de droit du travail (incluant hygiène, santé et sécurité), protection sociale ou promotion de l'égalité homme-femme, leur contenu est

caractérisé par une grande hétérogénéité, quelques DTAO mentionnant ces exigences et la plupart des autres les ignorant. Afin de promouvoir effectivement une commande publique responsable, les DTAO existants devraient mettre en œuvre l'obligation de conformité au cadre légal (Section 1).

Au-delà, la préoccupation de l'AC en faveur d'un impact réel sur le développement durable doit pouvoir être traduite dans les DAO par la mobilisation de mesures spécifiques APD insérées dans les documents types, mesures dont le principe aura été prévu dans le CMP révisé. Ces mesures vont figurer dans les documents appropriés du marché en suivant la chronologie de l'opération contractuelle. Pour les présenter, ce rapport va distinguer tout d'abord les mesures qui ont une vocation générale et que l'on peut par conséquent retrouver dans plusieurs DTAO, au à défaut dans des groupes de DTAO ayant des objets similaires (Section 2). Tandis que d'autres mesures sont plus spécifiques à l'un des 3 piliers des APD (Section 3)¹¹⁷.

Section 1 Les dispositions en faveur de la commande responsable à insérer dans tous les DTAO

Cette première action relève de la démarche de consolidation du droit applicable qui a été suivie précédemment pour la révision du CMP. Il ne s'agit pas de créer de nouvelles exigences juridiques mais seulement de rappeler aux parties la nécessité de se conformer aux lois en vigueur. C'est une traduction, dans les documents du marché, de l'obligation générale de conformité ou de *compliance* qui s'impose désormais aux entreprises afin d'assurer des achats publics responsables. **Elle va être matérialisée par le formulaire d'engagement à respecter la Charte de l'Ethique et de la commande publique responsable.** Ce rappel succinct dans les documents contractuels permettra d'éviter que le cocontractant n'ignore ces règles ou feigne de les ignorer. Incidemment, le rappel sera également bénéfique pour les Autorités contractantes qui devront mobiliser leurs équipes pour suivre plus scrupuleusement le bon déroulement de l'exécution des contrats. On peut parler à l'égard de ces règles de « socles de base » qui s'imposent aussi bien dans les relations commerciales que dans les achats publics, sans négociation ou aménagement possible entre les parties au contrat :

- **Rappeler les règles d'éthique et de lutte contre la corruption.** Cette exigence apparaissait déjà dans la plupart des DTAO à travers l'engagement d'adopter la Charte de Transparence et d'Ethique. Il convient néanmoins de généraliser ce rappel à toutes les procédures avec l'adoption de la nouvelle Charte de l'Ethique et des Achats publics responsables (voir Annexe X).
- **Rappeler les règles du droit du travail et de la protection des salariés,** y compris par référence aux conventions de l'OIT. Concernant les obligations tirées du droit du travail, notamment des exigences en matière d'hygiène, de santé et de sécurité, il importe de signaler leur caractère impératif, quel que soit le type de contrat. Non seulement le Titulaire devra veiller à s'y conformer, par exemple sur les chantiers des marchés de travaux, mais il devra également s'assurer que ses sous-traitants s'y conforment. La personne publique devra en conséquence exercer un contrôle actif et vérifier le bon respect de ces obligations légales.
- **Rappeler les exigences du droit de l'environnement et des droits connexes.** Il en va de même des interdictions tirées du droit de l'environnement, notamment des interdictions de polluer, d'utiliser des matières dangereuses ou encore d'utiliser des sacs plastiques telle qu'elle est désormais proclamée par la loi sénégalaise. Pour les marchés de travaux on y associera la mention, entre autres, du respect du droit de la construction, du droit de l'énergie ou encore du droit de l'assainissement.

Ce dispositif permet de formaliser l'engagement du titulaire et donc également sa responsabilité en cas de manquement. Il faut veiller à ce que ladite Charte soit également signée par les sous-traitants dans le cadre de leur contrat de sous-traitance et/ou dans le cadre de la mise en œuvre du mécanisme de paiement direct par l'autorité contractante.

Ces obligations générales pourront être renforcées et détaillées dans les cahiers des clauses techniques, à travers les Spécifications Environnementale, Sociales, Santé et Sécurité (ESSS), en particulier dans les grands marchés de travaux où les exigences seront plus précises. Cela permettra d'ajouter la prise en compte des questions de santé, pratiquement

¹¹⁷ Avertissement méthodologique : en raison de leur volume (plus de 2000 pages), les DTAO révisés n'ont pas été inclus dans le Rapport initial de 2021.

absentes des DTAO actuels, aussi bien dans les spécifications techniques que dans les clauses des CCAG. Enfin, ce rappel à la conformité aux règles applicables ayant une vocation très générale, les clauses préparées par l'AC pourront spécifier les obligations légales qui seraient propres au marché :

(par exemple) « *L'Entrepreneur doit, lors de la conception, l'exécution et l'achèvement des Travaux et Services et durant la période de garantie : [...] assurer la sécurité des personnes employées par lui ou par ses sous-traitants, et maintenir le Site (tant que celui-ci se trouve sous son contrôle) en bon ordre, de manière à éviter tous risques pour les personnes* ».

§1 Insérer un nouveau cas d'interdiction de candidater dans les IC

Conformément à la proposition d'introduire un nouveau cas d'interdiction de candidater à l'article 148 du CMP afin de renforcer l'application d'une commande publique responsable, les IC des DTAO devront reprendre cette hypothèse d'interdiction : sera interdit tout candidat qui « *a été convaincu d'avoir violé délibérément les obligations légales en matière de droit du travail, protection des salariés et respect des règles hygiène-santé-sécurité, ou les obligations relatives à la protection de l'environnement* ».

§2 Encadrer le rejet des offres anormalement basses

L'AC compétente peut rejeter, par décision motivée, une offre qu'elle juge anormalement basse, si elle détermine que son montant ne correspond pas à une réalité économique par rapport à la prestation offerte, ou qu'elle ne respecte pas la réglementation en matière sociale et environnementale, après avoir demandé au candidat toutes précisions utiles concernant en particulier les sous détails des prix.

§3 Insérer des clauses favorisant l'exécution responsable

- **Clauses à destination des sous-traitants** : Il importe de clarifier dans le CCAG les obligations qui pèsent sur les sous-traitants dans les clauses d'exécution comportant des considérations sociales et/ou environnementales.
- **Clause de dialogue** : Afin de prévenir les risques d'incidents ou d'incompréhension des exigences contractuelles, l'usage s'est répandu de prévoir une solution de dialogue entre l'acheteur et le titulaire pendant toute la durée du contrat. Elle débute par une réunion de lancement qui sera suivie de rendez-vous régulier, parfois même hebdomadaire. Cette méthode est particulièrement adaptée lorsque le titulaire est une PME qui a besoin d'être bien encadrée. Il participe également de la connaissance mutuelle des contraintes de la personne publique et de son titulaire, de manière à tirer le meilleur parti des capacités réciproques.
- **Clauses de sanction en cas de manquement aux obligations sociales ou environnementales**. L'autorité contractante doit disposer dans son cahier des charges, de sanctions adaptées avec des clauses qui précisent dans quels cas ces pénalités seront imposées, leur nature et leur montant. L'usage des pénalités peut constituer un outil contractuel efficace, dans le cadre d'un suivi d'exécution à échéance régulière. En référence, le nouvel article 133 du CMP devrait prévoir : *Sans préjudice d'éventuelles poursuites pour violation des législations concernées, le non-respect des obligations sociales, environnementales ou d'hygiène, santé et sécurité, par le titulaire ou par son sous-traitant, peut conduire l'autorité contractante, après mise en demeure, à prononcer une sanction financière sous la forme d'une pénalité forfaitaire journalière qui sera prélevée jusqu'à cessation du manquement constaté. Son montant est fixé, pour chaque catégorie de marchés, dans les cahiers des clauses administratives générales.*
- **Clause de résiliation pour manquement aux obligations sociales ou environnementales** : Cette clause devrait être prévue en application de la proposition d'un nouvel article 129.1 qui ajoute, parmi les cas de sanctions résolutoires, le manquement aux obligations sociales aux obligations environnementales qui figuraient déjà dans la version de 2014.

Section 2 Préparer des DTAO spécifiques « APD » afin de promouvoir leur impact positif

Outre la révision des DTAO existants, ce rapport propose également de préparer un nouveau jeu de DTAO incluant des dispositions APD « à impact ». Les AC auront ainsi le choix : soit d'utiliser les DTAO « classiques » mentionnés *supra* dans lesquels auront été insérées des exigences minimales pour assurer des achats publics responsables, soit d'utiliser des « DTAO-APD » afin de renforcer l'impact positif de leur stratégie de développement durable en faisant appel à des mesures

sociales et/ou environnementales adaptées aux caractéristiques du futur marché et mobilisables aux différents stades de sa passation.

§1 Préciser les critères de qualification des candidats

La rédaction actuelle des DTAO sénégalais, en particulier de leurs Instructions aux candidats (IC), survalorise l'étape de la qualification : les critères de qualification des entreprises deviennent des substituts à l'absence de critères d'attribution qualitatifs. La formule du DTAO Marchés publics travaux de grande taille, (I.C art. 37), que l'on retrouve dans d'autres DTAO, est emblématique de cette tendance : « *L'Autorité contractante attribuera le Marché au Candidat dont l'offre aura été évaluée la moins-disante et jugée substantiellement conforme au Dossier d'appel d'offres, à condition que le Candidat soit en outre jugé qualifié pour exécuter le Marché de façon satisfaisante* ». Plus significative encore, la rédaction du DTAO sur les Passation d'Accords-cadres pour des marchés de travaux (Janv. 2020) : (34.2 des IC) : « *Si le prix ne constitue pas un critère d'évaluation, comme indiqué dans les DPAO, l'Autorité contractante comparera uniquement les qualifications des candidats dont les offres ont été jugées substantiellement conformes à l'issue de l'évaluation technique (...)* ».

Aussi, pour des raisons de clarté et de sécurité juridique, les DTAO devraient :

- Enoncer précisément les critères de pré-qualification et de qualification ainsi que les justifications de capacités que doivent apporter les candidats ;
- Séparer clairement les critères de qualification des critères d'attribution.

Concernant les critères de préqualification ou qualification, il convient de mentionner dans les DTAO:

- Que l'appréciation s'effectue exclusivement en fonction de leur aptitude à exécuter le marché de façon satisfaisante et selon les critères suivants
 - a) références concernant des marchés analogues ;
 - b) moyens matériels et humains dont les candidats disposent pour exécuter le marché ;
 - c) capacité financière.
 - d) capacités à gérer les obligations sociales et environnementales avec :
 - la possibilité des renseignements sur le savoir-faire du candidat en matière de protection de l'environnement, du respect des mesures d'hygiène, de santé, de sécurité, de genre, et de développement social, le cas échéant .
 - la possibilité pour l'AC de mentionner des labels, certifications et autres quitus attestant des process suivis par le candidat ou, à défaut, par équivalence, l'explication des méthodes adoptées et des dispositions prises pour atteindre le niveau d'exigence requis;
 - le cas échéant la possibilité de prendre en compte la démarche RSE des candidats et des attestations fournies par les clients des entreprises ;
- Les justifications à apporter par les candidats doivent être précisées dans le DAO, en particulier pour les candidats qui bénéficient de mesures préférentielles :
 - Pour les PME et les startups, les entrepreneurs et entrepreneuses doivent fournir les attestations d'agrément ou de labellisation prévues par la réglementation applicable.
 - Pour les Artisans, attestations d'agrément ou de labellisation prévues par la réglementation applicable.
 - Pour les Artistes : (*justificatif à identifier*)
 - Pour les structures à vocation sociale ou éducative

Si le futur marché (en particulier de travaux) répond simultanément à plusieurs piliers, des certifications aux critères de qualification pourront être ajoutées pour exiger des capacités groupées : dont la certification ESSS (qualification environnementale, sociale, santé et sécurité) telle qu'une certification ISO ou norme internationale équivalente (l'équivalence est à démontrer par le candidat), en cours de validité applicable au Chantier :

- certification de gestion de qualité ISO 90001 ;
- certification de gestion de la santé et de la sécurité ISO 45001

A défaut, ou en plus, les candidats devront fournir une documentation ESSS, c'est-à-dire des documents de stratégie et procédures internes à l'entreprise qui seront jugées acceptables par le MO : avec, par ex,

- existence d'un dispositif de contrôle du respect des engagements ESSS pour les sous-traitants et autres partenaires,
- procédures spécifiques pour gérer des situations particulières au contrat dont : recrutement local et formation ESSS de la main d'œuvre locale (renforcement des capacités) des sous-traitants et partenaires locaux.
- Expérience ESSS, ex-chantier avec transfert de connaissance à un partenaire local ou formation de la main-d'œuvre locale ;
- Experts ESSS ; disponibilité dans l'entreprise d'Experts dédiés ES et expert santé et sécurité.

§ 2 Mentionner les cas de dispense de la garantie de soumission dans les Instructions aux Candidats

Les cas antérieurs : Les groupements d'ouvriers, les coopératives ouvrières de production, les coopératives d'artistes et les artisans individuels suivis par les chambres consulaires, les organismes d'études, d'encadrement ou de financement agréés, sont dispensés de fournir une garantie de soumission quand la valeur de soumission ne dépasse pas 50.000.000 de francs CFA.

Les nouveaux cas : Pour les marchés réservés aux structures de l'économie sociale et solidaire, l'Autorité contractante a la faculté de ne pas exiger de garantie de soumission afin de faciliter leur accès à la commande publique.

§ 3 Enoncer les critères d'attribution et la méthodologie de l'évaluation de l'offre économiquement la plus avantageuse

La nouvelle rédaction des IC doit présenter les modalités de l'évaluation de « l'offre économiquement la plus avantageuse ». La détermination de « l'offre économiquement la plus avantageuse » est effectuée à partir des critères suivants :

- Soit sur la base du prix,
- Soit sur la base du prix et d'autres critères, voire sous-critères, tels que le coût d'utilisation, les performances techniques, les initiatives relatives à l'emploi et à la formation professionnelle, les initiatives pour favoriser la participation des PME, des artisans ou structures sociales locales en tant que sous-traitants, l'accessibilité pour les personnes victimes de handicap le cas échéant. Peuvent s'ajouter les critères suivants :
 - La qualité, y compris la valeur technique et les caractéristiques esthétiques ou fonctionnelles, l'accessibilité, l'apprentissage, la diversité, les conditions de production et de commercialisation, la garantie de la rémunération équitable des producteurs, le caractère innovant, les performances en matière de protection de l'environnement, d'essor des approvisionnements directs de produits de l'agriculture, d'insertion professionnelle des publics en difficulté, la biodiversité, le bien-être animal;
 - Les délais d'exécution, les conditions de livraison, le service après-vente et l'assistance technique, la sécurité des approvisionnements, l'interopérabilité et les caractéristiques opérationnelles ;
 - L'organisation, les qualifications et l'expérience du personnel assigné à l'exécution du marché lorsque la qualité du personnel assigné peut avoir une influence significative sur le niveau d'exécution du marché.
 - D'autres critères peuvent être pris en compte s'ils sont justifiés par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution. Les critères d'attribution retenus doivent pouvoir être appliqués tant aux variantes qu'aux offres de base. Ils doivent être énumérés dans le dossier d'appel à la concurrence dans un ordre précis qui ne peut ensuite être modifié. Quant au calcul du poids respectif de ces critères, les analyses *supra* ont montré que le calcul des critères exprimé en termes monétaire paraissent mieux adaptées aux grands marchés car il nécessite une expertise plus rare à réunir pour les petits marchés. Pour ceux-ci la question du recours à la technique de la notation et de la pondération des critères devra être tranchée.

§ 4 Autoriser les variantes

Afin d'encourager les solutions environnementales ou sociales innovantes, l'Autorité contractante peut, lorsque le critère d'attribution est celui de l'offre « économiquement la plus avantageuse », demander aux candidats de proposer une

variante répondant à des exigences techniques minimales pour laquelle ils devront justifier avec précision l'amélioration technique et/ou l'économie générée et/ou l'impact environnemental ou social envisagé par la variante par rapport à la solution de base.

§ 5 Insérer des Clauses du CCAG relatives aux modalités d'exécution favorisant les APD

- **Clause relative au contenu « local »** : La mise en place de conditions particulières d'exécution peut aboutir à favoriser la dimension locale. Par exemple exiger un approvisionnement en circuit court dans les marchés de fournitures constitue un levier efficace pour offrir des perspectives aux fournisseurs « locaux » (c'est-à-dire sénégalais et communautaires). Favoriser les circuits courts permet également de satisfaire des exigences environnementales (en réduisant l'impact du transport des marchandises), tout en offrant des débouchés aux producteurs locaux (accès des PME) voire aux GIE ou coopératives de femmes pour satisfaire le critère social.
- **Prime et clauses incitatives à l'innovation sociale ou environnementale** : ces clauses vont permettre de préciser dans le cadre des contrats la possibilité d'une prime ESS dont le principe est désormais inscrit dans le CMP (art. 137).
- **Clause d'exemption de la garantie de bonne exécution pour les marchés réservés** : *Pour les marchés réservés aux artisans individuels, entreprises sociales, GIE, PME féminines, l'Autorité contractante a la faculté de ne pas exiger de garantie de bonne exécution afin de faciliter leur accès à la commande publique.*

Section 3 Introduire dans les DTAO des mesures ajustées aux piliers des APD

Face à la grande variété de mesures APD qui peuvent être déployées, l'AC doit être en mesure de sélectionner celles qui lui paraissent les plus adaptées à sa stratégie. Non seulement l'AC peut annoncer d'emblée dans la désignation même du marché lors de la publication de l'avis d'appel à concurrence, qu'elle entend procéder à un APD, (par exemple avec un intitulé « *marché public écologique de...* » ou « *marché public social de...* ») mais elle devra ensuite traduire cette orientation dans la rédaction de son DAO, et éventuellement à divers endroits du DAO (Instruction aux candidats pour les conditions de participations avec éventuellement recours aux marchés réservés ou marges de préférences, puis les critères de qualification des candidatures ou d'attribution des offres utilisés ; spécifications techniques et obligations d'exécution posant des clauses sociales et/ou environnementales). Autant d'étapes qui jalonnent la rédaction et qui doivent traduire les choix de l'AC pour accentuer plus ou moins l'impact social ou environnemental du futur marché. Dans ces conditions, les Documents type ont vocation à proposer les principales mesures qui peuvent appuyer la « durabilité » des futurs marchés publics, suivant les objectifs (social, environnemental ou économique, voire une combinaison de ceux-ci) que l'AC souhaite poursuivre.

Il convient également de tenir compte de la diversité de nature et d'objet des marchés publics. Par exemple, les obligations environnementales seront a priori plus nombreuses dans un marché de travaux en raison des incidences potentielles des travaux sur l'environnement, que dans un marché de services. Pour cette raison, les questions spécifiques ont été regroupées, avec des commentaires consacrés aux DTAO des travaux, aux DTAO des fournitures et aux DTAO des prestations intellectuelles.

§ 1 Insérer des mesures dans les DTAO renforçant l'impact social

Insérer des critères de qualification permettant d'évaluer les capacités sociales des candidats

Dans le cadre des marchés de travaux, si les impacts du futur chantier paraissent devoir être conséquents, des certifications aux critères de qualification pourront être ajoutées pour préciser les capacités attendues :

- dont la certification ESSS (qualification environnementale, sociale, santé et sécurité) telle qu'une certification ISO ou norme internationale équivalente (l'équivalence est à démontrer par le candidat), en cours de validité applicable au Chantier :
 - certification de gestion de qualité ISO 90001 ;
 - certification de gestion de la santé et de la sécurité ISO 45001
- A défaut, ou en plus, les candidats devront fournir une documentation ESSS, c'est-à-dire : des documents de stratégie et procédures internes à l'entreprise qui seront jugées acceptables par le MO : par ex :
 - existence d'une charte d'éthique dans l'entreprise,

- existence d'un dispositif de contrôle du respect des engagements ESSS pour le sous-traitant et autres partenaires,
- procédures spécifiques pour gérer des situations particulières au contrat dont : recrutement local et formation ESSS de la main d'œuvre locale (renforcement des capacités) des sous-traitants et partenaires locaux.

Tous ces éléments peuvent apparaître sous la dénomination « RSE » dans la démarche de l'entreprise.

Au titre de l'évaluation de l'expérience ESSS, le DAO pourra exiger des exemples de chantiers antérieurs avec transfert de connaissance à un partenaire local ou formation de la main-d'œuvre locale, ou précisément de Jeunes, etc...

Concernant le personnel spécialisé, l'AC pourra exiger personnel mis à dispositions, un Expert dédié questions Sociale et/ou un expert « santé et sécurité ».

Insérer des Clauses d'exécution à vocation sociale

L'insertion et la formation des personnes éloignées de l'emploi par le biais d'une clause sociale d'exécution. La clause sociale d'exécution permet « d'imposer aux entreprises soumissionnaires de s'engager à consacrer une part du marché, sous forme d'heures de travail, à la réalisation d'une action d'insertion professionnelle pour les publics éloignés de l'emploi »¹¹⁸. Elle vise donc l'insertion directe de publics rencontrant des difficultés sociales particulières (chômage longue durée, travailleur en situation de handicap, jeunes, personnes rencontrant des difficultés d'insertion sur le marché de l'emploi, groupes défavorisés ou minorités...). Cela permettra la réalisation du parcours d'insertion dans le cadre du marché et offrira la perspective d'un accès ou d'un retour à l'emploi des personnes concernées).

La clause sociale est plus répandue dans les marchés de travaux et les marchés de services simples (ex. nettoyage, entretien, collecte de déchets, plantations).

La clause sociale d'insertion implique de connaître préalablement la situation locale en matière d'emploi et l'offre d'insertion professionnelle de tous les publics éloignés de l'emploi effectivement mobilisable pour exécuter le marché. Dans le cas du Sénégal, les Centres de formation professionnelle constituent des relais à privilégier. Plusieurs données doivent être envisagées, tels que les métiers à mobiliser, les qualifications recherchées, le volume de main d'œuvre par activités, la durée de l'opération ou de la partie d'opération concernée, le marché de l'emploi pertinent, les acteurs disponibles et leurs caractéristiques et capacités.

La clause sociale d'insertion peut être prévue dans un marché public divisé en lots. L'allotissement permet de faciliter l'accès des marchés aux petites et moyennes entreprises (PME) tout en modulant la consistance des lots selon le niveau de technicité. Des lots dont la réalisation est moins technique pourront ainsi permettre d'activer un objectif HIMO en recrutant davantage de personnes.

La clause peut s'appuyer sur le calcul d'un taux d'insertion (voir 1^{ère} partie...) fixé par l'AC, c'est-à-dire un objectif de pourcentage d'insertion, par ex 20% sur la masse salariale qui devront ensuite être transformées en équivalent heures d'insertion.

Il est opportun de rédiger la clause en nombre d'heures d'insertion professionnelle, nombre qui est à déterminer au cas par cas, compte tenu de la spécificité de chaque marché. Ce type de rédaction simplifie le suivi de l'exécution du marché.

La clause sociale de formation sous statut scolaire pour les jeunes en situation de décrochage scolaire

La clause sociale de formation sous statut scolaire permet à un jeune en situation de décrochage scolaire de réaliser un parcours en entreprise, en vue d'acquérir une expérience significative dans le monde du travail. La clause doit fixer les âges requis pour bénéficier du dispositif.

Elle suppose en amont la mise en place d'un mécanisme de repérage des jeunes en décrochage scolaire. (Voir la préparation du marché supra)¹¹⁹

La clause sociale de formation implique la signature d'une convention de stage dans le cadre d'un parcours sécurisé de formation entre l'entreprise et un **Centre d'apprentissage rattaché au Ministère de l'Education**. Une copie de cette convention de stage est remise par l'entreprise à l'AC. Si le Centre de formation et l'entreprise ne réussissent pas à identifier des profils, aucune sanction ne peut être prise à l'encontre de l'entreprise. La clause sociale de formation peut être prévue dans un marché public alloti.

¹¹⁸ Guide sur les aspects sociaux de la commande publique du Ministère du Travail, Ministère de l'Economie et des finances, Ministère de l'Action et des Comptes Publics, France, (2018)

¹¹⁹ En France, il existe des « plateformes de suivi et d'appui aux décrocheurs » (PSAD) puis les jeunes sont inscrits au sein des réseaux « Formation Qualification Emploi » (FOQUALE) (Voir 1^{er} chapitre)

Modèle de Clause sociale de formation de Jeunes à insérer dans le Cahier des clauses administratives Générales (CCAG et CCAP) -pré-insérée dans les DTAO travaux révisés

ARTICLE ... : Clause sociale – Action de formation sous statut scolaire au bénéfice de jeunes en situation de décrochage scolaire

Le titulaire s'engage à réaliser une action de formation d'un ou plusieurs jeunes en situation de décrochage scolaire, âgés entre 16 et 25 ans, d'un niveau de qualification inférieur à ... Cette action de remobilisation est suivie par la Structure du Ministère chargé de l'Education nationale.

Conformément à son offre, le titulaire réalise une action en faveur d'un jeune en situation de décrochage scolaire.

Le volume horaire minimal exigé est de ... heures, à réaliser pendant la période ferme du marché. Néanmoins, le titulaire peut dépasser le volume horaire s'il le souhaite dans la limite des possibilités offertes par le Code du travail.

Dans le cadre de la clause sociale, le jeune bénéficiaire du dispositif est sous statut scolaire. Une convention de stage tripartite est conclue entre l'entreprise titulaire, la Structure du Ministère... (ou l'établissement scolaire de rattachement du jeune) et le jeune (ou son représentant légal).

Le titulaire du marché reçoit le jeune dans ses locaux, en immersion complète, et l'accompagne dans les tâches qui lui sont confiées. Le jeune est accompagné par la Structure du ministère chargé de l'Éducation nationale, qui désigne un tuteur pédagogique.

Le titulaire désigne un responsable des ressources humaines (RRH), qui est l'interlocuteur privilégié du (nom de l'acheteur), ainsi qu'un référent au sein de l'entreprise. Le référent « entreprise » et le tuteur pédagogique sont en relation directe.

L'action mise en œuvre fait l'objet d'une validation, par écrit, sous la forme d'un « bilan croisé » réalisé par le référent « entreprise » et le tuteur pédagogique.

Au terme de son parcours, le jeune bénéficiaire du dispositif peut intégrer un parcours de formation diplômant (reprise de scolarité) ou accéder à l'emploi (insertion professionnelle).

2. Exécution de la clause sociale

pendant la durée du marché et à l'issue du parcours

Le suivi de la clause sociale est réalisé par (nom de l'acheteur) et la MLDS, qui s'assurent de la réalité de l'action mise en œuvre par le titulaire dans le cadre du calendrier scolaire.

Lors de la réunion de lancement du marché, le thème de la clause sociale est abordé (confirmation des contacts).

Une réunion spécifique à la mise en œuvre de la clause sociale est organisée, sur proposition du titulaire ou du (nom de l'acheteur), dès qu'un ou plusieurs profils de jeunes sont proposés. La présence du référent entreprise est obligatoire et celle du responsable des ressources humaines souhaitable.

Le titulaire transmet également à (nom de l'acheteur) la convention de stage tripartite signée.

A l'issue du parcours, le tuteur pédagogique et le référent « entreprise » réalisent un bilan croisé faisant état du résultat de la clause sociale et attestant de la bonne exécution de la clause sociale par le titulaire. À la fin de l'action de rescolarisation, le titulaire du marché s'engage à étudier toutes les possibilités de formation ou d'embauche pérenne des personnes bénéficiaires de la clause sociale.

3. Contrôle et évaluation de l'action de formation

Tout au long de l'exécution des prestations du marché, le titulaire répond à toute demande du (nom de l'acheteur) ou de la Structure du Ministère relative à l'état d'avancement de la mise en œuvre de la clause sociale.

S'il rencontre des difficultés pour faire face à son engagement, le titulaire doit informer le (nom de l'acheteur) et la Structure ministérielle. Dans ce cas, ils étudient ensemble les moyens à mettre en œuvre pour parvenir à la réalisation des objectifs fixés.

Dans l'article relatif aux pénalités :

Paragraphe « Pénalités pour non-respect de la clause sociale

Le titulaire encourt sans mise en demeure préalable dans le cadre de l'application de la clause sociale prévue à l'article ... du CCAP/CCP les pénalités suivantes

- 5000 FCFA par jour ouvré de retard en cas de non transmission des justificatifs, attestations ou bilans demandés par l'AC ou la structure ministérielle dans le cadre de l'évaluation du dispositif social mis en œuvre par le titulaire;
- une pénalité égale au nombre d'heures prévues par le marché et non réalisées, multiplié par 4 (à adapter) en cas de non-respect des obligations relatives au volume horaire minimum exigé dans le cahier des charges.

(rédaction adaptée d'après la clause-type mentionnée en annexe)

§ 2 Insérer des mesures dans les DTAO renforçant l'attractivité économique

A la frontière entre la dimension sociale et la dimension économique des APD, les marchés réservés répondent au souci de développer les acteurs locaux de l'économie sociale et solidaire. Suivant nos propositions de révision du CMP, la possibilité de réserver des marchés à certaines catégories d'acteurs locaux de l'économie sociale et solidaire ne sera ouverte que pour des marchés de montants modestes, sous des seuils qui devront être définis par arrêté ministériel.

D'après l'article 50.1 §2 dans son nouvel aliéna, « *La participation aux Marchés réservés est restreinte aux acteurs de l'économie sociale et solidaire telles que les Associations, Coopératives ouvrières ou artisanales, GIE, Entreprises sociales, et Artisans individuels. L'Autorité contractante peut également recourir aux marchés réservés en invitant uniquement les PME ou les structures de l'économie sociale et solidaire employant au moins 30 % de personnes victimes de handicap, ou 50 % de jeunes non qualifiés ou 50 % de femmes. Un arrêté ministériel définit les seuils sous lesquels les marchés réservés sont possibles ainsi que la procédure de DRP à respecter* ». Par conséquent, seuls les DTAO des petites DRP doivent être révisés pour intégrer cette possibilité. Au stade des conditions de participation, l'Avis d'appel à concurrence devra annoncer si le marché va être réservé à une ou plusieurs de ces catégories envisagées par les nouvelles dispositions du CMP et le DAO devra expliquer les conditions de participation et de justification d'appartenance à la catégorie ciblée, en particulier la justification d'emploi d'au moins 50 % de jeunes non qualifiés et/ou de femmes et/ou de 30% de personnes victimes de handicaps.

Concernant l'insertion de la dimension économique dans les DTAO, plusieurs dispositions qui bénéficient aux PME et TPE peuvent voir leurs effets amplifiés :

Il en va ainsi de l'allotissement, de la levée de la garantie de soumission, de l'application des marges de préférences prévues par les textes lors de l'évaluation des offres, de l'usage de la sous-traitance locale, du recours à des critères favorisant le contenu « local », et l'adoption de clauses qui facilitent l'exécution par de petites structures (clause de dialogue).

L'allotissement : Dans la mesure du possible, les travaux, fournitures ou services doivent être repartis en lots donnant lieu chacun à un marché distinct. La division en lots permet de faciliter la candidature des petites et moyennes entreprises et des structures à vocation sociale et locale. Ce choix ne doit pas avoir pour objet ou pour effet de soustraire les marchés aux règles qui leur sont normalement applicables en vertu du présent décret. Cependant, à condition de justifier son choix, l'Autorité contractante peut estimer que le marché unique ou global présente des avantages économiques, techniques ou financiers en fonction des caractéristiques de l'opération envisagée.

Concernant la garantie de soumission : A la clause qui prévoit déjà que les « : *Les groupements d'ouvriers, les coopératives ouvrières de production, les coopératives d'artistes et les artisans individuels suivis par les chambres consulaires, les organismes d'études, d'encadrement ou de financement agréés, sont dispensés de fournir une garantie de soumission quand la valeur de soumission ne dépasse pas 50.000.000 de francs CFA.* », s'ajouterait « Pour les marchés réservés aux artisans individuels, entreprises sociales, GIE, PME à direction féminine, l'Autorité contractante a la faculté de ne pas exiger de garantie de soumission afin de faciliter leur accès à la commande publique. »

Les DTAO doivent étendre le recours aux marges de préférence

Il faut compléter les DTAO pour qu'ils offrent toutes les options des marges de préférence prévues dans le CMP, qu'ils s'agissent des marges déjà énoncées en particulier les dispositions favorables aux sous-traitants nationaux ou de l'UEMOA, ou des nouvelles que ce Rapport propose d'ajouter, notamment pour les PME à direction féminine. Les modalités de calcul qui n'ont été prévues que dans certains DTAO (Accord cadre fourniture connexe de janv. 2020 ; DTAO Passation des marchés de fournitures (Mai 2017) et DTAO Acquisition de Manuels Scolaires Selon L'Approche Par les Compétences, (Mai 2017) doivent également être explicitées dans tous les dossiers type prévoyant des acquisitions.

Toutefois ce souci d'exhaustivité doit aussi laisser place au réalisme. Certaines mesures préférentielles ne peuvent intervenir que dans des marchés aux montants adéquats. Il ne sert à rien d'inclure des dispositions réservées aux AOI dans les documents de petits marchés qui ne vont pas attirer une concurrence internationale. A l'inverse, les dispositions en faveur des marchés réservés pour des structures à vocation sociale ou éducative ne peuvent apparaître que dans des marchés modestes.

Intégrer dans les DTAO les dispositions suivantes :

(DTAO Fournitures actuel, Instructions au candidat (IC)) :

- | | |
|--------------------------------|---|
| 34. Marge de préférence | 34.1. Pour les marchés passés sur appel d'offres international, une préférence est accordée aux candidats de droit sénégalais ou de pays membres de l'UEMOA et aux candidats dont les offres ne comportent que des produits d'origine sénégalaise ou de pays membres de l'UEMOA, par rapport aux candidats de droit non communautaire, à condition que leurs offres ne soient pas supérieures de plus de quinze (15) pour cent à celle du moins disant.
<i>(Remarque : Application de l'art. 50 CMP 2014)</i> |
|--------------------------------|---|

34.2. Dans le cadre d'un appel d'offres national, la même préférence est accordée uniquement, à qualités équivalentes et à délais de livraison comparables aux groupements d'ouvriers, aux coopératives ouvrières de production, aux groupements et coopératives d'artisans, aux coopératives d'artistes et aux artisans individuels suivis par les Chambres consulaires, ainsi qu'aux organismes d'étude, d'encadrement ou de financement agréés. **(Remarque : application de l'art. 50 al 2 du CMP 2014)**

34.3. Quel que soit le type d'appels d'offres, le candidat à un marché public qui présente une offre en groupement avec une ou plusieurs startups, peut bénéficier d'une marge de préférence de cinq pour cent (5%). Cette marge est cumulée avec toute marge prévue par la réglementation en vigueur. **(Remarque : application du nouvel CMP art 47.9 – loi sur les Startups)**

34.4. Concernant l'encouragement à la sous-traitance, le titulaire d'un marché public de travaux ou d'un marché public de services peut sous-traiter l'exécution de certaines parties du marché jusqu'à concurrence de 40 % de son montant en recourant en priorité à des petites et moyennes entreprises de droit sénégalais ou à des petites et moyennes entreprises communautaires. Le candidat à un marché public qui aura prévu de sous-traiter 30 % des prestations objet du contrat à une PME à direction féminine pourra bénéficier d'une marge de préférence de cinq pour cent (5%). Cette marge est cumulée avec toute marge prévue par la réglementation en vigueur. Dans le cas d'un marché d'une collectivité locale ou de l'un de ses établissements publics, le candidat au marché qui aura prévu de sous-traiter au moins 30 % de la valeur globale du marché à une entreprise locale pourra bénéficier d'une marge de préférence qui ne pourra être supérieure à 5 %, cumulée avec les préférences visées ci-dessus - Le candidat à un marché public qui aura prévu de sous-traiter 30 % des prestations objet du contrat à une structure ou des structures de l'économie sociale et solidaire pourra bénéficier d'une marge de préférence de 5 cinq pour cent (5%). Cette marge est cumulée avec toute marge prévue par la réglementation en vigueur. **(Remarque : nouveau – application de l'article 48 CMP 2014)**

34.5. Dans le cadre d'un Appel d'offres national, il est instauré une marge de préférence dite « genre » en faveur des PME à direction féminine. En cas d'égalité entre une PME nationale et une autre PME, une marge de 5 % sera appliquée à l'offre présentée par la PME à direction féminine. Cette marge est cumulée avec toute marge prévue par la réglementation en vigueur.

34.6. Pour bénéficier de la préférence prévue ci-dessus, les candidats doivent joindre aux justifications prévues à l'article 44 du décret n°2014-1212 du 22 septembre 2014 portant code des marchés publics, une déclaration par laquelle ils demandent à bénéficier desdites dispositions, en même temps qu'ils apportent toutes justifications utiles sur l'exercice de leurs activités au Sénégal ou dans un pays membre de l'UEMOA, sur l'origine sénégalaise ou communautaire des produits ou sur leur existence et leur enregistrement conforme à la réglementation qui leur est applicable.

34.7. Suivant le régime préférentiel, l'Autorité contractante contrôlera pendant l'exécution du contrat le respect par le titulaire des conditions contractuelles relatives à la sous-traitance aux petites et moyennes entreprises nationales ou communautaires, l'emploi de la main d'œuvre nationale ou communautaire et l'utilisation des produits nationaux ou communautaires.

34.8. Pour l'octroi d'une marge de préférence relative aux produits d'origine sénégalaise ou de pays membres de l'UEMOA, l'Autorité contractante classera l'offre dans l'un des deux groupes ci-après :

(a)**Groupe A :** les offres proposant des fournitures d'origine sénégalaise ou de pays membres de l'UEMOA, si le Candidat établit à la satisfaction de l'Autorité contractante : (i) que le coût de la main d'œuvre, des matières premières et des composants d'origine sénégalaise ou de pays membres de l'UEMOA, représentent plus de trente pour cent (30%) du prix hors taxes des fournitures offertes, et (ii) que l'établissement dans lequel ces fournitures seront fabriquées ou assemblées, fabrique ou assemble des fournitures identiques au moins depuis la date de la remise des offres;

(b)**Groupe B :** toutes les autres offres.

Pour faciliter cette classification par l'Autorité contractante, le Candidat devra fournir dans son offre, toutes justifications nécessaires au classement de son offre dans le Groupe A.

34.9. L'Autorité contractante examinera d'abord les offres pour vérifier dans quel groupe les Candidats auront classé leur offre en préparant leurs soumissions. Il confirmera ou modifiera ce classement si besoin est.

34.10. Toutes les offres évaluées de chaque groupe seront ensuite comparées entre elles, pour déterminer quelle est l'offre évaluée la moins disante économiquement la plus avantageuse de chaque groupe. L'offre évaluée la moins disante économiquement la plus avantageuse de chaque groupe sera ensuite comparée avec l'offre évaluée moins disante économiquement la plus avantageuse des autres groupes. Si, de cette comparaison, il ressort qu'une offre du

Groupe A est l'offre évaluée **moins disante économiquement la plus avantageuse**, le Candidat qui l'a présentée se verra attribuer le marché.

- 34.11. Si, à la suite de la comparaison qui précède, l'offre évaluée **moins disante économiquement la plus avantageuse** fait partie du Groupe B, cette offre du Groupe B sera de nouveau comparée à l'offre évaluée **moins disante économiquement la plus avantageuse** du Groupe A, après qu'on ait ajouté au prix évalué des fournitures importées proposées dans l'offre la **moins disante économiquement la plus avantageuse** du Groupe B, et aux seules fins de cette comparaison supplémentaire, 10 % du prix de l'offre de ces fournitures.
- 34.12. Si l'offre du Groupe A est, dans cette comparaison supplémentaire, l'offre évaluée **moins disante économiquement la plus avantageuse**, elle sera retenue. Sinon, l'offre évaluée **moins disante économiquement la plus avantageuse** du Groupe B, par application des dispositions de la clause 34.5 ci-dessus sera retenue.

§ 3 Insérer des mesures dans les DTAO renforçant l'impact environnemental

Imposer des capacités environnementales

A l'heure actuelle, l'exigence de capacités en matière environnementale reste très rarement mentionnée dans les DTAO existants alors qu'elle figure pourtant dans le CMP¹²⁰ à travers l'alinéa (h) de l'article 44 du CMP 2014 qui dresse la liste des attestations et justifications à fournir par les candidats en précisant : « *des renseignements sur le savoir-faire du candidat en matière de protection de l'environnement, le cas échéant* ». En réalité, cette possibilité d'apprécier les capacités environnementales des candidats est très peu reprise dans les DTAO en vigueur.

Exiger la réalisation d'un PGES actualisé et enrichi dans les marchés de travaux

Le PGES est une étape imposée des marchés de travaux qui ont des conséquences sur leur entourage (social et environnemental). Le Titulaire doit soumettre ce plan au début du contrat ; un plan dans lequel il s'engage à prendre des mesures afin de prévenir et de compenser les inconvénients liés à la réalisation des tâches prévues au contrat. Pourtant, les DTAO actuels n'organisent pas clairement ni la méthodologie ni le contenu du PGES. Par ailleurs, le formulaire du PGES mérite d'être complété pour refléter des préoccupations sociales plus récentes telles que la santé des employés, ou le respect du genre. En matière environnementale, il conviendrait d'introduire un diagnostic portant sur la gestion des déchets et une obligation de démontage ou remise en état après la fin du contrat si besoin est. A cet effet, on pourrait s'inspirer de la loi française contre le gaspillage et pour l'économie circulaire (2020) qui a introduit une modification au code de la construction et de l'habitation : « *Lors de travaux de démolition ou réhabilitation significative de bâtiments, le maître d'ouvrage est tenu de réaliser un diagnostic relatif à la gestion des produits, matériaux et déchets issus de ces travaux. Ce diagnostic fournit les informations nécessaires relatives aux produits, matériaux et déchets en vue, en priorité, de leur réemploi ou, à défaut, de leur valorisation, en indiquant les filières de recyclage recommandées et en préconisant les analyses complémentaires permettant de s'assurer du caractère réutilisable de ces produits et matériaux. Il comprend des orientations visant à assurer la traçabilité de ces produits, matériaux et déchets. En cas d'impossibilité de réemploi ou de valorisation, le diagnostic précise les modalités d'élimination des déchets* ». Cependant la loi française exige une expertise sur la gestion des déchets effectuée par des tiers étrangers à la réalisation des travaux. Pour éviter un surcoût pour la personne publique, il vaut mieux, dans le contexte sénégalais, confier cette tâche à l'entreprise qui devra déjà préparer le PGES du marché de travaux ayant un impact sur l'environnement.

Dans le Cahier des Clauses administratives générales (CCAG), insérer des modalités d'exécution qui favorisent la protection de l'environnement

L'appel aux circuits courts : La mise en place d'une condition d'approvisionnement en circuit court qui peut accompagner les modalités d'exécution de certains marchés de fournitures serait un levier utile pour offrir des perspectives intéressantes aux fournisseurs « locaux » (c'est-à-dire Sénégalais ou Communautaires), de produits « locaux ». Cela permettrait de favoriser les circuits courts qui sont à préférer pour des questions environnementales, tout en offrant des débouchés aux producteurs locaux (accès des PME) voire aux GIE ou coopératives de femmes pour satisfaire le critère social.

Insérer l'exigence d'un plan de gestion des déchets dans les marchés de fournitures et marchés de travaux : • Obliger les fournisseurs à récupérer (et recycler ou réutiliser) les emballages des produits présente un double avantage :

¹²⁰ « Le code des Marchés publics est complété par un ensemble d'arrêtés et des dossiers types. Toutefois, les clauses environnementales et sociales ne sont prises en charge que dans certains dossiers types » (ARMP Guide d'APD, p. 21)

les processus d'emballage sont centralisés avant la réutilisation ou le recyclage et les fournisseurs sont incités à éviter tout emballage inutile. A cette fin, il faut prévoir des Spécifications pour des emballages écologiques (matériaux de recyclage sans PVC ou films de protection, comme le carton, le papier ou les matières végétales. Ces spécifications peuvent être complétées par les exigences suivantes : • Réduction au maximum des déchets produits dans le cadre de la réalisation du marché, en tenant compte, par exemple, d'objectifs spécifiques ou en définissant des quantités maximales et les sanctions correspondantes ou des clauses-bonus. • Utilisation de conteneurs ou d'emballages réutilisables pour le transport • Réduction des émissions de CO2 liées au transport ou d'autres gaz à effet de serre et d'émissions (oxyde d'azote, oxyde de soufre, poussière fine, etc.).

Insérer dans le CMP le principe d'une clause de maintenance Insérer dans les DTAO des clauses relatives à la maintenance, à la formation des personnels techniques et à la mise à disposition de pièces détachées. – éventuellement une obligation de démontage et de remise en état après la fin du contrat (dans les PPP) permet d'assurer la véritable durabilité du projet réalisé ou de la prestation effectuée.

Section 4 Développer des DTAO par produit ou par secteur

Préciser les modalités APD à travers une approche sectorielle ou approche produit passe de plus en plus par une approche plus ciblée qui consiste à identifier des produits spécifiques qui pourraient faire l'objet de documents d'appels d'offres adaptés prêts à l'emploi et dont les acteurs publics pourront s'emparer plus aisément. Cette approche est d'ailleurs recommandée pour le Sénégal dans le Guide des APD (2020) qui propose déjà des rédactions propres à certains marchés (par exemple, achat d'ordinateur, achat de véhicules). Comme mentionné dans la version initiale de ce Rapport remise en 2021, il existe plusieurs recueils de spécifications techniques et de clauses dédiés à des achats « verts » de différents produits qui ont été élaborés par la Commission Européenne dans le cadre du programme GPP¹²¹ : à titre d'exemple, les « Critères applicables aux marchés publics écologiques de l'Union européenne pour les services de nettoyage intérieur », https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/cleaning_product/fr.pdf

Au Sénégal, la sélection des produits et des secteurs doit être ciblée, compte tenu des réalités du Marché. A ce stade, par exemple, la rédaction d'un DTAO portant sur l'achat de véhicules de service à caractéristiques écologiques doit être pesée avec soins alors que les conditions locales ne paraissent pas encore rassembler les intrants (carburants spécifiques) ou infrastructures industrielles (garages et SAV) adaptés à ce type de véhicules.

En revanche, le Rapport de la FAO précité a identifié la question de l'alimentation dans les cantines scolaires comme un domaine pertinent en raison des forts besoins, de la structure très décentralisée du Marché et de la disponibilité locale des produits alimentaires. C'est de surcroît un domaine où les objectifs des APD se croisent particulièrement : dimension économique et locale avec la possibilité de faire appel aux petits producteurs locaux, dimension sociale et éducative pour satisfaire les besoins des enfants, dimension environnementale en privilégiant les produits écologiques. Le potentiel pour y démultiplier des marchés de fournitures APD est donc évident. Des travaux ont déjà été menés (Rapport FAO), des expériences réussies ont été conduites (par le PAM et l'AFD vers Matam). Mais il faut également encourager le Commissariat à la Sécurité Alimentaire (CSA) (rattaché à la Direction Générale de la Protection Sociale) à s'impliquer davantage dans les achats auprès des petits producteurs, notamment en structurant ses marchés sous forme d'accord-cadre.

¹²¹ https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm

Partie III ACCOMPAGNER L'ESSOR DES APD PAR DES APPUIS INSTITUTIONNELS DEDIES

En complément des révisions juridiques, le Rapport offre également des propositions d'appuis institutionnels au profit des acteurs du secteur privé mais également des Autorités contractantes¹²². Cette double perspective permet d'insister sur le caractère intersectoriel et interinstitutionnel de la commande publique qui doit s'appuyer sur une collaboration organisée avec le secteur privé. Tout d'abord il faut que désormais la conception des politiques publiques active les outils de la commande publique à travers un dispositif concerté et holistique de formation (Chapitre 6). Pour rendre les mesures APD opérationnelles, les actions identifiées doivent mobiliser les institutions publiques sénégalaises ainsi que le secteur privé afin de développer des pratiques et des réflexes davantage tournés vers la satisfaction des objectifs des APD, notamment afin d'attirer les PME et les Startups vers la commande publique et contribuer à un développement économique durable (Chapitre 7). Enfin, les Autorités contractantes doivent être accompagnées dans le déploiement des APD (Chapitre 8).

CHAPITRE 6 CONCEVOIR UNE MISE EN ŒUVRE TRANSVERSALE DE LA POLITIQUE DES APD

Les mesures d'accompagnement de la réforme débutent par la mise en œuvre d'un plan de formation à destination de tous les acteurs de la commande publique (Section 1). Mais ces mesures doivent aussi être conçues de manière concertée afin d'éviter les déboires passés avec l'élaboration d'un droit de la commande publique en silo, aussi des synergies ministérielles et administratives doivent-elles être mises en place (Section 2).

Section 1 Plan de formation et de sensibilisation à la réforme APD

La formation demeure une étape primordiale et incontournable du succès d'une réforme de l'action publique, surtout quand celle-ci atteint une certaine ampleur avec l'introduction de nouvelles dispositions juridiques et l'attente d'un changement notable des pratiques en vigueur. Au Sénégal, l'organisation de la formation aux achats publics relève, du moins pour le secteur public, de la compétence de l'ARMP (aujourd'hui ARCOP) qui devra piloter le programme puisqu'elle dispose de l'Institut de la régulation des marchés publics, dédié à la formation doté de moyens immobiliers, matériels et humains, et d'une expérience déjà largement reconnue.

Pour assurer son succès, le déploiement réussi du plan de formation sur les APD doit s'appuyer sur l'identification des publics-cibles, l'élaboration d'outils pédagogiques adaptés, et un calendrier réaliste.

Concernant l'identification des cibles, le modèle des cercles concentriques permet d'accentuer initialement les efforts sur les acteurs au centre des achats publics avant d'élargir progressivement les groupes ciblés pour atteindre les publics périphériques plus éloignés. On retrouve ainsi, les autorités contractantes à travers les agents des cellules de passation de marchés et des organes de contrôle qui doivent faire l'objet d'actions de formation prioritaires et poussées, puis les décideurs publics qui ont essentiellement besoin d'une sensibilisation aux enjeux des APD, et enfin les acteurs économiques qui nécessitent une introduction à l'élaboration des offres APD. Un chiffrage précis des effectifs devra être réalisé par l'ARCOP.

- **Formation des formateurs** : Pour mener les actions de formation, un groupe de Formateurs identifiés doit être préparé au domaine, aux règles et aux outils des APD. A cet égard, l'ARCOP ex-ARMP dispose déjà des Formateurs accrédités qui interviennent dans son Master ou dans des formations ponctuelles. Les personnels de l'ARCOP, ainsi que les Formateurs qu'elle emploie, devront être formés par un Consultant en charge du déploiement du plan de formation. Il serait également pertinent de faire bénéficier les enseignants des Universités qui travaillent sur les marchés publics et PPP (Juristes de droit public, Economistes, Gestionnaires), sans oublier

¹²² Ces mesures, expliquées brièvement ci-dessous, sont listées dans un tableau récapitulatif p. 135.

les enseignants dans les Ecoles d'Ingénieurs, de ces formations afin d'assurer la transmission rapide de la nouvelle réforme dans les cursus pertinents des étudiants.

- **Formation des agents des Cellules de passation de marchés** : Les Formateurs pourront ensuite prendre en charge l'apprentissage des CPM et services d'achats publics par des formations techniques et pratiques aux nouvelles réglementations et aux nouveaux DTAO APD.
- **Formation des organes de contrôle** : les corps de la DCMP, Cour des Comptes, OFNAC, Contrôleurs, pourront utilement bénéficier d'une formation poussée aux nouvelles exigences et sanctions en matière d'APD.
- **Sensibilisation des Directions des Ministères et Agences Nationales** : Etant donné le caractère transversal de la réforme APD, tant dans ses objectifs que dans ses conditions de mise en oeuvre, il importe d'atteindre tous les acteurs publics ou para-publics (Sociétés Nationales) qui ont un rôle majeur dans la commande publique. Ce dispositif pourrait être étendu aux **élus locaux**.
 - ✓ **Un Atelier de haut niveau** a déjà été organisé le 6 mai 2021 à l'attention des ministères, agences, établissements publics et quelques collectivités territoriales par le biais du réseau des Coordonnateurs de Cellule de Passation des marchés de l'ARMP.
 - ✓ Pour faire connaître la dimension sociale des APD, une action particulière devra viser les structures en charge de **l'emploi** des couches vulnérables (notamment les "Guichets uniques" qui sont en train d'être mis en place, la DER, 3FPT, le Ministère de l'économie sociale et solidaire), ainsi que les services du **Ministère de la femme et ceux en charge des personnes victimes de handicap**.
 - ✓ Pour diffuser la dimension environnementale et écologique, la formation devra viser **en particulier le Ministère de l'Environnement**.
- **Sensibilisation des milieux professionnels juridiques**: la présentation de la réforme devra également toucher des milieux professionnels, tels que les avocats, les magistrats, les membres des Chambres Consulaires et les autres organisations d'appui à l'entrepreneuriat. Ils devront être sensibilisés aux obligations sociales et environnementales ainsi qu'aux sanctions auxquelles s'exposent les opérateurs économiques en cas de non-respect. On pourra associer les Ecoles spécialisées, notamment d'Ingénieurs à cette diffusion de la réforme APD.
- **Actions formatrices pour les entreprises et en particulier les PME et startups** : toutes les actions à destination des PME devraient inclure un volet de présentation des enjeux du développement durable. Pour celles qui se tournent vers la commande publique, les APD devront être présentés à travers les procédures d'appels d'offres. A cet égard, l'ARMP/ARCOP organise déjà des formations pour les PME et même depuis mars 2021 pour les PME à direction féminine.
- **Vulgarisation auprès du grand public** : diffusion de la stratégie des achats publics durables, présentation de la Plateforme APD.

Les outils pédagogiques :

Le Module APD, déjà dispensé au sein du Master ARMP devra être étoffé pour inclure 3 volets : des exemples étrangers des APD, les enjeux et les modalités de la Réforme APD Sénégalaise, des cas pratiques en utilisant les étapes de l'opération contractuelle identifiées dans le Rapport ainsi que les DTAO révisés.

Les modalités d'enseignement privilégieront le présentiel mais le mode virtuel pourra également être utilement mobilisé pour atteindre des structures déconcentrées ou décentralisées.

Le matériel pédagogique sera adapté aux niveaux des cibles.

Le Guide des APD (adopté en 2020 par l'ARMP) sera systématiquement présenté aux participants des formations.

Actualisation du Guide du Soumissionnaire (accès des PME à la commande publique) de 2015

Création de la Plateforme APD pour diffuser les informations, les textes et permettre les échanges de bonnes pratiques.

Calendrier du plan de formation :

La formation des formateurs devra intervenir rapidement. Les autres niveaux de formation devront être ciblés en tenant compte du plan de réforme de la commande publique qui est envisagé, notamment du **calendrier d'adoption des textes**. Il serait également pertinent de tenir compte des travaux futurs dans le domaine des APD, notamment de préparation de DTAO pour des secteurs ou des produits particuliers.

Résultats attendus :

- X formateurs formés au domaine des APD
- X spécialistes de passation de marchés formés aux procédures APD
- X Responsables des Ministères sensibilisés aux enjeux des APD
- X PME/TPE formées aux candidatures et offres APD

- X premiers marchés APD sont conclus dès l'automne (données collectées par la DCMP et l'ARCOP)
- X plans de passation de marchés présentés pour l'année 2022 intégreront des marchés APD afin d'atteindre l'objectif de 20 % minimum d'APD (sur le total des achats annuels), ce pourcentage étant assigné par la Réforme à chaque acheteur public qui dispose d'un budget supérieur à 300 Millions de FCFA.

Section 2 Conception de la politique des achats publics durables : des synergies à mettre en place

Une véritable prise en compte de la transversalité de l'outil de la commande publique responsable doit amener à repenser les circuits de conception des textes juridiques qui la concerne. Veiller à la prise en compte des objectifs du développement durable devrait systématiquement soulever la question de leurs effets sur les procédures de la commande publique. Un exemple topique concerne la promotion du réemploi ou de l'économie circulaire, mode de production écologiquement vertueux et pourvoyeur de nombreux emplois car il repose sur l'utilisation d'une main d'œuvre nombreuse pour collecter puis transformer, et reconditionner des objets récupérés. Alors que de nombreuses startups se lancent sur ce créneau dans le cadre de la promotion d'une économie plus verte et plus sociale, les règles douanières et fiscales sénégalaises actuelles peuvent constituer un frein préjudiciable à l'extension de ces activités¹²³. Il y a là des marges de manœuvres fiscales à explorer pour optimiser la politique du développement durable aussi bien dans le secteur privé que dans la commande publique.

Il faut systématiser les études d'impact législatives afin de recenser en amont les interactions entre le droit de la commande publique et les différentes politiques publiques. Ce rôle doit en principe être exercé, d'après la Constitution, par le Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE) dans son art. 87-1 qui a été modifié en 2012¹²⁴ afin de lui adjoindre la compétence environnementale. Il peut ainsi être saisi, ou de sa propre initiative, pour rendre un avis sur « *tout plan ou projet de loi à caractère social, économique ou environnemental* ».

En matière de régulation, il faut coordonner la préparation des textes règlementaires intéressant la commande publique avec les autres Ministères concernés, suivant la méthode prônée par la Circulaire n° 000260 PM/SGG/DSL/db du 27 mars 2017 relative à la création de cellules juridiques rattachées au SGG. Cela permettra de proposer des textes de lois ou de décrets qui respecteront¹²⁵ la Circulaire primatoriale n° 00041 du 06 octobre 2015 relative aux « Règles de présentation et de rédaction des textes législatifs et réglementaires ». Notons que la nouvelle ARCOP est chargée par l'article 2 du décret du 21 octobre 2021 de la régulation de la commande publique : « *notamment en veillant à la mise en œuvre d'une commande publique responsable et durable* ». Pour contribuer à l'effectivité de cette disposition, tout texte relatif aux APD en particulier ou ayant une incidence sur la commande publique en général devrait être soumis pour avis à l'ARCOP afin qu'elle puisse participer à sa mise en œuvre. La formule suivante pourrait être insérée à la fin de ces textes :

Art. X. - Le Ministre de l'Economie, des Finances et du Plan et le Ministre de..., l'ARMP, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel.

Ce sera particulièrement édifiant pour les circulaires et autres notes d'explication et de sensibilisation aux APD qui pourraient être diffusées au sein des différentes Autorités contractantes.

¹²³ Dans le domaine des produits agricoles, l'exemption initiale lors de l'importation des intrants, conduit l'Administration des douanes à imposer des droits importants dès lors que les produits sont récupérés puis transformés après leur première utilisation initiale afin d'être recommercialisés, même dans le cadre de l'économie solidaire (par exemple dans la fabrication d'objets à partir de tuyaux d'irrigation abîmés).

¹²⁴ Loi constitutionnelle n° 2012-16 du 28 septembre 2012 portant révision de la Constitution (JORS, numéro spécial 6688 du 28 septembre 2012, p. 1187) : *Le Conseil économique, social et environnemental peut être consulté par le Président de la République, l'Assemblée nationale et le Gouvernement sur tout problème de caractère économique, social ou environnemental. Tout plan ou tout projet de loi de programmation à caractère économique, social ou environnemental lui est soumis pour avis. - Il peut aussi, de sa propre initiative, émettre un avis sur l'ensemble des questions d'ordre économique, social ou environnemental intéressant les différents secteurs d'activités de la Nation. - Une loi organique détermine le mode de désignation des membres du Conseil économique, social et environnemental ainsi que les conditions d'organisation et de fonctionnement de l'institution.*

¹²⁵ P.A. Toure, La légistique. Techniques de conception et de rédaction des lois et actes administratifs : une tradition de gouvernance normative, L'Harmattan, 2018.

CHAPITRE 7 ATTIRER LES PME ET LES STARTUPS VERS LA COMMANDE PUBLIQUE

Le développement économique durable passe par la participation accrue des PME à la commande publique aussi faut-il mobiliser des appuis institutionnels ministériels et locaux adaptés (Section 1). Mais l'attrait des PME pour la commande publique doit également être stimulé par le secteur privé lui-même, à commencer par les Grandes entreprises, titulaires des marchés publics (Section 2).

Section 1 L'appui institutionnel public aux PME

De nombreuses entités ont en charge l'appui aux PME¹²⁶, mais ce dispositif doit être repensé pour que 1) les actions en faveur des PME soient menées en cohérence et 2) que des actions spécifiques à l'accompagnement des PME vers la commande publique soient instaurées et pérennisées.

§1 Mobiliser les outils de financement des PME

Il faut s'appuyer sur les initiatives récentes telles que le *Compact with Africa* (financé par l'Allemagne) qui a aidé l'ADEPME à mettre en place un guichet unique afin de suivre les PME qui ont reçu un financement. Un dispositif d'évaluation du risque crédit de chaque PME est aussi progressivement mis en place (*scoring universel*) et une plateforme a été créée (e-rating) pour évaluer le niveau de risques des PME.

- Plus particulièrement pour le domaine de la commande publique, des études de faisabilité ont déjà été réalisées pour la création d'une Caisse des marchés publics qui devrait « permettre d'apporter aux PME des produits alternatifs de financement adaptés à toutes les étapes de soumission et d'exécution des commandes publiques et d'accompagner les petites entreprises pour un paiement diligent après exécution de leurs marchés ou par la mise à disposition de financements leur permettant de rester rentables. Ce schéma pourrait permettre de promouvoir la mise en place d'un système d'affacturage à destination des PME qui entrent sur les marchés publics. La Caisse des marchés publics serait en cours d'installation.

Enfin, les entreprises publiques pourraient également proposer, comme au Maroc, un pré-financement de leurs sous-traitants avec un accompagnement dans la chaîne de valeur en s'investissant dans la sélection structurée de leurs sous-traitants, leur formation selon un cahier des charges commun, l'octroi de garanties. L'APIX a déjà une expertise très avancée dans l'accompagnement des PME à travers son Bureau de la création des entreprises, elle y forme et prépare les entreprises à accéder à la commande publique. Il faut l'impliquer dans un système de mentorat et de certification de ses sous-traitants.

§ 2 Alléger le formalisme imposé par les procédures d'achats publics

L'un des freins identifiés à la participation des PME et Startups réside dans le formalisme des candidatures. Si l'on doit maintenir les exigences en matière de capacités afin d'assurer le sérieux et l'intégrité, il faut en revanche améliorer la charge administrative imposée aux entreprises, en particulier aux PME et autres « entreprises à caractère social et solidaire ». Certaines nous ont confié devoir consacrer jusqu'à 10 jours/homme pour remplir un dossier d'appels d'offres. Ces difficultés, habituelles dans la constitution des dossiers par les entreprises, sont renforcées au Sénégal par des lenteurs administratives structurelles qui transforment la réunion des pièces nécessaires, en un véritable parcours du combattant. Dans ces conditions très désincitatives pour les PME et les structures de l'économie sociale et solidaire, seules les structures suffisamment dotées en personnel peuvent effectivement participer. Le frein du formalisme appelle donc une attention particulière de la part des AC.

¹²⁶ Notamment :

L'Agence de Développement et d'Encadrement des petites et Moyennes Entreprises (ADEPME)

La Direction d'Appui au Secteur privé (DASP)

L'appui apporté par des structures à vocation financière telles que le FONSIS et le Fonds de Garantie des Investissements prioritaires (FONGIP).

Le Ministère de la formation professionnelle et ses Centres de formation sur le territoire.

La Délégation générale à l'entrepreneuriat (DER) pour encourager l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes...

Dans l'immédiat, le présent Rapport a proposé d'alléger le formalisme en permettant aux candidats de déposer des dossiers incomplets, dans lesquels certains justificatifs ou certificats officiels ne sont pas fournis. Ils pourront, à la place, déposer une attestation de demande du document auprès du service compétent, assortie d'une attestation sur l'honneur qui engage leur responsabilité si, par la suite le défaut de document devait révéler une tentative de fraude. Les candidats, notamment les PME, auront ainsi davantage de temps pour régulariser. Par ailleurs, et pour accélérer considérablement l'examen des offres, l'AC ne devrait désormais vérifier que les documents et attestations de la seule entreprise qui aura été retenue.

Section 2 L'appui du Secteur privé aux PME

Le secteur privé doit contribuer à faire émerger des PME solides qui assureront des fonctions de sous-traitance fiables et efficaces. C'est un enjeu important au Sénégal où le tissu est encore en manque de capacités dans de nombreux secteurs. Solliciter les grandes entreprises, dans le cadre de leur politique RSE, pourrait permettre de les inciter à encadrer des PME et à les guider par des activités de mentorat. Les entreprises titulaires « agréées » RSE pourraient délivrer des « certificats de bonne exécution des marchés de sous-traitance » qui seraient ensuite capitalisés par les PME et les aideraient à obtenir des marchés de premier rang.

Des fonds d'investissement spécialisés par exemple dans la formalisation de l'entrepreneuriat féminin, pourraient s'intéresser à l'accompagnement des PME et Startups vers la commande publique.

Un prix pourrait être créé afin d'encourager les entreprises spécialisées dans les APD : prix pour récompenser les entreprises mais également un prix pour récompenser les AC les plus vertueuses.

Devenu une référence, le Prix Orange de l'Entrepreneur Social en Afrique et au Moyen-Orient (POESAM) fête ses 10 ans. Il récompense chaque année les meilleurs projets technologiques à impact positif en Afrique et au Moyen-Orient. La compétition s'organise en deux temps : d'abord un concours national dans 17 pays ; puis un jury international désigne les vainqueurs du Grand Prix. Pour ce 10^e anniversaire, Orange récompensera plus de start-up avec le lancement du prix féminin international d'une valeur de 20 000€ et l'ajout d'un Prix spécial d'une valeur de 10 000€ propre à cette édition. Ce sont donc au total 5 prix qui seront décernés par le jury du Grand Prix international. La particularité de cette 10^{ème} édition du POESAM est la création du Prix féminin International, qui récompense soit une femme, soit un projet proposant une solution technologique pour améliorer les conditions de vie des femmes en termes d'autonomisation, de création ou de préservation des emplois, de collecte de données sur le genre, ou encore d'inclusion numérique et financière. Au total, quatre prix seront décernés lors du POESAM 2020, qui depuis sa création en 2011, a déjà soutenu une trentaine de projets. Le POESAM s'adresse aux étudiants, aux salariés ou aux entrepreneurs de plus de 21 ans, dont l'initiative a moins de trois ans d'âge. Au Sénégal, le POESAM a récompensé SenVitale, Sunu Mbay, 20 sur 20 –EdTech, WASOR/Senebot, Permas Partagés, Beugue Lire, Own Labs, EyoneMedicalSuite, ApiAfrique, MaTontine, Pass Courses, Niokobok et Kachilè.

CHAPITRE 8 ACCOMPAGNER LES AC DANS LE DEPLOIEMENT DES POLITIQUES APD

A titre préliminaire, le soutien aux Autorités contractantes dans la mise en œuvre de leur stratégie APD doit être porté par un dispositif efficace et cohérent d'informations et d'aides ciblées (Section 1). Au-delà, il convient également d'inciter les AC à utiliser les dispositifs APD par des mécanismes d'aides et de conseils centralisés (Section 2).

Section 1 Améliorer l'information des Autorités contractantes sur les APD

Plusieurs actions pourraient être déployées dans le cadre de la communication, des outils d'information et de la dématérialisation des procédures

§ 1 Lancer des événements de communication autour des APD

Plusieurs événements devront accompagner le lancement de la réforme ¹²⁷:

¹²⁷ Voir également le plan de formation *supra*

- Présentation/formation de haut-niveau aux cadres dirigeants des structures gouvernementales ;
- Présentation/formation de haut-niveau auprès des collectivités territoriales ;
- Communication auprès des Bailleurs de Fonds ;
- Communication sur les réseaux sociaux ;
- Communication auprès des Journalistes ;
- Communication auprès des structures d'accompagnement des PME ;
- Communication auprès des acteurs de l'économie sociale et solidaire ;
- Lancement de la plateforme publique sur les APD.

Développer les supports d'information

- Le rapport annuel de l'ARCOP ex-ARMP doit prendre en compte les APD et communiquer sur leurs réussites.
- Le site de l'ARCOP doit être ordonné afin de lister les DTAO toilettés en distinguant les DTAO « classiques » et les « DTAO - APD ».
- Le Guide explicatif à destination des AC doit être actualisé pour présenter les modalités d'utilisation des APD. Un seul exemple : il existe 17 procédures de DRP si on prend en compte les combinaisons entre les seuils, les types de marchés et les catégories d'AC. Si la diversité des procédures déployées répond au souci d'adapter les modalités de passation aux besoins des AC, elles risquent aussi d'éprouver des difficultés à choisir la procédure optimale.
- Un guide fiscal, ainsi qu'un guide pour l'accès des PME à la commande publique ont été élaborés mais ils devront être actualisés pour intégrer la réforme APD.
- Créer une Plateforme publique des APD

§ 2 Recourir à la Dématérialisation

Si le besoin de dématérialisation s'est lentement diffusé depuis plusieurs années, au fur et à mesure que les avancées technologiques permettaient d'envisager des moyens plus sûrs et plus efficaces pour acquérir les produits et services nécessaires, **le grand saut technologique et juridique à accomplir a longtemps conduit à différer la prise de décision**. Cependant la crise imposée par la pandémie du COVID a contribué à lever un certain nombre de barrières, et à diffuser de multiples usages des technologies numériques. Aussi la transformation numérique de la commande publique qui est désormais lancée à titre pilote pour les DRP doit être largement appuyée, en parallèle et en concertation à celle de l'action administrative qui a déjà commencé au Sénégal.

Au-delà de l'allègement des exigences de documentation, le Gouvernement pourrait vouloir accélérer la dématérialisation de certaines étapes des procédures d'achat afin de faciliter l'accès à la commande publique. Le processus de dématérialisation a été lancé pour les DRP et il faudra voir comment il se déroule et s'il commande des modifications des textes et des DTAO. Pour les autres procédures, il ne s'agit pas encore de tout dématérialiser, car c'est un vaste chantier qui doit être entrepris de manière globale mais des expériences peuvent être menées aux bouts de la chaîne. A ce niveau, une innovation a été développée avec succès par le Gouvernement marocain : créer une « base de données des fournisseurs » pour les entreprises qui peuvent ainsi conserver toutes leurs pièces officielles et y donner accès à l'AC en cas de candidature à un marché public. Le Maroc va également déployer un système de soumission numérique des factures par les titulaires. Un Rapport de la Banque mondiale paru en janvier 2021¹²⁸ passe plus largement en revue les principales techniques de dématérialisation disponibles en les croisant avec la maturité des systèmes nationaux de commande publique : il en ressort que l'implantation de la *blockchain* paraît être la technique qui apporte le plus de résultats en termes de sécurité, rapidité et simplification des procédures pour un « coût » d'adaptation juridique et technologique relativement modéré.

§ 3 Organiser le sourcing et les consultations pré-commerciales

Le sourcing, conduit par l'AC, est une étape primordiale lors de la définition des besoins car elle permet d'adapter le contenu et la configuration des documents d'appel d'offres aux capacités du secteur privé. Plus la connaissance du secteur privé sera fine, moins il y aura de risques d'appels d'offres infructueux et de déconvenues lors de l'exécution. C'est ainsi que les AC s'équipent contre « l'asymétrie d'informations » qui est souvent dénoncée par les Economistes lorsqu'ils

¹²⁸ World bank, Disruptive technologies in public procurement, January 2021
<http://documents1.worldbank.org/curated/en/522181612428427520/pdf/Disruptive-Technologies-in-Public-Procurement.pdf>

soulignent le déséquilibre d'informations entre la partie publique et la partie privée. Pour y pallier, un certain nombre d'activités peuvent être mutualisées entre les AC, notamment la veille des Marchés et la veille sur les prix de référence.

Aussi appelée « Sourcing », la connaissance des Marchés et des produits ou services disponibles est aujourd'hui considérée comme une technique essentielle à l'adéquation entre l'offre privée et les besoins publics. Le droit européen de la commande publique a inclus le *Sourcing* dans les nouvelles Directives¹²⁹ en prévoyant des garde-fous pour éviter que ces contacts pré-commerciaux organisés entre le secteur public et le secteur privé n'aboutissent à des liens qui mettraient en cause l'intégrité des futures procédures. Il faut donc organiser les contacts dans la transparence pour éviter les soupçons de corruption tout en veillant à ne pas porter atteinte à la propriété intellectuelle et, plus largement, au secret des affaires, par la divulgation ou la réutilisation non autorisée auprès d'autres candidats, ou de tiers, de certaines informations figurant dans les offres, telles que les prix, idées, procédés, pratiques commerciales, stratégie de l'entreprise etc... Indéniablement, une bonne connaissance des produits et services disponibles, de leurs caractéristiques et de leurs prix, contribuent à la préparation éclairée des services Acheteurs. Ils sauront ainsi si les besoins exprimés seront satisfaits grâce à des produits ou services déjà commercialisés (dits « produits sur l'étagère ») pour lesquels on peut attendre une forte concurrence ou bien s'il faut envisager des produits ou services spécialement conçus pour la demande publique, ce qui pourrait conduire à mobiliser des mécanismes de marchés innovants. Cette étape peut également servir à connaître davantage le secteur privé et le tissu des entreprises locales susceptibles de fournir la prestation attendue. Elle peut permettre d'identifier des startups à encourager.

Conseils pratiques à propos du Sourcing:

Il n'existe pas de méthode universelle de sourcing, cependant quelques recommandations peuvent être formulées, dans un esprit de transparence mais aussi de souplesse, et à adapter selon l'objet : Φ définir en premier lieu les objectifs poursuivis par la démarche ; Φ assurer une publicité proportionnée aux enjeux et au montant de la future consultation (ex : aucune si faible enjeu, site institutionnel ou profil d'acheteur, journal d'annonces légales, etc.) ; Φ laisser un délai raisonnable aux opérateurs économiques pour se manifester (ex : un mois) ; Φ sélectionner un panel représentatif de fournisseurs à solliciter le cas échéant (ex : PME / ETI / grandes entreprises, fournisseurs déjà connus / nouveaux entrants sur le marché) ; Φ conduire les entretiens, réaliser les visites de site dans le cadre d'une équipe (acheteur, prescripteur, juriste, etc.) et avec une répartition claire du rôle de chacun ; Φ refuser tous cadeaux (hors objets promotionnels de faible valeur) ou avantages et vérifier qu'aucun des participant n'est concerné par un conflit d'intérêt potentiel ; Φ assurer une traçabilité minimale des échanges (ex : modèle de compte-rendu synthétique, etc.) ; Φ assurer un niveau d'informations égal à toutes les entreprises participantes (liste de thématiques communes, ex : performance technique, structuration des coûts, développement durable...) et ne communiquer aucun élément de la future consultation ; Φ respecter la confidentialité des informations transmises par les entreprises (secret des affaires) et ne pas reprendre leurs idées / procédés novateurs dans le cahier des charges ; Φ respecter un délai de quelques semaines entre la fin du sourcing et le lancement de la consultation ; Φ évaluer a posteriori l'apport du sourcing pour l'amélioration des achats et la satisfaction des utilisateurs.

Afin de rassurer les opérateurs économiques inquiets du traitement qui pourrait être réservé aux données techniques et/ou financières qu'ils communiquent, une bonne pratique peut être de leur demander de signaler lors du sourcing (et plus généralement dans leurs offres) les éléments qu'ils estiment de nature confidentielle. Les Acheteurs qui manqueraient de moyens ou bien de pratique peuvent mutualiser cette phase avec d'autres administrations présentes sur le territoire. Pour les accompagner dans cette démarche, de même que pour permettre aux entreprises de se manifester, il existe différents outils et réseaux d'échanges (animation régionale conjointe Etat/collectivités, recours au « catalogues fournisseurs » des centrales d'achat, appui des CCI, pôles de compétitivité...).

DAJ/OECP Guide pratique « faciliter l'accès des TPE/PME à la commande publique » 2019, p. 7.

Mutualiser le « sourcing » permet de réunir les compétences et de prévenir le risque de collusion avec les entreprises. Dans le cadre du déploiement des APD au Sénégal, il serait judicieux de concentrer cette fonction d'enquête sur les innovations du secteur privé national et international auprès de l'entité en charge d'animer la plateforme publique APD. La structure, dotée d'Ingénieurs spécialisé(e)s en environnement, énergie et/ou questions sociales pourraient ainsi jouer le rôle de vigies pour le secteur public et partager ensuite les informations avec les acheteurs publics sur la plateforme publique APD. La veille technologique permet aux AC de connaître les évolutions des techniques de production, une

¹²⁹ Directive 2014/24 UE du 26/02/2014 sur la passation des marchés publics, article 40. *Consultations préalables du marché Avant d'entamer une procédure de passation de marché, les pouvoirs adjudicateurs peuvent réaliser des consultations du marché en vue de préparer la passation de marché et d'informer les opérateurs économiques de leurs projets et de leurs exigences en la matière. À cette fin, les pouvoirs adjudicateurs peuvent par exemple demander ou accepter les avis d'autorités ou d'experts indépendants ou d'acteurs du marché. Ces avis peuvent être utilisés pour la planification et le déroulement de la procédure de passation de marché, à condition que ces avis n'aient pas pour effet de fausser la concurrence et n'entraînent pas une violation des principes de non-discrimination et de transparence.*

vigilance particulièrement utile dans le domaine de la protection de l'environnement où les inventions se succèdent, renouvelant rapidement les caractéristiques de l'offre disponible. Ils pourraient organiser des salons et des événements afin de permettre aux Startups de proposer leurs innovations : certes, cela existe déjà au Sénégal mais ces meetings ne s'adressent pas particulièrement au secteur public.

Des mécanismes institutionnalisés de veille d'informations par secteurs ou produits peuvent être mis en place comme des « tableaux de prix » sur des fournitures basiques, préparés par des services économiques en charge de surveiller certains produits ou secteurs¹³⁰. Ces tableaux serviront de prix de référence que les CPM pourront consulter pour évaluer les offres proposées par les candidats, afin de détecter les prix artificiellement élevés mais aussi ceux anormalement bas. Cette veille des prix pourrait aussi être organisée à l'échelle de l'UEMOA pour éviter de trop grandes disparités dans les produits de base.

§ 4 Organiser le « sourcing social »

Connaître les besoins sociaux sur le territoire d'une collectivité ou dans un bassin d'emplois apporte des données cruciales pour assurer le succès d'un marché public à vocation sociale. De nombreuses initiatives sont actuellement lancées au Sénégal pour territorialiser la politique de l'emploi : pour que la commande publique puisse jouer sa carte, il faut l'inclure dans ces dispositifs, notamment dès le recensement des chômeurs. En ce domaine, on rappellera que le Guide APD 2020 a suggéré :

« Pour plus de transparence, faire passer l'information au niveau des communautés par le biais des Autorités administratives. Ces dernières vont ouvrir une liste sur laquelle seront inscrites toutes les personnes voulant travailler dans le chantier avec des précisions sur leur adresse, leur contact et l'emploi pour lequel ils veulent postuler. L'entreprise devra se baser sur cette liste pour effectuer ses recrutements au niveau local. - Il appartiendra à l'entreprise, au moment de recruter, pour des postes comme les manœuvres, ouvriers, chauffeurs etc., d'accorder la primeur aux populations locales et, à l'intérieur de ces dernières, les femmes et les personnes en situation de handicap. - L'entreprise doit fournir des données sur l'embauche locale qu'attestera la mission de contrôle, à chaque fois qu'elle ait besoin de facturer ».

Section 2 Inciter et aider les AC à utiliser les dispositifs APD

Il faut que les AC s'engagent sur des objectifs chiffrés d'APD chaque année. Cette exigence ne serait applicable qu'à partir de l'année 2022 en raison de l'annualité de la publication des plans prévisionnels. Par souci d'adaptation à la réalité locale, cette obligation ne devrait concerner que les AC sénégalaises les plus importantes et dotées des capacités adéquates. Pour les autres, l'adoption d'un objectif chiffré peut être décidée sur une base volontaire, notamment pour afficher et communiquer auprès des populations leurs engagements concrets en faveur du développement durable. A titre d'exemple, la formulation adoptée par le décret Tunisien n° 2014-1039 du 13 mars 2014 portant réglementation des marchés publics est intéressante : « Régimes préférentiels Art. 20.- L'acheteur public réserve annuellement aux petites entreprises un pourcentage dans la limite de 20% du montant estimé des marchés de travaux, de fourniture de biens et de services et d'études,... ».

Il serait souhaitable, dans le cadre de la préparation des futurs textes d'application sur les PPP, de prévoir une obligation similaire et à terme de prévoir un plan annuel unique de « commande publique » pour chaque AC, qui s'appuierait sur les objectifs nationaux déterminés dans le plan national. Un Arrêté pourra prévoir un seuil minimal d'application de cette exigence. Le présent rapport suggère de la rendre obligatoire pour les acheteurs publics disposant d'un budget supérieur à 300 Millions de FCFA, afin de reprendre un seuil utilisé pour les procédures de DRP.

Afin d'atteindre ces objectifs, les AC doivent pouvoir bénéficier d'une aide ciblée pour déterminer les obligations sociales et environnementales pertinentes. Les AC, et particulièrement leurs cellules de passation de marchés, ne disposent à l'heure actuelle que d'une expertise très limitée en matière de développement durable. Certes, des programmes de formation seront déployés dans le cadre de la mise en oeuvre du PNAPD mais il faut également leur apporter un service de conseils pour les accompagner dans l'inclusion fine des objectifs du développement durable dans leurs marchés publics. Dès lors, il faut instaurer un bureau de conseil en APD à destination des AC auquel elles pourront soumettre leur projet de plan de passation de marchés afin de vérifier si les actions envisagées rentrent bien dans le dispositif des APD. Ensuite, et au cas par cas, et en fonction de leurs besoins, elles pourront également se tourner vers cette structure lors de la préparation

¹³⁰ CF l'exemple de la Côte d'Ivoire

des documents d'appel d'offres. Cette procédure doit rester facultative pour éviter des lourdeurs et blocages de l'attribution des contrats. Le recours à une structure d'appui permettrait de concentrer l'expertise, encore trop rare, et d'assurer une montée en puissance des capacités. On peut en effet imaginer que des spécialistes de passation de marché venant d'autres ministères pourront effectuer des séjours de formation au sein de cette entité avant de retourner dans leurs CPM.

La localisation de cette aide ciblée doit être déterminée avec soins au sein de l'appareil institutionnel. Il ne s'agit pas de créer un niveau supplémentaire de contrôle *a priori*, qui relèverait sinon de la DCMP, mais bien d'apporter une aide effective aux CPM lors de la phase de préparation de leurs documents d'appels à concurrence sous la forme d'un avis simple. Un avis qui n'engagera pas la responsabilité de la structure d'appui qui doit rester un service interne à l'administration active. Aussi, plusieurs propositions peuvent être considérées :

- loger cette nouvelle attribution dans un service d'appui à la passation des marchés publics au sein du Ministère des collectivités locales pour conseiller les collectivités territoriales ;
- loger cette fonction au sein de l'entité en charge de la plateforme publique APD.

Dans le domaine des PPP, la vérification *a priori* des obligations sociales et environnementales à mettre en œuvre dans le cadre des projets PPP, devrait être confiée à l'organe d'appui en charge de superviser la préparation des contrats, éventuellement appuyée par des experts extérieurs. Au Bénin, ce rôle a été confié à la Cellule d'Appui au Partenariat Public-Privé en République (art. 5 de la loi PPP)¹³¹. Elle doit notamment émettre un avis sur « *la part réservée aux opérateurs nationaux et communautaires dans la mise en œuvre du projet, le potentiel de création d'emplois pour les nationaux, les modalités de transfert de technologie* » et « *les mesures de protection de l'environnement et de promotion du développement durable* ». La structure d'appui aux PPP pourrait ainsi prévoir le recrutement d'un spécialiste de l'environnement.

Une autre option pourrait consister à concentrer toute l'expertise en un seul point focal qui assurerait le soutien pour tous les types de contrats de la commande publique, tout en animant la plateforme des APD qu'il faudra mettre en place au Sénégal pour accompagner les Acheteurs publics et le Secteur privé dans le déploiement des APD.

Tableau récapitulatif des actions incitatives

Tableau récapitulatif des actions incitatives à l'essor des APD

Domaines	Modalités	Mesures	Indicateurs de résultats Collecte de données
ACCOMPAGNEMENT DES PME			
Labellisation des PME et startups	► Lancement du processus par le Ministère des PME Association de l'ARCOP pour la partie commande publique	► Adoption d'une méthodologie de labellisation des PME (décret) ► Adoption d'une méthodologie de labellisation des Startups (décret)	► Nombre de PME labellisés ► Nombre de Startups labellisées
Financement des PME	► Installation de la Caisse des PME¹³² ► Ou Banque publique sénégalaise (BNDE ?) avec service dédié aux PME dans la	► subventions d'investissement ► crédit-bail ► Affacturage ► Nantissement	► Nbr de PME financées par type de financement ► Nbr de Startups financées par type de financement

¹³¹ Décret 2018-156, 2 mai 2018, portant attributions, composition et modalités de fonctionnement de la Cellule d'Appui au Partenariat Public-Privé en République du Bénin, art. 5.

¹³² Etude de faisabilité d'une caisse des marchés publics (Volume 1 : Rapport diagnostic, page 10 – Septembre 2015) – Etude réalisée sur financement BAD dans le cadre du Projet d'Appui du Secteur Privé (PASP) sous l'égide de la Direction d'Appui au Secteur privé - DASP)

	commande publique avec services digitalisés ▪ société d'affacturage, assurera le paiement immédiat des factures aux fournisseurs moyennant une rémunération versée par l'acheteur public au factor		
Accompagnement des PME à direction Féminine (financement)	▪ Fonds et banques privés : ▪ Ex : WIC Academy (du fonds d'investissements Women investment club Sénégal) ▪ DER/Fj	▪ Investissement en capital ▪ Accompagnement adapté aux entreprises qui répondent au critère genre ▪ Coaching pendant 6 mois	▪ Nombre de PME féminines labellisées ▪ Nombre de Startup féminines labellisées
Accompagnement des PME dans le secteur des APD	▪ Fonds de promotion des APD	▪ Trophées des PME innovantes en matière d'APD	▪ création d'un réseau des primées
Incitations financières pour les PME à direction féminine	▪ Fonds de promotion des APD	▪ Trophée des PMEFéminines innovantes en matière d'APD ▪ Primes ▪ Prêts d'honneur	▪ Nombre de PME féminines récompensées ▪ Suivi
ENTREE DANS LA COMMANDE PUBLIQUE			
Accompagnement des structures à vocation sociale ou éducative vers la commande publique	▪ Groupe de travail ARCOP & Ministères, DER etc...	▪ Communication auprès des AC ▪ Communication auprès des chambres artisanales, ONG	▪ Nombre de marchés réservés attribués
Accompagnement des PMEs vers la commande publique	▪ Groupe de travail ARCOP & ADEPME ▪	▪ Communication auprès des AC ▪ Mesures de facilitation des paiement	▪ Adoption de Circulaire ou Directive
Allègement des charges financières des PME	▪ AC	▪ Dispenses de garantie de soumission et d'exécution ▪ versement des avances ▪ modulation des retenues de garantie, ▪ Paiement dans les délais	▪ Nombre de marchés conclus sans garantie de soumission ▪ Bilan d'efficacité
Accompagnement des PME vers la commande publique	▪ Entreprises engagées dans le cadre de la RSE	▪ Formation coaching ▪ mentoring ▪ sponsoring sont prévues pour renforcer les capacités et compétences des PME Certification des PME	▪ Nombre d'entreprises soutenues obtenant des sous-traitances ▪ Nombre d'entreprises obtenant des marchés
Accompagnement des PME vers la commande publique	▪ Par les Banques : Banque publique sénégalaise (BNDE ?) avec service dédié aux PME dans la commande publique avec services digitalisés		▪ Nombre de PME accompagnées vers la commande publique ▪ Nombre de PME sous-traitantes
Accompagnement des sous-traitants par les Entreprises publiques	Entreprises publiques	Création d'écosystèmes d'accompagnement des PME sous-traitantes	

		Préfinancement des sous-traitants dans les chaînes de valeur	
APPUI AUX AC			
Incitations des AC	ARCOP & Fonds de promotion des APD	■ Prix des AC vertueuses ■ Primes en cas de dépassement d'objectifs APD ■ Partage d'expérience sur la plateforme	■
Sourcing			
Aide aux AC – données sur le prix	Expertises extérieures, soit en réunissant un Comité technique d'études et d'évaluation des offres, soit en faisant appel à des experts individuels. (art 38 du CMP de 2014)	■ Banque de données de prix¹³³ ■	■ Des tableaux de données de prix sont disponibles et actualisés régulièrement
Identifications des besoins sociaux à transcrire en mesures APD	« Facilitateurs sociaux » Structures locales ONG Personne appartenant ou lié au service public de l'emploi local.	■ Le facilitateur conseille l'acheteur dans l'élaboration et la rédaction de la clause sociale, renseigne les entreprises soumissionnaires sur les réponses possibles localement, puis contrôle l'exécution de la clause et évalue son résultat	■ Des marchés à critères sociaux sont conclus
Identification des besoins environnementaux à transcrire en mesures APD			
Sélection de Secteurs pilotes	Groupe de travail (ARCOP + Ministère ou agence responsable du secteur) Identification des AC porteuses	■ Rédaction de DTAO spécifiques ■ Lancement d' AO tests	■ Des marchés sont conclus avec des données quantifiables
Sélection de Produits pilotes	Groupe de travail (ARCOP et Agences ou ministères responsables du secteur) Identification des AC porteuses	■ Rédaction de DTAO spécifiques ■ Lancement d'AO tests	■ Des marchés sont conclus
COMMUNICATION APD			
Communication ARCOP ex-ARMP	Site ARCOP Se rapprocher des agences régionales de l'environnement Se rapprocher des ministères concernés par les APD	■ Présentation APD ■ Actualisation et veille juridique ■ Publication des lois et textes pertinents ■ Classement et archivage ■ Introduire le genre dans les textes de nomination à l'ARCOP	■
Communication APD	Auprès des AC	■ Valoriser l'action APD dans la presse locale et nationale ■ signalétique informative dans les locaux administratifs, ou dans les milieux extérieurs, mettant en évidence les résultats APD ■ Organiser des réunions d'information	■ Réduction des délais de paiement (nombre de jours, par secteur et type de marchés) ■ Augmentation du nombre de candidats dans les AO ■ Augmentation d'u nombre de PME attributaires ■ Objectifs APD atteints
DEMATÉRIALISATION			
	■ Création d'une plateforme APD	■	■ Nombres de membres actifs sur la plateforme des APD

¹³³ Banque de données de prix en Côte d'Ivoire : www.marchespublics.ci/outils-gestion/bdpr

Démat. des DRP (en cours)	ARCOP + ?	■ Dématérialisation des DTAO avec des dispositions APD ■ Suivi des DRP avec des obligations sociales et environnementales	■ Nombre de DRP APD ■ Nombre d'AO avec communications dématérialisées
FORMATION			
Formation Stratégie	Adoption d'un plan de formation Organisme responsable : ARMP et autres ministères concernés	■ Déterminer les cibles, les outils le calendrier	■ Publication sur le site de L'ARCOP ■ Publication sur la plateforme APD
Formation cibles		■ Formation des formateurs ■ Formations des AC ■ Formation des Etudiants (Droit, économie, gestion, Ingénieurs) ■ Formations ciblées du secteur privé : Grandes entreprises, PME femmes Jeunes, Artisans, coopératives, entreprises sociales	■ Nombre de formateurs formés ■ Nombres d'AC formés par catégorie d'AC (coll. Territoriales, Communes, département, Administrations étatiques)
Formation outils		■ Rédaction d'un guide de l'AC en faveur des APD ■ Création d'outils virtuels d'aide aux APD ■ Création d'outils virtuels d'aide aux PME	
DONNEES			
Cartographie APD	Groupe de travail interministériel autour de l'ARCOP Localement : associer les ONG	■ Identification des besoins en APD par critères géographiques : nationaux et locaux ■ Identification des programmes & politiques publiques par piliers APD qui sont mis en œuvre par des marchés	■ Nombre de marchés APD lancés par programmes
Résultats, collecte de données	➤ Adoption d'indicateurs ➤ Identification des modalités de collectes ➤ Identification de l'organisme responsable ➤ Sanction en cas de non transmission de données	■	■ Nombre de Plans annuels de PM comportant des objectifs APD ■ Nombre de marchés attribués comportant des objectifs APD ■ Nombre et volume de marchés par type d'APD ■ Suivis des résultats par type d'APD ■ Incidents
Recensement des ESS Entreprises sociales et solidaires (à créer)	Ministère de la micro-entreprise et économie sociale et solidaire	■ Préparation de la loi ■ Groupe de travail avec l'ARCOP pour le volet accès des ESS à la commande publique	■ Adoption de la loi sur l'ESS ■ Adoption du décret sur l'entreprise ESS
Evaluation	Retour sur les résultats Consultations des AC	■ Recalibrage ■ Ajustements ■ Insertion du plan APD dans la réforme globale de la commande publique au Sénégal	■

CONCLUSION ET PLAN D'ACTIONS

Ce Rapport s'est d'abord efforcé de capitaliser sur l'existant, à savoir un tissu juridique déjà dense au Sénégal mais qui n'était pas opérationnel faute de mesures d'application reprises dans le champ de la commande publique. Il consolide et proclame à travers la nouvelle Charte de l'Éthique et de la commande publique responsable, les obligations éthiques, sociales (incluant l'interdiction des discriminations au travail, le respect des droits fondamentaux), environnementales et d'hygiène, santé et sécurité qui s'imposent à tous les titulaires des contrats publics. Il indique également les domaines du droit pour lesquels une collaboration doit être instaurée avec les Autorités en charge de la politique des achats publics (notamment droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de la construction etc...).

Les propositions formulées s'appuient sur la dimension transversale de la commande publique durable au-delà des seuls marchés publics. Non seulement le Code des marchés publics de 2014 contient déjà des dispositions sur lesquelles il est possible de s'appuyer, mais de nombreux textes ont été adoptés ou sont en instance de l'être dans d'autres domaines du droit facilitant les APD. C'est le cas de la loi sur le contenu local ou de la récente loi n° 2120-23 du 2 mars 2021 sur les PPP ainsi que le décret n° 2021-1443 du 27 octobre 2021 portant application de la loi PPP et de la loi pour une économie sociale et solidaire du 15 juin 2021.

Ce Rapport s'est ensuite attaché à mobiliser les mesures relatives aux APD au service des politiques publiques sénégalaises actuelles pour favoriser l'accès à la commande publique ou à la sous-traitance des PME, des PME à direction féminine, des acteurs de l'économie sociale et solidaire (GIE, des artisans et des groupements ouvriers locaux et futures entreprises sociales) qui emploient au moins 50 % de jeunes, ou 50 % de femmes ou 30 % de personnes victimes de handicap. Il promeut également les marchés innovants avec des dispositions spécifiques pour les Startups labellisées, les variantes, la création d'une prime à l'innovation environnementale ou sociale. Si l'on voulait résumer en quelques mots, les propositions de ce Rapport s'inspirent du SBA américain (*Small Business Act*) qui organise un accès protégé des PME à la commande publique, en y ajoutant en plus la dimension sociale et environnementale afin de satisfaire les objectifs d'un développement durable et inclusif, dans le respect du cadre de l'UEMOA.

Les mesures proposées permettent de clarifier les relations entre RSE (Responsabilité sociétale des entreprises) et APD qui partagent un socle commun, celui des ODD, mais qui divergent dans leur modalités¹³⁴. De fait, de nombreuses entreprises ont mis en place des actions poussées de RSE au Sénégal avec deux buts : soit communiquer sur leur image d'entreprises responsables, soit compenser des impacts négatifs de leurs activités. Pour le secteur minier, au titre de la 1ère catégorie d'actions, les entreprises s'efforcent d'employer et de former des travailleurs locaux, et/ou de mettre en place des actions sociales et d'améliorations locales dans le domaine de la santé, de l'éducation, de l'accompagnement des activités professionnalisantes des femmes et des jeunes, tandis que dans la 2^{dne} catégorie figurent des actions de dépollution ou de mise en place d'un système de traitement des produits chimiques utilisés dans les Mines¹³⁵. Mais dans le domaine de la commande publique, la RSE est souvent perçue comme un moyen de pallier l'insuffisance de l'offre d'infrastructures ou de services publics. Pourtant, l'articulation entre les obligations issues du marché et les actions de RSE de l'entreprise appelle une véritable réflexion que ce rapport a voulu lancer.

Ce Rapport propose une démarche juridique articulée :

1. Adopter par décret la Charte de l'éthique et de la commande publique responsable afin de concrétiser l'engagement de tous les candidats à se conformer à la législation sénégalaise et à s'efforcer de promouvoir le développement durable en adoptant des pratiques responsables ;
2. Adopter les révisions du Code des marchés publics afin de permettre aux Autorités contractantes de recourir aux APD, éventuellement avec un calendrier d'entrée en vigueur différée ;
3. Adopter les textes d'application du Code des marchés publics, le cas échéant ;
4. Adopter une circulaire demandant aux Autorités contractantes de fixer leur objectif annuel d'APD afin d'appliquer les préférences prévues par le CMP et d'inclure des exigences de durabilité ;

¹³⁴ Molino J. (2021) Public Procurement and Corporate Social Responsibility, In: Idowu S., Schmidpeter R., Capaldi N., Zu L., Del Baldo M., Abreu R. (eds) Encyclopedia of Sustainable Management, Springer, Cham.

¹³⁵ A titre d'exemple, le dispositif mis en place par la Société Petowal Mining Company (PMC) qui exploite depuis 3 ans la mine aurifère de Mako sur une concession minière de 87 km² dans la région de Kédougou (Source Le Soleil, 30 déc. 2020)

5. Adopter les révisions des Documents types d'appels d'offres en assurant la conformité de tous les DTAO à la commande publique responsable
6. Proposer également des « DTAO APD » spécifiques pour répondre aux stratégies APD des AC volontaires.

Sur le plan de l'accompagnement institutionnel, le Rapport recommande :

- L'intégration effective de la politique des achats publics durables dans la mission de régulation confiée à l'ARCOP. A cet égard, l'article 2 du Décret du 21 octobre 2021 vient de doter l'ARCOP de compétences particulières en matière de contrôle des objectifs et d'audit des actions des AC en matière d'APD. Elle doit aussi faire état de la mise en oeuvre de ces achats dans son rapport annuel remis au Président de la République et publié.
- Pour activer ces nouvelles dispositions, les Autorités contractantes (dans un premier temps les plus importantes d'entre elles) devront s'efforcer d'atteindre un objectif minimal de 20 % d'APD par rapport à la valeur annuelle de leurs marchés publics sous peine de sanctions financières qui viendront alimenter un Fonds de promotion des APD.
- Le service d'appui conseil de la DCMP devra être renforcé avec une structure d'accompagnement des AC à la préparation des documents d'appels d'offres incluant des dispositions APD, concentrant une expertise en droit de la commande publique et en droit de l'environnement.
- Les collaborations interministérielles seront instaurées afin d'adapter les DTAO aux règles sectorielles.
- Une plateforme électronique nationale relative aux APD, servant à la fois de lieux d'échanges entre AC sur les bonnes pratiques, de diffusion d'appels d'offres, de formation des PME sera créée avec l'aide de l'Agence sénégalaise de l'informatique en employant notamment des étudiants en formation.
- Une collecte systématique de données, à travers la soumission du plan annuel de passation de marchés qui devra indiquer les objectifs de l'AC en matière d'APD puis le Rapport annuel de contrôle soumis à l'ARCOP ex-ARMP et à la DCMP permettront de suivre la mise en oeuvre des APD. Des indicateurs de résultats sont également suggérés.

Du côté de la structuration de l'offre, les instances qui accompagnent la création de PME ou celles qui s'intéressent aux acteurs de l'économie sociale et solidaire, seront encouragées à proposer des parcours d'accès à la commande publique avec des formations et accompagnement spécifiques.

Au-delà, et pour des travaux futurs, le Rapport suggère de :

1. Prévoir un guide explicatif qui complète le Guide des APD (2020) afin d'inclure la dimension sociale et économique dans la commande publique durable ;
2. Rédiger des documents pédagogiques en construisant un plan de formation pour renforcer les capacités des acteurs (incluant les écoles d'ingénieurs) ;
3. Lancer des travaux de préparation de documents d'appels d'offres spécifiques par secteur ou par produit qu'il faudra identifier et sélectionner ;
4. Préparer un modèle de stratégie APD utilisable au niveau de chaque Acheteur public ainsi qu'un outil d'évaluation des besoins APD ;
5. Réviser la procédure de l'Etude d'Impact Environnemental pour lui conférer une dimension économique et sociale avec une procédure transparente et indépendante ;
6. Organiser une réflexion intergouvernementale autour des mesures hors CMP nécessaires au succès des APD (par exemple la politique fiscale des acteurs de l'économie sociale et solidaire, ou la politique fiscale des produits de l'économie circulaire) ;
7. Opérationnaliser la Caisse des Marchés Publics ;
8. Elaborer une stratégie nationale de la RSE avec un volet relatif à la commande publique afin de clarifier le rôle des entreprises titulaires des marchés publics, les attentes de la population et des AC. Cette politique de RSE pourra être l'occasion de systématiser l'engagement des grandes entreprises à accompagner l'essor des PME locales par un système de parrainage ou de certification de leurs sous-traitants.

LISTE des ANNEXES

Annexe 1 : Extraits du Plan National des Achats Publics durables (PNAPD) : Axe stratégique 4. Cadre juridique et institutionnel

(p. 25) « En l'état actuel de la réglementation, l'intégration de la durabilité dans les achats publics nécessite une modification du Code des Marchés Publics (2014) à travers l'introduction de nouveaux articles pour inciter les Autorités contractantes à une meilleure prise en compte des questions de protection et de valorisation de l'environnement et d'insertion sociale.

Les nouvelles dispositions réglementaires à insérer dans le Code des Marchés Publics devraient permettre aux achats publics d'être un véritable levier de développement économique et social durable.

Ces dispositions doivent également viser à établir un Rapport qualité d'exécution, prix et durabilité. Cette rentabilité pourrait être atteinte par l'élaboration et l'adoption d'une Charte de l'achat durable qui engagerait chaque autorité contractante et chaque candidat à un marché public à proposer des solutions environnementales et sociales. L'arsenal juridique pourrait être complété par la création d'un Observatoire Economique des Marchés Publics (OEMP), qui sera logé au Ministère chargé des finances et la mise en place d'un mécanisme d'incitations fiscales en faveur des entreprises qui s'inscrivent dans une démarche volontaire de développement durable en matière d'achats publics.

Axe stratégique 4. Indicateurs de résultats

Activité 4.1. Modifier le Code des Marchés Publics de 2014 pour une meilleure intégration des critères et clauses environnementales et sociales dans les différentes étapes de la procédure de passation des marchés publics

Activité 4.2. Elaborer et faire adopter une Charte nationale d'achats durables intégrant des dimensions environnementales et sociales

Activité 4.3. Créer un Observatoire Economique des Marchés publics fonctionnel pour une meilleure prise en compte des statistiques sur les achats publics durables

Activité 4.4. Mettre en place un dispositif d'incitations fiscales en faveur des entreprises qui s'inscrivent dans une démarche de développement durable en matière d'achats publics

Annexe 2 : Modèle d'engagement à respecter la Charte de l'Ethique et de la commande publique responsable

A : [nom et adresse de l'Autorité Contractante]

Madame/Monsieur,

Après avoir examiné, en vue de la soumission de notre proposition pour [insérer ici l'objet de la consultation ou du marché], nous, soussignés, avons bien pris connaissance des dispositions de la Charte de l'éthique et de la commande publique responsable approuvée par décret n° 2021....du X/X /2021 et nous engageons à respecter toutes les dispositions de ce texte nous concernant, pendant la procédure de passation du contrat et, si notre soumission est acceptée, pendant son exécution.

Nous savons, qu'à titre de sanction, nous pouvons être écartés temporairement ou définitivement du champ des contrats de la commande publique (notamment des marchés publics), conformément à la réglementation, s'il est établi que nous nous sommes livrés à une ou plusieurs des pratiques, ci-après, dans le cadre de la passation et de l'exécution du contrat :

- activités corruptrices à l'égard des agents publics en charge de la passation du marché ;
- manœuvres frauduleuses en vue de l'obtention du marché ;
- ententes illégales ;
- renoncement injustifié à l'exécution du marché si notre soumission est acceptée ; et,
- défaillance par rapport au droit applicable et aux engagements que nous aurons souscrit, en particulier :
 - violation des règles d'hygiène, de santé et de sécurité ;
 - violation de la réglementation sociale et du droit travail ;
 - violation de la réglementation environnementale (notamment : nuisances sonores et pollutions, dégradation de l'environnement, utilisation de substances toxiques, atteinte à la biodiversité et aux ressources naturelles, déforestation)
 - non-respect des normes énergétiques et de construction ;
 - violation des obligations socio-économiques (atteinte aux droits des populations locales, discriminations et traitements dégradants, dégradation du patrimoine naturel, culturel, architectural et touristique).

Nous savons aussi que ces sanctions administratives sont sans préjudice des sanctions pénales et civiles prévues par les lois et règlements en vigueur.

Veuillez agréer, Madame/Monsieur, l'assurance de notre considération distinguée

Fait le _____ 20 ____

Signature _____ en qualité de _____

dûment autorisé à signer le Candidat pour et au nom de [nom du Candidat ou du groupement d'entreprises suivi de "conjointement et solidairement"]

Annexe 3 Nouveau Modèle de PGES (adapté des Documents types de l'Agence Française de Développement 2019)

1.	Politique Environnementale	Déclaration de Politique ESSS signée par le directeur général de l'Entrepreneur définissant clairement l'engagement de l'Entrepreneur en matière (i) de gestion ESSS de ses travaux de construction et (ii) de respect des Spécifications ESSS du marché (si applicables).
2.	PGES-Travaux	Objectif du PGES-Travaux et contenu Calendrier de préparation et de mise à jour Assurance qualité et validation
3.	Ressources ESSS	Ressources humaines : Manager ESSS Superviseurs ESSS Responsable des relations avec les parties prenantes Personnel médical Logistique & communication : Véhicules ESSS Postes informatiques Equipe de mesures eau, air, bruit in situ Laboratoire d'analyse utilisé Reporting : Inspections hebdomadaires Mensuel Accident / Incident
4.	Réglementation ESSS	Définition des standards de la réglementation nationale ESSS en vigueur et des recommandations ESSS des institutions affiliées aux Nations Unies (OMS, OIT, IMO, IFC) qui s'appliquent à la conduite des travaux : Normes de rejets Salaire minimum Restriction de circulation jour et/ou nuit Autres
5.	Moyens de contrôle opérationnels ESSS	Définition des standards ESSS de l'industrie appliquée Procédure de suivi des travaux des Zones d'Activités : Fréquence Personnel Critères d'évaluation Procédure de détection et de traitement des non-conformités : Circulation de l'information Notification selon niveaux d'importance appliqués aux non-conformités Suivi de la fermeture de la non-conformité Gestion des données relatives au suivi et aux non-conformités : Archivage
6.	Zones d'Activités	Utilisation comme indicateur de performance Description des Zones d'Activités (définition à l'Article Erreur ! Nous n'avons pas trouvé la source du renvoi. des Spécifications ESSS) : Nombre Localisation sur carte topographique Activités Calendrier ouverture & fermeture Accès
7.	Plan Santé & Sécurité	Renvoi vers l'Annexe : un Plan de Protection de l'Environnement pour chaque Zone d'Activités. Identification et caractérisation des dangers pour la sécurité, l'hygiène et la santé y compris l'exposition du personnel aux produits chimiques, dangers biologiques et rayonnements. Description des méthodes de travail pour minimiser les dangers et contrôler les risques. Liste des types de travaux faisant objet d'un permis de travail Equipements de protection individuelle Présentation du dispositif médical des Zones d'Activités : Centre de soins, équipement médical et affectation du personnel médical Actes médicaux pouvant être effectués sur la Zone d'Activités Ambulance, communication Hôpital référent Procédure d'évacuation médicale d'urgence
8.	Plan de formation	Description de l'organisation interne et actions à prendre en cas d'accident ou incident Formations de base pour la main d'œuvre non qualifiée Formations Santé & Sécurité
9.	Conditions de travail	Description de la politique de ressources humaines pour les travailleurs directs ou indirects de la construction
10.	Recrutement local	Besoins en main d'œuvre locale : Profils de postes et niveaux de qualification requis Mécanisme de recrutement et calendrier de déploiement Formation initiale à donner par l'Entrepreneur liée à chaque profil de poste Localisation et gestion du ou des bureaux de recrutement local
11.	Plan de gestion du trafic	Description de la flotte de véhicules/engins utilisée pour la conduite des travaux Déploiement (Zone d'Activités et calendrier) et lieux d'entretien de chaque véhicule et engin Cartographie des itinéraires, horaires de circulation, zones de restriction des vitesses Lutte contre la poussière :

		Cartographie des portions routières où s'appliquent les mesures de réduction de la poussière Points d'eau identifiés ou à créer pour le ravitaillement des camions citernes Capacité des camions citernes mobilisés et calcul du nombre de camions nécessaires Largeur de la piste afin de déterminer si l'épandage demande un passage (piste étroite) ou 2 passages (piste large) Nombre d'épandages d'eau proposés par jour en fonction du climat
12.	Produits dangereux	Inventaire des Produits dangereux par Zone d'Activités et par période
13.	Effluents	Conditions de transport, de stockage et incompatibilité chimique Caractérisation des effluents vers le milieu récepteur Installations de prétraitements et/ou de traitement des effluents Mesures de réduction des teneurs en sédiments des ruissellements pluviaux Dispositifs de surveillance de l'efficacité des installations de prétraitement ou de traitement des effluents et de réduction des teneurs en sédiments des ruissellements Ressources et méthodes de suivi de la qualité des effluents et des ruissellements
14.	Bruits et vibrations	Estimation des fréquences, durées, jours calendaires et niveaux de bruits par Zone d'Activités
15.	Déchets	Inventaire des déchets par Zone d'Activités et par période Méthodologie de collecte, stockage intermédiaire, prise en charge ou traitement des déchets non dangereux ou inertes Méthodologie de stockage et prise en charge des déchets dangereux
16.	Défrichement et revégétalisation	Méthodes et calendrier de défrichement de la végétation et des activités de terrassement
17.	Biodiversité	Méthodes, espèces et calendrier de la revégétalisation des Zones d'Activités perturbées par les travaux Calendrier des activités de gestion de la faune et de la flore Mesures pour réduire l'impact sur les espèces de faune et flore sur la base des procédures du Maître d'Ouvrage Mesures de suivi de l'efficacité et de la performance du plan en place Mesures pour limiter les EEE Mesures de suivi de l'efficacité et de la performance du plan en place
18.	Lutte contre l'érosion	Localisation des zones sujettes à érosion Méthodes et calendrier de mise en œuvre des mesures antiérosives, incluant le stockage des terres végétales
19.	Documentation de la situation des Zones d'Activités	Liste et couverture des points de vue Méthode de prise de vue Archivage des photographies
20.	Remise en état des Zones d'Activités	Méthode et calendrier de remise en état des Zones d'Activités
21.	Annexes	Plan(s) de Protection de l'Environnement (nombre et lieu spécifiés en Section 6 "Zones d'Activités" ci-dessus) : Délimitation de la Zone d'Activités sur carte Zonage du défrichement, de stockage du bois utilisable, de brûlage des déchets forestiers Définition des activités se déroulant sur la Zone d'Activités : construction, stockage, résidence, bureaux, ateliers, production béton... Disposition des sites de travail sur la Zone d'Activités : ouverture, exploitation, remise en état, fermeture Zonage de stockage de terre végétale, des déblais de terrassement, de matériaux Voies d'accès et points de contrôle Calendrier d'occupation de la Zone d'Activités Organisation de la préparation de la Zone d'Activités Points de rejets liquides Points de prélèvements proposés pour le suivi la qualité de l'eau Points d'émission atmosphériques Localisation du lieu de stockage des produits dangereux Localisation et cartographie des installations de traitement des déchets lorsque prise en charge par un prestataire extérieur Toute autre information relevant de la gestion environnementale sur la Zone d'Activités Plan d'urgence Description des installations Caractérisation des dangers Situations d'urgence Structure organisationnelle – rôles et responsabilités Procédures d'urgence Ressources humaines et matérielles Déclenchement du plan Reporting Constat d'huissier pour les Zones d'Activités (dans les situations décrites aux Articles Erreur ! Nous n'avons pas trouvé la source du renvoi. , Erreur ! Nous n'avons pas trouvé la source du renvoi. et Erreur ! Nous n'avons pas trouvé la source du renvoi. des Spécifications ESSS, si applicables)

Textes consultés

Textes Sénégalais relatifs à la commande publique

Textes, codes et lois du Sénégal <https://www.sec.gouv.sn/lois-et-reglements/codes>

Lois :

Loi du 23 février 2021 relative aux contrats de partenariat public-privé

Loi n° 65-51 du 19 Juillet 1965 Portant Code des Obligations de l'Administration, et son projet de modification du 30 juin 2006

Loi 2014 09 du 20 février 2014 relative aux contrats de partenariat public privé et Décret 2015-386 du 20 février 2015

Décrets :

Décret d'application n° 2021-1443 du 15 novembre 2021 portant application de la loi n° 2021-23 du 02 mars 2021 relative aux contrats de partenariat public-privé

Décret n° 2020-1774 du 16 septembre 2020 abrogeant-le décret n° 2020-781 du 18 mars 2020 portant dérogation au Code des Marchés publics pour les dépenses relatives à la lutte contre la COVID-19.

Décret n°2020-781 portant dérogation au code des marchés publics pour les dépenses relatives à la lutte contre la Covid-19

Décret n° 2020-474 portant suspension de toute commande ou acquisition de véhicules Administratifs

Décret n° 2020-22 du 07 janvier 2020 portant modification de l'article 76 du décret n° 2014-1212 du 22 septembre 2014 portant Code des marchés publics

Décret n° 2017-527 du 11 avril 2017 portant nomination des membres du Conseil de Régulation des Marchés publics

Décret n° 2014-1212 du 22 Septembre 2014 Portant Code des Marchés Publics, (98 p.)

Décret n° 2009-401 du 29 mai 2009 fixant les modalités de recrutement, le statut et les pouvoirs des agents de l'ARMP chargés des enquêtes

Décret n°2007-546 du 25 Avril 2007 Portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des marchés publics

Décret n° 2007-547 du 25 Avril 2007 Portant création de la Direction Centrale des Marchés Publics (DCMP)

Arrêtés d'application du CMP de 2014 :

Note de présentation des arrêtés d'application du Décret n°2014-1212 du 22 Septembre 2014 Portant Code des marchés publics ;

Arrêté n° 00860 du 22.01.2015 fixant les seuils en dessous desquels il n'est pas requis de garantie de soumission en application de l'article 114 du CMP ;

Arrêté n° 00863 du 22.01.2015 Pris en application de l'article 79 du CMP relatif aux procédures applicables aux marchés passés par certaines communes

Arrêté n° 00864 du 22.01.2015 Arrêté pris en application de l'article 36-1 du Code des Marchés publics en fixant le nombre et les conditions de désignation des membres des commissions des marchés des Autorités contractantes

Arrêté n° 00865 du 22.01.2015 pris en application de l'article 35 du Code des Marchés publics relatif aux cellules de passation de marchés des Autorités contractantes

Arrêté n° 00866 du 22.01.2015, Arrêté pris en application de l'article 115 du Code des Marchés publics fixant les seuils en dessous desquels il est requis une garantie de bonne exécution

Arrêté n° 00861 du 22.01.2015 Fixant le modèle d'engagement des candidats à respecter les dispositions de la Charte de Transparence et d'éthique en matière de marchés publics pris en application de l'article 44 -F du Code des Marchés publics ;

Arrêté n° 00862 du 22.01.2015 Arrêté relatif aux commissions régionales et départementales des marchés publics dans les régions autres que Dakar, pris en application de l'article 36, al. 7 du CMP ;

Arrêté n° 00106 du 07.01.2015 Fixant les seuils de contrôle a priori des Dossiers de marché, pris en application de l'article 141 du CMP ;

Arrêté n°00107 du 07.01.2015 Relatif aux modalités de mise en œuvre des procédures de demande de renseignements et de prix en application de l'article 78 du décret n° 2007-545 du 25 avril 2007 portant Code des Marchés Publics, relatif aux procédures applicables aux marchés passés par les communautés rurales et certaines communes ;

- Arrêté pris en application de l'article 77-3 du Code des Marchés publics relatif aux commande pouvant être dispensées de forme écrite et donner lieu à règlement sur mémoires ou factures

Dossiers Type d'Appels d'Offres

8 DTAO relatifs aux travaux :

Dossier Standard de préqualification Passation des marchés de Travaux, de fournitures et de services (Mai 2017 – 76 p.)

DTAO Passation d'accords-cadres pour des Marchés de Travaux (Janvier 2020, 122 p.);

DT de demande de renseignement de prix (DRP) pour la passation de marchés de travaux (2017, 10 p) ;
 DTAO Passation des Marchés de Travaux (Grande taille) (2020, 205 p).
 DTAO Passation des Marchés de Travaux (de taille moyenne) (Mai 2017, 126 p.)
 le DTAO Passation de marchés de travaux (pour les communes dont le budget annuel initiale est inférieur à 300 millions de F CFA) (Mai 2017, 45 p.),
 DTAO Gestion et entretien des routes par niveaux de service (GENIS Marchés à obligation de résultats) (175 p)
 DTAO Marché clé en main (Mai 2017, 183 p.)

DSP :
 Dossier-type pour les DSP

7 DTAO pour les marchés de fournitures et de services non intellectuels :

DTAO Passation d'accords-cadres pour des marchés de fournitures et services connexes (Janvier 2020, 101p) ;
 DTAO Passation des Marchés de Services Physiques, (Mai 2017, 109 p.) ;
 DTAO Passation des Marchés de Fournitures et/ou Services (pour les communes dont le budget annuel initiale est inférieur à 300 millions de F CFA) (Mai 2017, 45 p.), qui régie les petits marchés de moins de 25 millions de F. CFA (Mai 2017, 19 p.) ;
 DTAO Passation des marchés de fournitures (Mai 2017, 111 p.) ;
 DTAO Acquisition de Manuels Scolaires Selon L'Approche Par les Compétences, (Mai 2017, 122 p.) ;
 DT DRP Passation des Marchés de Fournitures, (Mai 2017, 12 p)
 DTAO Passation des Marchés de Services Physiques (Mai 2017, 109p)

4 Documents-type pour les marchés de prestations intellectuelles :

DTP Passation des Marchés de Prestations intellectuelles Consultants individuels (montant inférieur à 5 000 000 FCFA) (Mai 2017, 72 p.)
 DTP Marchés de moins de 35 millions FCFA
 DTP Passation des Marchés de Prestations intellectuelles (Marchés de petits montants) (Mai 2017 – 74 p).
 DTP Passation des Marchés de Prestations intellectuelles (Marchés importants au-delà de 35 Millions FCFA) (Mai 2017- 156 p)
 Demande de propositions standard - Passation d'accords-cadres pour des Marchés de Prestations intellectuelles (Janvier 2020, 110 p.)

Textes Sénégalais relatifs à d'autres domaines pertinents du droit

Constitution du Sénégal

Energie

Loi n° 2010-21 du 20 décembre 2010 portant loi d'orientation sur les énergies renouvelable
 Loi n° 83-04 du 28 janvier 1983 sur l'utilisation rationnelle de l'énergie
 Décret n° 2017-1411 du 2017 portant interdiction de l'importation et de la production et de la commercialisation au Sénégal des lampes à incandescence et promotion des lampes à économie d'énergie
 Décret 2011-691 du 24 janvier 2011 instituant un Conseil de l'Energie (CNE)

Economie sociale et solidaire

Loi d'orientation n° 2021-28 du 15 juin 2021 relative à l'économie sociale et solidaire.

Environnement

La loi n°2020-04 du 8 janvier 2020 relative à la prévention et à la réduction de l'incidence sur l'environnement des produits plastiques
 Loi n° 2001-01 du 15 janvier 2001 portant Code de l'Environnement
 Décret n°2001 – 282 d'application du Code de l'Environnement
 Décret n° 2010-1281 réglementant les conditions d'exploitation du plomb issu des batteries usagées et d'autres sources et de l'utilisation du mercure
 Décret n° 2008-1007 en date du 18 août 2008 portant réglementation de la gestion des déchets biomédicaux.
 Arrêté Interministériel n° 009311 du 05 10 2007, portant gestion des huiles usagées.
 Arrêté ministériel n° 003165 du 21 mai 2003 réglementant l'exploitation d'un dépôt de gaz combustible domestique ;
 Arrêté Interministériel fixant les conditions de rejets des eaux usées et sa norme d'application.
 Arrêté ministériel n° 9468 MJEHP-DEEC du 28 novembre 2001 portant réglementation de la participation du public à l'étude d'impact environnemental ;
 Arrêté ministériel n° 9471 MJEHP – DEEC en date du 28 novembre 2001 portant contenu des termes de références des études d'impact ;
 Arrêté ministériel n° 9472 MJEHP-DEEC en date du 28 novembre 2001 portant contenu du Rapport de l'Etude d'impact environnemental

Arrêté ministériel n° 9470 MJEHP-DEEC en date du 28 novembre 2001 fixant les conditions de délivrance de l'Agrément pour l'exercice des activités relatives aux études d'impact sur l'Environnement.

Arrêté ministériel n° 9469 MJEHP-DEEC, du 28 novembre 2001 portant organisation et fonctionnement du Comité technique ;

Urbanisme :

loi n° 2008-43 du 20 août 2008 portant partie législative du Code de l'urbanisme

Décret n° 2009-1450 portant partie réglementaire du Code de l'Urbanisme

Droit du travail et protection sociale :

Loi n° 62-46 du 13 juin 1962 autorisant le Président de la République à ratifier les conventions internationales du travail n° 10, 12, 19, 52, 81, 89, 96, 99, 100, 101 et 102 ;

Loi 1997-17 du 1er décembre 1997 portant Code du Travail

Loi 2015-02 abrogeant et complétant certaines dispositions de la loi n°97-17 portant Code du travail (stage et apprentissage)

Loi 2013-06 complétant et modifiant certaines dispositions de la loi n°74-52 relative à la fête nationale et aux fêtes légales, modifiée

Loi 2003-23 modifiant les articles L24 et L25 du CT et ajoutant un article L 85 bis

Loi 2003-03 relative aux mutuelles de santé

Loi 1973-37 portant Code de la sécurité sociale

Décret 1989-1329 fixant l'organisation et les règles de fonctionnement des services de médecine du travail

Droits des Femmes :

- Loi n° 2010- 11 du 28 mai 2010 instituant la parité absolue Homme-Femme ;

- Décret n° 2004-426 du 14 avril 2004 portant création du Fonds national de Promotion de l'Entrepreneuriat féminin

- Décret n°2011-309 du 7 mars 2011 portant création, organisation et fonctionnement de l'Observatoire national de la parité - Décret n° 2011-819 du 16 juin 2011 portant application de la Loi instituant la Parité absolue Homme-Femme ;

- Lettre circulaire n° 00959 du 26 Mars 2013 relative à l'intégration du genre dans les Ministères Sectoriels.

Personnes atteintes de handicap

la Loi d'orientation sociale n° 2010-15 du 6 juillet 2010 sur la promotion et la protection des droits des personnes handicapées

PME

Loi d'Orientation n° 2020-02 du 7 Janvier 2020 relative au Petites et Moyennes Entreprises ;

Loi du 6 janvier 2020 sur les Startups

Loi d'orientation n°2008-29 du 28 juillet 2008 relative à la promotion et au développement des petites et moyennes entreprises (abrogée)

Divers :

- Loi n° 2012/ 22 du 27 décembre 2012 portant Code de transparence dans la gestion des finances publiques.

-Loi n°2013-10 du 28 décembre 2013 Portant Code général des Collectivités locales

- la loi n° 2004-21 du 06 juillet 2004 portant organisation des activités statistiques, modifiée et complétée par la loi n° 2012-03 du 03 j

- la loi n° 76-67 du 2 juillet 1976 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et aux autres opérations foncières d'utilité publique modifiée par la loi n° 85-08 du 3 janvier 1985

-Décret n° 2002-746 du 19 juillet 2002 relatif à la normalisation et au système de certification de la conformité aux normes

Textes MP et PPP, exemples étrangers pertinents

Burundi : loi n°1/19 du 19 juillet 2019 portant modification de la loi N°1/14 du 27 Avril 2015 portant Régime général des contrats de partenariat public-privé

Canada

Treasury Board of Canada Secretariat, Procurement Strategy for Aboriginal Business: Guidelines for Buyers/Government Officials, Contracting Policy Notice 1997-6. V

Cameroun

Décret no. 2018/366 du 20 juin 2018 portant le nouveau code des marchés publics

Côte d'Ivoire

Décret n° 2018-358 du 29 Mars 2018 Déterminant les règles relatives aux contrats de partenariats public-privé
Ordonnance n° 2019-679 du 24 juillet 2019 portant CMP : <https://loidici.biz/2020/02/17/le-code-des-marche-publics-2019/lois-article-par-article/codes/>

France Code de la commande publique, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000037701019/2019-04-01/

Loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire,
<https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000029313296/>

Gabon : -Ordonnance n° 22 /PR/2015 du 11 août 2015, relative aux Partenariats Public-Privé ;
-Loi n° 020/2016 du 5 septembre 2016 portant ratification de l'ordonnance n°0009/PR/2016 du 11 février 2016 relative aux partenariats public-Privé.
- Le décret n°000156/PR/MPIPPP du 18 mai 2018 institue l'organe d'évaluation chargé de procéder à l'analyse technique, juridique et financière des offres présentées par les soumissionnaires participant à la procédure de passation des PPP.

Madagascar

Décret n° 2017-149 Portant application de la loi n°2015-039 du 3 février 2016 sur le PPP relatif aux modalités d'application des dispositions concernant la passation des contrats de PPP
<http://www.droit-afrique.com/uploads/Madagascar-Decret-2017-149-application-loi-ppp-contrats.pdf>

Mauritanie : Loi n°2017-06 du 6 février 2017 relative au Partenariat Public-Privé (PPP) Texte d'application : le décret n°2017-125 du 2 novembre 2017

Niger : **Loi n°2018-40 du 05 juin 2018 portant régime des Contrats de Partenariat Public-Privé**
<http://www.finances.gouv.ne/index.php/actualites/publications-du-ministere/file/412-loi-2018-40-du-05-juin-2018-portant-regime-des-contrats-de-partenariat-public-privé-cppp>

Rwanda : La loi n°14/2016 du 2 mai 2016 régissant les partenariats public-privé

Togo : Loi n°2014-014 du 22 octobre 2014 portant modernisation de l'action publique de l'État en faveur de l'économie - Loi n°2009-13 du 30 juin 2009 relative aux marchés publics et délégations de service

Tunisie : Décret tunisien n° 2014-1039 du 13 mars 2014 portant réglementation des MP

Rapports

Sénégal

Plan Sénégal Emergent – Plan d'actions prioritaires 2019-2023, <http://www.finances.gouv.sn/pap2/>

Projet portant Loi de finances pour l'année 2021
http://www.finances.gouv.sn/wp-content/uploads/www.budget.gouv.sn_projet_portant_loi_de_finances_pour_l_annee_2021_2020-10-23_16-37.pdf

Direction de la prévision et des études économiques, Ministère de l'Economie et des Finances
DIRECTION GENERALE DE LA PLANIFICATION ET DES POLITIQUES ECONOMIQUES DIRECTION DE LA PREVISION ET DES ETUDES ECONOMIQUES
http://www.dpee.sn/IMG/pdf/etude_structure_optimale_des_investissements_publics_au_senegal_version_finale.pdf

Bureau de prospective économique, Tableau de bord de la mise en œuvre du PSE :
<http://www.big.gouv.sn/index.php/2020/03/27/tableau-de-bord-de-lemergence-globale-du-senegal/>

Point mensuel de conjoncture : novembre 2020
http://www.dpee.sn/IMG/pdf/point_conj_nov_2020_vf.pdf

Forum Politique de Haut Niveau, Objectifs de développement durable (ODD) – Revue nationale volontaire 2018,
<http://www.environnement.gouv.sn/sites/default/files/documenttheque/RNV%202018%20SENEGAL.pdf>

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE, STRATEGIE NATIONALE POUR LA PROMOTION DES EMPLOIS VERTS AU SENEGAL, nov 2015, https://www.un-page.org/files/public/Rapport_snpev_version_final.pdf

Ministère des Postes et Télécommunications, Stratégie Sénégal Numérique 2016-2025
www.senreforme.org/app/uploads/Strategie-Senegal-Numerique-2016-2025.pdf

Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) Violences basées sur le genre et Pouvoir d'action des femmes, déc. 2019
http://www.ansd.sn/ressources/publications/Rapport-VBG_ANSD-2019.pdf

Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) Recensement Général de la Population et de l'Habitat, de l'Agriculture et de l'Elevage (RGPHAE 2013) , Chapitre V :
PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP (2014) <http://www.ansd.sn/ressources/publications/rgphae-chapitre-handicap.pdf>

Consultations

Cabinet Carapaces, Appui à l'opérationnalisation des politiques positives de passation des marchés publics au Sénégal Propositions d'amélioration du cadre juridique Promotion de la participation des PME féminines dans le système de passation des marchés publics, Rapport soumis à la Banque mondiale dans le cadre du projet WEFI, Février 2021